

الوجيز في التنفيذ الجبري

"بين قانون المرافعات وأحكام الفقه الإسلامي"

دكتور

عبدالله عبدالحى الصاوي

أستاذ قانون المرافعات المساعد

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - جامعة الأزهر

الأستاذ الدكتور

حامد محمد أبو طالب

أستاذ قانون المرافعات بجامعة الأزهر

العميد السابق لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾﴾

﴿ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾﴾

صدق الله العظيم

سورة النجم [٣٩-٤١]

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم، سيدنا محمد ﷺ
سيد الأولين والآخرين، الذي مدحه ربه بما منحه فقال "وإنك لعلی خلق عظیم"^(١).

وبعد

فهذه مادة موجزة في التنفيذ الجبري، تتضمن قواعد التنفيذ ومتعلقاته، مقدماته ومنازعاته، طرقه وإجراءاته، ولا يخفى على أحد مدى أهمية مادة التنفيذ الجبري في الحياة العملية، التي أصبح الطالب قريباً منها، ومن ثم فينبغي أن يستعد لها أتم استعداد وأكملها، وإننا إذ نقدر أهمية هذه المادة فقد راعينا بجانب ذلك كله مصلحة الطالب، وضيق وقته وانشغال باله، وتقلب أحواله، فأوجزنا القول دون إخلال بتحصيل حقيقة المقصود، فآثرنا سهولة الصياغة مع قوة العبارة، ومتانة المباني مع عمق المقاصد والمعاني، لتظهر هذه المادة في صورة هي أحب للقلوب وأقرب للأفهام.

ولقد اهتم قانون المرافعات بتنظيم إجراءات التنفيذ الجبري بما يكفل تمكين صاحب الحق من اقتضاء حقه والانتفاع بمزاياه، بإجبار مدينه على تنفيذ ما التزم به؛ فإن لم يفعل، أُجبر على ذلك عن طريق تدخل السلطة العامة المختصة بالتنفيذ الجبري في الدولة، وتحت إشراف قضائي يكفل حماية حقوق كلا الطرفين، المنفذ والمنفذ ضده، والغير الذي قد يتأثر بإجراءات التنفيذ الجبري. ولم يشأ المشرع أن يترك لصاحب الحق سلطة اقتضاء حقه بنفسه، حتى لا يعمل على إذلال المدين أو التتكيل به في ثورة غضبه، أو يتعذر عليه الحصول على حقه، فأنشأ له سنداً تنفيذياً يجوز بمقتضاه التنفيذ الجبري ضد مدينه، وأوجب على السلطة العامة التدخل بحمايته وتنفيذ مقتضى السند التنفيذي الذي يخوله اقتضاء حقه جبراً عن الملتزم في هذا السند، وذلك كله تحت إشراف القضاء ورقابته، وعبر إجراءات راعى فيها المشرع التوازن الإجرائي بين حقوق الدائن والمدين، بحيث لا يجور أحدهما على الآخر.

(١) سورة القلم: الآية رقم (٤).

ولقد كان المشرع المصري موفقا في إنشاء إدارة تختص بالإشراف والرقابة على أعمال التنفيذ الجبري، من خلال قضاة متخصصون تتوفر فيهم خبرة قضائية خاصة تناسب أهمية إجراءات التنفيذ الجبري، فأصدر القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ المعدل لقانون المرافعات، والذي حلت بمقتضاه هذه "إدارة التنفيذ" في الرقابة والإشراف على إجراءات التنفيذ وإصدار الأوامر المتعلقة به، محل قاضي التنفيذ، والذي كان يناف به هذه الاختصاص قبل تعديل قانون المرافعات بالقانون المشار إليه، وفي الوقت ذاته أبقى على "قاضي التنفيذ" مسندا إليه الاختصاص بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.

هذا ولأهمية التنفيذ الجبري بالحجز ونزع الملكية وخطورة الأثر المترتب عليه من تجريد المدين من أمواله وبيعها جبرا عنه؛ فقد أفرد المشرع لهذا النوع من التنفيذ الكتاب الثاني من قانون المرافعات (المواد ٢٧٤ - ٤٨٦)، مبينا بتفصيل دقيق الإجراءات التي يجب اتباعها في الحجز على أموال المدين وبيعها، عبر تنظيم إجرائي دقيق، فرق فيه بين المنقولات والعقارات، فأفرد لكل منهما تنظيما يتناسب مع طبيعة المال المنفذ عليه وأهميته، مدفوعا بواجب حماية الغير الذي قد يضار من إجراءات التنفيذ، ففرق بين المنقول الموجود في حيازة المدين، وبين ذلك المملوك له الموجود في حيازة غيره، ووضع لكل حالة تنظيم إجرائي خاص بها، ثم فرق في التنفيذ على العقار بين عقار المدين وعقار غيره، منظما إجراءات خاصة للحجز على أي منهما، مبينا بعد ذلك ما يتبع من القواعد والإجراءات في توزيع حصيلة التنفيذ.

ولقد كان توفيق الله تعالى حليفا لنا في إعداد هذا المؤلف، فيسر أمر كتابته في ثلاثة أبواب، تناولنا في أولها: القواعد العامة في التنفيذ الجبري، وفي الثاني: إجراءات الحجز على المنقول، وفي الثالث: إجراءات التنفيذ على العقار، ثم مبحث خاص: لبيان قواعد توزيع حصيلة التنفيذ. وبعد هذا التوفيق والتيسير ندعو الله تعالى أن يجعله في مجاله علما ينتفع به، وأن يكتب لنا به أجرا في ميزان الحسنات أو يكفر بما بذل فيه من الجهد بعض السيئات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

المؤلفان

مبحث تمهيدي الحق في التنفيذ وأنواعه

مبحث تمهيدي

الحق في التنفيذ وأنواعه

من متطلبات فعالية النظام القضائي؛ أن يمتلك الوسائل الإجرائية للتنفيذ على المدين الممتنع عن وفاء التزامه، فإن هو امتنع عن التنفيذ اختياراً، كان للقضاء سلطة إجباره على هذا التنفيذ، تحقيقاً للعدالة ولأجل إيصال الحقوق لأصحابها، حتى لا يضطر الناس إلى اقتضاء حقوقهم بأيديهم، بما يمثل ردة إلى العصور البدائية الأولى، بما فيه من المخاطر التي تزعزع الأمن والسلم في المجتمع.

ولذلك "لا يتصور ثمة حق إلا إذا كان لصاحبه سلطة الإلتجاء إلى القضاء للزود عنه والاعتراف له به، وسلطة إجبار مدينه على تنفيذ ما التزم به، ولهذا لا يكفي المشرع بإجازة الإلتجاء إلى القضاء لحماية الحق بل هو أيضاً يمكن صاحبه من اقتضائه، أي يمكنه من الحصول على المنفعة التي يخولها له حقه، بإجبار مدينه على القيام بما التزم به؛ فإذا لم ينفذ المدين التزامه طوعاً واختياراً، أجبر عليه بتدخل السلطة العامة التي تجري التنفيذ تحت إشراف القضاء ورقابته، وبعبارة أخرى، تنحصر مهمة السلطة القضائية في أمرين أساسيين: الأول: تهيئة سند قابل للتنفيذ للدائن. والثاني: تمكينه من اقتضاء حقه من مدينه جبراً عنه"^(١).

وإذا نظرنا إلى الحكم القضائي، وعلى الرغم من أهميته التي لا تتكر، فإنه قد لا تكون له قيمة قانونية أو عملية إذا ظل مجرد عبارات مكتوبة غير قابلة للتنفيذ، فنجاح القضاء يقاس بمدى تنفيذ أحكامه، ذلك أن تنفيذ الحكم يعد بمنزلة لحظة الحقيقة بالنسبة لنظام القضاء كله^(٢)، إيماناً بأنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له^(٣).

(١) د. أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، ٢٠٠٧م، ص ١٠.

(٢) د. أحمد هندي: أصول التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٧م، ص ٣.

(٣) عبارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في رسالة القضاء التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري.

فالتنفيذ إذا يتمتع بأهمية بالغة في تحقيق العدالة في المجتمع، والأصل في التنفيذ أن يتم اختياراً من المدين؛ إلا أنه قد يماطل في تنفيذ التزامه ولا يملك الدائن إجباره على الوفاء، فهنا تتدخل السلطة العامة لتحقيق التوازن بين مركزي الدائن والمدين، فتجبر المدين على تنفيذ التزامه جبراً، تحت إشراف ورقابة القضاء، في الحالات التي تتوفر فيها شروط هذا الإجبار، والذي يسمى حينئذ "التنفيذ الجبري".

أولاً: التنفيذ الاختياري والتنفيذ الجبري:

بناء على ما سبق يمكننا القول بأن الأصل في التنفيذ أن يتم اختياراً، أي بإرادة المدين دون إجبار عليه من أي سلطة، وأياً كانت طبيعة الالتزام؛ سواء كان التزام بعمل أو بالامتناع عن عمل أو تسليم شيء، فإذا كان الالتزام بعمل كالالتزام بإقامة بناء، فإن تنفيذه اختيارياً يعني قيام المدين من تلقاء نفسه بهذا العمل، وإذا كان الالتزام بالامتناع عن عمل، كالالتزام بعدم البناء في مكان معين، أو الالتزام بعدم فتح محل تجاري من نوع معين في مكان أو فترة معينة؛ فإن تنفيذه اختيارياً يعني عدم إقدام المدين عليه، وإذا كان الالتزام بتسليم شيء، فإن تنفيذه اختيارياً يكون بتسليم الشيء محل الالتزام^(١).

ويحقق التنفيذ الاختياري مزايا عديدة للدائن وللمدين وللقضاء في نفس الوقت، فالنسبة للدائن يتيح له سهولة الحصول على حقه دون تكلفة أو جهد أو ضياع وقت ومكابدة، وبالنسبة للمدين يحفظ كرامته بتجنيبه مهانة التنفيذ القهري وبيع أمواله رغماً عن إرادته، وفتح الباب أمامه للدخول في تعاملات مع الآخرين دون خوف من مماطلاته. وبالنسبة للقضاء، يؤدي إلى تخفيف العبء عن القضاء وعن المحاكم ويضفي الاحترام الذاتي على الأحكام القضائية^(٢).

والأصل أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه عيناً؛ إلا أنه يجوز التنفيذ الاختياري بطريق التعويض؛ إذا اتفق الدائن والمدين على ذلك؛ فإذا تم الاتفاق بين الدائن والمدين على

(١) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، الجزء الأول، (بدون ناشر)، ٢٠٠٩م، ص ٦.

(٢) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٣-٤.

أن يدفع الثاني للأول تعويضا عن القيام بتنفيذ الإلتزام، فعلى الرغم من أن التنفيذ جاء هنا في صورة تعويض؛ إلا أنه تم اختيارا ودون إجبار من أي سلطة على المدين، وسواء كان ذلك بناء على طلب من الدائن وافق عليه المدين، أو عرض من المدين وافق عليه الدائن.

ونظرا لسهولة هذا النوع من التنفيذ وخلوه من المشكلات التي تثار في التنفيذ الجبري؛ فإن المشرع لم يتناوله بالتنظيم، ولم يبين طرق القيام به؛ إلا في حالة امتناع الدائن عن تسلم الحق المطلوب؛ فهنا يجب على المدين اتباع الإجراءات المقررة في قانون المرافعات، وذلك بأن يودع المطلوب خزانة المحكمة بعد أن يعرضه على الدائن عرضا حقيقيا^(١).

أما إذا امتنع المدين عن التنفيذ الاختياري؛ فإنه يجبر على التنفيذ، ويصبح التنفيذ حينئذ تنفيذا جبريا، وذلك بأن تجبره السلطة العامة وتحت إشراف القضاء ورقابته، بتنفيذ الإلتزام الذي امتنع عن تنفيذه اختيارا، متى كان الدائن قد حصل على سند تنفيذي يخول له سلطة اقتضاء حقه جبرا عن مدينه. وذلك إعمالا لنص المادة (١/١٩٩) مدني، والتي نصت على أنه "ينفذ الإلتزام جبرا على المدين".

والأصل في التنفيذ الجبري أن يكون تنفيذا عينيا بأن يجبر المدين على تنفيذ عين ما التزم به؛ فإن تعذر التنفيذ العيني؛ فإن التنفيذ الجبري يتم بطريق التعويض.

ثانيا: التنفيذ الجبري العيني والتنفيذ الجبري بطريق الحجز والبيع:

فرق المشرع بين طريقين من طرق التنفيذ الجبري، وهما: التنفيذ العيني، والتنفيذ بطريق الحجز والبيع، ويسمى التنفيذ العيني تنفيذا مباشرا، وهو الأصل في التنفيذ الجبري؛ بأن يجبر المدين على تنفيذ عين ما التزم به؛ فإذا كان موضوع الإلتزام تسليم منقول؛ أجبر على القيام بتسليمه عن طريق السلطة العامة، وإذا كان التزاما بتسليم

(١) نظم قانون المرافعات قواعد العرض والإيداع في الباب الأول من الكتاب الثالث (المواد ٤٨٧-٤٩٣)، وكذلك في المواد (٣٣٤-٣٤٠) من القانون المدني.

عقار أو إخلائه تم طرده من العقار بالقوة الجبرية، وإذا كان الإلتزام بهدم عقار مخالف، فيتم إزالة هذا البناء بالقوة الجبرية، وكذلك إذا كان الإلتزام سد مطل تم فتحه بشكل مخالف، وغير ذلك من صور التنفيذ العيني.

ويوصف التنفيذ الجبري في هذه الحالة بأنه تنفيذ عيني؛ لأنه ينصب على عين ما أمر به السند الذي يجرى تنفيذه، ويوصف كذلك بأنه تنفيذ مباشر، بالنظر إلى وسيلة التنفيذ، حيث تحقق تلك الوسيلة التنفيذ بغير إحداث أي تغيير في المركز القانوني لطالب التنفيذ أو المنفذ ضده، بمعنى أن اقتضاء الدائن لحقه يتم مباشرة، فهو لا يفعل سوى اقتضاء محل حقه دون الاعتداء على حقوق أخرى في ذمة المدين^(١).

وقد عني القانون المدني ببيان كيفية التنفيذ العيني، وذلك في الكتاب الأول، الفصل الأول (التنفيذ العيني) من الباب الثاني (آثار الإلتزام) المواد (٢٠٣-٢١٥ مدني)، حيث نصت المادة (١/٢٠٣) مدني على أنه "يجبر المدين بعد إعداره طبقاً للمادتين ٢١٩ و ٢٢٠ على تنفيذ التزامه عيناً متى كان ذلك ممكناً". ولم ينظم قانون المرافعات كيفية إجراء هذا التنفيذ؛ وإنما تطبق بشأنه القواعد العامة التي تتبع في طرق التنفيذ (المواد ٢٧٤-٣١٥ مرافعات).

ووفقاً لما أوجبه المادة (٢٠٣) من القانون المدني؛ فإنه يشترط لإجبار المدين على التنفيذ العيني، توفر الشروط الآتية:

- ١- أن يتمتع المدين عن التنفيذ العيني اختياراً.
- ٢- أن يتم إعدار المدين وفقاً للأحكام المقررة في المادتين (٢١٩ و ٢٢٠) مدني.
- ٣- أن يكون التنفيذ العيني ممكناً.
- ٤- ألا يكون التنفيذ العيني مرهقاً للمدين.

ويكون الإلتزام العيني ممكناً إذا لم يكن هناك مانعاً مادياً أو أدبياً يحول دون إجرائه، كما لو هلك الشيء الواجب تسليمه أو انتقلت ملكيته إلى الغير، فهنا يكون التنفيذ العيني غير ممكن، أو كان من شأن التنفيذ العيني المساس بحرية المدين

(١) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٤.

الشخصية كإكراهه على القيام بالعمل، كما لو كان المطلوب تصميم عمل فني معين، أو تأليف كتاب، أو بناء منزل^(١). ولا يكفي أن يكون التنفيذ العيني ممكنا لإجبار المدين على الوفاء به؛ وإنما يجب فضلا عن ذلك ألا يكون تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين^(٢).

فإذا توفرت شروط التنفيذ العيني؛ فإنه يمكن إجبار المدين على التنفيذ العيني بطريقة مباشرة، تتجاهل فيها السلطة العامة إرادة المدين، وتتولى هي تنفيذ الالتزام، وذلك كما في حالة قيامها بإزالة عقار تم بنائه على ملك الغير، أو إغلاق محل مخالف للقانون، أو إخلاء عقار وتسليمه إلى مالكه. غير أن تدخل السلطة العامة للقيام بالتنفيذ العيني المباشر، يقتضي توفر الآتي:

- ١- أن يتعلق الأمر بالالتزام غير نقدي، بألا يكون محله مبلغا من النقود؛ لأن الإجبار على دفع مبلغ نقدي لا يتم إلا بطريق الحجز والبيع، وليس بطريق التنفيذ المباشر.
 - ٢- أن يكون التنفيذ العيني ممكنا وغير مرهق للمدين.
 - ٣- ألا يكون في التنفيذ العيني اعتداء على الحرية الشخصية.
- فإذا كان التنفيذ عينيا وكان يقتضي تدخلا شخصا من المدين؛ فإن هناك وسيلتان لإجباره على تنفيذ التزامه عينيا، وهما الإكراه البدني، والإكراه المالي.

ثالثا: وسائل إجبار المدين على التنفيذ العيني:

أ- الإكراه البدني:

الإكراه البدني غير جائز في القانون المدني المصري، ذلك أن فكرة الإكراه البدني حتى باعتبارها وسيلة للضغط على المدين القادر على الوفاء، تخالف المبادئ المدنية الحديثة، فالمدين يلتزم في ماله لا في شخصه، وجزاء الالتزام هو تعويض لا عقوبة،

(١) د. رمزي سيف: قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات، دار النهضة، ١٩٥٧، ص ٩.

(٢) ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بشأن المادة (٢٠٣) "الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام عينيا وللمدين عرض القيام بذلك مابقي هذا التنفيذ ممكنا، ولم يستثن المشروع من هذه القاعدة إلا حالة واحدة، استمد حكمها من التقنين الألماني، فإذا لم يكن التنفيذ العيني ميسورا إلا ببذل نفقات لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر جراء التخلف عن الوفاء عينيا، اقتصر حق الدائن استثناء على اقتضاء التعويض".

فحبس المدين في الدين إنما يعني الرجوع بفكرة الإلتزام إلى عهده الأول، حيث كان المدين يلتزم في شخصه، وكان القانون الجنائي يختلط بالقانون المدني، فيتلاقى معنى العقوبة مع معنى التعويض في الجزاء الواحد^(١).

أما التشريعات الحديثة ومنها التشريع المصري، فإنها لا تجيز الإكراه البدني بالحبس، حيث ألغى المشرع المصري هذه العقوبة في الديون كقاعدة، فلا يجوز حبس المدين في المسائل المدنية إلا لتحصيل دين نفقة أو أجره الحضانة أو الرضاعة أو المسكن^(٢). كذلك يجوز حبس المدين لدين الحكومة الناشيء عن جريمة، وهناك بعض الحالات يمثل الإخلال بالإلتزامات فيها جريمة يعاقب عليها بالحبس.

ومن أهم وسائل الضغط على المدين لإكراهه على القيام بتنفيذ التزامه، وسيلة المنع من السفر، حيث يصدر القضاء المدني أمرا بمنع المدين الموسر من مغادرة البلاد حتى يفي بالتزاماته، وذلك بناء على طلب الدائن الذي بيده سند تنفيذي^(٣).

ب- الإكراه المالي:

إذا امتنع المدين عن الوفاء بما التزم به عينا، وكان تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه؛ فإن المشرع أجاز للدائن أن يطلب من القضاء إلزام المدين بهذا التنفيذ؛ وإلا حكم عليه بغرامة يدفعها عن كل يوم، أو فترة زمنية، يتأخر فيه الوفاء عن الأجل المعين له^(٤).

وقد نصت على ذلك المادة (٢١٣) من القانون المدني، بنصها على أنه "١- إذا كان تنفيذ الإلتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ، ويدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك. ٢- وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة".

(١) د. قري عبد الفتاح الشهاوي، الإلتزام، ص ٥٦.

(٢) وفقا لقانون إجراءات النقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

(٣) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ١٠.

(٤) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ١٥.

فالإكراه المالي يقصد به، أن يقوم القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينا في خلال مدة معينة؛ فإذا تأخر في التنفيذ، كان ملزما بدفع غرامة تهديدية عن هذا التأخير، تتبدى في كونها مبلغا معيناً عن كل يوم أو كل أسبوع أو عن كل شهر أو أية وحدة زمنية، أو عن كل مرة يأتي عملاً يخل بالتزامه، وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو إلى أن يمتنع نهائياً عن الإخلال بالالتزام، ثم يرجع إلى القضاء فيما تراكم على المدين من الغرامات التهديدية، ويجوز للقاضي أن يخفض هذه الغرامة أو يمحوها بتاتا^(١)، باعتبار أن الحكم الصادر بالغرامة حكماً تهديداً يمكن للمحكمة الرجوع عنه^(٢).

رابعاً: التنفيذ عن طريق الحجز والبيع:

والتنفيذ الجبري بالحجز والبيع هو الصورة الغالبة في التنفيذ الجبري، ويسمى التنفيذ بنزع الملكية، وذلك بتحقيق ما ينص عليه سند الدائن عن طريق الحجز على أموال المدين، ثم بيعها في المزاد العلني، لاقتضاء دين الدائن الحاجز منها.

والتنفيذ بالحجز أو بنزع الملكية، لا يكون إلا في حالة الالتزام بدفع مبلغ مالي، يستوي في ذلك أن يكون الالتزام مبلغاً مالياً في الأصل، أو كان التزاماً عينياً استحالة إلى مبلغ مالي نتيجة لتعذر التنفيذ العيني.

وفي هذه الوسيلة من وسائل التنفيذ الجبري، يجبر المدين على الوفاء بالتزاماته عن طريق الحجز على أمواله المملوكة له، المنقولة أو العقارية، وبيعها ليحصل الدائن على حقه من حصيلة البيع. وهذا هو ما سنتناوله بالتفصيل في هذا المؤلف إن شاء الله تعالى.

(١) د. قنري عبدالفتاح الشهاوي، الالتزام، ص ٥٩. ذلك أن الحكم بالغرامة التهديدية لا ينفذ إلا بعد تقديرها تقديراً نهائياً بناء على طلب المحكوم له "الدائن"، وفي هذه الحالة يعيد القاضي النظر في الغرامة، والتي يكون له تعديل مقدارها أو إلغاؤها، بحسب ما تم تنفيذه من الإلتزام.

(٢) والأحكام التهديدية تصدرها المحكمة ضد المدين الممتنع عن تنفيذ التزامه، إذا كان محل الالتزام عملاً يقتضى تدخل المدين نفسه، فتحكم عليه المحكمة بغرامة تهديدية عن كل فترة من فترات التأخير وذلك لحمله على الوفاء، فمثل هذه الأحكام لا تحوز الحجية ويجوز للقاضي الذي أصدرها أن يعدلها ومثالها كذلك إذا حكم على شخص بتقديم حساب في وقت معين وإلا حكم عليه بغرامة عن كل يوم تأخير.

الباب الأول

القواعد العامة في التنفيذ

الباب الأول

القواعد العامة في التنفيذ

تمهيد وتقسيم:

نظم المشرع القواعد العامة للتنفيذ في الباب الأول (المواد ٢٧٤ - ٣١٥) من الكتاب الثاني لقانون المرافعات، وجاء عنوان هذا الباب "أحكام عامة"، واشتمل على ستة فصول، تضمنت كل ما يتعلق بسلطة التنفيذ (سواء إدارة التنفيذ أو قاضي التنفيذ)، وبينت السند التنفيذي وما يتصل به، ثم نظمت أحكام النفاذ المعجل، والقواعد والأحكام المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية، ومحل التنفيذ، أي المال الذي يتم الحجز عليه، ثم إشكالات التنفيذ الوقتية والأحكام المتعلقة بها.

وهذه القواعد من الأهمية بمكان، إذ لا يمكن فهم إجراءات الحجز والبيع سواء للمنفولات أو العقارات؛ إلا بعد الوقوف على هذه القواعد العامة، والتي تضمن صحة إجراءات الحجز والبيع، ولذا وجب علينا أن نبين هذه القواعد بشيء من التفصيل قبل الحديث عن أنواع الحجز وما يتبع من إجراءات في الحجز والبيع للمنفول والعقار.

وقد قسمنا الأحكام التي تضمنتها هذه القواعد إلى موضوعات رئيسة، تتصل بأطراف التنفيذ، وسلطته، والسندات التي يجوز التنفيذ بمقتضاها، والحقوق التي يجوز الحجز اقتضاء لها، والأموال التي يجوز الحجز عليها، والمقدمات الإجرائية التي يجب أن تسبق عملية التنفيذ، والقواعد المتعلقة بمنازعاته الموضوعية والوقتية، وذلك في أربعة فصول على النحو الآتي:

الفصل الأول: أطراف التنفيذ والسلطة المختصة به.

الفصل الثاني: السندات التنفيذية.

الفصل الثالث: الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له، والمال الذي يجوز الحجز عليه.

الفصل الرابع: مقدمات التنفيذ، ومنازعاته.

الفصل الأول

أطراف التنفيذ والسلطة المختصة به

الفصل الأول

أطراف التنفيذ والسلطة المختصة به

تمهيد وتقسيم:

حرص المشرع أن يبين في قانون المرافعات، كافة القواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري، لما لها من بالغ الأثر على أطراف التنفيذ، أو غيرهم، وأن يبين من هم أطراف التنفيذ الذين تتخذ الإجراءات منهم أو في مواجهتهم، حتى لا يتعدى التنفيذ إلى غير أطرافه فيضار به من لم يتدخل في الإجراءات أو يعلم بها، وفي الوقت ذاته حتى يختصم في الإجراءات من يجب اختصامه أو إدخاله فيها، كالخلف العام أو الخلف الخاص، أو الغير الذي له علاقة بالمال محل الحجز، إعمالاً لفكرة الأثر النسبي للإجراءات.

وقد بين المشرع ما يجب توفره من شروط في أطراف التنفيذ، من حيث الصفة، وكيفية انتقالها، أو الأهلية وطبيعتها أو نوعها، وما يجب اتخاذه لمباشرة الإجراءات في مواجهة الخلف، وما يتخذ في حال فقد الأهلية أو زوال صفة من يباشر الإجراءات.

كما عمل المشرع على ألا يترك سلطة التنفيذ الجبري في يد الدائن، الذي قد يعجز عن اقتضاء حقه، أو قد ينكل بالمدين في سبيل اقتضاء هذا الحق، فأناط بإدارة التنفيذ التي حلت عملاً محل قاضي التنفيذ في الإشراف والرقابة على إجراءات التنفيذ، سلطة مباشرة هذه الإجراءات بواسطة معاوني التنفيذ، مع الإبقاء على اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في المنازعات الموضوعية والوقتيّة التي تتعلق بالتنفيذ.

ونبين ذلك في مبحثين، نتحدث في الأول منهما عن أطراف التنفيذ، وفي الثاني عن السلطة المختصة بالتنفيذ، وذلك على النحو التالي.

المبحث الأول

أطراف التنفيذ

أطراف التنفيذ، هم أشخاص الرابطة القانونية التي تدور حولها إجراءات التنفيذ، وهم الذين عمل المشرع على تنظيم وتحديد علاقاتهم ومراكزهم القانونية بما سنه من قواعد في قانون المرافعات للتنفيذ وإجراءاته. وهؤلاء هم طالب التنفيذ، وهو الدائن الذي يطلب من القضاء اتخاذ إجراءات التنفيذ اقتضاء لحقه، والمنفذ ضده، وهو المدين الممتنع عن تنفيذ التزامه اختياراً والذي تتخذ إجراءات التنفيذ الجبري في مواجهته، والغير الذي يكون له صلة بالمال المحجوز عليه. ولا يدخل ضمن هؤلاء، القائمون على إجراءات التنفيذ، سواء إدارة التنفيذ، أو معاون التنفيذ، أو قاضي التنفيذ، وإنما هؤلاء هم سلطة التنفيذ التي تتولى مباشرة الإجراءات والإشراف والرقابة عليها.

المطلب الأول: طالب التنفيذ

طالب التنفيذ هو الشخص الذي تتخذ لصالحه إجراءات التنفيذ، وهو الطرف الإيجابي الذي يطلب الحماية القضائية؛ أي الشخص الذي يتخذ المبادرة في تحريك السلطة القضائية للدولة نحو تمكينه من الحصول على حقه، فتتخذ إجراءات التنفيذ لصالحه، سواء كان صاحب حق شخصي أو حق عيني، وأياً ما كان طريق التنفيذ، سواء التنفيذ العيني، أم التنفيذ بالحجز والبيع، ويسمى هذا الشخص "الحاجز" إذا كان التنفيذ يتم بطريق الحجز، كما يسمى "الدائن" على اعتبار أنه صاحب الحق في التنفيذ^(١). وسواء كان هذا الدائن دائناً عادياً أو دائناً مرتهناً أو دائناً ممتازاً^(٢).

وعلى ذلك يمكن تعريف الحاجز أو طالب التنفيذ بأنه: كل من يجرى التنفيذ لصالحه على مال معين سواء أطلب هو التنفيذ أو أوجب القانون إدخاله في إجراءاته^(٣).

(١) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٢١٥ - د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ٤٢.

(٢) د. عبدالباسط جميعي: نظام التنفيذ في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، ١٩٦٦، ص ٥٣.

(٣) د. أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة في قانون المرافعات، ٢٠١٢م، ج ٨٧٧/٥.

وترجع أهمية تحديد طالب التنفيذ؛ باعتباره الطرف الإيجابي في التنفيذ، إلى أمرين^(١):
الأول: أن هذا الطرف تكون له وحده سلطة مباشرة للإجراءات، والقاعدة في التنفيذ بالحجز ونزع الملكية أنه إذا تعدد الحاجزون؛ فإن سلطة مباشرة إجراءات الحجز تخول للحاجز الأول (الأسبق في الحجز)، ويطلق عليه اسم الدائن المباشر للإجراءات، ومع ذلك يجوز أن يحل محله حاجز آخر، متى أهمل في مباشرة الإجراءات أو في تسيرها بما يؤثر في حقوق غيره من الحاجزين.

الثاني: أنه لا يستفيد من إجراءات ولا يضار منها إلا من كان طرفاً فيها، وهو ما يعرف بالأثر النسبي للإجراءات؛ ولذلك يترتب على تحديد الطرف الإيجابي للتنفيذ تحديد آثار إجراءاته، فمثلاً لا تنفذ التصرفات في المال المحجوز في مواجهة أشخاص الطرف الإيجابي وحدهم، بينما تكون صحيحة ونافذة بالنسبة لغيرهم، كذلك فإن أشخاص الطرف الإيجابي قبل بيع المنقولات أو العقارات المحجوزة يختصون بحصيلة التنفيذ، بحيث يتم التوزيع عليهم فقط، أما غيرهم ممن يحجز بعد البيع على الثمن، فلا يحجز إلا على ما قد يتبقى من هذا الثمن بعد استيفاء أشخاص الطرف الإيجابي لحقوقهم.

الشروط التي يجب توفرها في طالب التنفيذ:

لكي يصبح طالب التنفيذ أو الحاجز في مركز قانوني سليم، يخول له الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ؛ فإنه يجب أن يتوفر فيه شرط الصفة، وشرط الأهلية:

١- الشرط الأول: الصفة في طالب التنفيذ:

يجب أن يتوفر في طالب التنفيذ شرط الصفة؛ بأن يكون هو صاحب الحق في التنفيذ، وصاحب الحق في التنفيذ هو صاحب الحق الموضوعي، فطلب التنفيذ لا يقبل إلا من صاحب الصفة في مباشرة الإجراءات؛ فإذا قدم من شخص ليس له صفة في ذلك، فلا يكون هذا الطلب مقبولاً، وإذا قام هذا الشخص رغم عدم توافر الصفة بمباشرة إجراءات الحجز؛ اعتبر هذا الحجز كأن لم يكن، ولا يعتد به، ولصاحب الشأن رفع

(١) د. وجدي راغب فهمي: النظرية العامة في التنفيذ، منشأة المعارف، ١٩٧٤، ص ٢٦٥.

دعوى عدم الاعتداد بالحجز^(١).

ويقصد بالصفة أن يكون الحاجز هو صاحب الحق في التنفيذ، ويتم التأكد من ذلك عن طريق السند التنفيذي، والذي يجب أن يظهر أن طالب التنفيذ هو صاحب الحق في إجراءاته، وصاحب الحق في التنفيذ هو صاحب الحق الموضوعي، وتثبت الصفة بهذا المعنى لكل دائن سواء كان دائنا عاديا أو دائنا ممتازا^(٢)، كما تثبت لكل من يقوم مقام الدائن في مباشرة إجراءات التنفيذ، أي النائب عنه سواء كان نائبا اتفاقيا أي وكيلًا أو نائبا قانونيا كالولي أو الوصي أو القيم^(٣). كما يجوز لدائن الدائن أن يطلب التنفيذ متى توفرت شروط الدعوى غير المباشرة^(٤) المنصوص عليها في المادة ٢٣٥ و٢٣٦ مدني. وتثبت الصفة للنيابة العامة في الأحوال التي يكون لها فيها رفع الدعوى.

ولا فرق في الصفة بين الدائن العادي والدائن المرتهن، فتثبت الصفة لأيهما متى ظهر من سند التنفيذ أنه صاحب الحق في مباشرة الإجراءات، ومعنى ذلك أن للدائن العادي أن يحجز على أي مال مملوك لمدينه، ولو كان هذا المال مرهونا لدائن آخر أو محملا بحق تباعي آخر، غاية ما في الأمر أن الدائن المرتهن أو صاحب الحق التباعي، يقدم على الدائن العادي مباشر الإجراءات في اقتضاء حقه؛ ولذا فإن الدائن العادي غالبا ما لا يقدم على حجز مال مقيد بحق تباعي لصالح دائن آخر؛ لأنه قد لا يستفيد من هذا الحجز، عند اقتضاء صاحب الحق التباعي لحقه أولا^(٥).

(١) د. عزمي عبدالفتاح: قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، دار الفكر العربي ١٩٨٣، ص ٧٥٠-د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، ١٩٨١، ص ٧٠٦.

(٢) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، مؤسسة الثقافة الجامعية، ١٩٧٩، ص ٢٧١.

(٣) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٢٥٨.

(٤) وإن كان من الأفضل له أن يتبع طريق حجز ما للمدين لدى الغير حتى لا يتقيد بضرورة توافر الشروط اللازمة لقيامه باستعمال حقوق مدينه وحتى يتفادى استفادة باقي الدائنين الذين لم يتدخلوا في إجراءات التنفيذ التي يقوم بها، ومن ثم يتمكنون من مزاحمته عند حصوله على حقه، وذلك بعكس الحال في حجز ما للمدين لدى الغير، حيث يجب أن يتدخل هؤلاء الدائنون في إجراءات الحجز حتى يتمكنوا من استيفاء حقوقهم. (د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٨٧٩/٥).

(٥) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ٤٣.

وفي المقابل فإن للدائن صاحب الحق التبعية الحجز على أي مال مملوك لمدينه، ولو كان غير المال المرهون له، حتى وإن كان المال المرهون له يكفي لسداد قيمة الدين المضمون بالحق التبعية^(١).

الوقت الذي يجب أن تتوفر فيه الصفة لطالب التنفيذ:

يجب أن تتوفر الصفة في طالب التنفيذ عند البدء في إجراءات التنفيذ؛ فإن لم تتوفر هذه الصفة كانت الإجراءات باطلة، حتى ولو ثبتت له قبل تمام الإجراءات^(٢).

ومعنى ذلك أن شرط الصفة يقتضي أن يكون حق الدائن ثابتاً وقت التنفيذ، أي وقت البدء في إجراءات الحجز، فلو تحققت الصفة بعد ذلك؛ فإن ذلك لا يؤدي إلى تصحيح الإجراءات السابقة على تحقق الصفة؛ وإنما يكون الحجز باطلاً؛ لأن الحجز حين وقع لم يكن الحاجز دائناً أي لم تكن له صفة في اتخاذ إجراءات الحجز^(٣).

ويجب توفر شرط الصفة في كل حاجز ولو تعدد الحاجزون في حجز واحد، ذلك أنه لا يترتب على الحجز إخراج المال من ذمة المحجوز عليه، بل يظل في ذمته ضماناً عاماً لكافة الدائنين؛ ولذا يجوز توقيع حجوز أخرى على الأموال التي سبق حجزها وتتوحد الإجراءات ويجرى البيع في يوم واحد لمصلحة جميع الحاجزين^(٤).

انتقال الصفة في طلب التنفيذ إلى الخلف:

الحق في التنفيذ كحق مستقل ينتقل إلى من انتقل إليه الحق محل الحماية التنفيذية، فانتقال الحق في التنفيذ هو أثر لانتقال الحق الموضوعي، ويترتب على ذلك عدم

(١) أستاذي د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، مطبعة النور، ٢٠١٠م، ص ٢١.

(٢) د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ١٤٩.

(٣) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٢٧١. ويرى سيادته أن هذا الفرض يصعب تصور حدوثه، وذلك لأن إجراءات الحجز يسبقها اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بإعداد السند التنفيذي وإعلانه، ثم مباشرة الحجز فعلاً وكل هذه المراحل تؤكد صفة الحاجز، ولكن من المتصور أثناء مباشرة الحجز إلغاء السند الذي يباشر الحجز به، فهنا تزول الصفة ويزول تبعاً لها ما تم من إجراءات الحجز.

(٤) د. وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للتنفيذ، ص ٢٧٣.

إمكانية تصور انتقال الحق في التنفيذ إلى شخص آخر استقلالا عن الحق الموضوعي^(١).

ولما كان الحق في التنفيذ ينتقل بانتقال الحق الموضوعي؛ فإنه يجوز لخلف الدائن أن يباشر إجراءات التنفيذ في مواجهة المدين^(٢)، فيجوز للخلف العام كالوارث والخلف الخاص كالمحال له الدين أو الموصى له به أن ينفذ ضد المدين بشرط أن يثبت للأخير الصفة التي تخوله الحق في اتخاذ التنفيذ بدلا من الدائن الأصلي؛ لأن التنفيذ يؤدي إلى وفاء المدين بما عليه وهذا الوفاء لا يكون صحيحا إلا إذا حصل إلى من له صفة في اقتضائه^(٣).

هذا وقد نصت المادة (٢٨٣) مرافعات على أنه "من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ".

وتتضمن هذه المادة قاعدة مهمة، مفادها؛ أن الحلول القانوني أو الاتفاقي يترتب عليه أن يستكمل المحال له ما بدأه الدائن من إجراءات، سواء كانت إجراءات خصومة أو إجراءات تنفيذ.

فدلالة النص واضحة في أن القانون يخول من حل محل الدائن في حقه الموضوعي، الحق في الحلول محله أيضا فيما اتخذ من إجراءات تنفيذية، ومن ثم لا تبطل إجراءات التنفيذ التي اتخذها الدائن، وإنما يعتد بها ويستأنف من حل محل الدائن مباشرة الإجراءات من الإجراء الذي وصل إليه الحاجز، دون حاجة للبدء في الإجراءات من جديد، وذلك لتفادي الإطالة في الإجراءات وتفادي زيادة النفقات. ولا يقتصر الحلول في هذه الحالة على الحلول القانوني أو الاتفاقي (٣٢٤-٣٣١)، بل يمتد إلى حالة حوالة الحق التي نظمها القانون المدني في المواد (٣٢٤-٣١٤)^(٤).

(١) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٢٧٣.

(٢) د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ١٤٩.

(٣) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٥/٨٨٠.

(٤) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٥/١٠٠٤.

ويستوجب تغير صفات الخصوم في إجراءات التنفيذ؛ إخطار الخصم الآخر بها، حتى لا يفاجأ بموالة الإجراءات في مواجهة من أصبح غير ذي صفة، كما إذا بلغ القاصر سن الرشد، فانقضت صفة الولي أو الوصي، وكذلك حالة تغيير الخصم لموطنه، فهو ملزم بإخطار خصمه بموطنه الجديد^(١).

٢- الشرط الثاني: أهلية طالب التنفيذ:

يجب أن تتوفر الأهلية في طالب التنفيذ إلى جانب شرط الصفة؛ إذ لا تكفي الصفة لمباشرة الإجراءات؛ وإنما يجب فيمن يباشرها أن يكون أهلاً لذلك. وطالب التنفيذ يسعى إلى اقتضاء حقه الثابت في السند التنفيذي، واقتضاء الدين تصرف نافع نفعا محضاً، ومن ثم تكفي له أهلية الإدارة، ولا تلزم له أهلية التصرف^(٢).

وطالما أنه يكفي توفر أهلية الإدارة في طالب التنفيذ؛ فإنه يمكن للقاصر المأذون له بالإدارة طلب التنفيذ على أموال مدينه، كما يمكن للوصي القيام بذلك دون الحصول على إذن من المحكمة^(٣).

ولا يؤدي فقد الأهلية أثناء إجراءات التنفيذ إلى انقطاع إجراءات التنفيذ، وإنما يكون لمن قام مقام الخصم الذي فقد أهليته أو توفي أو فقد الصفة، الحلول محله في الإجراءات التي اتخذها^(٤).

المطلب الثاني

المنفذ ضده

المنفذ ضده هو الشخص الذي يقدم طلب التنفيذ، وهو من يتحمل بالإلتزام الثابت في السند التنفيذي؛ ولذا فإنه يعد الطرف السلبي في عملية التنفيذ^(٥). والأصل أن يوجه

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٢٦٢.

(٢) د. وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للتنفيذ، ص ٢٦٥.

(٣) د. محمود هاشم، قواعد التنفيذ الجبري وإجراءاته، دار الفكر العربي، ١٩٩١، ص ٨١.

(٤) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٢٢١.

(٥) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ٥٢.

التنفيذ ضد المدين، فهو المسئول الشخصي عن الدين، وهو أول من يجب التنفيذ عليه، باعتباره الملتزم في السند التنفيذي^(١). ويسمى "المحجوز عليه" في الحجز.

فلا يصح التنفيذ أو الحجز إلا على من كان مدينا شخصيا للحاجز، ومالكا للأموال المراد حجزها، فيجوز توقيع الحجز على المدين الأصلي وكفيله ووارثه ومن أوصى له بجزء من التركة في حدود ما استولى عليه الوارث أو الموصى له من تركة المورث^(٢).

ويشترط أن يتوفر في المنفذ ضده، شرط الصفة، وشرط الأهلية، فلا يجوز اتخاذ الإجراءات ضد من لا صفة له، ولا ضد من لا تتوفر فيه الأهلية اللازمة للحجز على أمواله، وذلك على النحو الآتي:

١- الشرط الأول: شرط الصفة في المنفذ ضده:

يجب أن يكون المدين المنفذ ضده "المحجوز عليه" ذا صفة في إجراءات التنفيذ؛ بأن يكون هو من يلزمه القانون بالأداء الثابت بالسند التنفيذي، ويتم التحقق من توفر هذه الصفة من السند التنفيذي. ومعنى وجوب توفر الصفة؛ أنه لا يصح توقيع الحجز إلا على من كان مدينا شخصيا للحاجز ومالكا للمال المراد حجزه.

وعلى سبيل الاستثناء قد تثبت الصفة لمن لا يكون مدينا شخصيا للدائن، أي لمن لا يكون ملتزما بالأداء الثابت بالسند التنفيذي، وذلك كالكفيل العيني وحائز العقار المرهون، وذلك لأن كل منهما يملك مالا مثقلا بحق عيني لمصلحة طالب التنفيذ، وبالتالي يكون لهذا الأخير أن يتتبع المال في أي يد كان^(٣).

وكما أشرنا سلفاً؛ فإنه التنفيذ يكون ضد المدين نفسه، كما يجوز التنفيذ ضد الخلف العام، أو ضد الخلف الخاص، وذلك على النحو الآتي:

(١) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٢٢١.

(٢) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٢٧٦.

(٣) د. وجدي راغب فهمي، النظرية العامة في التنفيذ، ص ٨٨٨.

التنفيذ في مواجهة الخلف العام:

الخلف العام، هو من يرث تركة المتوفي بأسرها أو حصة شائعة فيها، والقاعدة أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون، وطبقا لهذه القاعدة؛ فإن أموال المورث لا تنتقل إلا بعد وفاء ديونه، ولذلك فإن السند التنفيذي الصادر في مواجهة المورث ينفذ به في مواجهة التركة^(١).

وقد نص المشرع في المادة (٢٨٤) مرافعات على القواعد المتعلقة بالحجز في مواجهة الورثة، وهذه القواعد هدف القانون من وراءها إلى حماية طالب التنفيذ وحماية الورثة المنفذ ضدهم.

وجاء نص هذه المادة على النحو الآتي "إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.

ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم، بغير بيان أسمائهم وصفاتهم". ومفاد هذا النص أنه يجب إعادة إعلان السند التنفيذي إلى ورثة المدين المتوفى، كما يجب أن تتقضي ثمانية أيام كاملة قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ ضدهم، والحكمة من ذلك هي إتاحة الفرصة لهؤلاء الورثة للوفاء اختيارا إذا أرادوا ذلك، وأن تتاح لهم الفرصة للاستعداد لإجراءات التنفيذ إذا لم يوفوا اختيارا^(٢).

وقد راعى المشرع حالة طالب التنفيذ الذي قد لا يعرف ورثة مدينه، فعمد إلى التيسير عليه في الفقرة الثانية من المادة ذاتها؛ بأن أجاز له إعلان الأوراق قبل انقضاء ثلاثة أشهر من وفاة المدين، في آخر موطن كان لهذا المدين، ودون اشتراط بيان أسماء الورثة أو صفاتهم. والغرض من ذلك حماية مصلحة طالب التنفيذ، حتى لا

(١) د. عبدالباسط جميعي، نظام التنفيذ، ص ٤٥.

(٢) د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ١٥٦.

يكون مضطرا إلى إعلان الأوراق إلى كل وارث بإسمه، وبما قد يؤدي إليه ذلك من سقوط حقه أثناء بحثه عن هؤلاء الورثة.

وتجب الإشارة إلى أن نص الفقرة الثانية مقرر لمصلحة طالب التنفيذ، والذي يكون الحق في استعماله مباشرة دون الإعلان في موطن كل وارث وفقا للفقرة الأولى، ولا بطلان في ذلك؛ لأن النص لم يقرر البطلان، وغاية الأمر أنه إذا انقضت الثلاثة أشهر دون الإعلان على النحو المقرر في الفقرة الثانية، فلا يحق لطالب التنفيذ مباشرة الإجراءات حينئذ إلا بعد أن يعلن الورثة بأسمائهم وصفاتهم وفي موطن كل منهم^(١).

التنفيذ في مواجهة الخلف الخاص:

وذلك كأن يتم حوالة الدين طبقا للقواعد المقررة في القانون المدني، فإذا تمت الحوالة؛ فإنه يجوز للدائن أن ينفذ بمقتضى السند التنفيذي الصادر ضد مدينه، في مواجهة المحال إليه.

الاستثناءات على شرط الصفة في المنفذ ضده:

ما سبق بيانه بشأن شرط الصفة في المنفذ ضده، هو القاعدة العامة، وهذه القاعدة يرد عليها استثناءان، أولهما: عدم اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد بعض المدينين، وثانيهما: اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد غير الملزم بالدين.

الاستثناء الأول: عدم اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد بعض المدينين:

فهناك مدينين لا يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ ضدهم، وذلك لاعتبارات مختلفة، وأهم هؤلاء: الدول الأجنبية ورؤساؤها وممثلوها الدبلوماسيون، والمنظمات الدولية وممثلوها الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، وفي الحدود المقررة لهذه الحصانة. فقد استقرت قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية على عدم اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد هؤلاء الأشخاص.

وفي هذا السياق أيضا ووفقا للرأي الراجح في الفقه القانوني؛ فإنه لا يجوز التنفيذ

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٥/٨٨٩.

الجبري ضد الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة في مصر، وذلك فيما يتعلق بالأموال العامة، أما فيما يتعلق بالأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، فيمكن الحجز والتنفيذ عليها، وكذلك يمكن حجز أموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، لدى الغير.

والمنع من التنفيذ على أموال الدولة الخاصة -عند من يقول به- يقتصر على التنفيذ بنزع الملكية، أما التنفيذ المباشر فهو جائز ضد الدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية، كتسليم منقول أو إخلاء عقار أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل^(١).

الاستثناء الثاني: اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد غير الملزم بالدين:

ومقتضى هذا الاستثناء أن هناك حالات تتخذ فيها إجراءات الحجز في مواجهة أشخاص غير المدين، ولا تتوافر فيهم الصفة الواجب توفرها في المنفذ ضده. ومثال ذلك:

- حجز العقار في مواجهة الحائز الذي انتقلت إليه ملكية عقار مرهون، دون أن يكون مسئولاً عن الدين مسئولية شخصية. (مادة ٤١١ مرافعات).
- حجز العقار في مواجهة الكفيل العيني، وهو من قدم عقارا مملوكا له ضمانا لدين على غيره. (الفقرة الأخيرة للمادة ٤٠١ مرافعات).
- الحجز الذي يجريه المؤجر على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ضمانا لدين ناشئ عن علاقة الإيجار، حتى وإن كانت هذه المنقولات غير مملوكة للمستأجر. (مادة ٣١٧ مرافعات).

الشرط الثاني: شرط الأهلية في المنفذ ضده:

يجب أن تتوفر الأهلية في المنفذ ضده، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات في مواجهته، فإذا كان المنفذ ضده عديم الأهلية، فيجب اتخاذ الإجراءات في مواجهة من يمثله، نيابة عنه.

والأهلية اللازم توفرها في المنفذ ضده، هي أهلية التصرف، ومن ثم لا تكفي أهلية

(١) د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ١١٧.

الإدارة، إذا كان التنفيذ بنزع الملكية، أما في التنفيذ المباشر، فتكفي أهلية الإدارة، وبالتالي يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر في مواجهة القاصر المأذون له بالإدارة، في الأحوال التي يتعلق السند التنفيذي فيها بالتزام ناشئ عن الإدارة المأذون بها، ومتى كان التنفيذ يجرى على الأموال المأذون له بإدارتها^(١).

والعلة في هذا الاختلاف أن التنفيذ بنزع الملكية يؤدي إلى إخراج المال المحجوز عليه من ملك المنفذ ضده، ولذلك وجب أن تتوفر فيه أهلية التصرف، فإن لم تتوفر فيه هذه الأهلية، فيجب أن تتخذ الإجراءات في مواجهة من يمثله؛ وإلا كانت باطلة.

وإعمالاً لما نصت عليه المادة ١/٢٨٤ مرافعات، فإنه إذا فقد المدين المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل تمام التنفيذ، وجب إعلان من يقوم مقامه بالسند التنفيذي، وذلك سواء كان فقد الأهلية قبل بدء التنفيذ أو أثناء إجراءاته، ولا يكفي مجرد إعلان من يقوم مقام المدين الذي فقد أهليته، وإنما يجب مضي ثمانية أيام بعد إعلان السند التنفيذي وقبل مباشرة الإجراءات.

المطلب الثالث

الغير: ودوره في التنفيذ الجبري

يقصد بالغير في مفهوم التنفيذ الجبري، كل شخص له صلة بالمال المراد التنفيذ عليه، تقتضي إدخاله في إجراءات التنفيذ ويعد طرفاً فيه؛ وإن لم يكن ملزماً بالحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له^(٢).

ووفقاً لنص المادة (٢٨٥) مرافعات؛ فإنه "لايجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل". ويرى الفقه القانوني^(٣)، أنه يشترط لاعتبار شخصاً ما غيراً في مجال التنفيذ الجبري، ووفقاً لمفهوم المادة ٢٨٥ مرافعات، توفر

(١) د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ٩٦.

(٢) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٢٣٠.

(٣) د. عبدالباسط جميعي، نظام التنفيذ، ص ٥٩.

الشروط الآتية:

- ١- ألا يكون الشخص المطلوب منه التنفيذ قد اختصم في الدعوى الموضوعية بشخصه أو مثله فيها أحد أطرافها بحكم القانون.
 - ٢- ألا تتعلق له مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد اقتضاؤه، ولا يعود عليه من إجراء التنفيذ نفع ولا ضرر، فيستوي عنده أن يتم التنفيذ لمصلحة أي من الخصمين.
 - ٣- أن يكون من واجبه الاشتراك في تنفيذ السند التنفيذي، وذلك بسبب صفته أو وظيفته أو علاقته بالخصوم.
- فإذا لم يكن للشخص أية صلة قانونية بالتنفيذ تلزمه بالاشتراك فيه؛ فإنه لا يعتبر غيراً في التنفيذ بالمعنى الاصطلاحي، حتى وإن سمح له القانون بالتدخل فيه بشكل معين، ومثال ذلك من يدعي ملكية المنقولات أو العقارات محل الحجز.
- ويجب أن تكون الصلة التي تربط الشخص بالتنفيذ حتى يصبح من الغير؛ صلة خاصة بمحل التنفيذ، ولذا لا يعتبر من الغير من يشترك في التنفيذ لمهمة وظيفية، كقاضي التنفيذ، ومعاون التنفيذ، فهؤلاء ليسوا من الغير بالمعنى المقصود هنا. ولا ينطبق ذلك على جميع الحالات؛ فهناك حالات يعد فيها الموظف من الغير، وذلك كمعاون التنفيذ الذي يكون المال محل الحجز تحت يده، وذلك كما لو تم الحجز على ما للغير لدى الجهة حكومية^(١).
- ومن أمثلة الغير في التنفيذ: المحجوز عليه في حجز ما للمدين لدى الغير، ومأمور الشهر العقاري الذي يقوم بمحو القيد أو شطب التسجيل بناء على حكم قضائي، وكاتب المحكمة المكلف بحفظ الودائع الذي يقوم بصرف الوديعة لمن يصدر الحكم في صالحه، والحارس القضائي الذي يلزم بتسليم العين الموضوعة تحت الحراسة لمن يحكم له بملكيته^(٢).

(١) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ٦٦.

(٢) د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٢٩.

شروط التنفيذ في مواجهة الغير:

وفقا لنص المادة (٢٨٥) مرافعات؛ فإنه لا يجوز التنفيذ في مواجهة الغير، ولا أن يؤدي هذا الغير، المطلوب بموجب السند التنفيذي؛ إلا إذا توفرت الشروط الآتية:

١- إعلان المدين بالعزم على التنفيذ:

إذ يجب إعلان المدين أولا لشخصه أو في موطنه بالعزم على التنفيذ، على المال الموجود لدى هذا الغير، أو قيام هذا الغير بأداء المطلوب بالسند التنفيذي، وذلك حتى يتدارك المدين أمره ويبادر إلى الوفاء، فربما تكون له مصلحة في عدم التنفيذ على هذا المال، كما لو كان رصيذا مودعا في أحد البنوك، ولا يرغب في الحجز عليه حتى لا يفاجأ بانعدام الرصيد في حالات يكون قد وقع فيها على شيكات تخصم من هذا الرصيد^(١).

٢- مضي ثمانية أيام على الأقل بعد إعلان المدين وقبل التنفيذ:

فإذا وقع الحجز قبل انقضاء هذا الميعاد بكامله؛ فإن الحجز يكون باطلا، وذلك أن هذا الميعاد مقرر للمدين ليتدبر أمره قبل إجراء التنفيذ، فله يرغب في الاعتراض على الحجز وإعلان الغير بعدم التنفيذ، فيجب أن يترك له فرصة لذلك، ومن ثم لا يجوز التنفيذ قبل مضي الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة. ويجب مراعاة ذلك، سواء فيما يتعلق بالإعلان أو المدة، بالنسبة للتنفيذ الجبري أو الاختياري على السواء، بمعنى أنه لا يجوز للغير الوفاء اختيارا دون مراعاة ذلك، ولا يجوز التنفيذ عليه جبرا كذلك؛ إلا بتوفر الشرطين.

(١) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٢٨٩.

المبحث الثاني

السلطة المختصة بمباشرة إجراءات التنفيذ

أوجب القانون أن تكون هناك سلطة تباشر إجراءات التنفيذ، وهي لا تتمثل في الدائن لأنه لا يقوم بالتنفيذ؛ وإنما ينحصر دوره في تحريك النشاط القضائي بهدف البدء في التنفيذ، كما أنها لا تتمثل في المدين؛ لأنه لا يقوم بالتنفيذ أيضا بل يخضع له؛ فالسلطة التي تباشر التنفيذ إذا هي سلطة خارجية عن كل من الدائن والمدين^(١).

ولقد حرص المشرع في قانون المرافعات الحالي أن تكون هذه السلطة، ذات صفة قضائية، بخلاف ما كان عليه الحال في قانون المرافعات السابق، والذي كان يسند مهمة التنفيذ إلى قلم المحضرين، الذي كان يباشر إجراءات التنفيذ في جميع مراحلها، دون إشراف أو رقابة من القضاء، على اعتبار أن أعمال التنفيذ مجرد أعمال إدارية، مما أدى إلى تقليص دور قاضي التنفيذ^(٢)؛ إلا أن المشرع عدل عن هذه الفكرة في قانون المرافعات الحالي، فنص بداية على إسناد سلطة الإشراف والرقابة على أعمال التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وذلك بهدف تدعيم رقابة القضاء على كافة إجراءات التنفيذ، وتوحيد الاختصاص بالمسائل المتعلقة به في يد قاض واحد، يكون مختصا دون غيره بالفصل في كافة منازعات التنفيذ.

وعلى حد تعبير المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات، توفير إشراف فعال متواصل للقاضي على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته، وعلى القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم، وجمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في ملف واحد وفي يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الإلتجاء إليه^(٣).

ثم في تطور لاحق وأخير -حتى تاريخه- استحدث المشرع نظام إدارة التنفيذ بمقتضى القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ والمعدل لقانون المرافعات الحالي، وأسند إلى

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٥/٧٧٠.

(٢) د. عبدالباسط جميعي، نظام التنفيذ، ص٥٣.

(٣) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.

هذه الإدارة (المشكلة من قضاة)، سلطة الإشراف على كافة إجراءات التنفيذ، وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة به، وفي الوقت ذاته، أبقى على نظام قاضي التنفيذ، والذي أصبح دوره في القانون الحالي وبعد هذا التعديل، الفصل في كافة المنازعات الموضوعية والوقئية المتعلقة بالتنفيذ.

وبهذا القانون أيضاً، استبدل المشرع معاوني التنفيذ بمحضري التنفيذ، وأصبح معاونو التنفيذ هم المختصون بمباشرة الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ تحت إشراف ورقابة إدارة التنفيذ. ونحدث عن ذلك في ثلاثة مطالب، ثم نبين السلطة المختصة بالتنفيذ في الفقه الإسلامي في مطلب رابع، وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول

إدارة التنفيذ

إدارة التنفيذ هي السلطة التي تباشر إجراءات التنفيذ، وتتم إجراءات التنفيذ بالكامل تحت إشرافها؛ ذلك أن المشرع وزع الاختصاص بمسائل التنفيذ بين قاضي التنفيذ؛ وإدارة التنفيذ، بحيث أبقى على اختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ سواء كانت وقتية أم موضوعية، وأسند إلى إدارة التنفيذ الإشراف على الإجراءات وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ.

حيث نصت المادة (٢٧٤) مرافعات على أنه: "يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة كل محكمة جزئية.

ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف، ويعاونه عدد كاف من قضااتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة^(١).

(١) ويتولى مدير إدارة التنفيذ مباشرة اختصاصاتها، واتخاذ ما يراه لازماً لحسن سير العمل بها وانتظامه بما يكفل استمراره طوال الأوقات التي يجوز فيها البدء في إجراء التنفيذ طبقاً للمادة السابعة من قانون المرافعات (المادة ٢ من قرار وزير العدل رقم ٧٣٣٦ لسنة ٢٠٠٨ بتنظيم إدارة التنفيذ وقواعد اختيار معاوني التنفيذ وموظفي الإدارة).

ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم. ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائياً. ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل^(١).

ووفقاً لهذا النص؛ فإن المشرع أوجب أن تتم جميع إجراءات التنفيذ تحت إشراف إدارة التنفيذ بحيث يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ، وينشأ لكل طلب منها ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات، ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أي من قضاتها عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وما يصدره قاضي التنفيذ من أحكام. حيث ألزم المشرع إدارة التنفيذ بالإشراف على كافة إجراءاته بدءاً من تقديم طلب التنفيذ وانتهاء بتمام إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام القانون.

وفى هذا الصدد أوجب المشرع أن يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ، لتكون هذه هي أولى خطوات إشراف الإدارة على أعمال التنفيذ تتوالى بعدها الإجراءات التي تتولى الإدارة الإشراف عليها "ذلك أنه لا يجوز للدائن أن يقتضى من مدينه حقه لنفسه حتى لا يظلمه إذا أساء التقدير أو يعمل على إذلاله في ثورة غضبه، ثم قد يعجز هو عن اقتضاء حقه منه"^(٢) لذلك فقد أوجب المشرع أن تكون هناك سلطة تباشر إجراءات التنفيذ وتتولى الإشراف عليه، وهذه السلطة وفقاً للمادة (٢٧٤) مرافعات هي إدارة التنفيذ.

وقد أوجب المشرع في المادة (٢٧٨) أن يعرض ملف التنفيذ على مدير إدارة التنفيذ أو أي من قضاتها عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وما

(١) صدر قرار وزير العدل رقم (٨٤٥٨) لسنة ٢٠٠٧م بتنظيم إدارة التنفيذ وقواعد اختيار معاوني الإدارة وموظفيها ونشر في الوقائع المصرية العدد (٢٥٧) في ١١ نوفمبر سنة ٢٠٠٧م، ثم صدر قرار وزير العدل ٧٣٣٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن تنظيم إدارة التنفيذ وقواعد اختيار معاوني التنفيذ وموظفي الإدارة، ونشر في الوقائع المصرية العدد ٢٠٥ بتاريخ ٣ / ٩ / ٢٠٠٨.

(٢) د. أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ، ص ٢٥.

يصدره قاضي التنفيذ من أحكام.

ويجب على معاون التنفيذ عرض طلب التنفيذ والمستندات المرفقة به على مدير الإدارة أو من ندبه من قضاتها.

مع ملاحظة أنه إذا تم التأشير من مدير إدارة التنفيذ أو أحد قضاتها، أو من معاون التنفيذ بأنه تم اتخاذ إجراء معين فلا سبيل للدعاء بخلاف ذلك إلا بسلوك الطعن بالتزوير على هذا المستند الذي تم التأشير عليه باعتباره قد اكتسب صفة الرسمية بهذا التأشير.

ويمكن تحديد اختصاصات إدارة التنفيذ وفقاً لما قرره المادة (٢٧٨) في الآتي:

- ١- إعداد سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ.
- ٢- إنشاء ملف لكل طلب تنفيذ تودع به جميع الأوراق المتعلقة بالطلب.
- ٣- عرض ملف التنفيذ على مدير الإدارة أو أي من قضاتها عقب كل إجراء، ويثبت في الملف ما يصدره من قرارات وأوامر، وما يصدره قاضي التنفيذ من أحكام.

إجراءات العمل بإدارة التنفيذ:

في ضوء الاختصاصات التي أسندها المشرع إلى إدارة التنفيذ، صدر قرار وزير العدل رقم ٧٣٣٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن تنظيم إدارة التنفيذ وقواعد اختيار معاوني التنفيذ وموظفي الإدارة، وقد بين هذا القرار إجراءات العمل بالإدارة على النحو الآتي:

- ١- يتولى مدير الإدارة، أو من يعاونه من قضاتها، فحص ومراجعة كافة طلبات التنفيذ التي تلقاها والمستندات المرفقة بها، للتحقق من اختصاص الإدارة وسلامة السند التنفيذي وصلاحيته للتنفيذ الجبري، وتمام إعلانه للمنفذ ضده قانوناً، وانقضاء يوم على الأقل من تاريخ الإعلان، ويؤشر على الطلب المستوفى بقبوله وقيده في السجل المعد لذلك، وتحديد ميعاد التنفيذ ومعاون التنفيذ المكلف بإتمامه، مع التنسيق عند الاقتضاء مع مديرية الأمن المختصة في الأحوال التي تستوجب إجراء دراسة أمنية قبل التنفيذ، فإذا تبين لمدير الإدارة، أو من يعاونه، عدم استيفاء الطلب شروط قبوله أعاده إلى الطالب لاستيفائه (مادة ١٣ من القرار).

٢- يجرى التنفيذ بواسطة معاون التنفيذ المكلف بإتمامه تحت إشراف مدير إدارة التنفيذ ويعرض معاون التنفيذ عقب كل إجراء يتخذه الملف على مدير الإدارة أو أي من قضاتها.

وإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ ليأمر بما يراه لازماً. وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك - بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ - أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلي (مادة ١٤ من القرار).

٣- إذا أقيم إشكال أول أو منازعة تنفيذ موضوعية ذات أثر واقف للتنفيذ قانوناً، وجب على معاون التنفيذ عرض الأمر فوراً على مدير الإدارة لإرجاء التنفيذ لحين زوال الأثر الواقف.

وعلى كاتب الجلسة المختص موافاة القسم الكتابي فوراً بما يصدره قاضي التنفيذ والدوائر الاستئنافية من أحكام أو قرارات في منازعات التنفيذ الوقفية والموضوعية، وذلك لإثباتها بملف التنفيذ وعرضه على مدير الإدارة أو من يعاونه من قضاتها لإعمال مقتضى الحكم أو القرار (مادة ١٥ من القرار).

٤- إذا أثيرت إحدى عقبات التنفيذ أو إشكال ثان، تعرض الأوراق فوراً على مدير الإدارة أو من يعاونه من قضاتها للأمر بالإجراء المناسب

ويكون له أن يصدر ما يراه لازماً من قرارات لإزالة العقبات المادية التي تعترض التنفيذ، وله أن يأذن لمعاون التنفيذ بالاستعانة بمن يلزم الاستعانة به من رجال الإدارة وسائر الجهات الحكومية ذات الصلة .

وله عند الاقتضاء أن يستعين بأحد خبراء وزارة العدل المعيّنين بمقر المحكمة الابتدائية بأمانة على عاتق طالب التنفيذ (مادة ١٦ من القرار).

٥- ترسل كل إدارة تنفيذ إلى المكتب الفني لشئون التنفيذ، المشار إليه في الفصل السادس، إحصائيات شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية عن أعمال الإدارة

خلال الفترة السابقة، متضمنة أعداد طلبات التنفيذ وتاريخ ورود كل منها وموضوعه وما تم فيه والمتبقي منها وأسباب بقاءه (مادة ١٧ من القرار).

اختصاص إدارة التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ:

أسند المشرع الاختصاص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، إلى مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها، وذلك بنصه في المادة (٤/٢٧٤) على أنه "ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ". وقد كان الاختصاص بهذه الأوامر منعقدا لقاضي التنفيذ قبل صدور القانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ والمعدل لهذه المادة، والمعدل أيضا للمادة (٢٧٥) بحذف اختصاص قاضي التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر.

وكان يجب على المشرع بإصداره هذه التعديلات أن يحصر الاختصاص بالقرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويجعله في سلطة إدارة التنفيذ وحدها دون قاضي التنفيذ، على النحو الذي هدف إليه القانون من هذه التعديلات، غير أن ذلك لم يكن، فالمشرع نص في المادة الأولى من القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أنه "وتستبدل عبارة (إدارة التنفيذ) بعبارة (قاضي التنفيذ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي المواد ٣٥٦، ٣٥٨، ٣٦٥، ٣٦٧، ٣٧٦، ٣٧٩، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٨، ٤٨٢، ٤٨٣ من ذات القانون" قاصدا من وراء ذلك أن تؤول سلطة إصدار الأوامر التي كانت لقاضي التنفيذ إلى إدارة التنفيذ.

إلا أن التعداد الذي ورد في هذه المادة لم يحصي الأوامر التي كان يختص بها قاضي التنفيذ؛ بل بعضها فقط، مما أبقى الاختصاص ببعض الأوامر التي تنظمها نصوص أخرى، منعقدا لقاضي التنفيذ، على غير مراد المشرع (وسنبين ذلك لاحقا). ونعتقد أنه كان من الأوفق الاكتفاء بعبارتي المادتين (٢٧٤ و ٢٧٥) بعد تعديلها.

والأوامر المشار إليها وفقا لنص المادة الأولى من القانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ والتي أصبح الاختصاص بها منعقدا لإدارة التنفيذ، هي:

- ١- الإذن لمعاون التنفيذ أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه. (مادة ٣٦٥).
- ٢- الأمر بتعيين خبير لتقويم المصوغات أو سبائك الذهب أو الفضة أو المعادن النفيسة أو المجوهرات أو الأحجار الكريمة. (مادة ٣٥٨).
- ٣- الأمر بنقل الأشياء المحجوزة وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة، أو الأمر بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة بحراسة الأشياء المحجوزة مؤقتاً (مادة ٣٦٥).
- ٤- الأمر بتقدير أجر الحارس على المنقولات المحجوزة. (مادة ٣٦٧).
- ٥- الأمر بلبصق عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلان أو بيان الأشياء المطلوب بيعها في الإعلانات تفصيلاً (مادة ٣٧٩).
- ٦- الأمر باتباع الإجراءات المقررة في توزيع حصيلة التنفيذ، في حالة عدم كفاية الحصيلة وعدم الاتفاق على توزيعها. (مادة ٤٧٣).
- ٧- إعداد قائمة التوزيع المؤقتة. (مادة ٤٧٤).
- ٨- الأمر بإثبات ملاحظات، أو اتفاق ذوي الشأن في محضر جلسة التسوية الودية، واتخاذ التدابير التي يقتضيها حسن سير إجراءات توزيع حصيلة التنفيذ. (مادة ٤٧٥ و ٤٧٦).
- ٩- إعداد قائمة التسوية النهائية، وإيداعها، وفقاً للقواعد المقررة. (مادة ٤٧٨ و ٤٨٢).
- ١٠- تسليم أوامر الصرف لمستحقيها وفقاً للمادة ٤٨٣.

التظلم من الأوامر المتعلقة بالتنفيذ:

أنطت المادة (٤/٢٧٤) الاختصاص بنظر التظلم من الأوامر المتعلقة بالتنفيذ لمدير إدارة التنفيذ، ويكون التظلم من الأمر بعريضة تقدم إليه، ويصدر قراره في التظلم، ويكون هذا القرار نهائياً غير قابل للطعن^(١).

(١) ويكون التظلم بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ مبيناً بها صفة المتظلم وأوجه تظلمه، ويرفق بها المستندات المؤيدة لها، ويقيد التظلم بعد سداد الرسم المقرر باعتبار التظلم أمراً على عريضة، ولا يكون للتظلم في ذاته

وفي ضوء ما أشرنا إليه سلفاً؛ فإننا نعتقد أن هناك إشكالية في شأن التظلم من هذه الأوامر، في الحالات التي يختص فيها قاضي التنفيذ بإصدار الأمر، ذلك أن للأوامر على العرائض التي يصدرها القاضي نظاماً إجرائياً للتظلم منها، وفقاً للقواعد العامة المقررة في المواد (١٩٧-١٩٩).

المطلب الثاني

معاونو التنفيذ

استبدال محضري التنفيذ بمعاوني التنفيذ^(١):

نصت المادة (٣/٢٧٤) مرافعات على أنه "ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم". وقد ورد بالملحظة الإيضاحية للقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بهذا الشأن أنه: "وفي صدد استكمال تشكيل الإدارة الحقت بالعمل العدد الكافي من معاوني التنفيذ والموظفين، وخولت المادة لوزير العدل سلطة تحديد قواعد اختيار موظفي الإدارة - سيما معاوني التنفيذ - وتحديد كيفية تنظيم شئونهم حرصاً منها على أن يكون هؤلاء ممن تتوافر فيهم كفاية معينة، وممن يتمتعون بالتأهيل المناسب الذي يعينهم على حسن أداء واجباتهم والاضطلاع بالمهام المنوطة بهم".

ومعاونو التنفيذ طائفة جديدة من أعوان القضاء تختلف عن المحضرين، يعهد إليهم المشرع بممارسة الاختصاصات التي يقوم بها محضري التنفيذ في ظل نظام قاضي التنفيذ، حيث استبدل المشرع معاوني التنفيذ بمحضري التنفيذ وفقاً لنص المادة (٣/٢٧٤) مرافعات المشار إليه بعد تعديله بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بحيث أصبح معاوني التنفيذ هم المختصون بمباشرة إجراءات التنفيذ بدلاً من المحضرين الذين كانوا يهيمنون على هذه الإجراءات. وقد راع المشرع في اختيار معاوني التنفيذ أن يكونوا

أثر واقف للقرار أو الأمر محل التظلم، ما لم يأمر مدير إدارة التنفيذ بذلك. ولمدير إدارة التنفيذ سماع إيضاحات الأطراف، ويفصل في التظلم بقرار مسبب. ويعتبر القرار الصادر من مدير إدارة التنفيذ في التظلم نهائياً. (مادة ٥ من قرار وزير العدل رقم ٧٣٣٦ لسنة ٢٠٠٨).

(١) نصت المادة الأولى من القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على استبدال عبارتا (معاون التنفيذ) و(معاوني التنفيذ) بكلمتي (المحضر) و (المحضرين) أينما وردت أي منهما بهذا الكتاب.

ممن تتوافر فيهم خبرة كافية لمباشرة إجراءات التنفيذ وذلك ضماناً لأداء هذا العمل على الوجه الذي نص عليه القانون.

وقد نص المشرع في المادة (٢٧٩) مرافعات على أن: "يجرى التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلم السند التنفيذي إلى إدارة التنفيذ. فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ.

فإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك - بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ - أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية"^(١).

دور معاوني التنفيذ واختصاصاتهم في إجراءات الحجز والتنفيذ:

قلنا إن المشرع عهد إلى معاوني التنفيذ ممارسة الاختصاصات التي كان يقوم بها محضري التنفيذ في ظل نظام قاضي التنفيذ، حيث استبدل معاوني التنفيذ بمحضري التنفيذ دون تغيير في الاختصاصات أو الواجبات التي كان يضطلع بها المحضرين، ولذلك فإن معاوني التنفيذ يقومون بدور بالغ الأهمية في إجراءات الحجز والتنفيذ، وسنقف على هذا الدور بشكل تفصيلي عند حديثنا عن طرق وإجراءات الحجز والتنفيذ في البابين الثاني والثالث من هذا المؤلف.

ونكتفي هنا بالإشارة إلى بعض من الاختصاصات التي يباشرها معاون التنفيذ في الإجراءات، وذلك على النحو الآتي:

- ١- إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي، وذلك في الأحوال التي لا يجوز الحجز فيها إلا بسند تنفيذي، والتحقق من مضي يوم على الأقل بعد إعلان السند التنفيذي وقبل إجراء التنفيذ (مادة ٢٨١).

(١) هذه المادة مستبدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ وكان نصها قبل التعديل "يجرى التنفيذ بواسطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي. فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضي التنفيذ. فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية".

- ٢- قيام معاون التنفيذ بقبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة، وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص (مادة ٢٨٢).
 - ٣- إجراء التنفيذ بموجب مسودة الحكم في المواد المستعجلة والقيام برد المسودة بمجرد الانتهاء من التنفيذ (مادة ٢٨٦).
 - ٤- مراعاة ما أوجبه القانون في الحجز على الأموال من حيث ما لا يجوز الحجز عليه منها (المادتان ٣٠٥ و ٣٠٦).
 - ٥- اتخاذ ما يلزم لإجراء الحجز من كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة، بشرط حضور مأمور الضبط القضائي وتوقيعه على محضر الحجز (مادة ٣٦٥/١).
 - ٦- تفتيش المدين وتوقيع الحجز على ما في جيبه؛ في الحالات التي تأذن فيها إدارة التنفيذ بذلك (مادة ٢/٣٥٦).
 - ٧- تحرير المحاضر اللازمة لإجراء الحجز ومباشرة إجراءاته ومحضر الجرد للتدخل في الحجز وكذلك محضر البيع وغيرها مما نص عليه القانون، (المواد ٣٥٣ و ٣٧١ و ٣٩١).
 - ٨- إعلان محضر الحجز والأمر الصادر به في الحجز التحفظي (مادة ٣٢٠).
 - ٩- لصق الإعلانات الخاصة ببيع المنقولات المحجوزة على باب المكان الذي توجد به هذه الأشياء وعلى باب العمدة أو شيخ البلد أو المقر الإداري الذي يوجد به المكان وفي اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية (مادة ٣٦٣)، وكذلك لصق الإعلانات اللازمة لبيع العقار (مادة ٤٢٩).
 - ١٠- تعيين الحارس على الأشياء المحجوزة (مادة ٣٦٤)، أو اتخاذ ما يلزم من التدابير للمحافظة على هذه الأشياء في حالة تعذر تعيين الحارس ورفع الأمر فوراً إلى إدارة التنفيذ (مادة ٣٦٥).
 - ١١- دخول العقار محل التنفيذ للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ومشتملاته، بناء على الأمر الصادر بذلك من إدارة التنفيذ (مادة ٣/٤٠١).
- وغير ذلك من الواجبات والاختصاصات التي نص عليها القانون، فضلاً عما تكلفه به إدارة التنفيذ من واجبات لازمة لمباشرة إجراءات الحجز والتنفيذ.

المطلب الثالث

قاضي التنفيذ

أولاً: نظام قاضي التنفيذ قبل إصدار القانون رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٧ وبعد إصداره:

استحدث المشرع نظام قاضي التنفيذ في القانون الحالي رقم (١٣) لسنة ١٩٦٨ قبل تعديله بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، ومنحه اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام، بالإشراف على إجراءات التنفيذ والفصل في المنازعات المتعلقة به، فكان قاضي التنفيذ هو المختص دون غيره بنظر كل ما يتعلق بمسائل التنفيذ، وذلك بهدف إشراف فعال متواصل للقاضي على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته، وعلى القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم، كما يهدف إلى جمع شتات المسائل المتعلقة به في ملف واحد وفي يد قاضي واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الإلتجاء إليه^(١).

غير أن المشرع عدل عن هذا النظام بشكل جزئي؛ فاستحدث إدارة التنفيذ بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، وأناط بها سلطة الإشراف على إجراءات التنفيذ وإصدار الأوامر المتعلقة به، وفي الوقت ذاته أبقى على نظام قاضي التنفيذ؛ إلا أنه حصر اختصاصه الأصيل في الفصل في المنازعات الموضوعية والوقئية المتعلقة بالتنفيذ.

ولم يجعل المشرع قاضي التنفيذ أحد قضاة إدارة التنفيذ التي تتولى الإشراف على الإجراءات؛ وإنما قاض مستقل عنها وغير خاضع لإشرافها؛ فأصبح التنفيذ بذلك خاضعاً من ناحية إجراءاته لإدارة التنفيذ، ومن حيث منازعاته لقاضي التنفيذ، وبقيت الأوامر المتعلقة بالتنفيذ تتردد من حيث الاختصاص بها بين إدارة التنفيذ وقاضي التنفيذ، في توزيع مضطرب وغير دقيق من نظراً (وسنبين ذلك).

ثانياً: من هو قاضي التنفيذ؟

حددت المادة (٢٧٤) قبل تعديلها بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ قاضي التنفيذ بأنه؛ قاض للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية.

(١) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.

وقد خلا قانون المرافعات من نص مماثل بعد تعديل هذه المادة^(١)، حيث استبدل قاضي التنفيذ بإدارة التنفيذ فيما يتعلق بالإشراف على الإجراءات، وأبقى له اختصاص الفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقائية، ويتبين من النص المشار إليه قبل تعديله؛ أن قاضي التنفيذ هو أحد قضاة المحكمة الابتدائية يندب في مقر كل محكمة جزئية، للفصل في منازعات التنفيذ وفقا لنص المادة (٢٧٥)، ومن ثم فهو لا يمثل محكمة خاصة أو استثنائية بل هو جزء لا يتجزء من النظام القضائي المدني، ولا يعتبر دائرة مختصة بالتنفيذ في المحكمة الجزئية؛ وإنما هو محكمة قائمة بذاتها مشكلة منه على سبيل الانفراد، كما هو الشأن في سائر المحاكم الجزئية المشكلة من قاض منفرد، وهو لا يوجد إلا على مستوى محكمة أول درجة فقط أي المحكمة الجزئية، فلا توجد دوائر مخصصة في المحاكم الاستئنافية لنظر الاستئناف المرفوع ضد الأحكام الصادرة منه^(٢).

ومن ثم فإن قاضي التنفيذ يوجد في مقر كل محكمة جزئية حتى في المدن التي توجد بها محكمة ابتدائية، ومقتضى كونه محكمة جزئية قائمة بذاتها أنه إذا رفعت دعوى متعلقة بالتنفيذ أمام المحكمة الجزئية التي بها قاضي التنفيذ؛ أو رفعت دعوى عادية لا تتعلق بالتنفيذ أمام قاضي التنفيذ؛ فإن القرار الصادر في الحالتين يكون حكما بعدم الاختصاص والإحالة، وليست مجرد إحالة إدارية على نحو ما يتم في حالات رفع الدعوى إلى دائرة غير مختصة في ذات المحكمة^(٣).

(١) وأتفق في ذلك مع رأي أستاذي الدكتور / الأنصاري النيداني، في أن المشرع عندما عدل المادة ٢٧٤ مسندا الاختصاص بالإشراف على التنفيذ فيها لإدارة التنفيذ، غفل عما كانت تنص عليه هذه المادة قبل تعديلها من تعريف لقاضي التنفيذ، وبذلك أصبح قانون المرافعات بعد تعديله خاليا من أي مادة أو نص يعرف قاضي التنفيذ ويبين ماهيته، وهو لا شك نقص غير مغتفر وتعديل غير موفق (لأستاذي، قانون التنفيذ الجبري، ص ٢٥-٢٦).

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٥/٧٧٦- د. فتحي والي، الوسيط، ص ٧٨- د. أمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الثالث (التنفيذ)، منشأة المعارف بالإسكندرية، ١٩٨٢، ص ٢٤.

(٣) د. أمينة النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الثالث، ص ٢٥.

ثالثا: الإجراءات المتبعة أمام قاضي التنفيذ:

لما كان قاضي التنفيذ -كما سبقت الإشارة- في مستوى المحكمة الجزئية؛ فهو يعتبر -رغم ندبه من بين قضاة المحكمة الابتدائية- قاضيا جزئيا وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهذا ما قرره المادة (٢٧٤) قبل تعديلها، بنصها على أنه "وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك".

ولا شك أن ما تضمنته هذه المادة في شأن قاضي التنفيذ وما يتبع أمامه من الإجراءات، قبل تعديلها، لا زال قائما؛ ومن ثم فإن صحيفة الدعوى الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ يجب أن تكون موقعة من محام إذا زادت قيمتها عن خمسين جنيها (مادة ٧٨ من قانون المحاماة)، كما أن ميعاد الحضور أمام قاضي التنفيذ يكون ثمانية أيام في الدعاوى الموضوعية والوقفية وأربعين وعشرين ساعة في الدعاوى المستعجلة (مادة ٦٦ مرافعات)، وتتبع أمامه كافة الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ومن الأمثلة المستثناة من اتباع إجراءات المحاكم الجزئية أمام قاضي التنفيذ، حالة الطلبات العارضة والمرتبطة؛ فالقانون يوجب في المادة ٢/٤٦ على المحكمة إحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط إلى المحكمة الابتدائية المختصة إذا كان يترتب على الفصل بين الدعوى الأصلية والطلبات العارضة أو المرتبطة بها ما يضر بحسن سير العدالة، غير أن هذا النص لا يسري أمام قاضي التنفيذ، حتى وإن توفرت مقتضيات الإحالة -الإضرار بحسن سير العدالة- وإنما يحيل الطلب العارض أو المرتبط وحده ويفصل في الدعوى الأصلية؛ ذلك أن الدعوى الأصلية منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري ولا يختص بها إلا قاضي التنفيذ وحده، فيفصل في الدعوى الأصلية باعتباره مختصا بها نوعيا، ويحيل الطلب العارض أو المرتبط إذا لم يكن مختصا به نوعيا^(١).

(١) د. أمينة النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الثالث، ص ٢٥ - ٢٦.

رابعاً: اختصاصات قاضي التنفيذ بعد صدور القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧:

أصدر المشرع القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ المعدل لقانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، واستحدث بمقتضاه نظام إدارة التنفيذ، وأسند إليها الإشراف على إجراءات التنفيذ بنص المادة (٢٧٤) على النحو الذي سبق بيانه، ومع ذلك أبقى على نظام قاضي التنفيذ، ونص في المادة (٢٧٥) على أن "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقئية أياً كانت قيمتها. ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقئية بوصفه قاضياً للأمر المستعجله".

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات عن هذه المادة، أنها قصرت اختصاصات قاضي التنفيذ على إصدار الأحكام دون القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، والتي أضحت من اختصاص مدير إدارة التنفيذ وقضااتها.

أ- الاختصاص الوظيفي لقاضي التنفيذ:

وفقاً لنص المادة (٢٧٥)؛ فإن اختصاص قاضي التنفيذ أصبح قاصراً على الفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقئية، وهذا الاختصاص متعلق بمنازعات تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي (باعتبار قاضي التنفيذ فرعاً من جهة القضاء العادي) وذلك في تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية والتجارية، أياً كان محل التنفيذ. ولكن بالنسبة للمحاكم الجنائية فإن لها اختصاصها المستقل عن المحاكم المدنية؛ ولذلك فإن الأصل أن المحاكم الجنائية تختص بسائر المنازعات التي ترفع من المتهم في الأحكام الصادرة من هذه المحاكم مهما كانت طبيعة الحكم، ولو كان تنفيذه سوف يتم على أموال المحكوم عليه؛ ومن ثم لا يختص قاضي التنفيذ بنظر أي إشكال يقيم من المحكوم عليه بصدد تنفيذ الأحكام الصادرة ضده من القضاء الجنائي، ويراعى نص المادة (٥٢٧) إجراءات جنائية^(١).

(١) د. أحمد ملبجي، الموسوعة الشاملة، ج ٧٨٢/٥. وذكر سيادته الاستثناء من هذا الأصل، وهو ما نصت عليه المادة ٥٢٧ إجراءات جنائية، بنصها على أنه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات. فوفقاً لهذا النص

ولا يحول ذلك دون القول باختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ الذي يجرى على المال أو يكون مآله أن يجرى على المال، حتى ولو كان سند التنفيذ صادرا من جهة أخرى غير جهة القضاء العادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ومؤدى ذلك اختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ على المال، تنفيذا لحكم صادر من القضاء الإداري؛ إلا إذا كان أساس المنازعة مسألة من اختصاص القضاء الإداري وحده، ولا يختص قاضي التنفيذ بطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية لأنها من اختصاص جهة القضاء الإداري بنص القانون^(١).

ب- الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ:

قاضي التنفيذ في القانون المصري هو محكمة قائمة بذاتها في مستوى المحكمة الجزئية، وذلك على الرغم من أنه يندب من بين قضاة المحكمة الابتدائية، ويتم ندبه في مقر كل محكمة جزئية^(٢)؛ إلا أنه يختص بجميع منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها، أي دون التقيد بالنصاب القيمي للمحكمة الجزئية.

ووفقا لما نصت عليه المادة (٢٧٥) فإن قاضي التنفيذ يختص بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقائية؛ وهذا الاختصاص متعلق بالنظام العام، ومن ثم فإن له اختصاص موضوعي، واختصاص وقتي:

١- الاختصاص الموضوعي لقاضي التنفيذ:

يختص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية، بصفته قاضيا للمسائل الموضوعية، وسواء كانت هذه المنازعات مرفوعة الدائن أو المدين أو الغير، وذلك إذا كانت هذه المنازعات متعلقة بالحجز على منقولات المدين أو عقاراته، أو كانت متعلقة بما له لدى الغير.

ينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ بنظر منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية، متى توفرت الشروط التي وردت في النص.

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٥/٧٨١.

(٢) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني، التنفيذ الجبري، ص ٩.

ومن أمثلة هذه الدعاوى: دعوى رفع الحجز، ودعوى استرداد المنقولات المحجوزة، ودعوى الاستحقاق الفرعية، والفصل في الاعتراضات على قائمة شروط البيع، وغير ذلك. فمثل هذه الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ، يختص بها قاضي التنفيذ بصفته، قاضيا موضوعيا.

٢- الاختصاص المستعجل:

يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية (إشكالات التنفيذ) بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، ويخضع في مباشرته لهذه الوظيفة القضائية للقواعد المتعلقة بالفصل في الدعاوى المستعجلة.

خامسا: استثناءات ترد على اختصاص قاضي التنفيذ^(١):

وهذا الاختصاص لقاضي التنفيذ هو الأصل بالنسبة للمنازعات الموضوعية والوقتية، غير أن هناك بعض الاستثناءات على هذا الأصل في مسائل متعلقة بالتنفيذ وينعقد الاختصاص بنظرها لقاض آخر غير قاضي التنفيذ، ومثالها:

١- نص المادة ٢١٠ مرافعات، والتي أوجبت على الدائن بدين تتوفر فيه شروط استصدار أمر الأداء؛ إذا أراد حجز ما يكون لمدينه لدى الغير، في الأحوال التي يجوز فيها استصدار أمر بالحجز التحفظي، أن يستصدر هذا الأمر من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء.

٢- نص المادة ٣/٣٢٠ والتي أوجبت في الحالات التي يجرى فيها الحجز التحفظي بأمر من القاضي؛ رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز أمام المحكمة المختصة.

٣- نص المادة ٣٢١ والتي أوجبت رفع دعوى صحة الحجز إلى المحكمة التي سبق رفع الدعوى بالحق أمامها.

٤- نص المادة ٣٣٣ مرافعات، والتي أوجبت رفع دعوى صحة الحجز في حجز ما للمدين لدى الغير، أمام المحكمة المختصة.

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٥/ ٧٩٦.

٥- نص المادة ٣٤٩ مرافعات، والتي أوجبت رفع دعوى صحة الحجز في الحجز تحت يد النفس، أمام المحكمة المختصة.

والحق أن دعوى صحة الحجز لا تتعلق بالتنفيذ؛ وإنما تتعلق بمرحلة سابقة عليه، وهي مرحلة تكوين السند التنفيذي، ويبرر ذلك أنها لا ترفع إلا في الحالات التي يكون الحجز فيها موقعا بمقتضى إذن من قاضي الأمور الوقفية، أو المحكمة التي تنظر دعوى الحق، فكان منطقياً أن تخرج عن الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ^(١).

هذا وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التنفيذ يختص بمنازعات التنفيذ المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية، ومن ثم يخرج عن اختصاصه المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، وذلك لاختصاص محكمة الأسرة بهذه المسائل (مادة ١٥ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة).

كما لا يختص قاضي التنفيذ بالمسائل التي تتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية، حيث تختص جهة الإدارة بتنفيذها وفقاً للمادة (٥٤) من قانون مجلس الدولة، واستثناء من ذلك يكون لجهة الإدارة أن تختار اللجوء إلى قاضي التنفيذ فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها ضد أحد الأفراد والتي يجرى تنفيذها على الأموال كأحكام التعويض أو الرد، أو أن تلجأ إلى طريق الحجز الإداري.

كما لا يختص قاضي التنفيذ بالمسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجنائية، حيث يرفع الإشكال المقدم من المحكوم عليه بشأن تنفيذ حكم الجنايات إلى محكمة الجنايات إذا كان صادراً منها، وإلى محكمة الجنايات المستأنفة فيما عدا ذلك (مادة ٥٢٤ إجراءات جنائية). غير أن المادة (٥٢٧) إجراءات جنائية أوردت استثناء على هذا الأصل، مقتضاه أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات.

(١) د. رمضان إبراهيم علام: الوجيز في قواعد التنفيذ الجبري، مكتبة الدراسات العربية، سلطنة عمان،

وتجدر الإشارة أيضا إلى عدم اختصاص قاضي التنفيذ بالمسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، حيث نص المشرع في المادة (٧) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، والمعدلة بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩، على اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالفصل دون غيرها في منازعات التنفيذ الوقفية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التي تصدرها المحكمة، ويتم الطعن في أحكامها الصادرة في هذا الشأن أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية^(١).

سادسا: مدى اختصاص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ:

أشرنا إلى أن المشرع وبمقتضى القانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ سلب الاختصاص بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، من قاضي التنفيذ، وأناط بإدارة التنفيذ سلطة إصدار هذه الأوامر، وقلنا إن عبارة المشرع في هذا الشأن لم تحسم الاختصاص بهذه الأوامر بشكل كامل لإدارة التنفيذ؛ فالمشرع حين نص في المادة الأولى من القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أن "وتستبدل عبارة (إدارة التنفيذ) بعبارة (قاضي التنفيذ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي المواد ٣٥٦، ٣٥٨، ٣٦٥، ٣٦٧، ٣٧٦، ٣٧٩، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٨، ٤٨٢، ٤٨٣ من ذات القانون"، لم يحص به المواد التي كانت تمنح قاضي التنفيذ اختصاصا بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، بل بقي الكثير من المواد التي أبقى فيها المشرع لقاضي التنفيذ اختصاصا بالإشراف على التنفيذ وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة به، وهو ما يثير مشكلة تنازع الاختصاص بين قاضي التنفيذ وإدارة التنفيذ^(٢). ومن ذلك على سبيل المثال:

اختصاص قاضي التنفيذ بالإذن بتكليف الحارس بالإدارة أو الاستغلال أو باستبدال

(١) د. عبدالله عبدالحى الصاوي: التنظيم الإجرائي للنقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة القطرية مقارنة بالمحاكم الاقتصادية المصرية، بحث منشور بالمجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل - قطر، العدد ٣٢ لسنة ٢٠٢٢، ص ١٠٨.

(٢) أستاذي د. الأنصاري النيداني، قانون التنفيذ الجبري، ص ٢٢.

حارس بحارس آخر (مادة ٣٦٨)، والإذن بالجني أو الحصاد (مادة ٣٧٠)، والأمر بإجراء البيع في غير السوق وغير مكان وجود المنقولات المحجوزة (مادة ٣٧٧)، والإذن بالحجز وتقدير الدين في الحجز التحفظي (مادة ٣١٩)، وفي حجز ما للمدين لدى الغير (مادة ٣٢٧)، والإذن بالحلول محل الدائن الذي يباشر الإجراءات (مادة ٤٠٢)، والأمر بالتأشير بهذا الحلول (مادة ٤٠٣). وغيرها من المواد التي لم يتم تعديلها، وظل الاختصاص بالأوامر منعقدا فيها لقاضي التنفيذ، خلافا للمادتين (٢٧٤-٢٧٥) مرافعات.

سابعا: الاختصاص المحلي بمنازعات التنفيذ:

حددت المادة (٢٧٦) الاختصاص المحلي بنظر المنازعات المتعلقة بالتنفيذ، على النحو الآتي:

- ١- إذا كان الحجز يتم على المنقول الموجود لدى المدين؛ فإن الاختصاص ينعقد لقاضي التنفيذ الذي يقع المنقول في دائرته.
- ٢- إذا كان الحجز على المنقول لدى المدين؛ فإن الاختصاص ينعقد لقاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته موطن المحجوز لديه.
- ٣- إذا كان التنفيذ يتم على العقار؛ فإن الاختصاص ينعقد لقاضي التنفيذ الذي يقع العقار في دائرته.
- ٤- إذا تعددت العقارات التي يتم التنفيذ عليها؛ وكانت تقع في دوائر محاكم؛ فإن الاختصاص ينعقد لإحداها.

والحقيقة أنه رغم تحديده اختصاص المحلي بهذا الشكل؛ إلا أنه يثير إشكالية مهمة فيما يتعلق بحالة تعدد مكان المنقولات المراد الحجز عليها لدى المدين بأن كانت تقع في دوائر متعددة، وكذلك حالة تعدد المحجوز لديهم؛ إذ لم يتعرض المشرع لهاتين الحالتين ولم يقرر قاعدة بشأنهما كما هو الحال في تعدد العقارات.

ومن ثم يكون الاختصاص بالنسبة لكل منقول يراد الحجز عليه أو محجوز لديه لقاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته المنقول أو المحجوز لديه، دون اعتداد بمكان

المنقولات الأخرى أو المحجوز لديهم الآخرين، وهو ما يعني تعدد الحجز وتعدد قضاة التنفيذ المختصون بالمنازعات التي تنشأ عن تنفيذ جبري يتم لصالح حاجز واحد بمقتضى سند تنفيذي واحد. وهو أمر لا يستقيم في نظرنا ونتفق مع بعض الفقه في أهمية تدخل المشرع بمعالجة هذه الحالة؛ إما بتقرير ذات القاعدة المقررة في العقارات، أو عقد الاختصاص لمحكمة موطن المحجوز عليه أيا كان موقع المنقول أو تعدده أو تعدد الغير الذي يوجد المنقول في حيازته^(١).

ثامنا: مدى تعلق اختصاصات قاضي التنفيذ بالنظام العام:

يتعلق الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ بالنظام العام، ومن ثم لا تجوز مخالفته، وعلى المحكمة أن تطبق قواعد هذا الاختصاص من تلقاء نفسها دون انتظار دفع من الخصوم. ونتفق مع رأي بعض الفقه^(٢) فيما يتعلق بالاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ، حيث يذهب هذا البعض إلى القول بأن الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ يكون متعلقا بالنظام العام إذا كان تحديده يتم وفقا لأحكام المادة (٢٧٦) مرافعات، ولا يتعلق هذا الاختصاص بالنظام العام إذا كان تحديده يتم وفقا للقواعد العامة في الاختصاص المحلي، أو وفقا لنص آخر كما في دعوى رفع الحجز (مادة ٣٣٥).

تاسعا: الطعن في الأحكام التي يصدرها قاضي التنفيذ:

وفقا لتعديل المادة (٢٧٧) بمقتضى القانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧؛ فإن جميع الأحكام التي يصدرها قاضي التنفيذ سواء أكانت موضوعية أم وقتية، وأيا كانت قيمة الدعاوى التي صدرت فيها الأحكام؛ فإن الطعن فيها يكون بالاستئناف، وتختص بنظر هذا الاستئناف المحكمة الابتدائية التي يتبعها قاضي التنفيذ.

وينتقد البعض هذا التعديل، لأن الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية والتي تستأنف أمام المحكمة الابتدائية، لن تصل إلى محكمة النقض، ومن

(١) د. أمينة النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الثالث، ص ٢٧-٢٨.

(٢) د. عيد القصاص، التنفيذ الجبري، ج ١/٤٧٨.

ثم لن تتمكن من إعمال رقابتها عليها وتوحيد المبادئ القانونية المتعلقة بالتنفيذ، كما أنه أحيانا قد تتعلق المنازعة الموضوعية بالحق الموضوعي، وليس من المنطقي أن تفصل المحكمة الابتدائية في مثل هذه المنازعة نهائيا مهما كانت قيمتها^(١).

المطلب الرابع

السلطة المختصة بالتنفيذ في الفقه الإسلامي

القاعدة العامة في الفقه الإسلامي أن الاختصاص بتنفيذ الأحكام القضائية ينعقد للقضاة، يستوي في ذلك أن يقوم القاضي بتنفيذ الحكم الذي أصدره، أو يقوم بتنفيذ حكم أصدره قاض آخر غيره^(٢)، وهذه القاعدة يرد عليها استثناء بشأن الأحكام القضائية التي يعجز القاضي عن تنفيذها، فإن الاختصاص بتنفيذها ينعقد لوالي المظالم^(٣).

فالسلطة القضائية في الشريعة الإسلامية هي ذاتها السلطة المختصة بتنفيذ الأحكام، وقد روي عن النبي ﷺ وهو خير من قضى بين الناس، أنه نفذ الكثير من الأحكام التي قضى بها، وهناك من الأحكام ما كان النبي ﷺ ينتدب لها أصحابه رضي الله عنهم للقيام بتنفيذها^(٤).

ويشترط لاختصاص القاضي بتنفيذ الحكم القضائي^(٥): أن يكون قويا قادرا على

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٨٤٩/٥.

(٢) تبصرة الحكام لابن فرحون، ج ١١٦/١ - ١١٧.

(٣) الأحكام السلطانية للماوردي، ص ٨٣.

ويختص والي المظالم بتنفيذ ما وقف من أحكام القضاة لضعفهم عن تنفيذها وعجزهم عن المحكوم عليه لقوة يده (المرجع السابق، ص ٨٣) ويشترط فيمن يتولى هذا المنصب أن يكون جليل القدر نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر العفة، قليل الطمع، كثير الورع، لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة، وثبتت القضاة، فاحتاج إلى الجمع بين صفتي الفريقين، وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين (د. محمود الأمير يوسف الصادق: تنفيذ الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٨م، ص ٢٥٤ - ٢٥٥).

(٤) د. أحمد علي يوسف جرادات: نظرية تنفيذ الأحكام القضائية المدنية في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦م، ص ١٠٠.

(٥) تبصرة الحكام لابن فرحون، ج ١٧/١، معين الحكام للطرابلسي، ص ١١، الإحكام للقرافي، ص ٥٦.

التنفيذ بانتزاع الحق لأصحابه من ذوي النفوذ والسلطان الظالمين، لأن القاضي الضعيف عاجز عن التنفيذ لا يكلف به، وإنما يكلف فقط بإصدار الحكم ولا يكلف بتنفيذه، لأن التنفيذ متعذر عليه، قال القرافي "وليس للقاضي السياسة العامة لا سيما الحاكم الذي لا قدرة له على التنفيذ كالحاكم الضعيف القدرة على الملوك الجبابة، فهو ينشئ الإلزام على الملك العظيم، ولا يخطر له تنفيذه لتعذر ذلك عليه"^(١). وشرط القدرة على التنفيذ لازم وضروري حتى يستطيع القاضي تنفيذ أحكامه على الممتنعين عن التنفيذ الاختياري ممن يميلون إلى التسويق والمماطلة، لذلك كان من الضروري توافر هذا الشرط في القاضي؛ لأن القاضي الذي لا تجد أحكامه تنفيذا لا احترام له ولا منزلة له^(٢).

قاضي التنفيذ في الفقه الإسلامي:

يتضح مما سبق أن القاعدة العامة في الفقه الإسلامي أن الاختصاص بالتنفيذ ينعقد للقضاة، واستثناء لوالي المظالم؛ إلا أن ذلك لا ينفي جواز تعيين قضاة خاصين بالتنفيذ فقط، بحيث تكون مهمتهم الأساسية تنفيذ الأحكام القضائية، ذلك أن الفقهاء متفقون على جواز تخصيص القضاء، كما في الاختصاص المكاني، والزماني، والنوعي، والقيمي^(٣).

وعلى ذلك فإن القانون يتفق مع الفقه الإسلامي في أن القضاء هو المختص بتنفيذ الأحكام القضائية، وأنه ليس لصاحب الحق اقتضاء حقه جبرا من المحكوم عليه، وإن كان قانون المرافعات أفرد للتنفيذ إدارة متخصصة هي إدارة التنفيذ، وأسند إليها الاختصاص بإجراءات التنفيذ، كما نص على بعض الاختصاصات لقاضي التنفيذ، فإن الفقه الإسلامي، يجيز هذا الأمر بتعيين قضاة يختصون فقط بتنفيذ الأحكام القضائية دون غيرهم.

(١) الإحكام للقرافي، ص ٥٦ .

(٢) د. محمود الأمير يوسف الصادق، مرجع سابق، ص ٢٥٣.

(٣) المرجع السابق، ص ٢٦٢ - ٢٦٣.

الفصل الثاني

السندات التنفيذية

الفصل الثاني

السندات التنفيذية

فكرة السند التنفيذي وأهميته:

يشترط لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري أن يكون بيد الدائن سندا تنفيذيا قبل البدء في هذه الإجراءات، ذلك أنه لا يجوز أن يباشر الدائن التنفيذ الجبري سواء بطريق التنفيذ المباشر أو التنفيذ بطريق الحجز ونزع الملكية؛ إلا إذا كان بيده السند التنفيذي الذي يخول له الحق في اتخاذ إجراءات هذا التنفيذ واقتضاء حقه جبرا عن المدين؛ إذ السند التنفيذي هو السبب المنشئ للحق في التنفيذ^(١). وقد نصت المادة (٢٨٠) مرافعات على أنه "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء".

والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحركات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند عليها صيغة التنفيذ التالية:

على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجراءاته ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك". ويعرف السند التنفيذي بأنه "عمل قانوني يتخذ شكلا معينا ويتضمن تأكيدا لحق الدائن الذي يريد الاقتضاء الجبري، أو الورقة التي أعطاها القانون صفات محددة وشروط خاصة تجعلها صالحة لأن تكون هي الأساس الذي عليه يمكن البدء في التنفيذ الجبري".

والتعداد الذي أورته الفقرة الثانية من المادة (٢٨٠) مرافعات للسندات التنفيذية، ورد على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز التنفيذ بغير هذه السندات ولا يجوز الإضافة إليها ولو كان بيد الدائن مستند مؤكد لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء؛

(١) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني: التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية، دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٩، ص ٢٥، وقانون التنفيذ الجبري، ص ١٣٢.

إلا أنه يجب القول بأن المشرع قد ذكر في هذه المادة "الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة" ووفقا لذلك فإن أية ورقة أخرى يصفى عليها المشرع القوة التنفيذية تعتبر سنداً تنفيذياً، سواء أكان ذلك في قانون المرافعات أو غيره من القوانين^(١).

قواعد أساسية في السند التنفيذي:

"ثمة قواعد أساسية تتعلق بالسند التنفيذي وتوضح ملامحه، هذه القواعد هي:

- ١- أنه لا يجوز التنفيذ بغير سند تنفيذي، فهو ضروري للتنفيذ لأنه الوسيلة الوحيدة التي اعتبرها القانون مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ، ونتيجة لذلك لا يقبل من الدائن تقديم أي دليل غيره لسلطة التنفيذ لكي يقنع هذه السلطة بالقيام بالتنفيذ وحتى ولو كان للدائن حق موضوعي ولكنه غير ثابت في سند تنفيذي مستوف للشكل الذي يزوده بالقوة التنفيذية، فإنه لن يستطيع تنفيذ هذا الحق جبراً.
- ٢- أن السندات التنفيذية قد وردت في القانون على سبيل الحصر فهي محددة بمقتضى القانون ومعني ذلك أنه لا يجوز الإضافة إلى السندات التنفيذية المنصوص عليها في صلب التشريع، ويبطل الاتفاق الذي قد يبرمه ذوو الشأن بإضفاء الصفة التنفيذية على محرر لم يعتبره المشرع سنداً تنفيذياً.
- ٣- أن السند التنفيذي كاف لإجراء التنفيذ، ومعني ذلك أن السند التنفيذي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية يكفي لبدء إجراءات التنفيذ وللاستمرار فيه حتى النهاية ما لم تنثر منازعة في التنفيذ".

وقوة السند التنفيذية نظام لمسئولية إجرائية تقع بقوة القانون دون حاجة إلى حكم أو أمر قضائي، إذا لم يقر الملزم في هذا السند بتنفيذه اختياراً ثم طلب صاحبه الإجراء في تنفيذه، وبالتالي فإن واقعة الامتناع هذه وطلب الإجراء في التنفيذ، هما مفترضان نشاط القوة التنفيذية باعتبارها نظاماً للمسئولية عن عدم التنفيذ الاختياري للسند التنفيذي، وهما مقدمة التنفيذ الجبري أو مقدمات التنفيذ، على نحو ما يجري به الإصطلاح في اللغة القانونية^(٢).

(١) د. أحمد ملبجي، الموسوعة الشاملة، ج٩١٣/٥.

(٢) د. أحمد حشيش: نظرية القوة التنفيذية لسند التنفيذ، دار الفكر الجامعي، ٢٠٠٢م، ص٣٦٩.

المبحث الأول

الأحكام

"الحكم هو أهم السندات التنفيذية على وجه الإطلاق وهو يصلح لمباشرة كافة أنواع التنفيذ سواء بطريق الحجز ونزع الملكية أو بالطريق المباشر وذلك حسب طبيعة الحق الموضوعي الواجب اقتضاؤه فإذا كان محل الإلتزام الوارد في الحكم مبلغا من النقود فإن هذا الحكم ينفذ بطريق الحجز ونزع الملكية، أما إذا لم يكن محل الإلتزام الوارد في الحكم مبلغا من النقود كما لو صدر الحكم بإلزام المدين بالقيام بعمل معين أو بتسليم شيء معين فإن تنفيذ هذا الحكم يكون بطريق التنفيذ المباشر"^(١).

ولا تعتبر جميع الأحكام من قبيل السندات التنفيذية وإنما الذي يصدق عليه هذا الوصف منها نوع معين من الأحكام، هي الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري، وهي أحكام الإلزام التي تلزم المدين بأداء معين كأن تلزمه بتسليم منقول إلى الدائن أو بأن يؤدي له مبلغا من النقود.

أما الأحكام المقررة والمنشئة؛ فإنها لا تكون قابلة للتنفيذ الجبري ولا تعتبر سندات تنفيذية، ذلك أن حكم الإلزام هو الذي يقرر أو يؤكد حقا لأحد الخصوم ويلزم الخصم الآخر بأدائه، وهذا الحكم وحده هو الذي يقبل مضمونه التنفيذ الجبري.

ومن ثم "فلا يقبل التنفيذ الجبري إلا الأحكام الصادرة بإلزام محدد، والمناطق في تعريف ما للحكم من قوة إلزام هو بفهم مقتضاه وتقصي مراميه على أساس ما يبينه المنطوق وما جاء بالأسباب من الرجوع إلى ما تنازع حوله الطرفان"^(٢).

والقاعدة أن حكم الإلزام لا يكون قابلا للتنفيذ الجبري إلا إذا كان نهائيا بمعنى أن يكون الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي، والأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي هي تلك التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف.

وقد نصت على هذه القاعدة المادة (١/٢٨٧) مرافعات بنصها على أنه: "لا يجوز تنفيذ الاحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزا..."

(١) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني، التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية، مرجع سابق، ص ٢٦.

(٢) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٢٤.

وإذا كانت هذه هي القاعدة في التنفيذ الجبري للأحكام؛ فإنها يرد عليها استثناء؛ مقتضاه: جواز تنفيذ الحكم ولو لم يكن نهائيا إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل؛ وذلك تطبيقا لنص المادة (١/٢٨٧) مرافعات والتي أوردت هذا الاستثناء بنصها على أنه "لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم".

وللحديث عن الأحكام كسندات تنفيذية؛ فإننا نتناولها في خمسة مطالب:

المطلب الأول

صورة الحكم القضائي القابلة للتنفيذ الجبري

يتم تنفيذ الحكم القضائي بموجب الصورة التنفيذية، وهي تختلف عن مسودة الحكم، وعن نسخته الأصلية، وعن الصورة البسيطة للحكم. والصورة التنفيذية للحكم هي الصورة الرسمية مذيلا بالصيغة التنفيذية، وبمقتضاها يتم تنفيذ الحكم جبرا؛ إذ الحكم كسند تنفيذي يشترط لإمكان التنفيذ به أن يكون مشتملا على الصيغة التنفيذية؛ إذ لا يجوز التنفيذ كقاعدة؛ إلا بمقتضى صورة تنفيذية من السند التنفيذي (مع مراعاة الاستثناء من هذه القاعدة)، والصورة التنفيذية صورة من نسخة الحكم الأصلية تختتم بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية.

وتكمن أهمية الصورة التنفيذية والحكمة منها، في تسهيل مهمة معاون التنفيذ في التحقق من حق الطالب في التنفيذ، فلا يختلط الأمر عليه ولا على ذوي الشأن فيما يتعلق بحق حائزها في التنفيذ، بحيث يبادر إلى التنفيذ بمجرد وجود الصيغة التنفيذية على صورة الحكم، وبحيث تبادر السلطات المختصة أيضا بالمعاونة على التنفيذ باستعمال القوة الجبرية^(١).

تسليم صورة الحكم التنفيذية:

نصت المادة (١٨١) مرافعات على أنه "تختتم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة، ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التنفيذ، ص ٢٢١.

للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه".

ويتضح من نص هذه المادة أن صورة الحكم التنفيذية لا تسلم إلى وفقا للشروط الآتية:

- ١- أن تسلم الصورة التنفيذية لأحد الخصوم الماثلين في الدعوى؛ إذ لا يجوز تسليمها لأي شخص يطلبها.
- ٢- أن تسلم للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، وإذا تعدد المحكوم لهم الذين تعود عليهم منفعة من تنفيذ الحكم؛ فإنه يجوز تنفيذ صورة تنفيذية لكل منهم.
- ٣- عدم جواز تسليم أكثر من صورة تنفيذية واحدة؛ فلا يجوز تسليم الخصم أكثر من صورة تنفيذية واحدة، منعا من التلاعب بالتنفيذ.
- ٤- أن يكون الحكم من الأحكام التي يجوز تنفيذها جبرا^(١).

الصيغة التنفيذية التي تذيّل بها صورة الحكم:

قلنا إن الصورة التنفيذية للحكم، هي صورة من نسخة الحكم الأصلية تختتم بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية، ونص الصيغة التنفيذية وفقا للفقرة الأخيرة من المادة (٢٨٠) مرافعات هو "على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك". وهذه الصيغة تتضمن أمرا إلى معاوني التنفيذ بإجراء التنفيذ، وأمرا إلى رجال السلطة العامة بمعاونتهم، وهي عنصر من العناصر المكونة للصيغة التنفيذية، ويؤدي تخلفها إلى بطلان السند التنفيذي بطلانا متعلقا بالنظام العام^(٢).

(١) وقد قضت محكمة النقض بأن مفاد نهي القانون عن تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عودة منفعة عليه من تنفيذه ونهي عن تسليمها إليه إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه، فإن وضع صيغة التنفيذ على الحكم المراد تنفيذه الذي بيد الخصم يكون شاهدا على أنه هو صاحب الحق في إجراء التنفيذ، وأنه لم يسبق له إجراؤه، وأن هذا الحكم جائز تنفيذه جبرا. (الطعن رقم ١٢٧٨ لسنة ٦٧ قضائية جلسة ١١/٧/١٩٩٨).

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٥/٩٤٠.

امتناع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى:

نصت المادة (١٨٢) مرافعات على أنه "إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالباها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقفية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للإجراءات المقررة في باب الأوامر على عرائض".

ومن ثم فإن على قلم الكتاب متى توفرت شروط إعطاء الصورة التنفيذية، أن يعطيها للخصم صاحب المصلحة الذي توفرت في جانبه هذه الشروط، فإن امتنع قلم الكتاب عن ذلك لأي سبب من الأسباب؛ فإن للخصم أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقفية بالمحكمة التي أصدرت الحكم، والذي يكون له أن يأمر على ذات العريضة بتسليم الصورة التنفيذية للخصم، متى توفرت الشروط اللازمة لذلك.

عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم:

القاعدة وفقا لما قرره المادة (١٨٣) مرافعات أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم، وذلك لتفادي تكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد^(١)، واستثناء من هذه القاعدة نصت المادة المشار إليها على جواز إعطاء صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم؛ إذا ضاعت الصورة الأولى. فإذا ضاعت الصورة التنفيذية الأولى أو هلكت؛ فإن للخصم أن يحصل على صورة ثانية، ولكن وفقا للإجراءات التي قررتها المادة، وهي: رفع دعوى بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.

وتبحث المحكمة في هذه الحالة مسألة ضياع أو هلاك^(٢) الصورة التنفيذية الأولى دون التعرض لموضوع الحكم ذاته، وعلى الخصم إعلان خصمه الآخر بصحيفة

(١) د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٤٨.

(٢) وتجب الإشارة هنا إلى أن الحكم بإعطاء الخصم صورة تنفيذية ثانية، مشروط بضياع أو هلاك الصورة الأولى، بمعنى أن تكون قد فقدت فعلا، أما إذا كانت موجودة في مكان يصعب الحصول عليها منه؛ فإن ذلك لا يعد فقدا أو هلاكا لها، ولا يجيز المطالبة بصورة ثانية. ويجب على المحكمة أن تتحقق من فقد الصورة التنفيذية الأولى بأن يثبت المدعي ذلك بكافة طرق الإثبات، وليس عليه أن يثبت أن الفقد أو الهلاك كان لسبب أجنبي لا يد له فيه، ولكن لا يجوز للمحكمة أن تكتفي بادعاء الخصم دون دليل، اكتفاء بعدم قيام دليل ينقض هذا الادعاء (نقض ١٩٦٩/٥/١٥ لسنة ٢٠ قضائية).

دعوى طلب صورة تنفيذية ثانية، ليصدر الحكم في مواجهته، أو يقدم ما لديه للمحكمة فيما يدعيه خصمه من ضياع الصورة الأولى أو هلاكها.

الاستثناء من قاعدة التنفيذ بمقتضى صورة تنفيذية:

قلنا إن القاعدة العامة تقضي بعدم جواز التنفيذ إلا بمقتضى صورة تنفيذية للحكم، وقد أورد المشرع استثناء من هذا القاعدة في المادة (٢٨٦) مرافعات بنصها على أنه "يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمعاون التنفيذ وعلى معاون التنفيذ أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ".

ووفقا لهذا النص؛ فإنه يجوز تنفيذ الحكم المستعجل بموجب مسودته، وكذلك الحكم الموضوعي في الأحوال التي يكون التأخير فيها ضارا، ودون حاجة إلى صورة تنفيذية، بناء على أمر المحكمة بذلك، ووفقا لسلطتها التقديرية فيما تراه من سرعة تنفيذ الحكم، وبناء على طلب الخصم؛ إذ ليس للمحكمة أن تأمر بذلك من تلقاء نفسها.

وإذا أمرت المحكمة بذلك؛ فإن على الكاتب أن يقوم بتسليم مسودة الحكم مباشرة إلى معاون التنفيذ، لا إلى المحكوم له، وعلى معاون التنفيذ أن يقوم بالتنفيذ بمقتضى المسودة في هذه الحالات ودون حاجة إلى تزويل المسودة بالصيغة التنفيذية، ثم يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.

المطلب الثاني

النفاذ العادي للأحكام

الفرع الأول

القاعدة العامة في التنفيذ الجبري للأحكام

تقضي القاعدة العامة في تنفيذ الأحكام أنه: "لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم" (المادة ١/٢٨٧ مرافعات).

ووفقا لهذه القاعدة؛ فإن الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري تنفيذا عاديا، هي الأحكام الانتهائية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف، حيث تنقسم الأحكام من حيث قابليتها للطعن فيها من عدمه، إلى أحكام ابتدائية، وأحكام نهائية، وأحكام باتة.

وقد أراد المشرع الإجرائي تحقيق نوع من التوازن بين مصلحة المحكوم له، ومصلحة المحكوم عليه، فرأى أن مصلحة المحكوم له؛ تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، حتى وإن كان قابلا للطعن فيه، ومصلحة المحكوم عليه عدم تنفيذ الحكم إلا إذا أصبح مستقرا لا يحتمل الإلغاء؛ وذلك حتى لا يتعرض لمخاطر تنفيذ حكم قابل للإلغاء؛ فنص على آلية إجرائية يتم بها تحقيق التوازن بين المصلحتين المتعارضتين، وهي عدم جواز التنفيذ الجبري للأحكام، ما دامت قابلة للطعن بالاستئناف؛ ومن ثم لا يقبل التنفيذ الجبري إلا الحكم النهائي الذي لا يقبل الطعن بالاستئناف، وهي الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي (كقاعدة عامة)^(١).

وعلة هذه القاعدة هي أن الحكم النهائي الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية، يتضمن تأكيدا للحق الثابت به بدرجة يرجح معها احتمال تأييده، إذا ما تم الطعن فيه بطريق طعن غير عادي، كما أن الطعن بالطرق غير العادية لا يجوز إلا في أحوال معينة ولأسباب محددة نص عليها المشرع، وذلك بعكس الحال بالنسبة لطرق الطعن العادية التي يجوز اللجوء إليها دون التقيد بأسباب معينة^(٢).

ووفقا لهذه القاعدة؛ يمكننا القول بأن الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري هي^(٣):

١ - الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى:

وهي الأحكام التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى في حدود النصاب الانتهائي لها، والأحكام التي تصدرها هذه المحاكم في الدعاوى المتفق مسبقا بين الخصوم على

(١) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ج ١/١٠٨.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٥/١٠٢٢.

(٣) د. أحمد عوض هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٢٦، د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري،

استئناف الحكم الصادر فيها، وكذلك الأحكام التي تكون انتهائية بحكم القانون^(١).

٢- أحكام الدرجة الأولى التي انقضى ميعاد الطعن فيها:

فإذا صدر حكم محكمة الدرجة الأولى قابلاً للطعن فيه، وفوت الخصوم ميعاد الاستئناف دون الطعن في الحكم؛ فإن الحكم يصبح انتهائياً قابلاً للتنفيذ، والأمر كذلك بالنسبة للأحكام التي يتم الطعن فيها بالاستئناف، وتنقضي خصومة الاستئناف دون الحكم، إما لسقوط الخصومة، أو تركها، أو عدم تجيلها في الميعاد المقرر بعد الوقف.

٣- الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف):

والمقصود بها الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية، والأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالي، فهذه الأحكام تصدر انتهائية قابلة للتنفيذ الجبري، حتى وإن كانت قابلة للطعن بطريق غير عادي.

٤- الأحكام الصادرة في الطعون غير العادية:

وهي الأحكام الصادرة من محكمة النقض، والأحكام الصادرة في التماس إعادة النظر، وذلك لكونها أحكاماً باتة غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.

الفرع الثاني

الاستثناء من قاعدة جواز تنفيذ الحكم

أشرنا إلى أن القاعدة العامة في التنفيذ الجبري، جواز تنفيذ الحكم الإنتهائي الحائز لقوة الأمر المقضي، رغم قابليته للطعن فيه بالنقض أو التماس إعادة النظر أو كان قد تم الطعن فيه بالفعل؛ لأن حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي؛ قرينة على صحته وصحة ما قضى به، وعلى الرغم من ذلك؛ فإن هذا الحكم يبقى مهدداً وقابلاً للإلغاء من محكمة

(١) كالحكم في المنازعة في اقتدار الكفيل أو الحارس أو كفاية ما يودع من كفالة بشأن النفاذ المعجل، والحكم الصادر في دعوى قصر الحجز، والحكم الصادر في دعوى التطليق للخلع.

وتجب الإشارة إلى أن الحكم الإنتهائي الصادر من محكمة الدرجة الأولى يكون قابلاً للتنفيذ، ولو كان قابلاً للطعن فيه بالاستئناف لتعارضه مع حكم آخر سابق عليه ولم يحز قوة الأمر المقضي، أو لبطلانه، أو لوجود بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، أو لمخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام (المادتان ٢٢١ و٢٢٢ مرفعات).

الطعن؛ فإذا ألغي هذا الحكم بعد تنفيذه أو البدء في التنفيذ؛ فإن ذلك يقتضي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وهو أمر لا يكون متاحا في جميع الأحوال، بل قد يكون صعبا أو متعذرا أو حتى مستحيلا، فضلا عما يصيب المنفذ ضده من أضرار نتيجة تنفيذ الحكم الذي ألغي في الطعن.

فالتنفيذ في هذه الحالة ورغم استناده إلى حكم نهائي، يبقى محفوا بالمخاطر نتيجة لاحتمال إلغاء الحكم المطعون فيه، وقد أراد المشرع أن يتفادى هذه المخاطر بآليات إجرائية تكفل التوازن بين مصلحة المنفذ والمنفذ ضده، على النحو الذي انتهجه في القاعدة العامة التي أشرنا إليها بشأن الحكم القابل للتنفيذ الجبري؛ فعمد إلى منح محكمة الطعن (غير العادي) سلطة تقديرية في الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، متى طلب الخصم منها ذلك، وتوفرت الشروط المقررة قانونا.

وبهذا يكون المشرع قد وازن بين المصلحتين المتعارضتين؛ بأن سمح للمحكوم له السير في تنفيذ الحكم النهائي، وأعطى للمحكوم عليه الحق في طلب وقف التنفيذ من المحكمة التي تنظر الطعن غير العادي، ولهذه الأخيرة سلطة الموازنة بين الأمرين، والأمر بما تراه وفقا للقيود والضمانات المقررة قانونا.

وقد يبدو لأول وهلة أن وقف التنفيذ مقرر لمصلحة المحكوم عليه وحده، ولكن تدقيق النظر في العلة من الوقف يؤكد أنه يصب في مصلحة الخصمين، فمصلحة المحكوم عليه بادية ومعلومة، ومصلحة المحكوم له في التآني حتى يصبح الحكم باتا غير قابل للطعن بأي وسيلة، حتى لا يتحمل مغبة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ إذا ما ألغي الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فضلا عن أن وقف التنفيذ دائما يكون محاطا بضمانات وقيود تكفل حصره في نطاق ضيق، وينحصر في الحالات التي يرجح معها إلغاء الحكم^(١).

ويرمي طلب وقف التنفيذ إلى تعطيل القوة التنفيذية للحكم؛ ومن ثم فهو طلب وقتي يهدف طالبه إلى الحماية من الضرر الذي يصيبه من تنفيذ الحكم أثناء التنفيذ، وهو

(١) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٥٨.

بهذه الصورة لا يعد طعنا في الحكم المطلوب وقف تنفيذه^(١).

وإذا كان طلب وقف التنفيذ طلبا وقتيا؛ فإن الأمر الصادر به هو قضاء وقتي، تستند فيه المحكمة إلى ظاهر الأوراق، ومن ثم لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يقيد سلطة المحكمة في العدول عنه عند الفصل في الطعن على الحكم^(٢).

والأمر بوقف تنفيذ الحكم الانتهائي، سلطة مخولة لمحكمة الطعن غير العادي، أي محكمة النقض، أو المحكمة التي تنتظر التماس إعادة النظر، ونبين ذلك في غصنين:

الغصن الأول

وقف التنفيذ من محكمة النقض

نصت المادة (٢٥١) مرافعات، على القاعدة المتعلقة بوقف التنفيذ من محكمة النقض، وقد تضمنت هذه القاعدة شقين؛ الأول: وهو الأصل؛ ومقتضاها أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم، والثاني: استثناء من الأصل، ومقتضاه سلطة المحكمة في الأمر بوقف التنفيذ وفقا لشروط محددة.

ووفقا لما قرره هذه المادة؛ فإن الطعن في الأحكام الانتهائية بطريق النقض لا يوقف تنفيذها، ولكن قد يقف التنفيذ إذا أمرت محكمة النقض بوقفه مؤقتا، متى توفرت شروط معينة^(٣)، ووفقا لإجراءات محددة، نبينها فيما يلي:

أولاً: شروط وقف التنفيذ من محكمة النقض:

يشترط لوقف التنفيذ من محكمة النقض، توفر أربعة شروط، على النحو الآتي:

١- الشرط الأول: طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن بالنقض:

وهذا الشرط يقتضي بداهة أن يكون هناك طعن بالنقض على الحكم المطلوب

(١) د. وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، ص ١٠٤.

(٢) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٥٩.

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقا للمادة ٢٥١ مرافعات، قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا أثر له على الفصل في ذلك الطعن أو في غيره". (الطعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٦١ قضائية - جلسة ١٥/٣/١٩٩٢).

(٣) أستاذي د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٥٢.

وقف تنفيذه؛ إذ لا يجوز تقديم طلب الوقف مستقلاً دون طعن، ولا يكفي الطعن لمنح المحكمة سلطة الأمر بالإيقاف؛ وإنما يجب أن تتضمن صحيفة الطعن طلب الخصم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه؛ ومن ثم لا يقبل الطلب إذا جاء في صحيفة مستقلة قبل الطعن أو بعده أو حتى معه، فيحكم بعدم قبول الطلب ولو كان في ورقة مستقلة قدمت مع صحيفة الطعن بالنقض^(١). ولا يجوز تقديم طلب جديد لوقف تنفيذ الحكم إذا رفض الطلب الأول المقدم في صحيفة الطعن بالنقض^(٢).

وقد هدف المشرع من وراء هذا الشرط، ضمان جدية طلب التنفيذ من خلال تقديمه في صحيفة الطعن بالنقض؛ بأن يبادر الطاعن إلى إبدائه فور تقديم الطعن؛ إذ تدل هذه المبادرة على جدية الطلب؛ ولذلك قرر المشرع رسماً باهظاً على طلب وقف التنفيذ، لضمان إحجام الطاعنين عن تقديم طلبات الهدف منها عرقلة سير التنفيذ دون أن تكون جدية^(٣).

وإعمالاً لهذا الشرط؛ فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بوقف تنفيذ الحكم؛ إلا إذا طلب الخصم منها ذلك في صحيفة الطعن بالنقض، وشرط ذلك أيضاً أن تكون صحيفة الطعن صحيحة، وقدمت في الميعاد المقرر قانوناً، وأن يظل الطعن قائماً لم ينزل عنه الخصم أو يقضى بسقوطه.

٢- الشرط الثاني: أن يقدم الطلب قبل تمام التنفيذ:

وهو شرط بديهي يستفاد ضمناً مما قرره المادة (٢٥١) وإن لم تنص صراحة عليه؛ لأن منطق الأمور يقتضية؛ فإذا تباطأ الطاعن في تقديم طلب وقف التنفيذ إلى ما بعد تمام التنفيذ؛ فإن طلبه لا يكون له محل، ومن ثم يكون يحكم بعدم قبوله^(٤).

(١) د. أحمد مليجي، التنفيذ، ص ٣٦٩- د. عبدالباسط جميعي، نظام التنفيذ، ص ١١٦.

(٢) وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه "لا يجوز طلب وقف التنفيذ من جديد بعد رفضه استناداً إلى خطر لم يكن ماثلاً وقت التقرير بالطعن، ومن باب أولى استناداً إلى ما قد يكون فات الطاعن بيانه أثناء نظر طلبه الأول من أدلة على توافر ذلك الخطر". نقض ١٩٥٤/١٢/٣٠.

(٣) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٣٧٥/٥.

(٤) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ١٢٤.

ولكن ما الحكم إذا كان التنفيذ قد بدأ بالفعل ولم يتم، هل يجوز للطاعن أن يطلب وقف تنفيذ الحكم الذي بدأ، أم يجب أن يقدم الطلب قبل البدء في التنفيذ؟ العبرة ليست بالبدء في التنفيذ من عدمه؛ وإنما بتمام التنفيذ، ومن ثم يجوز تقديم الطلب قبل البدء في التنفيذ، أو بعد البدء فيه وقبل تمامه، وهنا ينصرف أثر الطلب إلى الإجراءات اللاحقة على تقديم الطلب دون السابقة عليه، بمعنى أن طلب وقف التنفيذ يكون مقبولا فقط بالنسبة لما لم يتم تنفيذه من أجزاء الحكم^(١).

وهنا تثار الإشكالية بالنسبة لإجراءات التنفيذ التي تتخذ بعد تقديم الطلب وحتى الحكم فيه، وهي إشكالية حسمها المشرع بالنص على أنه "ينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ"، وهو ما يعني عدم الاعتداد بإجراءات التنفيذ التي تمت من تاريخ تقديم طلب الوقف، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وقت تقديم الطلب^(٢)، أما ما تم من إجراءات قبل تقديم الطلب فلا يتصور وقفه^(٣). ولا شك أن هذا الحل يوازن بين مصالح الخصوم وتعارضها في طلبات وقف التنفيذ^(٤).

٣- أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه:

ومؤدى ذلك أن تكون هناك خشية من وقوع ضرر من التنفيذ، وأن يكون هذا الضرر جسيما، وألا يكون في الإمكان تدارك هذا الضرر إذا تم التنفيذ، ثم صدر بعد فترة زمنية الحكم الأساسي في الطعن الأصلي الموجه إلى الحكم الانتهائي المطعون فيه^(٥).

(١) د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، ص ٤٦.

(٢) د. وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للتنفيذ، ص ١٠٧.

(٣) وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "الحكم بوقف التنفيذ يسري على ما لم يكن قد تم قبل صدوره من إجراءات تنفيذ الحكم المطعون فيه، لأن ما تم لا يتصور وقفه، ولأن الشارع إنما قصد بوقف التنفيذ في النقض تقادي الضرر قبل وقوعه، ولا يمكن إلغاء ما تم من التنفيذ إلا بنقض الحكم المطعون فيه، وهذا يختلف تماما عن حكم وقف التنفيذ موضوعا وسببا وأثرا". (نقض ١٩٥٤/٥/١٣).

(٤) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات بشأن المادة (٢٥١) منه.

(٥) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٣٧٨/٥.

ومن ثم فلا يشترط تحقق الضرر بالفعل من التنفيذ؛ وإنما يكون محتمل الوقوع، ولا يكفي في ذلك مجرد الضرر أيا كان أثره؛ وإنما يجب أن يكون هذا الضرر جسيما، وهو الضرر غير العادي الذي يتجاوز ما ينبغي أن يتحملة المحكوم عليه لتنفيذ الحكم، ليس هذا فقط؛ وإنما يجب أن يكون هذا الضرر الجسيم مما يتعذر تداركه، بمعنى أن تكون هناك صعوبة من إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، بأن يكون ذلك صعبا ومرهقا؛ كتطبيق حكم بهدم عقار، ولا يشترط أن يكون مستحيلا.

والحكمة من ذلك مراعاة حال المحكوم له الذي يستمد حقه في التنفيذ من حكم انتهائي غير قابل للتنفيذ، ولذلك تشدد المشرع في طبيعة الضرر الذي يسوغ للمحكمة الأمر بوقف تنفيذ الحكم النهائي.

واستخلاص الخشية من وقوع الضرر الجسيم الذي يتعذر تداركه، من المسائل التي تخضع لتقدير محكمة النقض، تستخلصها من ظروف كل حالة على حدة، سواء كانت هذه الظروف موضوعية أو شخصية، وهي تراعي في ذلك جسامه الضرر وتعذر تداركه^(١). وسواء كان هذا الضرر ماديا أو أدبيا.

٤- الشرط الرابع: أن يكون من الراجح إلغاء الحكم المطعون فيه:

والمقصود بهذا الشرط؛ أن يكون الطعن بالنقض الذي قدم طلب الوقف تبعا له، مبنيا على أسباب جدية يكشف ظاهرها على أن الاحتمال الأقرب للحدوث هو إلغاء الحكم المطعون عليه، بحيث تستشف منها المحكمة احتمال إلغاء الحكم عند الفصل في الطعن، وذلك أن محكمة النقض عندما يطلب منها وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه؛ إنما تمارس حماية وقتية مستعجلة لحق مهدد، حتى يتسنى حمايته موضوعيا بعد الفصل في الطعن المرفوع، ولا يمكن حماية حق حماية وقتية إلا إذا ترجح وجوده، وترجح الوجود لن يأتي إلا بتقدير سريع لجدية أسباب الطعن وما تحمله من احتمال إلغاء الحكم^(٢).

(١) د. أمينة مصطفى النمر: إجراءات التنفيذ، ص ٢٠١.

(٢) د. أحمد ملجي، الموسوعة الشاملة، ج ٣٨٢/٥ - د. أحمد ماهر زغلول، أصول التنفيذ، دار النهضة، ص

وعلى الرغم من أن هذا الشرط لم يرد النص عليه في المادة (٢٥١) إلا أن جمهور الفقه القانوني يتفق على وجوب توفره، لكونه شرطاً بديهاً من الناحية الواقعية؛ وعلى محكمة النقض أن تتبينه عند فحصها لأسباب الطعن بالنقض، حتى لا تتخذ الأسباب الواهية ذريعة لوقف التنفيذ في حالات لا يترجح فيها إلغاء الحكم المطعون فيه.

ثانياً: النظام الإجرائي لوقف التنفيذ من محكمة النقض:

نصت المادة (٢٥١) مرافعات على النظام الإجرائي لوقف التنفيذ من محكمة النقض، حيث أوجبت تقديم طلب الوقف إلى المحكمة، كما أوجبت على طالب الوقف أن يطلب من المحكمة تحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ، بناءً على عريضة يقدمها لرئيس المحكمة، ويجب على الطاعن (طالب وقف التنفيذ) أن يعلن خصمه بهذه الجلسة وبصحيفة الطعن، كما يجب إبلاغها للنياية العامة، وللمحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم ما تراه من ضمانات لهذا الوقف. ونبين ذلك فيما يلي:

١- تقديم طلب وقف التنفيذ وطلب تحديد جلسة لنظره:

قلنا إن محكمة النقض لا تملك الأمر بوقف تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها؛ وإنما يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب مقدم من الطاعن، ويجب أن يكون طلب وقف التنفيذ في ذات صحيفة الطعن، فلا يجوز تقديمه مستقلاً، ويقدم هذا الطلب إلى الدائرة التي تختص بنظر الطعن بالنقض.

هذا ولا يكفي طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن لتحديد جلسة لنظر الطلب؛ وإنما يجب على طالب الوقف فضلاً عن ذلك أن يتقدم بعريضة إلى رئيس المحكمة يطلب فيها تحديد جلسة لنظر طلب الوقف، وعلى الخصم بعد تحديد الجلسة أن يعلن خصمه بالجلسة وبصحيفة الطعن بالنقض، كما يجب عليه إبلاغ النياية العامة بالجلسة وبالصحيفة لأن تدخلها وجوباً في جميع الطعون المدنية التي تنظرها محكمة النقض.

٢- نظر طلب وقف التنفيذ والضمانات المقررة للمطعون ضده:

تختص بنظر طلب الوقف الدائرة التي تنتظر الطعن بالنقض، باعتبارها أقدر من غيرها بالفصل في طلب الوقف، ولا يشترط حضور الخصوم أمامها، بل يجوز الفصل فيه ولو لم يحضر خصوم الطعن، ولها في سبيل قبول طلب الوقف أو رفضه سلطة تقديرية للتحقق من توفر مبررات وأسباب الخشية من التنفيذ، سيما ما يتعلق بالضرر الذي يصيب المحكوم عليه جراء تنفيذ الحكم، وسلطة المحكمة في هذا الشأن لا تقتصر على قبول الطلب كلية أو رفضه كلياً وإنما يجوز لها أن تأمر بالوقف الجزئي بأن تأمر بوقف تنفيذ جزء معين مما قضى به الحكم، دون الجزء الآخر، بل إن سلطتها تمتد إلى حماية حق المطعون عليه (المحكوم له)، وذلك بأن تقيد الأمر بالوقف بضمانات معينة تراها، كالأمر بتقديم كفالة، أو غيرها مما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه، ذلك أن الوقف إنما يرد على حكم نهائي يقرر له الحق في التنفيذ.

ولما كان المطعون ضده، يتمتع بحكم نهائي يقرر حقه؛ فإنه وفي سبيل تحقيق التوازن بين مصلحته ومصلحة الطاعن الذي قبل طلبه بوقف تنفيذ الحكم، قرر له المشرع ضمانات تكفل مراعاة مصلحته في مواجهة خصمه، وهذه الضمانات منها كما قلنا، سلطة المحكمة أن توجب تقديم كفالة، أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حقه. فضلاً عما أوجبه المشرع في الفقرة الأخيرة للمادة (٢٥١) على المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ؛ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر، وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده.

٣- طبيعة الحكم بوقف التنفيذ والأثر المترتب عليه:

قلنا إن وقف التنفيذ مسألة وقتية، ومن ثم فالحكم الصادر فيها هو حكم وقتي لا يقيد المحكمة التي أصدرته عند نظرها للطعن بالنقض، فلها أن تعدل عنه ولا أثر له فيما تقضي به من حكم في الطعن بالنقض^(١).

(١) وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة

ويترتب على الحكم بوقف التنفيذ؛ امتناع المحكوم له عن البدء في التنفيذ إن لم يكن بدأ فيه، ومنعه من الاستمرار في تنفيذ الحكم إذا كان قد بدأ في التنفيذ، وكما أشرنا سلفاً ووفقاً لما نصت عليه المادة (٢/٢٥١) فإن الأمر الصادر بوقف التنفيذ ينسحب على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المطعون ضده من تاريخ تقديم طلب وقف التنفيذ، فيجب عليه إعادة الحال إلى ما كانت عليه وقت تقديم الطلب لا وقت الحكم.

الفصل الثاني

وقف التنفيذ من محكمة التماس إعادة النظر

التماس إعادة النظر "طريق غير عادي للطعن في الحكم النهائي يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته متى توفر سبب من الأسباب التي بينها القانون على سبيل الحصر، ولا يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس فيه، ولكنه يستهدف محو هذا الحكم، ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره، ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد"^(١).

ويرفع التماس إعادة النظر إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وذلك لأن الالتماس يبنى على أسباب غابت عن هذه المحكمة لسهو غير متعمد أو فعل يرجع إلى أحد الخصوم، ولو أنها تنبّهت إليه لتغير حكمها، فيكفي تنبيهها إلى ذلك لتتدارك ما وقع في الحكم من خطأ متى تبين سببه^(٢).

ويوجه التماس إعادة النظر إلى الأحكام النهائية، سواء كانت صادرة من محاكم الدرجة الثانية، أو محاكم الدرجة الأولى في حدود نصابها النهائي، بل يجوز الطعن في حكم النقض بالتماس إعادة النظر عندما تتصدى للموضوع وتفصل فيه.

٢٥١ من قانون المرافعات هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تنبيهه المحكمة من جسامه الضرر الذي يخشى من التنفيذ وإمكان تداركه، وليس لها الحكم من تأثير على الفصل في الطعن ولا على الفصل في طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين الخصومتين". (الطعن رقم ١٤٢٨ لسنة ٤٨ قضائية - جلسة ١٩٨٢/٣/٩).

(١) أستاذي د. الأنصاري النيداني: الطعن بالنقض أمام المحاكم العليا، دار الجامعة، ٢٠١٢م، ص ٥٢٣.

(٢) د. أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة، ج ٩/٥.

والحكمة التي من أجلها نص المشرع على التماس إعادة النظر، وعودة النزاع إلى المحكمة مرة ثانية بعد إصدارها الحكم فيه وحيازة هذا الحكم للحجية، هي أن المشرع لم يشأ الإبقاء على حكم قضائي ظاهر العوار، فاسد الأساس، صدر بناء على قواعد مغلوطة، وإرادة قضائية معيبة؛ فأتاح لكل محكوم عليه بحكم قضائي انتهائي، أن يعود إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم؛ لتعيد نظر النزاع على ضوء الوقائع الصحيحة والتي لو كانت تعلمها لما أصدرت الحكم القضائي المطعون فيه^(١).

والقاعدة أن الطعن بالتماس إعادة النظر، لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، واستثناء من هذه القاعدة أعطى المشرع لمحكمة التماس إعادة النظر سلطة تقديرية في الأمر بوقف التنفيذ متى توفرت شروط محددة.

شروط وقف التنفيذ من محكمة التماس إعادة النظر:

أوردت المادة (٢٤٤) مرافعات، شروط وقف التنفيذ من محكمة التماس إعادة النظر، وذلك بنصها على القاعدة العامة، والاستثناء، في هذا الصدد؛ فقضت بأن رفع التماس إعادة النظر لا يترتب عليه وقف التنفيذ، واستثناء من ذلك يجوز للمحكمة التي تنتظر الالتماس، أن تأمر بوقف التنفيذ، إذا توفرت الشروط الآتية:

١- أن يطلب الخصم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه:

فلا تملك المحكمة أن تقضي بوقف التنفيذ من تلقاء نفسها لمجرد الطعن أمامها بالالتماس؛ وإنما يجب على الخصم أن يطلب من المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالالتماس، ويختلف هذا الشرط عما سبق تناوله في طلب وقف التنفيذ من محكمة النقض، أن المشرع هنا على خلاف الطعن بالنقض لم يشترط أن يكون الطلب ضمن صحيفة الطعن، ومن ثم يجوز للخصم طلب وقف التنفيذ من محكمة الالتماس بشكل مستقل عن الطعن، أي يجوز له أن يطلب ذلك بعد تقديم صحيفة الالتماس، وأثناء نظر الطعن ولو بعد ميعاد الالتماس، بل ويجوز تعدد الطلبات أو تكرار الطلب، متى

(١) د. محمود السيد التحيوي: الطعن في الأحكام القضائية، دار الفكر الجامعي، ٢٠٠٧م، ص ١٥١.

تغيرت الظروف التي بني عليها السبب الأول^(١)، غاية ما في الأمر أنه لا يجوز للخصم أن يطلب وقف التنفيذ من المحكمة؛ إذا لم يطعن في الحكم؛ فطلب وقف التنفيذ لا يجوز أن يكون مستقلاً في غير طعن.

٢- أن يتم تقديم الطلب قبل تمام التنفيذ.

٣- أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

٤- أن يكون من الراجح إلغاء الحكم المطعون فيه.

وقد سبق أن تناولنا هذه الشروط عند الحديث عن وقف التنفيذ من محكمة النقض؛ فحيل إلى ما سبق بيانه منعا للتكرار.

إجراءات طلب وقف التنفيذ من محكمة التماس إعادة النظر:

لم ينص المشرع على إجراءات معينة تتبع بشأن طلب وقف التنفيذ من محكمة التماس إعادة النظر، ومن ثم نتفق مع ما ذهب إليه الفقه القانوني من اتباع الإجراءات المقررة بشأن وقف التنفيذ من محكمة النقض، ولمحكمة التماس وفقاً لما نصت عليه المادة (٢٤٤) إذا أمرت بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه.

والحكم الصادر من محكمة التماس بوقف التنفيذ، شأنه شأن الحكم الصادر من محكمة النقض؛ حكم وقتي لا يفيد المحكمة عند الفصل في الطعن بالتماس إعادة النظر، ويترتب عليه ذات الأثر المترتب على حكم النقض بوقف التنفيذ.

(١) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ١٤٥

المطلب الثالث

النفاذ المعجل للأحكام

بينا في المطلب السابق القاعدة العامة في التنفيذ الجبري للأحكام، وقلنا إن الأحكام التي تنفذ جبرا وفقا لهذه القاعدة، هي الأحكام الانتهائية التي لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف.

غير أن المشرع ولا اعتبارات قدرها أجاز على سبيل الاستثناء من هذه القاعدة تنفيذ الأحكام الابتدائية نفاذا معجلا رغم قابليتها للطعن بالاستئناف، أو كان قد تم الطعن فعلا، ونص على ذلك في المادة (٢٨٧) بنصه على أنه "لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوبا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم. ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية".

ومفاد هذا الاستثناء؛ جواز تنفيذ الأحكام الابتدائية نفاذا معجلا قبل صدور الحكم النهائي في موضوعها، وهذا النفاذ المعجل قد يكون بقوة القانون في حالات محددة نص فيها القانون على تنفيذ الحكم الابتدائي لا اعتبارات خاصة بكل حالة، وقد يكون بأمر المحكمة في الحالات التي خولها المشرع سلطة الأمر بالنفاذ المعجل فيها.

ونظرا لأن هذا الحكم لم يحز قوة الأمر المقضي، ومعرضا للإلغاء أو التعديل من محكمة الاستئناف؛ بما يعني أن حجيته قلقة وغير مستقرة؛ فإن المشرع حرص على تحقيق نوع من التوازن بين مصلحة المحكوم له والمحكوم عليه في النفاذ المعجل، فقرر بعض الضمانات لتعويض المحكوم عليه عن الأضرار التي قد تلحق به إذا لم يمكن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ المعجل.

ونبين المقصود بالنفاذ المعجل وفكرته، وأنواعه، وضمانات المحكوم عليه فيه، وذلك في ثلاثة فروع على النحو الآتي:

الفرع الأول

فكرة النفاذ المعجل

يقتضي التنفيذ العادي للأحكام، انتظار صدور الحكم النهائي، وعدم التعجل في تنفيذ الحكم الابتدائي، خشية إلغائه من محكمة الاستئناف، مع ما يترتب على ذلك من آثار وربما أضرار تتعلق بما تم تنفيذه من الحكم.

غير أن المشرع رأى أن هناك حالات تستدعي تنفيذ الحكم معجلاً قبل أن يصير نهائياً، لاعتبارات قدرها في بعض الحالات؛ فجعل التنفيذ المعجل فيها بقوة القانون، أو ترك للمحكمة تقديرها في حالات أخرى؛ فجعل التنفيذ المعجل فيها بإذن المحكمة.

وهذه الاعتبارات منها ما لاحظته المشرع من أن هناك حالات يكون فيها سند المحكوم له قويا بحيث يرجح معه احتمال تأييد الحكم إذا طعن فيه؛ كالحكم بناء على سند رسمي، ومنها حالات يكون فيها موضوع الدعوى مستعجلاً مما يتعين معه تنفيذ الحكم الصادر فوراً؛ وإلا فأت الغرض الذي قصده المشرع من الفصل في الموضوع بصفة مستعجلة، ومنها حالات يكون المحكوم له ممن رعاها المشرع برعاية خاصة^(١).

ومن ثم فإن رائد المشرع في تقرير هذا الاستثناء هو تلبية حاجة المحكوم له إلى الحماية الوقتية لحقه الذي أثبتته الحكم الابتدائي، فقد يكون في حاجة ماسة إلى تنفيذ الحكم، كاحتياجه إلى المبلغ المحكوم به مثلاً، ويتعرض لضرر جسيم إذا تأجل التنفيذ لحين صدور الحكم النهائي^(٢)، فيعتمد المشرع إلى منحه حقا استثنائياً في التنفيذ المعجل للحكم، مراعاة لمصلحته ومنعاً للضرر الذي قد يترتب على تأخير التنفيذ.

ووفقاً لذلك يمكننا القول أن النفاذ المعجل؛ هو قابلية الحكم الابتدائي للتنفيذ بقوة القانون أو بحكم المحكمة، قبل أن يصير نهائياً. وهو بذلك يخالف القاعدة في تنفيذ الأحكام، حيث يضاف عليها قوة تنفيذية رغم قابليتها للطعن بالاستئناف، أو تقديم هذا الطعن فعلاً.

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٥٧.

(٢) أستاذي د. الأنصاري النيداني، قانون التنفيذ الجبري، ص ٢١٣.

وهو تنفيذ قلق غير مستقر غير مستقر يتعلق مصيره بمصير الحكم ذاته، يبقى إذا بقي وأيدته محكمة الطعن، ويزول ويسقط وتسقط إجراءاته إذا ألغت محكمة الطعن الحكم، ولهذا يوصف بأنه مؤقت^(١). فالنفاذ المعجل بهذا المفهوم هو صورة من صور الحماية القضائية الوقتية أو المستعجلة تمارس في مرحلة التنفيذ القضائي^(٢).

"والحكمة التي تقرر من أجلها النفاذ المعجل؛ هي القضاء على المحاولات التسوية التي قد يقوم بها المحكوم عليه لتأخير التنفيذ استفادة من الأثر الموقف للإستئناف، فهي ميزة يمنحها القانون للمحكوم له لتنفيذ الحكم الابتدائي قبل أن تستقر حجيته؛ إذ المحكوم له يضمن بموجب هذا النظام تنفيذا مبكرا للحكم بمصلحته، فمن خلال النفاذ المعجل أو الوقتي يحاول المشرع التوفيق بين مصلحة المحكوم له في جواز تنفيذ الحكم الصادر له دون ترصص حتى يصبح نهائيا، وبين مصلحة المحكوم عليه في ألا ينفذ عليه من الأحكام إلا ما أصبح نهائيا، من أجل ذلك حرص المشرع على تحديد حالات النفاذ المعجل وأوردها في القانون على سبيل الحصر"^(٣).

ولما كان القانون قد أورد حالات النفاذ المعجل على سبيل الحصر، فإننا نتفق مع ما ذهب إليه جمهور الفقه القانوني من القول بأنه لا يجوز للخصوم الاتفاق على أن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل في غير الحالات التي نص عليها المشرع، وسواء كان الاتفاق سابقا على صدور الحكم أو لاحقا له، وإن كان من الجائز أن يتفق الخصوم على عدم تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل؛ إلا بعد أن يتم الطعن فيه ويصير نهائيا^(٤).

الشروط اللازمة لشمول الحكم بالنفاذ المعجل:

لم ينص المشرع على الشروط اللازمة لشمول الحكم الابتدائي بالنفاذ المعجل،

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٥٦.

(٢) د. أحمد ماهر زغلول، أصول التنفيذ، ص ١١٤.

(٣) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ، ص ٣١.

(٤) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ١٥٣.

اكتفاء بتعداد حالاته، سواء في النفاذ المعجل القانوني، أو النفاذ المعجل القضائي، وباعتبار أن لكل حالة منها الشروط الخاصة بها. ونتفق مع ما ذهب إليه بعض الفقه^(١)، من أن شروط الحكم بالنفاذ المعجل بصفة عامة، هي ذاتها الشروط اللازمة للحماية الوقتية أو المستعجلة، وهذه الشروط هي:

١- خشية الضرر الجسيم، أو الحاجة والضرورة.

٢- ورجحان وجود الحق (قوة السند التنفيذي).

وهذه الشروط لازمة في نوعي النفاذ المعجل، غاية ما في الأمر أن المشرع افترض وجودها في النفاذ المعجل القانوني دون إثبات من الخصم، وغل يد القاضي عن بحثها أو تقديرها، في حين ترك له السلطة التقديرية في حالات النفاذ المعجل القضائي.

الفرع الثاني

أنواع النفاذ المعجل

نص المشرع على نوعين للنفاذ المعجل، أولهما: النفاذ المعجل بقوة القانون، وذلك في حالات محددة نص فيها القانون على نفاذ الحكم الابتدائي نفاذا معجلا دون سلطة تقديرية للمحكمة في ذلك؛ وهو بذلك نفاذ حتمي أو وجوبي، ويسمى "النفاذ المعجل القانوني"، وثانيهما: النفاذ المعجل بأمر المحكمة، وذلك في حالات محددة على سبيل الحصر، أعطى فيها المشرع للمحكمة سلطة الحكم بالنفاذ المعجل للحكم الصادر منها بصفة ابتدائية، شريطة أن تنص على ذلك في حكمها، وهو بذلك نفاذ جوازي أو تقديري، ويسمى "النفاذ المعجل القضائي".

وعلة التفرقة بين حالات يكون فيها النفاذ المعجل بقوة القانون، وأخرى يكون فيها النفاذ المعجل بأمر المحكمة؛ أن المشرع رأى في الحالات الأولى أنها واضحة وظاهرة لا تحتاج إلى بيان، فلا يخفى أمرها على السلطة التي يطلب منها إجراء التنفيذ، كالحكم في مادة مستعجلة أو مسألة تجارية، أما في الحالات الأخرى فلا بد من تدخل

(١) استاذي د. الأنصاري النيداني، قانون التنفيذ الجبري، ص ٢١٤.

المحكمة حتى تتحقق بنفسها من توفر شروط النفاذ المعجل التي أوجبها القانون؛ ومن ثم فليست غاية المشرع من هذا التقسيم؛ أن يظهر حرصه على حالات دون أخرى؛ وإنما لأنه افترض مقدما توفر دواعي النفاذ المعجل في الحالات الأولى، ولم يفترض ذلك في الحالات الثانية، وترك للمحكمة سلطة التقدير بحسب ظروف كل قضية^(١).

وأيا كان نوع النفاذ (قانوني أم قضائي)؛ فإن الحكم المشمول به ينفذ نفاذا معجلا رغم قابليته للطعن فيه بالاستئناف، بل ولو كان مطعونا فيه بالاستئناف فعلا، دون حاجة لانتظار الحكم النهائي من محكمة الطعن.

الفصل الأول

النفاذ المعجل القانوني

أولاً: المقصود بالنفاذ المعجل القانوني:

قلنا إن النفاذ المعجل القانوني؛ هو الذي يقرره القانون في حالات محددة على سبيل الحصر، ويجعل النفاذ المعجل فيها وجوبيا أو حتميا، ولا يكون للمحكمة دور في الحكم به، ولا سلطة لها في عدم شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حالة من هذه الحالات.

فهي حالات افترض فيها المشرع بنفسه توفر الدوافع الكافية لشمول الحكم الابتدائي بالنفاذ المعجل لاعتبارات قدرها، ولم يترك للمحكمة سلطة تقدير توفرها من عدمه، وهو ما يعني أن الحكم الصادر في مسألة من هذه المسائل، يكون دائما مشمولا بالنفاذ المعجل، ولا ينال من ذلك ألا تنص المحكمة في حكمها على النفاذ المعجل؛ فإذا نصت على ذلك؛ فإنما ذلك منها تزييدا لم يتطلبه القانون؛ وإن لم تنص على ذلك؛ فالنفاذ المعجل مقرر قانونا دون حاجه لأن تنص عليه المحكمة في حكمها، بل إن حكمها يكون معيبا إذا قضت بعدم النفاذ المعجل في حالة من حالات النفاذ الوجوبي؛ ويكون قابلا للطعن عليه بطريق خاص، وهو التظلم (الوصفي) من وصف الحكم.

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٦٦-٦٧.

وحالات النفاذ المعجل القانوني وردت في قانون المرافعات في مادتين فقط؛ هما (٢٨٨-٢٨٩)، فضلا عن ذلك فإنه قد تكون هناك حالات في قوانين أخرى على سبيل الحصر.

ثانيا: حالات النفاذ المعجل القانوني:

وردت هذه الحالات على سبيل الحصر في المادتين (٢٨٨-٢٨٩) مرافعات، وفي المادة (٦٥) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وهذه الحالات هي: الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والأوامر على العرائض، والأحكام الصادرة في المواد التجارية، والأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية.

١- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة:

الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة مشمولة دائما وفي جميع الأحوال بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وذلك بنص المادة (٢٨٨) مرافعات، والتي نصت على أن "النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، والأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة".

وينفذ الحكم المستعجل نفاذا معجلا بقوة القانون أيا كانت المحكمة التي أصدرته؛ أي سواء كان صادرا من القاضي المستعجل في دعوى مستعجلة مستقلة، أو كان صادرا من محكمة الموضوع في طلب مستعجل بالتبعية لدعوى موضوعية أمام محكمة الموضوع، أو كان صادرا من قاضي التنفيذ في منازعة وقتية من منازعات التنفيذ^(١).

ولا يتطلب تنفيذ الحكم المستعجل نفاذا معجلا أن يطلب الخصم ذلك من المحكمة؛ وإنما يكون الحكم نافذا معجلا ولو لم يطلبه الخصم، لكون ذلك مقررا بنص القانون، فالحكم في هذه الحالة يستمد قوته التنفيذية مباشرة من نص القانون^(٢). فالحكم

(١) د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٦٤.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ١٠٤١/٥.

المستعجل يسبغ على المحكوم له حماية وقتية، ولا تكتمل هذه الحماية إلا بنفاذها نفاذاً معجلاً؛ فالنفاذ المعجل في هذه الحالة تمليه طبيعة الحكم^(١).

والحكمة من تنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة نفاذاً معجلاً؛ أن هذه الأحكام لا تحتل بطبيعتها التأخير، ولا تكون ذات جدوى إذا لم تنفذ فوراً، فصفة الاستعجال على النحو المشار إليه تبرر أن يصدر الحكم في هذه المسائل بصفة مستعجلة، وأن ينفذ نفاذاً معجلاً؛ وإلا لو انتظرنا حتى يصبح الحكم نهائياً؛ لأدى ذلك إلى فوات الغرض منه، كما أن الغالب في هذه الأحكام أن المحكوم عليه لا يضرار من تنفيذها معجلاً، كونها تقضي بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق^(٢).

وإعمالاً لما نصت عليه المادة (١٧٨) مرافعات؛ فإنه يجب على المحكمة أن تبين في حكمها، ما إذا كان الحكم صادراً في مادة مستعجلة، فإن لم تبين ذلك؛ فإن حكمها يكون صحيحاً، ولا يترتب على ذلك بطلان.

ومع ذلك يجب مراعاة أن معاون التنفيذ يجب عليه تنفيذ الحكم المستعجل دون حاجة إلى نص المحكمة على النفاذ المعجل كما سبق القول، طالما وجد الحكم صادراً في مسألة مستعجلة؛ إلا أن إغفال المحكمة ذكر بيان يفيد صدور الحكم في مسألة مستعجلة، وعدم وضوح ذلك في منطوقه؛ يترتب عليه امتناع الكاتب عن وضع الصيغة التنفيذية على الحكم، وهو ما يعني تعذر نفاذه بقوة القانون^(٣).

الكفالة في النفاذ المعجل للأحكام المستعجلة:

الأصل وفقاً لما قرره المادة (٢٨٨) المشار إليها، أن النفاذ القانوني لهذه الأحكام غير مشروط بالكفالة؛ فالكفالة ليست واجبة بنص القانون، ومع ذلك واستثناء من هذا الأصل؛ فإن القانون أعطى للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالكفالة إذا رأى مقتضى لذلك؛ ومن ثم تجب التفرقة بين النفاذ المعجل؛ وهو يكون وجوباً بقوة القانون، وبين

(١) د. وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي، ص ٧٦.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ١٠٤١/٥ - د. عبدالعزيز بديوي، الوجيز، ص ٦٦.

(٣) د. أحمد هندي، أصول قانون المرافعات، ص ٣٥.

الكفالة، وتكون جوازية بأمر المحكمة.

٢- الأوامر على العرائض:

يتضح من نص المادة (٢٨٨) أن الأوامر الصادرة على العرائض تنفذ نفاذا معجلا بقوة القانون في جميع الأحوال، وأيا كان القاضي الأمر بها، أي سواء كان قاضي الأمور الوقفية، أو رئيس الدائرة التي تنتظر الموضوع، أو قاضي التنفيذ، ولا يمنع من ذلك قابليتها للطعن فيها بطريق التظلم، أو التظلم فعلا.

والحكمة من تقرير النفاذ المعجل بقوة القانون للأوامر على العرائض؛ أنها تصدر بإجراءات مؤقتة، وتقتضي مصلحة الخصوم السرعة والتعجل في اتخاذها، فالنفاذ المعجل يتفق وطبيعتها؛ لأنها تصدر بإجراءات وقتية أو تحفظية في غيبة الخصم، وتعطيل قوتها التنفيذية للطعن فيها، يفوت الغرض الذي تهدف إليه^(١).

هذا وتجب الإشارة إلى أن النفاذ المعجل للأوامر على العرائض غير مشروط بتقديم كفالة؛ إذ الأمر بالكفالة جوازي للمحكمة متى رأت ذلك.

٣- الأحكام الصادرة في المواد التجارية:

وقد خص المشرع هذه الأحكام بالنص عليها في مادة مستقلة، هي المادة (٢٨٩) مرافعات، والتي نصت على أن "النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية وذلك بشرط تقديم كفالة". فالمشرع في هذه المادة يخص الأحكام التجارية بشرط لازم لتنفيذها نفاذا معجلا، وهو تقديم كفالة.

ومن ثم فإن الحكم الصادر في مادة تجارية يكون نافذا نفاذا معجلا بقوة القانون بشرط تقديم كفالة ولو كان قابلا للطعن فيه بالاستئناف أو كان قد تم الطعن فيه فعلا، وذلك دون حاجة للنص في الحكم على النفاذ المعجل؛ كونه مقررا بقوة القانون.

وعلة شمول الأحكام التجارية بالنفاذ المعجل، ما تقتضيه طبيعة هذه المعاملات من السرعة والائتمان، ومن تعجيل الوفاء بالديون وسرعة السير في إجراءات

(١) د. عبدالباسط جميعي، المبادئ العامة في التنفيذ، ص ٨٣.

الخصومة^(١)، فمن المعلوم أن المعاملات التجارية تقتضي أن يحصل التاجر على حقوقه بسرعة تى يستطيع أن يفي بالتزاماته أيضا بذات السرعة^(٢).

ويرجع في تحديد تجارية المادة إلى ما تنص عليه قواعد القانون التجاري، ونرجح أنه يتم تحديد تجارية المادة بحسب التكييف القانوني الذي يعطيه القاضي لوقائع النزاع^(٣)، وإن كان البعض يرى أن الضابط في تحديد تجارية المسألة؛ يكون بالنظر إلى المحكوم عليه، أي أن المسألة تعتبر تجارية بالنسبة إلى المحكوم إليه^(٤).

وعبارة المشرع في المادة (٢٨٩) تتسع لتشمل كل كم يصدر في مادة تجارية؛ أيا كان مصدر الالتزام فيها عقدا أو غير عقد، أيا كان دليله (مكتوبا أو غير مكتوب)، وسواء كان موضوعه تنفيذ عقد تجاري أو فسخه^(٥).

حكم الكفالة في حالة النفاذ المعجل للأحكام الصادرة في مادة تجارية:

تولى المشرع بنفسه بيان حكم الكفالة في هذه الحالة، فنص على أن الكفالة واجبة بقوة القانون، وأن النفاذ المعجل لهذه الأحكام مشروط بتقديم الكفالة، فلا سلطة للقاضي في الإعفاء من الكفالة، بل عليه أن يقضي بها في جميع الأحوال ولو لم يطلبها الخصم، مادام الحكم صادرا في مادة تجارية ولا بطلان إذا لم ينص الحكم على الكفالة فهي واجبة بقوة القانون^(٦). أما إذا أخطأت المحكمة وأعفت المحكوم له من الكفالة؛ فيجوز للمحكوم عليه التظلم من وصف الحكم، طالبا منع التنفيذ لحين قيام المحكوم عليه بتقديم الكفالة المناسبة^(٧).

(١) د. وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للتنفيذ، ص ٧٧.

(٢) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ١٦١.

(٣) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ١٧٣.

(٤) د. أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ، ص ٨٥ هامش ٢.

(٥) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ١٠٤٧/٥.

(٦) وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن النعي على الحكم بإغفاله النص على إلزام المحكوم له بتقديم كفالة رغم شمول الحكم بالنفاذ المعجل لصدوره في مادة تجارية. وارد على غير محل. (الطعن رقم ٩٣٥ لسنة ٥٧ قضائية - جلسة ١٩٩٢/٤/٩).

(٧) أستاذي د. الأنصاري النيداني، قانون التنفيذ الجبري، ص ٢٢٠.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام التجارية المقصودة هنا؛ هي الأحكام الموضوعية، يستوي أن يكون الحكم صادرا بكامله في مادة تجارية أم كان صادرا في مادة تجارية في شق منه فقط؛ فالحكم الصادر في الموضوع فقط هو ما ينطبق عليه حكم هذه المادة، دون الأحكام المستعجلة، ذلك أن الحكم المستعجل الصادر في مسألة تجارية، ينفذ نفاذا معجلا وفقا لما نصت عليه المادة (٢٨٨) بشأن النفاذ المعجل للأحكام المستعجلة، ومن ثم تكون الكفالة بشأنه جوازية وليست وجوبية^(١).

٤- الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية:

بخلاف ما نص عليه قانون المرافعات بشأن حالات النفاذ المعجل القانوني، في الحالات الثلاث التي سبق بيانها؛ فإن هناك قوانين أخرى نصت على النفاذ المعجل القانوني للأحكام الصادرة في بعض المنازعات، وهي:

نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ بشأن تعديل أحكام بعض النفقات، والتي نصت على أنه "تتظر الدعاوى المتعلقة بنفقة الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين على وجه الاستعجال، ولطالب النفقة أن يستصدر أمرا من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له. والنفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو أجره الحضانة أو الرضاعة أو المسكن للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين".

ونص المادة (٥٤) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه "تكون الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها في المسائل الآتية: الحساب، رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية، رد الولاية، إعادة الإذن للناصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة، ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب. وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل

(١) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ١٦٣.

في الطعن.

وكذلك نص المادة (٦٥) من ذات القانون، والتي نصت على أن "الأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة".

فبمجرد صدور حكم من هذه الأحكام؛ فإنه يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون، دون حاجة لأن تصرح المحكمة بذلك في حكمها، ودون طلب من المحكوم له، ويقصد بأحكام النفقات، أحكام الإلزام الموضوعية التي تصدر بأداء نفقة واجبة لأحد الأقارب أو الأزواج، كالحكم الصادر بإلزام الأب بالإنفاق على ابنه، والحكم الصادر بأداء نفقة لأبيه، والحكم الصادر بإلزام الزوج بأداء نفقة لزوجته أو لمطلقتها. فالنص هنا يتحدث عن الأحكام الصادرة بالنفقات، ولم يحددها بالنفقات المؤقتة؛ إذ تكون هذه الأخيرة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون باعتبارها من المسائل المستعجلة التي تندرج تحت حكم المادة (٢٨٨)، وتشمل الأحكام الصادرة بالنفقة؛ الحكم الصادر بتقرير النفقة والحكم الصادر بزيادة النفقة، باعتباره صورة من صور أداء النفقة. وبالإضافة إلى الأحكام الموضوعية الصادرة بإلزام الزوج بأداء نفقة لزوجته أو لأحد أقربائه؛ فإنه ينفذ نفاذا عاجلا بقوة القانون أيضا الأحكام الصادرة بأجرة الحضانة أو الرضاع أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته أو مصاريف ذلك^(١).

ومن هذه الحالات أيضا، نص المادة (٧٠) من ذات القانون، والتي نصت على أنه "يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتا متى يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب التنفيذ إلى حين صدور حكم من المحكمة في موضوع حضانة الصغير".

(١) أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٣٦.

الفصل الثاني

النفاذ المعجل القضائي

ويقصد به سلطة المحكمة في الأمر بالنفاذ المعجل للأحكام الابتدائية في حالات محددة - وفي غير الحالات التي يوجب القانون فيها نفاذ الحكم معجلاً - فيستمد الحكم قوته التنفيذية من أمر القاضي؛ بحيث يجب أن يتضمن الحكم أمراً صريحاً يقضي بالنفاذ المعجل؛ بأن يقرر القاضي "مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل"؛ فإن لم ينص على ذلك؛ فلا ينفذ الحكم نفاذاً عاجلاً^(١).

والقاضي في حالات النفاذ المعجل القضائي، لا يصرح به من تلقاء نفسه، بل لابد أن يطلبه الخصم من المحكمة؛ إذ ليس لها أن تقضي بشيء لم يطلب منها؛ فإن حكمت بالنفاذ المعجل دون طلب من الخصم؛ فإن الحكم يكون قابلاً للتظلم الوصفي^(٢).

ولا يخضع طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل لشكل معين فيجوز أن يكون شفهاياً أو مكتوباً، ولا يلزم تقديمه في ميعاد محدد؛ وإنما يجوز طلبه في صحيفة الدعوى، أو أثناء نظرها وقبل إقفال باب المرافعة فيها^(٣)، غاية ما في الأمر أنه ليس للخصم أن يعود إلى المحكمة بعد إصدار حكمها ويطلب منها شموله بالنفاذ المعجل، لخروج النزاع عن ولاية المحكمة بإصدار الحكم فيها.

والأمر بالنفاذ المعجل أو عدم الأمر به، مسألة تقديرية للمحكمة، فلها أن ترفض شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم توفر حالة من الحالات التي نص عليها القانون، ويجوز لها أن تشمل شقاً من الحكم بالنفاذ المعجل دون الشق الآخر. والحكم بالنفاذ المعجل شأنه شأن غيره من الأحكام، من حيث وجوب تسببيه إعمالاً لنص المادة (١٧٦)، وإلا كان معيباً^(٤). بينما لا يجب تسبیب رفض الأمر بالنفاذ المعجل.

(١) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٤١.

(٢) د. أمينة مصطفى النمر، إجراءات التنفيذ، ص ١٦٩.

(٣) د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ٦٤.

(٤) د. أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ، ص ٦٦ - ٦٧.

وبديهي أن الخصم لا يملك طلب النفاذ المعجل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وعليها إذا طلب منها ذلك أن تقضي بعدم قبول الطلب باعتباره طلبا جديدا؛ إذا قصد به شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الفترة السابقة على الفصل في الطعن؛ أما إذا كان مقصودا منه شمول حكم الاستئناف ذاته بالنفاذ المعجل؛ فإن عليها أن تقضي أيضا بعدم القبول، وذلك لانعدام المصلحة من الطلب؛ ذلك أن حكم الاستئناف واجب النفاذ طبقا للقواعد العامة باعتباره حكما نهائيا^(١).

والحكم بالنفاذ المعجل يشمل الطلب الأصلي وتوابعه ما دام قد قضي بها، ووفقا للرأي الذي نرجحه؛ فإنه يشمل كذلك المصاريف وتأخذ حكم الطلب الأصلي؛ لأن المصاريف تابع من توابع الطلب الأصلي، ومتى حكم بها فإنها تأخذ حكم الطلب الأصلي في صدد القابلية للتنفيذ، وذلك منعا من تعدد إجراءات التنفيذ وتعقدها في المسألة الواحدة؛ إذ القول بغير ذلك يجعل المحكوم له يسير في إجراءات النفاذ المعجل اقتضاء للطلب الأصلي، ثم يسير في إجراءات أخرى لاقتضاء المصاريف، وهو عبء لا يمكن القول به، سيما في ظل سلطة القاضي التقديرية في النفاذ المعجل منعا للضرر، والتي يمكن الاستناد إليها في القول بأن القاضي أمر بالنفاذ المعجل للشرع المتعلق بالمصاريف في الحكم، حتى لا يترتب على تأخير تنفيذه ضرر بالمحكوم له^(٢).

نطاق السلطة التقديرية للمحكمة في الأمر بالنفاذ المعجل القضائي:

وردت حالات النفاذ المعجل القضائي في المادة (٢٩٠) مرافعات، حيث عدد المشرع الحالات التي تملك المحكمة فيها الأمر بنفاذ الحكم نفاذا معجلا؛ إلا أنه أورد في نهاية هذه المادة حكما عاما أو قاعدة عامة، تقضي بسلطة المحكمة في الأمر بالنفاذ المعجل إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له؛ ومن ثم فقد وسع المشرع بهذه القاعدة، ما حدده فيما سبقها من حالات، حتى إن بعض

(١) د. عبدالعزيز بديوي، الوجيز في التنفيذ، ص ٦٤- د. عيد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ١٦٧.

(٢) د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٧٠.

الفقه^(١) رأى أن الحالة الأخيرة كان يمكن الاكتفاء بها وحدها، لأنها تغني عن بقية الحالات، بحيث يترك للقضاء في كل حالة تقدير ما إذا كان من الملائم شمولها أو عدم شمولها بالنفاذ المعجل في ضوء المعيار الذي قرره المشرع بشأن خشية الضرر الجسيم بالمحكوم له.

ولهذا نتفق مع ما ذهب إليه البعض^(٢) من أن حالات النفاذ المعجل القضائي التي عدتها المادة (٢٩٠) إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر؛ استنادا إلى الحالة الأخيرة التي أعطت للمحكمة سلطة الأمر بالنفاذ المعجل في حالات أخرى ترى فيها ذلك استنادا إلى فكرة الضرر، ومن ثم يستطيع الخصم في غير الحالات المبينة في المادة طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، ويملك القاضي إجابة طلبه إذا رأى من ظروف الدعوى أن تأخير التنفيذ يترتب عليه ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

ولكننا مع ذلك نرى؛ أنه ليس معنى ذلك أن المحكمة تملك الحكم بالنفاذ المعجل في غير هذه الحالات، وإنما تنحصر سلطتها التقديرية في الحالات التي حددها المشرع، وفي كل حالة أخرى ترى فيها أن هناك خشية من ضرر جسيم يصيب المحكوم له جراء تأخير تنفيذ الحكم؛ فإذا لم تتوفر هذه الخشية، فلا تملك المحكمة سلطة الخروج على الحالات المقررة في نص المادة؛ وإلا كان حكمها معيبا.

كما أن التعداد الذي أورده المشرع في هذه المادة لا يعني وجوب الحكم بالنفاذ المعجل متى توفرت حالة من هذه الحالات؛ وإنما الأمر جوازي ومتروك لسلطة المحكمة التقديرية، والتي يكون لها ألا تأمر بالنفاذ المعجل في حالة من الحالات المنصوص عليها، ولها إذا أمرت به أن توجب تقديم كفالة أو تعفي المحكوم عليه منها، فالحكم بالكفالة جوازي أيضا في كل حالة من هذه الحالات.

ففي كافة حالات التنفيذ المعجل القضائي يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في

(١) د. عبدالباسط جميعي، مبادئ التنفيذ، ص ٢٤٥.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ١٠٥٥/٥ - د. أحمد هندي، أصول التنفيذ، ص ٤١.

تقدير مدى توفر شروط الحماية المستعجلة بشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، حيث يقوم بتقدير كل حالة على حدة للتحقق من توفر هذه الشروط، والعبرة في ذلك بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما قام في ذهن الخصوم أو ما اتفقوا عليه^(١).

وتتضح الحكمة من النفاذ المعجل القضائي؛ إذا نظرنا إلى حالاته؛ فهي حالات يعود بعضها إلى قوة تأكيد الحق الثابت في الحكم، ما يقلل من احتمال إلغاء الحكم في الاستئناف، وحالات أخرى تستند إلى الضرر الذي قد يتعرض المحكوم له فيها من تأخير التنفيذ^(٢).

حالات النفاذ المعجل القضائي:

الحالة الأولى: الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتببات:

تجب الإشارة بداية إلى أننا تناولنا الأحكام الصادرة بأداء النفقات ضمن حالات النفاذ المعجل القانوني (الوجوبي)، وهي النفقات التي يقرها قانون الأحوال الشخصية، ومن ثم تخرج هذه النفقات عن نطاق الحالة التي نتناولها الآن.

فالنص الذي نتناوله الآن وإن كان يبدو ناصا عاما بشأن كافة النفقات؛ إلا أن الواقع القانوني غير ذلك، إذ لا تندرج النفقات التي تقرها قوانين الأحوال الشخصية ضمن عمومية هذا النص؛ لأن الأحكام الصادرة بها مشمولة دائما بالنفاذ المعجل بقوة القانون^(٣). هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية؛ فإن الحكم الصادر بأداء نفقة وقتية لا يندرج أيضا ضمن أحكام هذا النص، وذلك لأن الحكم بأداء النفقة الوقتية، هو حكم مستعجل، وينفذ نفاذا معجلا بقوة القانون طبقا للمادة (٢٨٨) مرافعات.

ومن ثم فإن نص المادة (١/٢٩٠) ينحصر تطبيقه في الأحكام الموضوعية التي تصدر بأداء نفقة مقررة بموجب اتفاق بين الأطراف، ويقصد بالحكم الصادر بأداء

(١) أستاذي د. الأنصاري النيداني، قانون التنفيذ الجبري، ص ٢٢٨.

(٢) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٤٢.

(٣) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ١٨١.

النفقة؛ الحكم الصادر بتقريرها أو زيادتها، وذلك لأن الحكم بزيادة النفقة صورة من صور أدائها، كما أن حكمة النفاذ تتوفر في الحالتين، ولكن الحكم الصادر بإسقاط النفقة لا يجوز شموله بالنفاذ المعجل^(١). ومن ثم يشترط لإعمال هذه الحالة ثلاثة شروط:

- ١- أن يكون الحكم صادرا بأداء نفقة أو زيادتها، وليس بإسقاطها.
- ٢- أن يكون الحكم حكما موضوعيا بأداء النفقة، وليس حكما وقتيا، لشمول هذا الأخير بالنفاذ المعجل طبقا للمادة (٢٨٨) مرافعات.
- ٣- ألا تتعلق النفقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، لشمولها بالنفاذ المعجل القانوني، طبقا للمادة (٦٥) من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

والحكمة من شمول الأحكام الصادرة بأداء النفقات بالنفاذ المعجل، هو التعجيل بحصول المحكوم له على ما يمكنه من مواجهة مطالب الحياة؛ إذ قد تكون النفقة هي المورد الذي يعيش عليه المحكوم له^(٢).

أما الأحكام الصادرة بأداء الأجور والمرتبات؛ فهي تندرج أيضا ضمن أحكام هذا النص، ويقصد بها الأحكام الموضوعية بأداء أجر أو مرتب ناشيء عن علاقة عمل، أيًا كانت طبيعة هذه العلاقة، وأيّا كان القانون الذي ينظمها^(٣).

إلا أنه يجب أن يكون الأجر ناشئا عن علاقة عمل لا عن عقد مقاوله، ويستوي أن يكون العمل خاضعا لقانون العمل أو لأحكام عقد العمل الفردي^(٤)، وقد تكون هذه العلاقة علاقة موظف بجهته الوظيفية خاضعة للقانون العام، وقد تكون علاقة عقدية خاضعة لقانون العمل، وبالتالي فقد يكون من حكم لصالحه بالأجر موظفا أو عاملا أو

(١) د. رمزي سيف، إجراءات التنفيذ، ص ٤٥.

(٢) د. أمينة مصطفى النمر، إجراءات التنفيذ، ص ١٨٢.

(٣) د. أحمد فتحي والي، التنفيذ، ص ٣٤ - د. أحمد ماهر زغلول، ص ١٣٢.

(٤) د. رمزي سيف، ص ٥٢.

خادما أو أجيرا^(١)، فيجوز أن يشمل بالنفاذ المعجل الحكم بأجر خادم من خدم المنازل أو عامل عرضي.

والأحكام التي تشمل بالنفاذ المعجل هي فقط الأحكام الصادرة بالأجر أو المرتب؛ فإذا لم يكن المطلوب أجرا؛ وإنما تعويضا أو معاشا أو مكافأة؛ فلا يجوز شمول الحكم الصادر به بالنفاذ المعجل، كذلك إذا لم يكن مطلوب المدعي في الدعوى التي صدر فيها الحكم ناشئا عن عقد عمل، بل هو مجرد أتعاب مقابل القيام ببعض الأعمال مثل ما يطلبه الطبيب أو المحامي من أتعاب؛ فإنه لا يجوز شمول الحكم أيضا بالنفاذ المعجل إذ لا يسري عليه نص المادة ١/٢٩٠ مرافعات^(٢). ومن ثم يشترط لإعمال هذه الحالة:

- ١- أن يكون الحكم صادرا بأداء أجر أو مرتب، دون غيرها من المستحقات الأخرى.
- ٢- أن يكون الأجر ناشئا عن علاقة العمل، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو القانون الذي ينظمها.

وتبدو غاية المشرع في شمول هذه الأحكام بالنفاذ المعجل؛ أن الأجر أو المرتب المحكوم به، قد يكون المورد الوحيد للمحكوم له، ومن ثم يكون في حاجة ماسة إليه، فإذا تأخر تنفيذ الحكم الصادر به؛ فإن ذلك قد يصيبه بأضرار بالغة.

الحالة الثانية: إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة:

والمقصود بهذه الحالة أن يكون هناك حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي^(٣)، صدر في دعوى سابقة بين نفس الخصوم (ومن ثم يقبل التنفيذ وفقا للقواعد العامة)، ثم بعد ذلك صدر حكم آخر في دعوى أخرى بين نفس الخصوم، لمصلحة المحكوم له

(١) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ١٨٢.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ١٠٥٨/٥.

(٣) أي حكم نهائي غير قابل للطعن فيه بالاستئناف، أو كان قابلا للطعن بالاستئناف وفوت الخصم ميعاد الطعن، أو طعن فيه بالفعل وحكم بعدم قبول الطعن أو ببطلانه أو بتأييد الحكم المطعون فيه.

في الدعوى الأولى وفي مواجهة ذات المحكوم عليه، في موضوع يرتبط بموضوع الدعوى الأولى، ويكون هذا الحكم الثاني ابتدائياً، أي لا يجوز تنفيذه طبقاً للقواعد العامة. وهنا يجوز شمول الحكم الثاني بالنفاذ المعجل الجوازي، وذلك بالاستفادة من صلاحية الحكم الأول^(١).

ومثال ذلك: سبق صدور حكم بالمسئولية عن التعويض بغير تحديد مقداره، ثم صدور حكم لاحق بالتعويض بمبلغ محدد. ومثال ذلك أيضاً: سبق صدور حكم بفسخ عقد بيع، ثم صدور حكم لاحق بتسليم المبيع للبائع^(٢).

هذا إذا كان الحكم السابق حائزاً لقوة الأمر المقضي، والأمر كذلك أيضاً إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة. ويشترط إذا لإعمال هذه الحالة، توفر الشروط الآتية^(٣):

١- أن يكون الحكم السابق من الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري، سواء كان حائزاً لقوة الأمر المقضي أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة، وسواء أكان صادراً من محكمة مدنية أو من محكمة جنائية.

٢- أن يتحد الخصوم في الحكمين؛ اللاحق والسابق، بأن يكون الخصوم في الحكم الثاني، هم ذاتهم الخصوم في الحكم الأول.

٣- أن يكون الحكم الثاني قد استند على ما فصل فيه الحكم السابق، بمعنى أن يكون الحكم السابق هو الأساس القانوني للحكم الثاني، وإن اعتمد هذا الأخير على عناصر واقعية غير الحكم الأول. وبمعنى آخر أن يكون الحكم السابق هو المقدمة الضرورية للحكم الجديد^(٤)، كما في المثالين المشار إليهما.

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٨٨.

(٢) أستاذي د. حامد أبو طالب، مرجع سابق، ص ٧١.

(٣) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ١٦٩-١٧٠.

(٤) أستاذي د. الأنصاري النيداني، قانون التنفيذ الجبري، ص ٢٣٤.

الحالة الثالثة: إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي لم يطعن عليه بالتزوير:

السند الرسمي حسب ما تنص عليه المادة (١٠) من قانون الإثبات المصري، هو السند الذي يحرره موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ويثبت فيه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. ورسمية السند على هذا النحو هي التي ترجح احتمال وجود الحق. والسندات الرسمية هي بذاتها التصرفات والعقود التي يحررها الموظفون العموميون المختصون بضبطها وتوثيقها دون غيرها من المحررات الرسمية^(١).

الأصل أن السند الرسمي واجب النفاذ بذاته بغير حاجة إلى رفع دعوى لاستصدار حكم يبنى على هذا السند، وذلك متى توفرت الشروط القانونية لاعتبار هذا السند الرسمي؛ سندا للتنفيذ بموجبه؛ فإذا لم تتوفر هذه الشروط، كأن يكون الدين الثابت به غير معين المقدار مثلاً أو كان معلقاً على شرط واقف، أو كان محله أداء غير قابل للتنفيذ الجبري؛ فيجب اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بهذا السند. وإذا كان السند محرراً في الخارج؛ فلا يجوز تنفيذه إلا بعد الالتجاء إلى القضاء، والتحقق من توفر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في مصر^(٢).

والحالة التي نحن بصددنا الآن تتعلق بالحكم الصادر بناء على سند رسمي عندما يكون السند بذاته غير قابل للتنفيذ إلا بعد صدور حكم يبنى عليه؛ فرأى المشرع جواز شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الحق الذي يقرره الحكم بصورة لا يحتمل معها أن يلغى في الاستئناف.

ويشترط لشمول الحكم بالنفاذ المعجل في هذه الحالة ثلاثة شروط:

١- أن يكون الأساس الذي اعتمد عليه القاضي في حكمه؛ هو السند الرسمي، بحيث

(١) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ١٨٦.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٨٨- د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ١٠٦٣/٥.

لا تقوم للحكم قائمة إلا به^(١).

٢- ألا يكون السند الرسمي قد طعن فيه بالتزوير؛ لأن الطعن بالتزوير يؤدي إلى التشكيك في السند ويزعزع ما له من قوة في الإثبات، نظرا لاحتمال الحكم بتزويره، ومن ثم انعدام قيمته كورقة رسمية لها حجية في الإثبات، ويكفي لمنع شمول الحكم بالإنفاذ المعجل مجرد الطعن في السند بالتزوير، ولو رفض الطعن بعد ذلك، ولكن لا يكفي مجرد إنكار الخط أو التوقيع أو المنازعة في صحة السند أو في تفسيره^(٢). وإنما

(١) أستاذي د. الأنصاري النيداني، قانون التنفيذ الجبري، ص ٢٣٤.

ولا يثير هذا الشرط صعوبة إذا كان الحكم قد قضى بتنفيذ الالتزام الثابت بالسند الرسمي، وإنما تثار صعوبة في حالة الحكم بفسخ العقد الرسمي، فقد اختلف الفقه بالنسبة للحكم الابتدائي الصادر بفسخ عقد رسمي هل يعتبر منبئيا على هذا العقد الرسمي؟

١- ذهب رأي في الفقه إلى أن الحكم لا يعتبر منبئيا على السند الرسمي، ولا يجوز شموله بالإنفاذ المعجل إلا إذا قضى بتنفيذ الالتزام الثابت فيه. (د. رمزي سيف، ص ٤٧ - د. أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ، ص ٨٨).

٢- وذهب رأي ثان إلى أن الحكم بفسخ العقد يعتبر نتيجة لهذا العقد؛ إذ هو تنفيذ للشرط الفاسخ الوارد في العقد سواء كان شرطا صريحا أو ضمنيا، ولذلك يعتبر الحكم بالفسخ منبئيا على العقد؛ ومن ثم يجوز شموله بالإنفاذ المعجل.

٣- وذهب رأي ثالث إلى وجوب التفرقة بين وجود شرط فاسخ في العقد، وبين تخلفه، فإذا وجد الشرط الفاسخ؛ فإن الحكم بالفسخ يعتبر حكما منبئيا على العقد الرسمي. أما إذا لم يوجد شرط فاسخ صريح في العقد؛ فإن الحكم يكون منشئا لحالة قانونية جديدة ليس مبناها العقد بل مبناها عدم تنفيذه، ولذلك لا يعتبر الحكم منبئيا على العقد الرسمي. (د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ٧٢ - د. عبدالباسط جميعي، مبادئ التنفيذ، ص ١٠٧).

ونتفق مع جمهور الفقه في ترجيح الرأي الأول، استنادا إلى أنه في جميع الأحوال يقوم الفسخ على وقائع خارجة عن العقد ولذلك تنتفي الحكمة من شمول الحكم بالإنفاذ المعجل؛ إذ تكمن هذه الحكمة في أن الأمر المحكوم به أدنى إلى التحقق والثبوت لأن السند الرسمي يشهد بصحته، وهي الوقائع التي تفيد عدم تنفيذ العاقد لالتزامه (د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ١٠٦٥/٥). فالحكم الابتدائي الذي يجوز شموله بالإنفاذ المعجل ويبنى على عقد رسمي، هو ذلك الحكم الذي يصدر بتنفيذ الأداءات التي يتضمنها هذا العقد، أما الحكم بالفسخ فلا يجوز تنفيذه معجلا؛ لأن الفسخ في حقيقة الأمر لا يعتبر تنفيذا للأداءات التي يتضمنها هذا العقد. (د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ١٨٩).

(٢) د. فتحي والي، التنفيذ، ص ٦٩.

يجب أن يكون قد تم الطعن بالتزوير في هذا السند فعلا ووفقا للإجراءات القانونية المقررة في قانون الإثبات للطعن بتزوير المحررات الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان قد طعن في السند بالتزوير، ثم حكمت المحكمة بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه، وفقا للمادة (٤٩) إثبات؛ أو كان مدعي التزوير قد نزل عن ادعائه، أو حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى التزوير؛ فلا يكون للإدعاء بالتزوير أثر ويجوز شمول الحكم بالتنفيذ المعجل^(١).

٣- أن يكون المحكوم عليه طرفا في هذا السند الرسمي، ويعتبر الشخص طرفا في السند الرسمي بالمعنى الواسع؛ إذا كان طرفا فيه بنفسه، أو كان خلفا لأحد أطرافه خلافة عامة أو خاصة^(٢).

الحالة الرابعة: إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام:

والإقرار وفقا لتعريف المشرع؛ هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة^(٣). فهو اعتراف من المقر بإرادته المنفردة بحق عليه لصالح المقر له، بما يعفي هذا الأخير من عبء إثباته باعتباره يمثل تسليما له به^(٤).

ولأن الإقرار من أقوى الأدلة مدنيا؛ فإن له في المجال الإجرائي ذات الأهمية؛ إذ يجعله المشرع صالحا لرفع الحكم الابتدائي -الضعيف في الأصل- غير الصالح للتنفيذ الجبري، إلى مصاف الأحكام القوية؛ بأن يجعل الحكم الابتدائي قابلا للتنفيذ طالما بني عليه هذا الحكم^(٥).

(١) أستاذي د. الأنصاري النيداني، قانون التنفيذ الجبري، ص ٢٣٧.

(٢) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ١٧٣.

(٣) المادة (١٠٣) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م، والمعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧م.

(٤) د. همام محمد زهران: أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، ٢٠٠٢م، ص ٣٣٠.

(٥) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٤٢.

والمقصود بإقرار المحكوم عليه بنشأة الالتزام وفقا لهذه الحالة، أن يكون قد أقر بأصل الالتزام، أي بنشأة الالتزام صحيحا، أي كان مصدر هذا الالتزام، سواء كان تعاقديا أو غير تعاقدى، وأيضا كان الدليل عليه سواء كان كتابيا أو غير كتابي، ويجب أن يشتمل الإقرار على قيام الالتزام وعلى صحته أي يجب أن يقر المحكوم عليه بأن أصل الالتزام قد نشأ صحيحا^(١).

فإذا أقر المحكوم عليه أمام المحكمة شفاهة أو كتابة في مذكرة قدمت إليها، بنشأة التزامه فإن الحكم الصادر بناء على هذا الإقرار يجوز شموله بالنفاذ المعجل لقوته، حتى وإن نازع المحكوم عليه في بقاء هذا الالتزام لأي سبب من الأسباب، كما لو ادعى أن الالتزام انقضى بالوفاء أو المقاصة أو التقادم مثلا، فيكفي لقيام هذه الحالة، أن يقر المحكوم عليه بأمرين؛ نشأة الالتزام، وصحته، حتى وإن نازع بعد في بقاءه.

ولا نعني بذلك أن يكون المحكوم عليه مقرا بما ادعاه خصمه من طلبات، لأن مثل هذا الإقرار يعد قبولا للحكم، ويحول دون الطعن فيه، فيكون بذلك قابلا للتنفيذ وفقا للقواعد العامة دون حاجة إلى شموله بالنفاذ المعجل. كذلك لا يندرج في هذه الحالة اعتراف المحكوم عليه بصحة ورقة مدعى صدورها منه؛ إذا نازع في صحة الالتزام الوارد بها، كالادعاء ببطلانه للخطأ أو الإكراه أو غير ذلك^(٢). ومن باب أولى إذا أنكر الخصم الورقة العرفية ذاتها؛ فلا مجال للقول بتوفر سبب للحكم بالنفاذ المعجل.

وبناء على ما سلف يمكن القول إن إقرار المحكوم عليه بنشأة الالتزام المدعى به يعد سببا لجواز شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وفقا لسلطة المحكمة التقديرية في هذا الشأن. ولا يشترط أن يكون هذا الإقرار قضائيا قد تم أمام المحكمة؛ وإنما يجوز شمول الحكم بالنفاذ المعجل، ولو كان الإقرار تم خارج القضاء، لأن النص جاء عاما ولم يشترط أن يكون الإقرار قضائيا^(٣).

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٥/١٠٦٦.

(٢) د. رمزي سيف، التنفيذ، ص٤٩.

(٣) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص١٨٤.

ومن ثم فإن هذه الحالة توجب توفر شرطين للحكم بالنفاذ المعجل، هما :

- ١- إقرار المحكوم عليه بنشأة الالتزام المدعى به صحيحا.
- ٢- استناد الحكم إلى هذا الإقرار بشكل أساسي للحكم بالنفاذ المعجل.

الحالة الخامسة: إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفي لم يجده المحكوم عليه:

وتتشابه هذه الحالة مع الحالة مع الحالة الثالثة (استناد الحكم إلى سند رسمي)، وتختلف عنها في طبيعة السند، ووسيلة الاعتراض عليه، فالسند هنا هو سند عرفي وليس رسمي، والاعتراض عليه يكون بجده أو إنكاره، وليس الطعن بتزويره. ووفقا لنص المادة (٢٩) إثبات؛ فإن "إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية".

ولذلك يجوز لمن يحتج عليه بورقة عرفية أن يختار بين إنكار توقيعها أو الإدعاء بتزويرها، والإنكار ليس إلا اتخاذ موقف سلبي من الورقة، وبالتالي ليس على المنكر عبء الإثبات؛ وإنما يكفيه الإنكار مع بيان الأسباب، ويقع عبء الإثبات إذا على المتمسك بالورقة^(١).

وتفترض الحالة التي نحن بصدها الآن، استناد الحكم إلى سند عرفي، وعدم جحد هذا السند أو إنكاره من المحكوم عليه به، ومن ثم فليس للمحكمة أن تأمر بالنفاذ المعجل في هذه الحالة إلا إذا توفرت الشروط الآتية:

- ١- أن يستند الحكم إلى سند عرفي، والسند العرفي أو المحررات العرفية، هي التي يحررها أصحاب الشأن بغير أن يتدخل موظف عام في تحريرها. ويجب أن يكون هذا السند مثبتا للالتزام المدعى به، وأن يكون المحكوم عليه أو سلفه طرفا فيه، وأن يستند الحكم على هذا السند؛ فإن لم يتحقق ذلك؛ بأن كان السند غير مثبت للالتزام، أو لم يكن المحكوم عليه طرفا فيه، أو لم تبين المحكمة حكمها عليه؛ وإنما

(١) د. همام محمد زهران، أصول الإثبات، ص ٣١٤.

على أدلة أخرى؛ فإن شرط إعمال هذه الحالة لا يكون متوفراً، ولا يجوز شمول الحكم بالنفاذ المعجل استناداً إلى هذا السبب^(١).

٢- ألا يجحد المحكوم عليه السند الصادر منه أو من سلفه؛ إذ الجحود يؤدي إلى هدم قوة الورقة العرفية في الإثبات، ومن ثم لا يكون هناك مبرر للنفاذ المعجل^(٢).

ويتحقق جحد المستند العرفي بإنكار المحكوم عليه الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة على الورقة العرفية، وإذا كان المحكوم عليه خلفاً عاماً أو خاصاً، فيكفي لتحقيق الجحود من جانبه أن يحلف يمينا أنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هي لمن تلقى عن الحق^(٣).

وتجدر الإشارة إلى أن السند العرفي لا يعتبر مجحوداً إذا كان قد حكم نهائياً بصحته في دعوى سابقة بإنكاره أو بالادعاء بتزويره، كما لا يعتبر مجحوداً أيضاً إذا كان التوقيع فيه مصدقاً عليه؛ إذ لا أثر لإنكار المحكوم عليه في مثل هذه الحالات على قوة السند العرفي في الإثبات^(٤).

الحالة السادسة: إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به:

وتفترض هذه الحالة أن يكون طالب التنفيذ قد حصل على سند تنفيذي (أيا كان نوعه)، وبدأ في التنفيذ اقتضاء له، ثم ثارت منازعة موضوعية في التنفيذ، ترتب عليها وقف إجراءات التنفيذ التي بدأت؛ ثم يصدر الحكم في المنازعة لمصلحة طالب التنفيذ، فيجوز للقاضي حينئذ شمول الحكم الصادر في المنازعة بالنفاذ المعجل، والاستمرار في إجراءات التنفيذ التي وقفت، يستوي في ذلك أن يكون الاختصاص بالمنازعة لقاضي التنفيذ أو لمحكمة أخرى، ما يستوي أن يكون الحكم، قد صدر برفض الدعوى، أو عدم قبولها أو عدم الاختصاص بها أو ببطلان صحتها أو اعتبارها كأن لم

(١) د. أحمد أبو الوفاء؛ إجراءات التنفيذ، ص ٩١ - د. عيد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ١٧٦.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ١٠٦٨/٥.

(٣) وذلك وفقاً لما قرره المادة (١٤) من قانون الإثبات.

(٤) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ١٠٦٨/٥.

تكن^(١).

ومثال ذلك: في التنفيذ على عقار مثلا يحدث اعتراض على قائمة شروط البيع، ويؤدي هذا الاعتراض إلى وقف التنفيذ، ثم يصدر حكم فاصل في الاعتراض، ويكون هذا الحكم قابل للطعن فيه بالاستئناف باعتباره حكما ابتدائيا، فهنا يجوز شموله بالنفاذ المعجل إذا طالب ذلك صاحب المصلحة^(٢).

وقد قصد المشرع من النص على هذه الحالة؛ تمكين طالب التنفيذ من تفادي الآثار المترتبة على مشاكسة خصمه، الذي يسعى إلى وقف التنفيذ بإقامة منازعات غير جديده، فمنح المحكمة سلطة تقديرية بحسب ما يستبين لها من ظروف كل حالة في الأمر بالنفاذ المعجل للحكم الصادر في هذه المنازعات^(٣).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة تنطبق فقط على الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية، أما الأحكام الصادرة في المنازعات الوقتية؛ فهي أحكام مستعجلة وتكون مشمولة بالنفاذ المعجل القانوني دائما وفقا للمادة (٢٨٨) مرافعات.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المشرع استثنى دعوى استرداد المنقولات المحجوزة، من الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية المشمولة بالنفاذ المعجل القضائي، وخصها بحكم خاص، جعل النفاذ المعجل فيها وجوبيا بقوة القانون، فنص في المادة (٣٩٥) على أنه "يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة ٩٩، أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، أو حكم باعتبارها كذلك، كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف".

(١) أستاذي د. الأنصاري النيداني، قانون التنفيذ الجبري، ص ٢٤١.

(٢) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ١٨٦.

(٣) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٩٣.

الحالة السابعة: إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له:

هذه الحالة تجب جميع الحالات السابقة المقررة في المادة ٢٩٠، ويجب على القضاء أن يتحرز عند إعمالها، وألا يتوسع في تطبيقها^(١)، وقد سبقت الإشارة إلى أن بعض الفقه^(٢) ذهب إلى القول بأن هذه الحالة كان يمكن الاكتفاء بها عن باقي حالات النفاذ المعجل القضائي، بحيث يترك للقاضي تقدير مدى الحاجة إلى شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وقد استحدثت المشرع هذه الحالة في القانون الحالي، وصاغها صياغة مرنة، مستهدفاً بها مواجهة كل حالة يرى القاضي فيها أن تأخير التنفيذ يترتب عليه ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له، واستغنى بهذا النص عن إيراد بعض الحالات التي كان يوردها القانون القديم، كحالة إجراء الإصلاحات العاجلة، ودعاوى الحيازة، وبذا أزال المشرع الجمود الذي كان يغل يد القاضي في ظل القانون القديم^(٣).

ويمثل النص على هذه الحالة معياراً عاماً يخول القاضي سلطة تقديرية في أن يأمر بالتنفيذ المعجل في كل حالة تقتضي فيها الظروف ذلك^(٤)، والضرر الجسيم يظهر من توفر عنصر الاستعجال في وقائع الطلب، هذا الاستعجال الذي يحاول الطالب درء خطره، بطلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وهذا النفاذ المعجل يحقق للمحكوم له حماية وقتية انتظارا لصدور الحكم الموضوعي^(٥).

ولابد في الضرر الذي يبرر الأمر بالنفاذ المعجل وفقاً لهذه الحالة؛ أن يكون جسيماً فلا يكفي الضرر العادي ولو كان محققاً للأمر بالنفاذ المعجل، ولكن التساؤل الذي يثور في هذا الشأن؛ ما المقصود بالضرر الجسيم بمصلحة المحكوم له، والذي

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٦٤.

(٢) د. عبدالباسط جميعي، المبادئ العامة في التنفيذ، ص ٨٧.

(٣) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ١٠٥٨/٥.

(٤) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ١٨٣.

(٥) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ١٨٠.

يترتب على خشية وقوعه؛ الأمر بالنفاذ المعجل؟

الحقيقة أن المشرع لم يضع معياراً أو ضابطاً للضرر الجسيم هنا؛ وإنما جعل الضرر الجسيم ذاته ضابطاً لشمول الحكم بالنفاذ المعجل، ومن ثم نتفق مع الفقه^(١) القانوني، في أن تقدير جسامة الضرر مسألة نسبية تخضع لتقدير المحكمة، تستخلصه من ظروف كل حالة على حدة، فما قد يعد ضرراً جسيماً في دعوى قد لا يعد كذلك في أخرى، وهكذا، والمحكمة في ذلك تبحث في الظروف الموضوعية والشخصية في كل حالة لتستخلص منها احتمال جسامة الضرر، وقد يكون من صور ذلك، أن يكون المحكوم عليه مهدداً بخطر الإعسار أو الإفلاس، أو غير ذلك.

والقاضي في سبيل بحثه عن جسامة الضرر الذي يصيب المحكوم له جراء تأخير التنفيذ، يجب عليه أن يوازن بين ما يصيب المحكوم له من ضرر إذا لم ينفذ الحكم نفاذاً معجلاً، وما يصيب المحكوم عليه من ضرر نتيجة التنفيذ المعجل للحكم الابتدائي، وفي سبيل ذلك عليه الاستعانة بضابط آخر لا يقل أهمية، وهو مدى احتمال تأييد الحكم إذا طعن فيه بالاستئناف؛ فإذا ترجح لديه تأييد الحكم، وإصابة المحكوم له بضرر نتيجة تأخير التنفيذ، فله أن يأمر بالنفاذ المعجل، وإذا بدا له أن الحكم قد يلغى في الاستئناف، فله ألا يأمر بالنفاذ المعجل.

ونحن نرى أنه يجب على المحكمة تسبيب حكمها بالنفاذ المعجل تسبيبا كافياً، بأن تبين الظروف الواقعية التي تبرر حدوث الضرر الجسيم، وعدم الاكتفاء بالقول بأن تأخير التنفيذ يترتب عليه ضرر جسيم؛ فإن هي فعلت فإنها تكون قد استندت إلى أسباب عامة لا تصلح لتسبيب أمرها بالنفاذ المعجل^(٢).

حكم الكفالة في حالات النفاذ المعجل القضائي:

انتهينا من بيان الحالات التي تملك المحكمة فيها سلطة تقديرية في شمول حكمها

(١) د. رمزي سيف، التنفيذ، ص ٥٢ - د. وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للتنفيذ، ص ٧٩.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ١٠٦٠/٥.

بالنفاذ المعجل وفقا لما قرره المادة (٢٩٠) مرافعات، ويجب أن نشير إلى أن المادة ذاتها، أعطت للمحكمة إلى جانب هذه السلطة، سلطة الأمر بالكفالة أو عدم الأمر بها في كل حالة من هذه الحالات، وبحسب ما تستبينه من ظروف كل حالة على حدة، فقد تأمر بالكفالة في دعوى، ولا تأمر بها في دعوى مماثلة، لظروف ترى فيها الكفالة لازمة هنا، وغير ضرورية هناك. ومن ثم فالكفالة جوازية للمحكمة في جميع حالات النفاذ المعجل.

الفرع الثالث

ضمانات المحكوم عليه في النفاذ المعجل

هذه الضمانات منها ما يهدف إلى الحماية قبل إجراء التنفيذ، كتعليق التنفيذ على تقديم كفالة، ومنها ما يهدف إلى وقف هذا التنفيذ كليا، ومنها ما يهدف إلى إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ. هذا فضلا عن حق المحكوم عليه في التظلم من وصف الحكم، ولكننا لا نتفق مع من يرى التظلم الوصفي مجرد ضمانة للمحكوم عليه في النفاذ المعجل، إذ هو بهذه الصورة يكون حقا للمحكوم عليه وحده، والأمر ليس كذلك؛ فهو حق للمحكوم له كما هو حق للمحكوم عليه، ومن ثم فهو طريق طعن خاص للتظلم من الوصف الخطأ للحكم القضائي، ولذا نتناوله في مطلب مستقل بعد الانتهاء من بيان ضمانات المحكوم عليه في النفاذ المعجل.

ونتناول ضمانات المحكوم عليه في النفاذ المعجل، في ثلاثة أغصان، نتحدث في أولها عن الكفالة، وفي الثاني عن طلب وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف، وفي الثالث إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ.

الفصل الأول

إلزام المحكوم له بتقديم كفالة

أولا: المقصود بالكفالة:

الكفالة في حالات النفاذ المعجل جميعها -باستثناء حالة واحدة- جوازية للمحكمة، فلها في حالات النفاذ المعجل القانوني أو القضائي؛ أن تأمر بتقديم الكفالة، ولها أن

تعفي المحكوم له منها رغم النفاذ المعجل للحكم، بحسب ما تراه من ظروف كل حالة أو كل قضية، وذلك فيما عدا حالة واحدة لا تملك المحكمة إعفاء المحكوم له من تقديم الكفالة فيها، وهي الأحكام الصادرة في المواد التجارية؛ إذ الكفالة فيها مقررّة وجوباً بنص القانون. وإذا أمرت المحكمة بتعليق التنفيذ على تقديم كفالة، أو كانت الكفالة مقررّة بنص القانون؛ فيجب تقديمها قبل البدء في التنفيذ؛ وإلا كان باطلاً^(١). وتهدف الكفالة إلى ضمان مخاطر التنفيذ المعجل في حالات لا يكون بإمكان المحكوم له فيها إعادة الحال إلى ما كانت عليه، إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه^(٢).

وبهذا المفهوم يمكن تعريف الكفالة بأنها؛ وسيلة علاجية يستخدمها المشرع لضمان إعادة الحال إلى ما كانت عليه، إذا تغيرت الظروف؛ بأن ألغي الحكم من محكمة الاستئناف بعد أن نفذ عاجلاً، وتبين أن المحكوم له المنفذ عاجلاً معسراً. وهي بهذا المعنى وسيلة علاجية، لا تمنع التنفيذ المعجل؛ وإنما تدفع القاضي للحكم به، مطمئناً إلى حماية حقوق المحكوم عليه في مواجهة المحكوم له الذي قد لا يتمكن من إعادة الحال إلى ما كانت عليه^(٣).

ثانياً: مدى الإلزام بتقديم الكفالة:

الكفالة قد تكون وجوبية ومقررّة بنص القانون، وقد تكون جوازية ومتروكة لسلطة المحكمة التقديرية في الأمر بها أو الإعفاء منها، وذلك على النحو الآتي:

١ - الكفالة الواجبة بقوة القانون:

أوجب المشرع تقديم الكفالة في حالة واحدة فقط من حالات النفاذ المعجل، وذلك في الأحكام الصادرة في المواد التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة (٢٨٩)، فيجب تقديم الكفالة في هذه الأحكام، سواء أمرت المحكمة بها في الحكم أو لم تأمر بها؛ لأنها مقررّة وجوباً بقوة القانون، ولا تملك المحكمة إعفاء المحكوم عليه من تقديمها.

(١) أستاذي د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٧٨.

(٢) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ٢٠٦.

(٣) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٨٠-٨١.

أما حالات النفاذ المعجل القانوني الأخرى، فإن الأمر بالكفالة متروك لسلطة المحكمة التقديرية (مادة ٢٨٨).

٢- الكفالة الجوازية:

فيما عدا الحالة المشار إليها سابقاً؛ فإن الحكم بالكفالة يكون جوازيًا ومتروكاً لسلطة المحكمة التقديرية في الحالات الأخرى، سواء كان النفاذ المعجل مقرراً بقوة القانون، كما هو الحال في الأحكام المستعجلة والأوامر على العرائض (مادة ٢٨٨)، أو كان الحكم بالنفاذ المعجل متروكاً للسلطة التقديرية للمحكمة، كما هو الحال في حالات النفاذ المعجل القضائي (مادة ٢٩٠)؛ إذ تملك المحكمة في جميع هذه الحالات سلطة الأمر بالكفالة أو الإعفاء منها، بحسب ما يتبين لها في كل دعوى.

وسلطة المحكمة في هذا الشأن تمتد إلى الأمر بالكفالة من تلقاء نفسها، ولو لم يطلبها المحكوم عليه، ولا يعد ذلك قضاءً من المحكمة بما لم يطلبه الخصوم، وذلك لأن طلب الخصم من المحكمة شمول الحكم بالنفاذ المعجل، يمنحها سلطة قبول الطلب كاملاً أو منتقاصاً، فضلاً عن أنه من غير المعقول أن يفترض الخصم أنه سيكون محكوماً عليه، ويطلب سلفاً إلزام خصمه بتقديم كفالة في حالة شمول الحكم بالنفاذ المعجل، حتى لا يفصح عن ضعف موقفه^(١).

ثالثاً: صور الكفالة أو طرق تقديمها:

١- تقديم كفيل مقتدر:

وذلك بأن يأتي المحكوم له بشخص آخر يضم ذمته المالية إلى ذمته هو مما يؤدي إلى تقوية الضمان الذي يحصل عليه المحكوم عليه. فالكفيل هو الشخص الذي يقبل أن يتعهد في كامل ذمته المالية بأن يفي بما يتحمل به المحكوم له في حالة إلغاء الحكم الذي ينفذ معجلاً^(٢).

(١) د. أمينة مصطفى النمر، إجراءات التنفيذ، ص ١٨٨- د. فتحي والي، التنفيذ، ص ٨٠.

(٢) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٨٢- د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ٧٩- د. عيد محمد

القصاص، ص ٢١٢- د. عزمي عبدالفتاح، قواعد التنفيذ، ص ٢٠٢- د. وجدي راغب فهمي، ص ٨٤.

ولم يشترط المشرع في الكفيل سوى أن يكون مقتدرا؛ أي موسرا، فلا يجب أن يكون رجلا، بل يجوز تقديم كفيل مقتدر رجلا كان أو امرأة، شخصا طبيعيا أم اعتباريا، مصريا كان أم أجنبيا، مادام موطنه في مصر^(١)، ولا يغني اقتدار المدين أو يساره عن هذا الشرط، فلا يجوز أن يقدم نفسه كفيلًا؛ وإنما لابد أن يقدم كفيلًا مقتدرا^(٢).

٢- إيداع ما يكفي من النقود أو الأوراق المالية خزانة المحكمة:

وذلك بأن يقوم المحكوم له بإيداع مبلغ من النقود خزانة المحكمة، أو يودع أوراقا مالية أخرى كالأسهم والسندات، فكأن المحكوم عليه في هذه الصورة يقوم بوضع "وديعة نقدية" خزانة المحكمة كضمان لإعادة الحال في حالة إلغاء الحكم المشمول بالإنفاذ المعجل، ولا يشترط أن يكون هذا المبلغ مساويا لقيمة المحكوم به؛ وإنما يشترط أن يكون كافيا لإعادة الحال إلى ما كانت عليه، إذ أن معنى "مافيه الكفاية" كما وردت في النص؛ ما يكفي لتعويض الضرر الذي يصيب المحكوم عليه من جراء التنفيذ، وذلك إذا ما تحددت نهائيا مراكز الخصوم بعد صدور الحكم النهائي. ويعيب هذا النظام كما هو واضح أنه يؤدي إلى تجميد المبالغ المودعة خزانة المحكمة وتعطيل الاستفادة منها طوال الفترة اللازمة لصيرورة الحكم نهائيا أو لصدور الحكم النهائي^(٣).

٣- إيداع حصيلة التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم المحكوم به إلى حارس مقتدر:

وفي هذه الصورة لا يحصل المحكوم له على ما ينتج من التنفيذ؛ وإنما يودعه خزانة المحكمة، إذا كان مبلغا نقديا، أو يسلمه إلى حارس مقتدر، إذا كان منقولًا، وقد يبدوا من هذه الحالة عدم انتفاع المحكوم له من التنفيذ المعجل للحكم؛ إلا أنه لا شك أن هذه الوسيلة تكون نافعة له، لأنه يضمن على الأقل ألا يقوم المدين بتهريب المحكوم به^(٤).

(١) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٨٢.

(٢) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني، قانون التنفيذ الجبري، ص ٢٥٣.

(٣) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٨٣ - أستاذي د. الأنصاري النيداني، قانون التنفيذ الجبري،

ص ٢٥٤ - د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٢٠٢.

(٤) الإشارة السابقة.

رابعاً: إجراءات تقديم الكفالة:

الحق في اختيار نوع الكفالة من إحدى الصور التي بينهاها، مقرر للمحكوم له؛ بحسب ما يناسبه؛ فلا يجوز للمحكمة أن تجبره على صورة معينة من صور الكفالة، ولكن المشرع أوجب عليه في المادة (٢٩٤) أن يعلن المحكوم عليه بصورة الكفالة التي اختارها، وأن يكون هذا الإعلان على يد محضر بورقة مستقلة، أو ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء. وعليه أن يبين في ورقة الإعلان موطناً مختاراً تعلن له فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة^(١).

وهدف الإعلان أن يعلم المحكوم عليه بالكفالة التي تضمن حقه في حالة إلغاء النفاذ المعجل وحتى يستطيع أن ينازع في كفاية هذه الكفالة.

خامساً: دعوى المنازعة في كفاية الكفالة:

وهي الدعوى التي يرفعها ذي الشأن (المحكوم عليه) إذا رأى أن الكفالة التي اختار طالب التنفيذ تقديمها غير كافية، فيقوم برفع هذه الدعوى للمنازعة في كفاية الكفالة؛ كان يعترض على اقتدار الكفيل، أو ينازع في كفاية المبالغ أو الأوراق التي اختار المحكوم له إيداعها خزانة المحكمة، أو يعترض على اقتدار الحارس الذي يسلم إليه الشيء المحكوم به (مادة ٢٩٥ مرافعات).

وتختص بنظر هذه الدعوى محكمة التنفيذ المختصة محلياً وفقاً للمادة (٢٧٦) مرافعات^(٢)، ويجب رفع هذه الدعوى في خلال ثلاثة أيام من إعلان المحكوم له الخيار

وأتفق مع ما ذهب إليه بعض الفقه من أنه كان يجب اشتراط الأمانة في الحارس، وليس الاقتدار؛ لأن مهمة الحارس تنحصر في القيام بحراسة الشيء ورعايته والمحافظة عليه. (د. أحمد هندي، ص ٨٤).

(١) ولا يترتب البطلان على إغفال بيان الموطن المختار في الإعلان؛ وإنما يعمل بالقاعدة المقررة في المادة (١/١٢) مرافعات، وهي جواز الإعلان في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلان بها في الموطن المختار.

(٢) والتي يجري نصها على أنه "يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المدين في دائرتها، وفي حيز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجور لديه، ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها؛ فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها".

بالكفالة، ولا يكفي لرفع الدعوى وإيداع صحيفتها واعتبارها مقامة إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة؛ وإنما يجب تكليف المدعى عليه بالحضور أمام قاضي التنفيذ خلال الثلاثة أيام المذكورة، والحكم الصادر في هذه المنازعة يكون نهائيا غير قابل للطعن فيه.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز التنفيذ إلا بعد الحكم في هذه الدعوى إذا رفعت، أو بعد مضي الميعاد المقرر لرفعها دون أن ترفع.

فإذا انقضى الميعاد دون رفع الدعوى، أو رفعت وحكم برفضها؛ أخذ على الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة، أو التعهد على الحارس بقبول الحراسة، وبعد هذا التعهد سندا تنفيذا في مواجهته بالنسبة للالتزامات المترتبة على تعهده.

الفصل الثاني

وقف النفاذ المعجل من محكمة الاستئناف

قنن المشرع سلطة محكمة الاستئناف في الأمر بوقف النفاذ المعجل، في المادة (٢٩٢) بنصها على أنه "يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له".

نطاق سلطة المحكمة في الأمر بوقف التنفيذ المعجل وحكمته:

بداية نؤكد على أن حكم هذه المادة يسري بالنسبة للأحكام أو الأوامر المشمولة بالنفاذ المعجل، سواء أكان الأمر على عريضة أو كان أمر أداء، فيجوز كذلك طلب وقف النفاذ المعجل من المحكمة التي تنتظر التظلم من هذا الأمر. هذا ومن الملاحظ أن نص المادة المذكور لم يفرق بين أي من حالات النفاذ المعجل، سواء القانوني أو القضائي، فمن ثم فإن لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل ولو كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل الوجوبي بقوة القانون، وفي أي حالة من حالات النفاذ

المعجل القانوني.

وتبدو الحكمة من قبول طلب الوقف في الاستئناف؛ في أن الفصل في الاستئناف الأصلي قد يستغرق وقتاً طويلاً، وقد يصدر حكم المحكمة الاستئنافية بعد مرور هذا الوقت بإلغاء الحكم المستأنف بعد أن يكون نفذ تنفيذاً معجلاً في حالات يصعب على المحكوم له إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا تم إلغاء الحكم المشمول بالإنفاذ المعجل^(١).

الطبيعة القانونية لوقف التنفيذ المعجل:

يعد هذا الوقف صورة من صور الحماية الوقتية، لأن محكمة الاستئناف حين تنتظر طلب الوقف، لا تفحص خطأ الحكم المشمول بالإنفاذ المعجل؛ وإنما تنتظر في مدى الضرر الذي يصيب المحكوم عليه، ومدى احتمال إلغاء الحكم المطعون فيه^(٢).

شروط وقف التنفيذ المعجل من محكمة الاستئناف:

تضمنت المادة (٢٩٢) الشروط اللازمة للحكم بوقف التنفيذ المعجل من محكمة الاستئناف، وهذه الشروط هي:

١- أن يطلب المحكوم له وقف تنفيذ الحكم من المحكمة التي تنتظر الاستئناف:

ويقتضي هذا الشرط أن يقوم المحكوم عليه بتقديم طلب إلى المحكمة التي تنتظر الاستئناف على الحكم المشمول بالإنفاذ المعجل بوقف هذا التنفيذ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بالوقف من تلقاء نفسها؛ لأن المحكمة لا تقضي إلا بما يطلبه الخصوم، ولا يكفي مجرد الطلب من المحكمة مجرداً عن طعن في الحكم، بلا لابد من أن يكون طلب الوقف تابعاً للطعن بالاستئناف، بمعنى أن يكون الخصم قد طعن بالاستئناف فعلاً وقدم طلب وقف التنفيذ تبعاً لهذا الطعن، أما إذا قدم الطلب مستقلاً في غير طعن؛ فإن على المحكمة أن تقضي برفضه.

(١) د. وجدي راغب فهمي، النظرية العامة في التنفيذ، ص ٩٦.

(٢) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ١٩٠ - ١٩١.

ولم يشترط المشرع أن يرد طلب الوقف في صحيفة الطعن بالاستئناف، كما هو الحال في الطلب من محكمة النقض؛ وإنما يجوز أن يرد مستقلاً بشرط أن يكون هناك طعن صحيح على الحكم، فإذا كان الطعن بالاستئناف باطلاً؛ فإن على المحكمة أن تمتنع عن الفصل في طلب الوقف^(١). ولم يشترط القانون ميعاداً معيناً لتقديم طلب وقف التنفيذ، ومن ثم نميل إلى القول بجواز تقديمه في أي وقت ولو بعد الميعاد المقرر للطعن، وقبل إقفال باب المرافعة، كما يجوز تكرار تقديم الطلب بأسباب جديدة ما دام الاستئناف قائماً^(٢).

٢- أن يقدم الطلب قبل تمام التنفيذ:

وهذا شرط بديهي يستفاد من طبيعة وقف التنفيذ وما يهدف إليه من حماية وقتية؛ فإذا كان التنفيذ قد تم؛ فلا يكون للطلب محلاً يرد عليه ولا يمكن قبوله، أما إذا كان التنفيذ قد تم جزئياً؛ فإن الوقف يسري على ما لم يتم من التنفيذ، ونؤيد القول بأن حكم الوقف ينسحب على ما تم من إجراءات التنفيذ بعد تقديم الطلب، بحيث يجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه وقت تقديم الطلب وليس وقت الحكم^(٣).

٣- أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم بالمحكوم عليه:

فلا يكفي الضرر العادي للحكم بوقف النفاذ المعجل؛ وإنما يشترط أن يكون هذا الضرر جسيماً، وفقاً لمفهوم الضرر الجسيم الذي تحدثنا عنه، ولم يشترط المشرع في هذا الضرر الجسيم أن يكون مما يتعذر تداركه، وإنما يكفي أن يكون الضرر جسيماً بحيث يتجاوز ما ينبغي أن يتحمله المحكوم عليه، ويرجع في تقدير جسامة الضرر إلى ظروف كل حالة على حدة بحسب ما تتبينه المحكمة من الوقائع المعروضة.

٤- أن تكون أسباب الطعن في الحكم مما يترجح معها إلغاؤه:

فلا تكفي الخشية من الضرر الجسيم لتبرير الحكم بوقف التنفيذ المعجل؛ وإنما لابد

(١) د. وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للتنفيذ، ص ٩٨.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ١٠٨٣/٥.

(٣) د. رمزي سيف، التنفيذ، ص ٣٦.

أن يترجح لدى المحكمة مما قدم إليها من أسباب؛ أن الحكم سيتم إلغاؤه، فالحكم في طلب وقف التنفيذ، هو حكم وقتي ولا بد من توفر شروط الحماية الوقتية لإجابته، وهي الاستعجال، ورجحان وجود الحق.

خامسا: الحكم في طلب وقف النفاذ المعجل وضمانات المحكوم له:

الحكم في طلب وقف النفاذ المعجل حكم وقتي، لا يحوز حجية أمام المحكمة التي أصدرته، ولا يقيدھا عند الفصل في الموضوع، فلھا أن تعدل عنه عند الفصل في الاستئناف، وللمحكمة في شأن هذا الطلب سلطة تقديرية كاملة بحسب ما يترجح لديها، فلھا أن ترفض الطلب، ولھا أن تقبله، كليا أو جزئيا، وباعتبار هذا الحكم حكما وقتيا؛ فإنه يجوز الطعن فيه على استقلال وفقا للمادة (٢١٢) مرافعات، وقبل صدور الحكم الفاصل في الاستئناف.

هذا وقد استحدثت المشرع بالفقرة الثانية للمادة (٢٩٢) مقتضاه منح المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر المحكوم عليه الذي استجابت لطلبه بوقف التنفيذ، بتقديم كفالة، أو بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم عليه، وهي سلطة جوازية للمحكمة، فلھا أن تأمر بها، أو أن تحكم بوقف التنفيذ بلا كفالة.

الفصل الثالث

إعادة الحال إلى ما كانت عليه وجبر الضرر الناتج عن الخطأ في التنفيذ

وترتبط هذه الضمانة بحالة إجراء التنفيذ المعجل للحكم، بمعنى أن يكون المحكوم له قد قام بالفعل بتنفيذ الحكم، ثم صدر حكم الاستئناف وألغى الحكم المشمول بالنفاذ المعجل بعد تنفيذه، فهنا يجب على المحكوم عليه أن يقوم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وذلك برد ما تم قبضه؛ إذا كان التنفيذ بقبض مال، أو فتح نافذة كان قد تم سدها، أو إغلاق نافذة تم فتحها، كما تلغى التأمينات التي يكون المحكوم له قد حصل عليها بموجب الحكم الملغى^(١).

(١) د. أحمد ماهر زغلول، آثار إلغاء الأحكام بعد تنفيذها، دار النهضة العربية، ١٩٩٢م، ص ٣٢ - د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٦٣.

على أنه قد لا يكفي إعادة الحال إلى ما كانت عليه، لجبر الضرر الذي أصاب المحكوم عليه جراء التنفيذ المعجل، فقد يفوق الضرر المادي أو المعنوي الذي أصابه قيمة الحق الذي جرى التنفيذ لاقتضائه، وهنا يثور التساؤل عن مدى مسؤولية المحكوم له عن تعويض الضرر الذي أصاب المحكوم عليه.

وبداية تجب التفرقة بين أمرين؛ أولهما: إذا كان المحكوم له سيء النية في إجراء التنفيذ المعجل؛ فإنه يسأل عن الضرر الذي أصاب المحكوم عليه، لأنه تسف في استعمال هذا الحق ولم يكن حسن النية، وثانيهما: إذا كان المحكوم عليه حسن النية في إجراء التنفيذ المعجل؛ فإن للفقهاء المسألة رأيين^(١):

الرأي الأول: أن المحكوم له يلزم بتعويض الضرر الذي أصاب المحكوم عليه:

ويستند هذا الرأي إلى أن المحكوم له يستعمل رخصة في النفاذ المعجل، وهذه الرخصة له أن ينتفع بها إذا شاء، أو يتريص صدور الحكم النهائي الذي يؤكد حقه في التنفيذ، فإن استعمل هذه الرخصة وأجرى التنفيذ استنادا إليها؛ فإنما يجريه على مسؤوليته، وكأنه يضمن ثبات الحكم واستقراره، فضلا عن أن التنفيذ المعجل يحمل معنى التسرع وعدم التبصر والتروي، مما يوجب مسؤوليته عن تعويض الأضرار التي تصيب المحكوم عليه؛ إذا ألغي الحكم في الاستئناف^(٢).

الرأي الثاني: عدم إلزام المحكوم له بتعويض الضرر الذي أصاب المحكوم عليه:

ويستند هذا الرأي إلى أن المحكوم له إنما أجرى التنفيذ استنادا إلى حق مقرر

(١) انظر في عرض الرأيين: د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٨٦-٨٨.

(٢) وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأي في بعض أحكامها؛ فقضت بأن "تنفيذ الأحكام تنفيذا مؤقتا يكون على مسؤولية طالب التنفيذ وحده؛ إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له، إن شاء انتفع بها وإن شاء تريص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه؛ فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه؛ فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسؤوليته بغير تبصر، فيتحمل مخاطره إذا ألغي الحكم، ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحال إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذي قد ينشأ عن التنفيذ". (نقض مدني ١٩٦٧/٥/٢٣).

بمقتضى القانون؛ ومن ثم لا يسأل عن استعمال حق مقرر قانونا، ولا عن تعويض الضرر الذي يصيب المحكوم عليه جراء التنفيذ المعجل استنادا إلى هذا الحق. وأعتقد أن الرأي الثاني أولى بالترجيح، وذلك لأن المحكوم له بحكم مشمول بالنفاذ المعجل؛ إنما جاء استعماله لحقه واقتضائه إياه قبل صيرورة الحكم نهائيا، استنادا إلى اعتبارات رعاها القانون لأنواع معينة من الحقوق، مستندا في ذلك إلى القانون، وإلى منطوق الحكم المشمول بالنفاذ المعجل. ثم بالقياس على المحكوم له بحكم قابل للطعن بالنقض والذي يقوم بالتنفيذ رغم ذلك أو رغم الطعن فيه فعلا، ولم يقل أحد بمسؤوليته عن التعويض إذا ألغت محكمة النقض الحكم المطعون فيه بعد تنفيذه.

المطلب الرابع

التظلم من الخطأ في وصف الحكم (الاستئناف الوصفي)

أولا: فكرة الاستئناف الوصفي والمقصود به:

تناولنا في المطلبين السابقين (الثاني والثالث)، كيفية تنفيذ الحكم القضائي، وقلنا إن النفاذ العادي للأحكام، هو تنفيذ الأحكام الانتهائية غير القابلة للطعن بالاستئناف، وهذه هي القاعدة العامة، واستثناء من هذه القاعدة، يجوز تنفيذ الأحكام الابتدائية نفاذا معجلا بقوة القانون أو بحكم المحكمة، وهذه الأخيرة قد تكون مشمولة بالنفاذ المعجل المشروط بالكفالة أو بدونها.

ويعتمد ذلك على وصف المحكمة للحكم بأنه ابتدائي غير قابل للتنفيذ، أو قابلا للتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها، أو أنه انتهائي، ومن ثم ينفذ نفاذا عاديا، غير أن المحكمة قد تخطئ في وصف الحكم، وذلك في إحدى الصور الآتية:

١- أن تصف المحكمة الحكم الانتهائي بأنه ابتدائي، مما يؤدي إلى وقف قوته التنفيذية.

٢- أو تصف الحكم الابتدائي بأنه انتهائي، مما يجعله قابلا للتنفيذ الجبري.

٣- أو ترفض شمول الحكم بالنفاذ المعجل، في إحدى الحالات الوجوبية المقررة بقوة

القانون، فيتعطل بذلك تنفيذه.

٤- أو تقضي بالنفاذ المعجل من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم، في إحدى الحالات الجوازية.

٥- أو تأمر بالإعفاء من الكفالة الواجبة بقوة القانون.

والواضح من هذه الحالات التي قد تخطأ المحكمة فيها في وصف الحكم؛ أن التظلم من بعضها يكون مقصوداً منه طلب تنفيذ الحكم، وفي البعض الآخر يكون مقصوداً منه منع تنفيذ الحكم، والتظلم بذلك قد يقدم من المحكوم له الذي يرمي من وراء تظلمه إلى تنفيذ الحكم، أو من المحكوم عليه الذي يرمي من وراء تظلمه إلى منع تنفيذ الحكم، ولهذا أشرنا إلى عدم إدراج التظلم الوصفي ضمن ضمانات المحكوم عليه في النفاذ المعجل باعتباره طريق طعن في الوصف الخاطيء للحكم.

وبهذا يكون المقصود من التظلم أو الاستئناف الوصفي، تصحيح خطأ قانوني وقعت فيه محكمة أول درجة، وهذا الخطأ ينصب على وصف خاص بالحكم، وهذا الوصف يؤثر في قوة الحكم التنفيذية^(١).

ويختلف الاستئناف الوصفي عن الاستئناف العادي؛ لأنه لا يتناول القضاء الوارد بالحكم؛ وإنما ينصب فقط على وصف إجرائي يؤثر في تنفيذ الحكم، فهو طريق خاص للطعن في الحكم بسبب عيوب محددة نص عليها القانون، ويهدف إلى تصحيح الخطأ في وصف الحكم^(٢).

ثانياً: الاختصاص بالاستئناف الوصفي وإجراءاته:

ينعقد الاختصاص بنظر الاستئناف الوصفي للمحكمة الاستئنافية بالنسبة للمحكمة التي أصدرت الحكم، حيث نصت المادة (٢٩١) مرافعات على أنه "يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون

(١) د. وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للتنفيذ، ص ٩١.

(٢) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٢٠٨.

ميعاد الحضور ثلاثة أيام. ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. ويحكم في التظلم مستقلاً عن الموضوع".

ووفقاً لهذا النص؛ فإن الاستئناف الوصفي يرفع أمام المحكمة التي تستأنف أمامها أحكام المحكمة التي أصدرت الحكم، فقد يرفع أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، أو أمام محكمة الاستئناف، بحسب المحكمة الصادر منها الحكم المطعون عليه بالخطأ في الوصف.

وقد أجاز المشرع للطاعن أن يرفع طعنه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن على يد محضر، أو تقديمه شفاهة أثناء نظر الاستئناف على الموضوع، ويعني ذلك أنه لا يشترط وجود طعن بالاستئناف على الموضوع، ويجوز الطعن في الوصف استقلاً، كما يجوز أن يكون الطعن في الوصف تابعاً للطعن الأصلي بالاستئناف، وميعاد الحضور في التظلم، ثلاثة أيام فقط، ولا محل لهذا الميعاد إذا قدم التظلم شفاهة في الجلسة وكان المطعون ضده حاضراً^(١). ويشترط توفر المصلحة في الطعن وإلا حكم بعدم قبوله^(٢).

ولم يقيد المشرع الاستئناف الوصفي بوجوب رفعه في ميعاد معين، ومن ثم تجب التفريق بين حالتين: الأولى: إذا كان هناك استئناف مرفوع عن الحكم؛ فلا يتقيد التظلم الوصفي بميعاد معين، ويجوز تقديمه في أي وقت أثناء نظر الاستئناف، وإلى أن يتم إقفال باب المرافعة. والثانية: إذا لم يرفع استئناف أصلي عن الحكم؛ فلا يجوز رفع الاستئناف الوصفي بعد انتهاء ميعاد الاستئناف الأصلي؛ لانقضاء المصلحة حينئذ، حيث يصبح الحكم انتهائياً قابلاً للتنفيذ وفقاً للقواعد العامة^(٣).

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٥/١٠٧٢-١٠٧٣.

(٢) د. رمزي سيف، التنفيذ، ص ٥٤.

(٣) د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٨٢.

ثالثاً: شروط قبول الاستئناف الوصفي:

يشترط لقبول التظلم من وصف الحكم، توفر الشروط الآتية:

- ١- أن تتوفر المصلحة لطاعن في الطعن على وصف الحكم:
ويعد هذا الشرط إعمالاً للقاعدة العامة المقررة في المادة (٣) مرافعات.
- ٢- أن يقع خطأ من المحكمة في وصف الحكم يؤثر في قوته التنفيذية.
- ٣- أن يرفع الاستئناف الوصفي قبل أن يحوز الحكم قوة الشيء المقضي.

رابعاً: الأثر المترتب على التظلم والحكم فيه:

لا يترتب على مجرد رفع التظلم أثراً في التنفيذ، فلا أثر لتقديم الاستئناف الوصفي على تنفيذ الحكم، أو منع تنفيذه؛ إلا إذا قضي بقبول التظلم^(١).

ويجب على المحكمة المرفوع إليها الاستئناف الوصفي أن تفصل فيه على استقلال (مادة ٢٩١) ولو كان هناك طعن بالاستئناف على الحكم الأصلي، ومؤدى ذلك أن يقتصر الحكم في هذا الطعن على طلب تعديل وصف الحكم، دون التطرق لموضوع الحكم أو ما قضى به، وطلب تعديل وصف النفاذ؛ طلب وقتي، لا يؤثر على الاستئناف الموضوعي، ولا يمنع المحكمة من الفصل في الموضوع، ولا يقيد بها عند الفصل فيه.

المطلب الخامس

تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

وفقاً لنص المادة (٢٩٦) مرافعات فإنه يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي، في مصر بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام المصرية فيه. بحيث تكون للأحكام الأجنبية قوة تنفيذية على إقليم الدولة حتى ولو كان التنظيم القضائي مختلفاً في الدولتين طالما كان الحكم الأجنبي غير متعارض مع النظام العام أو الآداب في مصر، وكان هذا الحكم مستوفي للشروط التي نص عليها قانون

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٥/١٠٧٥.

المرافعات.

والأصل أن الحكم الأجنبي لا ينفذ بقوة القانون في بلد آخر غير البلد الذي صدر فيه، وهذا مظهر من مظاهر استقلال الدولة وسيادتها حتى لا ينفذ على أرضها حكم صادر في دولة أخرى. ومن ناحية ثانية فإن تحقيق العدالة يقتضي أن تتأكد المحاكم الوطنية من خلو الحكم الصادر في بلد أجنبي من العيوب الجوهرية التي تعوق تنفيذه في مصر، ولو كان هذا الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري في الدولة الأجنبية التي صدر فيها؛ إلا أنه توفيراً للوقت والجهد والنفقات أجاز المشرع الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي في مصر بعد مراجعته والتأكد من استيفائه للشروط التي نص عليها قانون المرافعات.

والأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي: هو إجراء قضائي به يمنح الحكم قوة تنفيذية في الجمهورية فيكون قابلاً فيها للتنفيذ الجبري كما هو قابل له في أرض الدولة التي صدر فيها^(١).

شرط التبادل لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر:

يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام المصرية، وذلك تطبيقاً لشرط التبادل أو المعاملة بالمثل. ومعنى ذلك أن الحكم أو الأمر الأجنبي يعامل في مصر فيما يتعلق بقابليته للتنفيذ بما يعامل به الحكم المصري في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم الأول وهذا يقتضي الرجوع إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم في شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية، كما يقتضي أن يكون تقدير التبادل على أساس القوة التنفيذية التي تمنحها المحاكم الأجنبية للحكم الصادر من المحاكم المصرية بصرف النظر عن الإجراءات الشكلية التي تتبعها تلك المحاكم^(٢).

وهذا يعني أن الحكم الأجنبي الذي صدر أمر بتنفيذه قد تمت مراجعته للتأكد من استيفاءه للشروط التي تطلبها المشرع قبل منحه الصيغة التنفيذية. وأن البلد الأجنبي الذي صدر الحكم فيه يعامل الأحكام المصرية بذات المعاملة، وأن الحكم قد حاز قوة

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، مرجع سابق، ص ٢١٣.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص ٢١٤ - د. أحمد مليجي، الموسوعة ج ٥/١١٣٢.

الأمر المقضي طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه، وأن الخصوم قد كلفوا بالحضور أو مثلوا تمثيلا صحيحا في الدعوى التي صدر فيها الحكم، وأن الحكم لا يتعارض مع حكم آخر صادر من المحاكم المصرية، وأن الحكم لا يتضمن أمرا مخالفا للنظام العام أو الآداب في مصر. كما يجب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم^(١).

فإذا منح الحكم الأجنبي القوة التنفيذية بصدور أمر بتنفيذه في مصر فإن ذلك يعد قرينة على صحة إجراءات هذا الحكم وعلى توافر الشروط التي تطلبها المشرع لمنحه القوة التنفيذية وأن الحكم قد تمت مراجعته قبل صدور الأمر بتنفيذه.

ومن ثم فلا يقبل الادعاء بخلاف هذا الأصل وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات صحة ما يدعيه؛ فإذا ما أثبت المدعي عكس ذلك بأن أثبت مثلا أن الحكم الأجنبي يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية، أو أن الحكم لم يحز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه بأن كان مطعونا عليه بطريق عادي أو كانت مواعيد الطعن عليه بهذا الطريق مازالت سارية لم تنقضي، أو أن الأحكام المصرية لا يتم تنفيذها في هذا البلد لعدم توافر شرط المعاملة بالمثل، أو أثبت أن الحكم صدر بناء على إجراءات باطلة لعدم تكليف الخصوم بالحضور أو لعدم تمثيلهم في الدعوى التي صدر فيها الحكم تمثيلا قانونيا صحيحا؛ فإنه لا يعمل هنا بقرينة الصحة ولا يمكن القول بأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت.

(١) وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "وجوب وضع هذه الصيغة على الأحكام الأجنبية التي تنفذ بالجمهورية متى تحققت موجبات تنفيذها لديها، لا يحول دون ذلك وضع الصيغة التنفيذية على تلك الأحكام بمعرفة الدولة التي أصدرتها. علة ذلك، اختلاف أثر ونطاق سريان نفاذ كل من الصيغتين داخل إقليم كل دولة، فلا يعد ذلك وضعاً لصيغة تنفيذية ثانية". (الطعن رقم ٢٧٦٢ لسنة ٦١ قضائية - جلسة ١٩٩٨/١/٢٤).

المبحث الثاني

أحكام المحكمين

التحكيم نظام أو طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات سواء كانت مدنية أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية، فالتحكيم قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، إذ يعتمد أساساً على حرية أطراف النزاع في اختيار قضاتهم بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد التي يقيمون بها، وتسمى "هيئة التحكيم" وتتكون من محكم واحد أو أكثر حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم^(١).

والتحكيم بهذا المعنى، وسيلة من الوسائل يختاروها المتنازعون وبموجبها يتم الفصل في النزاعات التي نشأت أو تنشأ بينهم عن طريق طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين (محكم أو محكمين) للبت فيه دون اللجوء إلى الجهة المختصة أصلاً بالفصل في مثل هذا النوع من المنازعات، وفي حالة اختيار أكثر من شخص يجب أن يكون عددهم وتراً^(٢).

فهو آلية من آليات الحلول البديلة لفض المنازعات تسمح للأطراف بحل نزاعهم بدون تقاضي خارج محاكم الدولة. وبمعنى آخر عملية حل النزاع المتفق عليها بين الأطراف والتي يتم فيها عرض النزاع على محكم واحد أو أكثر ممن يصدر قراراً لحسم النزاع المعروف عليهم^(٣). وبذلك يكون نظاماً أو طريقاً خاصاً للفصل في المنازعات سواء كانت مدنية أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية^(٤).

(١) د. درويش مدحت الوحيدي: التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلاقات الدولية، مطابع شركة البحر والهيئة الخيرية، غزة، ١٩٩٨، ص ٣٦.

(٢) د. كرم محمد زيدان النجار: المركز القانوني للمحكم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢٠١٠م، ص ٥٤.

(٣) د. عبد الحميد المنشاوي: التحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٧م، ص ١٣.

(٤) د. عمر عيسى الفقي: الجديد في التحكيم في الدول العربية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ٢٠٠٣م، ص ٤١.

القوة التنفيذية لحكم التحكيم:

يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية، ويجب أن يكون حكم التحكيم مسببا؛ إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم. ويجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا^(١).

ولا تقبل أحكام التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية^(٢)، ولكن يجوز رفع دعوى ببطلان الحكم التحكيمي وفقا للقواعد المقررة في المادتين (٥٣ و ٥٤) من قانون التحكيم.

وقد منح المشرع قوة تنفيذية للحكم التحكيمي؛ فنص في المادة (٥٥) من قانون التحكيم، على أنه "تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي، وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون".

الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم:

على الرغم من أن حكم التحكيم يحوز حجية الأمر المقضي، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق طعن، على النحو الذي أشرنا إليه؛ إلا أنه لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا صدر أمرا من القضاء بتنفيذه، والأمر بتنفيذ حكم التحكيم والذي يمنحه القوة التنفيذية، يصدر من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من قانون التحكيم، وهي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، وإذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو خارجها؛ فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق

(١) المادة (٤٣) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.

(٢) المادة (٥٢) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.

الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر .

طلب تنفيذ حكم التحكيم:

يقدم طلب تنفيذ حكم التحكيم إلى رئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر مرفقا به^(١):

- ١- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
- ٢- صورة من اتفاق التحكيم.
- ٣- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا باللغة العربية.
- ٤- صورة من المحضر الدال على إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر النزاع. وفقا لما أوجبه المادة (٤٧) من قانون التحكيم.

شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم:

لا يحوز حكم التحكيم قوة تنفيذية إلا إذا صدر الأمر بتنفيذه من القضاء على النحو المشار إليه، ولا يصدر هذا الأمر إلا إذا توفرت الشروط الآتية^(٢):

- ١- ألا يكون الحكم التحكيمي متعارضا مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
- ٢- ألا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
- ٣- أن يكون قد تم إعلانه إعلانا صحيحا.

أثر الأمر الصادر في طلب تنفيذ حكم التحكيم:

لبيان هذا الأثر نفرق بين قبول الطلب وإصدار أمر التنفيذ، وبين رفض الطلب:

- ١- إذا أصدر القاضي أمره بتنفيذ حكم التحكيم؛ فإن هذا الأمر لا يقبل التظلم منه، وتمنح بمقتضاه القوة التنفيذية للحكم التحكيمي.
- ٢- أما إذا رفض الطلب؛ فيجوز التظلم من هذا الرفض إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع والمشار إليها في المادة (٩) من قانون التحكيم، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الرفض.

(١) المادة (٥٦) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.

(٢) المادة (٥٨) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.

المبحث الثالث

الأوامر

تعد الأوامر وفقا لنص المادة (٢٨٠) مرافعات من السندات التنفيذية التي يتم التنفيذ بمقتضاها، ويقصد بها ما يصدره القضاة من قرارات بناء على طلب خصم دون سماع اقوال الخصم الآخر ودون تكليفه بالحضور^(١). والأمر هو الشكل العام الذي تصدر فيه أعمال الحماية التنفيذية والولائية، وإن كان من الممكن أن يصدر هذا العمل في شكل حكم^(٢) ويصدر الأمر في أحوال استثنائية نص عليها المشرع وخالف فيها القواعد الأساسية في الالتجاء إلى القضاء، حيث أجاز للخصم الإدلاء بالطلب أمام القاضي في غيبة خصمه^(٣).

والأوامر القضائية ليست على درجة واحدة من حيث قوتها التنفيذية وذلك لاختلاف طبيعتها أو مضمونها - حيث تصدر أوامر الأداء عن السلطة القضائية للقاضي بينما تصدر الأوامر على العرائض عن السلطة الولائية للقاضي - لذلك فإن أوامر الأداء لا تقبل التنفيذ الجبري إلا إذا كانت نهائية شأنها في ذلك شأن الأحكام، بينما تحوز الأوامر على العرائض القوة التنفيذية بمجرد صدورها.

ويكون الأمر الصادر على عريضة واجب التنفيذ ولو لم ينص القاضي الأمر على ذلك في أمره بل حتى ولو لم يطلب الخصم شمول الأمر بالنفاذ، وعلى عكس ذلك فإن أمر الأداء وإن كان في شكله الخارجي ومنهجه الاجرائي أمرا على عريضة، إلا أنه من ناحية حقيقته وطبيعته تكون له علاقة مركبة، فهو ليس عملا قضائيا محضا وليس عملا ولائيا محضا، ولكنه عمل قضائي ذو شكل استثنائي؛ لذلك فهو لا يتمتع بذات القوة التنفيذية التي تتمتع بها الأوامر على العرائض، حيث لا يقبل التنفيذ الجبري إلا إذا كان نهائيا غير قابل للنظم أو الطعن^(٤).

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، مرجع سابق، ص ١٢٢.

(٢) د. الأنصاري حسن النيداني، التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية، مرجع سابق، ص ٥٥.

(٣) د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص ١٢٢.

(٤) المرجع السابق، ص ١٠٢ وما بعدها.

المطلب الأول الأوامر على العرائض

الأوامر على العرائض، هي تلك الأوامر التي تصدر من قاضي الأمور الوقتية بما له من سلطة ولائية، بناء على طلب يقدم من الخصم على عريضة ليصدر القاضي أمره عليها في غيبة الخصوم، دون تسبيب، بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي طبيعتها السرعة أو المباغتة، دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه، ولا تحوز حجية الأمر المقضي، ولا يستند القاضي الوقتي سلطته بإصدارها، فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب^(١).

فحيث يستلزم القانون لإمكان اتخاذ إجراء تحفظي، أمراً من القضاء بذلك، أو حيث ينبغي استئذان القضاء للقيام بعمل قانوني أو إجراء قضائي، أو حيث تجب مصادقة القضاء على تصرف قانوني أو على قرار ولائي، وبشرط ألا يكون ثمة نزاع قائم على شيء من ذلك من قبل، فإن الالتجاء إلى القضاء للحصول على أمره أو إذنه أو مصادقته لا يكون بدعوى، وإنما يكون بعريضة تقدم إلى القاضي من ذوي الشأن، مبينا بها المطلوب وما يبرره^(٢).

وبناء على هذه العريضة المقدمة إلى القاضي فإنه يصدر أمره، إما بإجابة الطالب إلى كل مطلوبه، أو إلى جزء منه، أو يرفض إجابة الخصم إلى طلبه، وذلك دون سماع الخصم الآخر. وللخصم الذي رفض طلبه أن يعيد تقديم نفس الطلب إلى القاضي، أو يرفع به دعوى موضوعية، لأن الأمر على العريضة لا يحوز الحجية.

وقد نظم المشرع الأوامر على العرائض في الباب العاشر من قانون المرافعات (المواد ١٩٤-٢٠٠)، فتسري أحكام هذه المواد على كافة الأوامر على العرائض، ما لم يقرر القانون أحكاماً خاصة بنوع منها^(٣).

(١) نقض: الطعن رقم ٤٥٠ لسنة ٤٨ قضائية- جلسة ١٨/١٢/١٩٧٨.

(٢) المستشار. سيد حسن البغال، المطول، مرجع سابق، المجلد الأول، ص ٧٨٥.

(٣) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٩١٩.

القوة التنفيذية للأوامر على العرائض (النفاذ المعجل للأمر):

وفقا لنص المادة (٢٨٨) مرافعات، فإن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأوامر على العرائض، وذلك ما لم ينص الأمر على تقديم كفالة. ومفاد ما قررته هذه المادة أن الأوامر على العرائض تنفذ نفاذا معجلا بقوة القانون، حتى وإن كانت قابلة للتظلم منها، أو كان قد تم التظلم منها بالفعل، وقد راعى المشرع في ذلك الطبيعة الوقتية لهذه الأوامر، حيث تصدر باتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية، ولذا يقتضي تنفيذها شيء من السرعة، فضلا عن كونها تصدر في غيبة الخصم الآخر ويقصد مفاجأته مما يقتضي شمولها بالنفاذ المعجل، كما أنها تتعلق بإجراءات وقتية لا خطر منها^(١).

ومؤدى شمول هذه الأوامر بالنفاذ المعجل القانوني؛ أن المحكمة لا تملك سلطة إزاء تنفيذها معجلا، فلا تملك المحكمة وقف النفاذ المعجل للأمر على عريضة، كما لا يؤثر في شمولها بالنفاذ المعجل عدم النص على ذلك في الأمر؛ لأن النفاذ المعجل لها مقرر بقوة القانون دون حاجة لنص المحكمة.

ولم يشترط المشرع وجوب تقديم كفالة لتنفيذ الأمر على عريضة؛ بل جعل الأصل تنفيذها معجلا بدون كفالة، واستثناء من هذا الأصل أعطى للمحكمة سلطة الأمر بالكفالة إذا رأت مقتضى لذلك بحسب الظروف التي صدر فيها الأمر، ويعنى ذلك أن سلطة المحكمة التقديرية تقتصر على الحكم بالكفالة أو عدم الحكم بها، دون أن تمتد هذه السلطة إلى النفاذ المعجل للأمر.

وإذا رفع التظلم من الأمر على عريضة أو طعن فيه؛ فإن ذلك لا يؤثر في النفاذ المعجل للأمر، وإنما يكون للمحكمة التي تنظر التظلم وفقا للمادة (٢٩٢) سلطة تقديرية في الأمر بوقف النفاذ المعجل، سواء بكفالة أو بغير كفالة، والحكم الصادر في التظلم يكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، باعتباره حكما وقتيا (مادة ٢٨٨).

(١) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ٢٥٣.

المطلب الثاني

أوامر الأداء

أولاً: تعريف أوامر الأداء:

نظام أوامر الأداء نظام استثنائي للقضاء الموضوعي، لا يقتضي اتباع الإجراءات المعتادة للخصومة، بل يستلزم اتباع إجراءات مختصرة شبيهة بنظام الأوامر على العرائض، حيث يصدر الأمر بناء على عريضة تحرر من نسختين متطابقتين يقدمها الدائن أو وكيله إلى القاضي المختص، ويرفق بها سند الدين، وما يثبت حصول التكليف بوفائه، فإذا تحقق القاضي من توافر شروط استصدار الأمر فإنه يصدر أمره على إحدى نسختي العريضة وفقاً للإجراءات التي حددها المشرع.

وإذا رأى من صدر ضده الأمر التظلم منه فعليه أن يقدم تظلمه إلى المحكمة المختصة ابتداء بنظر الدعوى وذلك في الميعاد الذي حدده المشرع، وينظر التظلم وفقاً للإجراءات المعتادة للخصومة^(١). وقد نظم المشرع أوامر الأداء في الباب الحادي عشر من قانون المرافعات (المواد ٢٠١ - ٢١٠).

ويمكن تعريف أمر الأداء بأنه: القرار القضائي الصادر في الموضوع المنصب على ديون محلها نقوداً أو منقولات معينة بالذات أو بالنوع والمقدار متى كانت ثابتة بالكتابة ومعينة المقدار وحالة الأداء وسبق أن كلف الدائن مدينه بالوفاء بها، وهذا القرار القضائي يصدر من قاضي الأداء على عريضة من الدائن لكي يأمر مدينه بأدائه^(٢).

ثانياً: القوة التنفيذية لأمر الأداء:

تختلف القوة التنفيذية لأمر الأداء عنها بالنسبة للأوامر على العرائض؛ ذلك أن المشرع نص في المادة (٢٠٩) مرافعات على أنه "تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاد المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون". وبهذا النص أحال المشرع فيما يتعلق بتنفيذ أوامر الأداء إلى القواعد العامة

(١) د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ٥٥٢.

(٢) المرجع السابق، ص ٥٥٣.

في تنفيذ الأحكام. ووفقا لهذه القواعد فإنه:

١- الأصل أن أمر الأداء لا ينفذ معجلا؛ وإنما يخضع للقاعدة العامة في التنفيذ العادي؛ ومقتضاها عدم تنفيذه إلا إذا أصبح نهائيا، أي غير قابل للتظلم منه أو الطعن عليه بالاستئناف، سواء بفوات المواعيد، أو تأييد الأمر.

وقد نظم المشرع طرق الطعن في أمر الأداء في المادة (٢٠٦) مرافعات؛ فأجاز للمدين الصادر ضده الأمر الطعن فيه بأحد طريقين، الأول، التظلم من الأمر أمام المحكمة الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال، والثاني، استئناف الأمر أمام المحكمة المختصة. حيث قدر المشرع أن أمر الأداء يصدر في غير مواجهة بين الخصوم، ودون سماع أقوال المدين، فنظم له طريقا خاصا للطعن في الأمر الصادر في غيبته، من خلال التظلم منه، أي كانت قيمة الحق الصادر به الأمر، وأيما كان القاضي الذي أصدره. ولأن أمر الأداء يصدر بمقتضى السلطة القضائية للقاضي شأنه في ذلك شأن الحكم القضائي، فإن المشرع أجاز للمدين استئناف الأمر الصادر ضده إذا كان الأمر بحسب قيمة الحق المطلوب أدائه يقبل الاستئناف.

٢- تخضع أوامر الأداء لقواعد التنفيذ المعجل الخاصة بالأحكام، فيكون منها النافذ معجلا بقوة القانون والنافذ معجلا بأمر المحكمة.

وعلى سبيل المثال؛ فإذا كان أمر الأداء صادرا في مادة تجارية موضوعية؛ فإنه يكون نافذا معجلا بقوة القانون بشرط تقديم كفالة، كما يجوز للقاضي الذي يصدر أمر الأداء أن يأمر بتنفيذه معجلا في الأحوال التي ورد النص عليها في المادة (٢٩٠) مرافعات^(١).

ويخضع أمر الأداء لما تخضع له الأحكام، سواء من حيث التظلم الوصفي، أو من حيث وقف التنفيذ، فيجوز التظلم الوصفي منه إذا أخطأ القاضي في وصف الأمر من حيث قابليته للتنفيذ العادي أو المعجل، أو أخطأ بشأن الكفالة ضمانا للتنفيذ

(١) د. عيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ص ٢٦٠.

المعجل. كما يجوز للمحكمة التي تنتظر التظلم من الأمر أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف التنفيذ المعجل للأمر إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم، وكانت أسباب الطعن في الأمر مما يترجح معها إلغاؤه، ولها حينئذ أن تأمر بوقف التنفيذ مع تقديم الكفالة، أو بدونها (مادة ٢٩٢).

تنفيذ الأوامر الأجنبية في مصر:

نصت المادة (٢٩٦) مرافعات على أن "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه". ونصت المادة (٢٩٨) على الشروط التي يجب التحقق من توافرها في الحكم أو الأمر الأجنبي قبل إصدار الأمر بتنفيذه، ولذا يمكن القول بأن الأوامر الأجنبية تنفذ في مصر بنفس الشروط التي سبق ذكرها عن تنفيذ الأحكام الأجنبية.

المطلب الثالث

أوامر التقدير

ويقصد بها الأوامر التي تصدر بتقدير التزام أو حق معين يقبل التنفيذ الجبري، كأمر تقدير مصاريف الدعوى، أو أمر تقدير الرسوم القضائية، أو أمر تقدير أتعاب الخبير. وتختلف القواعد المتعلقة بتنفيذها، عن تلك المتعلقة بالأوامر على العرائض. ونتناول هذه الأوامر على النحو الآتي:

أولاً: أمر تقدير مصاريف الدعوى:

ورد النص على هذا الأمر ونظامه القانوني في الفصل الثاني من الباب التاسع في قانون المرافعات (المواد ١٨٤ - ١٩٠).

حيث أوجب القانون على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها؛ أن تحكم من تلقاء نفسها ودون طلب من الخصوم في مصاريف الدعوى، ويدخل في حساب هذه المصاريف مقابل أتعاب المحاماة، ويحكم بالمصاريف على الخصم المحكوم عليه في الدعوى (الذي خسر الدعوى)^(١). وقد اعتد القانون بواقعة

(١) المادة (١٨٤) مرافعات.

خسارة الدعوى، وحدها كسبب للحكم بالمصاريف دون حاجة لأسباب أخرى.

ولكن هناك حالات قد يحكم فيها بالمصاريف كلها أو بعضها على الخصم الذي كسب الدعوى، وذلك^(١):

- ١- إذا كان الحق المحكوم به مسلما به من قبل المحكوم عليه.
 - ٢- أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
 - ٣- أو كان المحكوم له قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى، أو بمضمون هذه المستندات.
- وهناك حالة أخرى يجوز فيها الحكم بالمصاريف على الخصمين؛ وذلك إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، فللمحكمة حينئذ أن تحكم على كل خصم بتحمل ما دفعه من المصاريف، أو تأمر بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة، أو تحكم بجميع المصاريف على أحد الخصمين، متى رأت ما يبرر ذلك^(٢).
- وقد حرص المشرع فضلا عن بيان من يتحمل مصاريف الدعوى؛ أن يبين كيفية تقديرها، وأن يبين القوة التنفيذية للأمر الصادر بتقديرها.

ففيما يتعلق بتقديرها؛ أوجب أن تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن ذلك؛ فإن تعذر تقديرها في الحكم لأي سبب؛ فإن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم يقوم بتقديرها بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له، وعلى هذا الأخير إعلان العريضة والأمر الصادر عليها إلى المحكوم عليه^(٣).

والأمر الصادر بتقدير المصاريف في هذه الحالة، يكون قابلا للتظلم منه، ويحدث هذا التظلم بأحد طريقتين:

- ١- إما أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير.
- ٢- أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال ثمانية أيام التالية لإعلان الأمر.

(١) المادة (١٨٥) مرافعات.

(٢) المادة (١٨٦) مرافعات.

(٣) المادة (١٨٩) مرافعات.

وعلى الرغم من أن الأمر الصادر بتقدير المصاريف، هو أمر على عريضة، والحكم الصادر في التظلم منه، هو حكم في تظلم من أمر على عريضة؛ إلا أنه لا يسري عليه أو على الحكم في التظلم، النظام المقرر لتنفيذ الأوامر على العرائض بشمولها بالنفاذ المعجل؛ ذلك أن أمر تقدير المصاريف والحكم الصادر في التظلم منه يعتبر مكملًا للحكم الصادر بتحديد الملتمزم بالمصاريف، ومن ثم يكون تابعًا له من حيث القوة التنفيذية، فلا يكون قابلاً للتنفيذ إلا إذا أصبح حكم الإلزام بالمصاريف نهائياً^(١).

ثانياً: أمر تقدير الرسوم القضائية:

يختص رئيس المحكمة أو القاضي بحسب الأحوال، بتقدير الرسوم القضائية بناء على طلب من قلم الكتاب، ويعلن أمر التقدير إلى المطلوب منه سداد الرسم^(٢). ويجوز لصاحب الشأن بعد صدور هذا الأمر، أن يعارض في تقدير الرسوم بأحد طريقين:

١- أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير.

٢- بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر.

ويقوم المحضر أو قلم الكتاب بحسب الأحوال بتحديد اليوم الذي تنتظر فيه المعارضة في التقدير^(٣)، وتفصل في المعارضة المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضي المختص بحسب الأحوال، ويجوز استئناف الحكم الذي يصدر في هذه المعارضة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره؛ وإلا سقط الحق فيه^(٤).

ولا يحوز أمر التقدير القوة التنفيذية التي للأوامر على العرائض، ومن ثم لا يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون؛ وإنما ينفذ تنفيذاً عادياً وفقاً للقواعد العامة؛ إذا أصبح انتهاً غير قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف، سواء بفوات الميعاد، أو بتأييده في الاستئناف^(٥).

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٢٠٤.

(٢) المادة ١٦ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤.

(٣) المادة (١٧) من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤.

(٤) المادة (١٨) من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤.

(٥) د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ١٠٩.

ثالثاً: أمر تقدير أتعاب الخبير:

تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته أو قاضي محكمة المواد الجزئية الذي عينه بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى. فإذا لم يصدر هذا الحكم في الثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى^(١). ويستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصروفات^(٢).

وللخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه^(٣).

لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إيداع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير^(٤).

ويحصل التظلم بتقرير في قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام، على أنه إذا كان قد حكم نهائياً في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات^(٥).

ومن حيث القوة التنفيذية لأمر تقدير أتعاب الخبير؛ فإنه يكون مشمولاً بالنفاد المعجل بقوة القانون، كما هو الشأن في الأوامر على العرائض، على النحو الذي سبق بيانه، غير أنه يختلف عنها في أن للتظلم منه أثر موقف للتنفيذ يترتب عليه بمجرد رفع التظلم، خلافاً للقواعد العامة في التظلم من الأوامر على العرائض.

(١) المادة (١٥٧) من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨.

(٢) المادة (١٥٨) من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨.

(٣) المادة (١٥٩) من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨.

(٤) المادة (١٦٠) من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨.

(٥) المادة (١٦١) من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨.

المبحث الرابع المحررات الموثقة

يقصد بالمحررات الموثقة تلك المشتمة على التصرفات والعقود التي يحررها الموثقون، وهم الموظفون المختصون بتحريرها وضبطها وتوثيقها^(٢). فهذه المحررات تكون مشتمة على تصرفات قانونية، ويقوم بتحريرها وتوثيقها موظفون مختصون بمكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل أو القناصل المصريون في الخارج بوصفهم موثقين^(٣).

والمحررات الموثقة من السندات التنفيذية التي نص عليها المشرع، على أن يراعى بشأنها اتباع الشروط والإجراءات التي نص عليها المشرع، بأن يكون المحرر الموثق قد تم تحريره بمعرفة أحد الموثقين المختصين بذلك وفقا للقانون، وأن تراعى كافة الأوضاع الشكلية والموضوعية التي تطلبها القانون، وأن يكون الموثق الذي يظهر توقيعه على المحرر هو من قام بتوقيعه فعلا، وأن يكون المحرر له أصل في مستندات وسجلات المكتب الذي تم التوثيق فيه، وأن التوثيق تم بالشكل الذي رسمه القانون.

والأصل أن هذا التوثيق قد ورد على التزام يجوز تنفيذه جبرا^(٤)، من حيث كونه محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، والأصل كذلك أن الحق الثابت بالمحرر لم يسقط بالنقادم. وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل إثبات صحة ما يدعيه، بحيث إذا ادعى المدين تزوير هذا المحرر فإن عليه أن يسلك طريق الطعن بالتزوير، كما لو ادعى أن التوقيع الثابت على المحرر ليس لأحد الموثقين وإنما هو توقيع مزور، أو أن

(٢) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٢٠٨.

(٣) د. أحمد مليجي، المرجع السابق، ص ٩٣٠.

(٤) وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "المقصود بالعقود الرسمية المشار إليها في المادة ٤٥٧ من قانون المرافعات السابق، الأعمال القانونية التي تتم أمام مكاتب التوثيق للشهر العقاري، والمتضمنة التزاما بشيء يمكن اقتضاؤه جبرا، مما يجعل لها بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للتلتجاء إلى القضاء". (الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٣٦ قضائية - جلسة ١٩٧١/١/١٩).

البيانات المثبتة بالمحرر غير صحيحة وغير مطابقة للحقيقة، أو أن المحرر الموثق ليس له أصل في سجلات ومستندات مكتب الشهر العقاري الذي تم التوثيق فيه.

ففي مثل هذه الادعاءات وغيرها مما يناقض صحة المحرر ويخالف القول بأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، لا يمكن اعتبار المحرر سنداً تنفيذياً يمكن التنفيذ بمقتضاه.

حيث يستمد المحرر الموثق قوته التنفيذية - فضلاً عن نص المادة ٢٨٠ مرافعات- من الثقة في أعمال الموثق الذي أوجب عليه القانون إجراءات معينة تؤكد وجود الحق على نحو يغني عن اللجوء إلى القضاء، إلى جانب أن الشخص الذي يقر بحق أمام الموثق يكون قد ارتضى منح صاحب الحق سنداً تنفيذياً يغنيه عن رفع الدعوى أمام القضاء والحصول على حكم بحقه^(١).

ويتم التنفيذ بموجب الصورة التنفيذية للمحرر الموثق، وهي صورة تؤخذ من الأصل المحفوظ في مكتب التوثيق، ويقوم الموثق بوضع الصيغة التنفيذية عليها ويوقعها الموثق وتختم بختم الشهر العقاري، وعبارات الصيغة التنفيذية التي توضع على المحرر الموثق، هي نفس عبارات الصيغة التنفيذية التي توضع على الأحكام وغيرها من السندات التنفيذية.

وقد وردت النصوص المتعلقة بالصورة التنفيذية للمحررات الموثقة في قانون التوثيق رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧، لا في قانون المرافعات، ووفقاً للمادة الثامنة من هذا القانون، لا تسلم صورة من المحررات التي تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن، ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقفية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها^(٢).

السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي:

نصت المادة (٣٠٠) مرافعات على أن "السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي

(١) د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ١٠٢.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٩٤٧/٥.

يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية. ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ الذي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصه. ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في الجمهورية".

المبحث الخامس

محاضر الصلح

محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح:

وفقا لنص المادة (١٠٣) مرافعات فإنه يكون للخصوم في أية حالة تكون عليها الدعوى أن يطلبوا من المحكمة إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.

ووفقا لنص المادة المشار إليه؛ فإن محاضر الجلسات المثبتة للصلح -سواء تم الصلح في الجلسة وأثبت في محضرها، أو كان الخصوم قد كتبوا ما اتفقوا عليه واثبتوا محتواه في محضر الجلسة- فإن هذا المحضر تكون له قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.

ويجب أن يراعى في ذلك الإجراءات التي تطلبها المشرع في هذا المحضر. من حيث صحة إجراءات الصلح التي تم اثباتها في المحضر، وأيضا صحة توقيع الخصوم أو وكلائهم على المحضر، وصحة الاتفاق الذي تم حاقه بالمحضر واثبتا محتواه فيه وأن توقيعات الخصوم على هذا الاتفاق صحيحة وأنهم اتفقوا على إثبات محتوى هذا الاتفاق بمحضر الجلسة لاعتباره سنداً تنفيذياً بما اتفقوا عليه.

وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل إثبات صحة ما يدعيه، بحيث إذا ما ادعى

أحد الخصوم خلاف هذا الأصل فإن عليه أن يثبت ما يدعيه عملاً بقريضة الصحة التي تقتض صحة الإجراءات وفقاً لما تطلبه القانون. إلا أنه لما كان محضر الجلسة محرراً رسمياً يكتسب صفة الرسمية بتوقيع الكاتب عليه؛ فإنه لا يمكن إثبات عكس الثابت فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير على هذا المحضر.

المبحث السادس

الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي

لم يحصر المشرع أنواع السندات التنفيذية في المادة (٢٨٠) مرافعات، بما سبق تناوله من سندات فقط؛ وإنما نص في نهاية الفقرة الثانية لهذه المادة على "الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة". ومن أمثلة هذه الأوراق الأخرى:

١- محضر تعهد الكفيل (المادتان ٢٩٣ و ٢٩٥ مرافعات):

والمقصود به، المحضر المشتمل على تعهد الكفيل الذي كفل المحكوم له في النفاذ المعجل، حيث نصت المادة (٢٩٣) مرافعات على أنه "في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلًا مقتدرًا..."، ونصت المادة (٢/٢٩٥) على أنه "ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده". ومن ثم يعد هذا المحضر سنداً تنفيذياً في مواجهة الكفيل بالالتزامات المترتبة على تعهده.

٢- محضر بيع المنقولات المحجوزة (مادة ٣٨٩ مرافعات):

ذلك أن المادة (٣٨٤) مرافعات أوجبت أن يتم بيع المنقولات المحجوزة بالمزاد العلني، وعلى الراسي عليه المزاد أن يقوم بدفع الثمن؛ فإن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً؛ فإن المادة (٣٨٩) أوجبت إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه.

٣- محضر التسوية الودية لتوزيع حصيلة البيع (مادة ٤٧٦ مرافعات):

حيث نصت المادة (٤٧٦) مرافعات على أنه "إذا حضر ذوو الشأن وانتهى إلى اتفاق على التوزيع بتسوية أثبتت إدارة التنفيذ اتفاقهم في محضرها وتوقعه وكاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي".

المبحث السابع

السند التنفيذي في الفقه الإسلامي

لا يجوز التنفيذ الجبري وفقا لقانون المرافعات كما ذكرنا؛ إلا إذا كان بيد الدائن سندا تنفيذيا، ولا بد من توافر شروط محددة في هذا السند، وأن يتم إعلانه للمدين قبل التنفيذ، والأمر على خلاف ذلك في الفقه الإسلامي، ذلك أن الفقه الإسلامي ومن خلال موروته الفقهي لم يذكر فكرة السند التنفيذي على الإطلاق، ولم يتعرض الفقهاء المسلمين لهذا الموضوع، وإنما تركوا الأمر كله بيد القاضي، فهو الذي يصدر الحكم، ثم هو الذي يتولى تنفيذه بنفسه أو تحت إشرافه، دون أي إجراءات، فالحكم في الشريعة واجب النفاذ فور صدوره^(١).

وعلى هذا فقد حصل خلاف كبير بين الفقهاء حول مدى حق الشخص في اقتضاء حقه دون الالتجاء للقضاء، فهناك حقوق يمكن اقتضاؤها دون اللجوء إلى القضاء، وذلك باتفاق الفقهاء، من ذلك:

الحقوق الواردة على العقار أو المنقول، كمالك العقار يسترده من غاصبه، والمنقول من سارقه، ومستأجر العقار أو المنقول، له استرداده ممن اغتصبه أو سرقه، إذا لم يترتب على ذلك فتنة أو مفسدة، كذلك الحقوق المتعلقة بالنفقة للزوجة والأبناء يجوز استيفاؤها بلا دعوى^(٢).

فقد ورد أن هند بنت عتبة اشتكت إلى رسول الله ﷺ إن أبا سفيان رجل شحيح لا يترك لي وولدي ما أنفق عليه، فقال لها ﷺ «خذي ما يكفيك وولديك بالمعروف»^(٣).

أما الحقوق ذات الخطر العظيم كالقصاص والقذف والنكاح والطلاق والرخصة، وغيرها من سائر العقود والفسوخ، فلا يمكن لأصحابها استيفاؤها، وإنما يشترط لها سبق

(١) د. أحمد علي يوسف جرادات، مرجع سابق، ص ١٤٤ و ١٥٠.

(٢) المغني لابن قدامة، ج ٣٢٥/٩، نهاية المحتاج للرملي، ج ٣١٤/٨.

(٣) صحيح مسلم بشرح النووي، ج ٧/١٢.

دعوى عند قاض أو محكم^(١).

واختلف الفقهاء في باقي الحقوق، ولهم في ذلك ثلاثة آراء^(٢):

الأول: أن للدائن استيفاء دينه بلا دعوى من مال المدين، قدر حقه، سواء أكان المال من جنس الحق أم لم يكن من جنسه، وإليه ذهب المالكي، والشافعية^(٣).

الثاني: أنه يجوز للدائن أن يأخذ جنس حقه فقط، دون الترافع إلى القضاء، وإليه ذهب الحنفية^(٤).

الثالث: أنه لا يجوز للدائن اقتضاء حقه ودينه قبل الرجوع إلى القضاء، بل تشترط الدعوى في كل شيء، وإليه ذهب الحنابلة^(٥).

ويجب لتنفيذ الحكم في الفقه الإسلامي أن تتوفر مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية، وهي: أن يكون الحكم صادرا من قاض صحيح التولية، وأن يتقدم صدور الحكم دعوى صحيحة، وأن يصدر الحكم بناء على دليل إثبات لم يظهر بعد صدور الحكم ما يبطله، وأن يصدر الحكم موافقا لمصادر الأحكام الشرعية، وأن يستوفي الحكم الشروط الشكلية الواجبة في إصداره^(٦).

(١) المغني لابن قدامه، ج ٣٢٥/٩، مغني المحتاج للشربيني، ج ٤٦٢/٤، د. أحمد يوسف جرادات، ص ١٤٥.

(٢) د. أحمد علي يوسف جرادات، مرجع سابق، ص ١٤٥.

(٣) مغني المحتاج للشربيني، ج ٤٦٢/٤، الوجيز للغزالي، ج ٢٦٠/٢، د. محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى، ص ١١٩.

(٤) المغني لابن قدامه، ج ٣٢٩/٩، د. محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى، ص ١٤٤.

(٥) المغني لابن قدامه، ج ٣٢٥/٩.

(٦) د. محمود الأمير يوسف الصادق، مرجع سابق، ص ٣٥٢ وما بعدها.

الفصل الثالث

الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له والأموال التي يجوز الحجز عليها

الفصل الثالث

الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له

والأموال التي يجوز الحجز عليها

ونقصد بالحق الذي يجرى الحجز اقتضاء له، الدين الذي للدائن في ذمة المدين، والذي امتنع هذا الأخير عن الوفاء به اختياراً، أو الالتزام الذي يقع على عتقه وامتنع عن أدائه، وسواء كان هذا الحق حقا ماليا في الأساس، أو التزاما تحول إلى حق مالي أو تعويض، نتيجة عدم القيام به.

وليس كل حق للدائن في ذمة مدينه، يجيز للأول أن يحجز على أموال الثاني ثم يبيعها جبرا؛ وإنما يشترط في هذا الحق توفر شروط معينة، وهي أن يكون الحق محقق الوجود، وحال الأداء، ومعين المقدار، فإذا اختلت هذه الشروط أو أحدها؛ فإنه لا يجوز للدائن التنفيذ على أموال مدينه وبيعها جبرا، وإذا توفرت هذه الشروط وامتنع المدين عن تنفيذ التزامه اختياراً، كان للدين الحق في اقتضاء حقه جبرا بالحجز على أموال مدينه وبيعها.

وقد أراد المشرع أن يوفر الحماية القانونية اللازمة لهذا الدائن في مواجهة مدينه الممتنع عن الوفاء أو تنفيذ التزامه، فأعطاه سلطات تجيز له الحجز على جميع أموال مدينه، ودون اشتراط التناسب بين الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له والمال الذي يتم التنفيذ عليه، وله في سبيل ذلك أن يختار ما يشاء من أموال مدينه للتنفيذ عليها.

وفي هذا السياق لم يترك المدين عرضة لتعسف الدائن؛ وإنما أعطاه وسائل يستطيع بمقتضاها أن يحد من سلطة الدائن في الحجز على أمواله، ليس هذا فقط بل وفر له نوع من الحماية راعى بمقتضاه اعتبارات معينة، ومنع الدائن مراعاة لهذه الإعتبارات من الحجز على بعض أموال مدينه، بحيث تخرج هذه الأموال من نطاق الأموال التي يجوز الحجز عليها. ونبين ذلك في مبحثين على النحو الآتي.

المبحث الأول

الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له

لكل دائن أن يطلب اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة مدينه مهما كان دينه صغيرا فلا يشترط لإجراء التنفيذ أن يبلغ الحق المراد اقتضاؤه مبلغا معيناً، ومن ثم فكل حق يجوز التنفيذ به علي أموال المدين من عقارات ومنقولات يستوي أن يكون هذا الحق صغيراً أو كبيراً .

وأيضاً فكل دائن أن يطلب اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة مدينه ، يستوي أن يكون الدين ديناً عادياً، أو ديناً مضموناً برهن أو امتياز أو اختصاص^(١) فلا فرق بين دائن عادي وغيره من ناحية جواز التنفيذ عليه بين الدائنين المنفذين^(٢).

الشروط الواجب توافرها في الحق الذي يجري التنفيذ اقتضاء له :

لابد من توافر شروط معينة في الحق الذي يتضمنه السند التنفيذي حتي يمكن التنفيذ اقتضاء له، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة ٢٨٠ مرافعات علي هذه الشروط بقولها " لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء".

والغالب أن وجود سند تنفيذي بيد الدائن من شأنه أن يدل علي تحقق هذه الشروط ومع ذلك فهناك حالات يتوافر فيها السند التنفيذي ويمتتع التنفيذ لأن الحق الثابت بالسند ينقصه شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها^(٣).

وعلي ذلك فلا بد أن يكون الحق المراد التنفيذ اقتضاء له قد استجمع ثلاثة شروط:

١- محقق الوجود ٢- معين المقدار ٣- حال الأداء .

وتخلف شرط من هذه الشروط يمنع من اتخاذ إجراءات التنفيذ، وإذا تم التنفيذ رغم تخلف شرط منها كان التنفيذ باطلاً^(٤).

(١) إجراءات التنفيذ أ.د / أحمد أبو الوفا ص : ٢٤٧ .

(٢) قواعد تنفيذ الأحكام والعقود أ.د / رمزي سيف ص : ١٣٤ .

(٣) المبادئ العامة للتنفيذ، أستاذنا الدكتور / عبد الباسط جميعي . يرحمه الله . ص : ٦٥، قواعد تنفيذ الأحكام، أ.د / رمزي سيف، ص : ١٣٤ .

(٤) التنفيذ الجبري أ.د / أمينة النمر، ص : ١٥٩ .

الشرط الأول: أن يكون محقق الوجود:

ومعني ذلك أن يكون الحق موجودا في ذمة المدين علي وجه أكيد وهو يكون كذلك إذا كان الحق غير متنازع فيه وغير معلق علي شرط واقف^(١)، ولا يعني عدم النزاع في الحق إقرار المدين به وإنما يعني خلو الحق من النزاع الجدي ويقصد به النزاع الذي يثير الشك في وجود الحق^(٢).

وعلى ذلك فلا يجوز التنفيذ بحكم بتقديم حساب إذ قد يسفر ذلك عن براءة ذمة المدين كما لا يجوز تنفيذ حكم بغرامة تهديدية لأنه حكم تهديدي وليس قطعي ويلزم تحديد مقدار التعويض تحديدا نهائيا بمقتضي حكم آخر - وللمحكمة عند تحديدها مبلغ التعويض الذي يلزم به المدين أن تراعي الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين فلها أن تحط عن المدين الغرامة ولها أن تعدلها زيادة ونقصا.

ويلاحظ أن الحق إذا كان محقق الوجود في جزء منه ومنتازعا علي جزء آخر، فيجوز التنفيذ اقتضاء للجزء المحقق مهما قلت قيمته .

الشرط الثاني: أن يكون الحق معين المقدار:

ويجب أن يكون الحق الذي يجري التنفيذ اقتضاء له معلوم المقدار. فإذا كان التنفيذ يجري لاقتضاء مبلغ من المال -تنفيذ غير مباشر - فيلزم أن يكون المبلغ معلوما مقداره .

ويعتبر الحق معلوم المقدار إذا أمكن تعيينه بعملية حسابية بسيطة بناء علي أرقام مأخوذة من نفس السند التنفيذي، كما إذا كان المبلغ المطلوب مائة جنيه بفائدة قدرها ٥% فمن السهل معرفة قيمة الفائدة التي تضاف إلي أصل المبلغ^(٣) وكما إذا كان المطلوب مبلغا معينا تم تسديد جزء منه فإن الجزء الباقي يعتبر معينا .

أما إذا كان التنفيذ تنفيذا مباشرا كتسليم شيء معين بذاته أو هدم جدار أو تخلية

(١) التنفيذ علماً وعملاً للأستاذين/ أحمد قمحة، وعبد الفتاح السيد، ص : ٥٨، إجراءات التنفيذ أ.د / أحمد أبو الوفا ص : ٢٤٧ .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩/١/١٩٧١، الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٣٦ ق.

(٣) التنفيذ الجبري، أ.د / فتحي والي، ١١٤ .

عقار فيقصد بهذا الشرط تعيين الشيء المطلوب تسليمه والجدار المطلوب هدمه والعقار المراد تخليته تعينا نافيا للجهالة .

وتطبيقا لهذا الشرط لا يجوز التنفيذ بحكم يلزم المحكوم عليه بالمصاريف دون أن يحددها ولا يجوز تنفيذ حكم يقرر مسئولية المحكوم عليه عن التعويض دون أن يحدد قيمته ، وأيضا لا يجوز تخلية عقار لم يذكر عنوانه أو حدوده.

ولا يغني شرط وجود الحق في ذمة المدين علي وجه أكيد عن شرط تعيين هذا الحق، وذلك لأمرين أولهما: أن المدين له أن يتفادى إجراءات التنفيذ على أمواله بالوفاء طوعا ولا يمكنه ذلك إذا لم يعرف ما هو مطلوب منه. ثانيهما: أن معاون التنفيذ يكف عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف (م ٣٩٠ مرافعات)، وعلي ذلك فلا بد من معرفة قدر الديون المحجوز من أجلها حتى يكف معاون التنفيذ عن بيع بقية المحجوزات عند قدر معين.

الشرط الثالث: أن يكون الحق حال الأداء:

كما يجب أن يكون الحق الذي يجري التنفيذ اقتضاء له حالا فالحق المؤجل لا تقبل دعوي المطالبة به قبل حلول الأجل فمثل هذه الدعوى لا تكون مقبولة لرفعها قبل الأوان^(١)، وإذا كانت المطالبة بالحق المؤجل غير مقبولة فلا يجوز اقتضاء مثل هذا الحق جبرا عن المدين من باب الأولى^(٢)، ذلك أن المدين قد يوفي بالدين من تلقاء نفسه عند حلول الأجل.

وعلي ذلك لا يجوز التنفيذ لاقتضاء حق مؤجل إلا عند حلول الأجل إلا إذا كان الأجل مقررا لمصلحة الدائن وحده، ونزل عن حقه فيه أو سقط حق المدين في الأجل من الأسباب المسقطة له^(٣).

(١) أصول المرافعات أ.د. / أحمد مسلم، ص : ٣٢٣، ٣٢٤ .

(٢) إجراءات التنفيذ أ.د. / أحمد أبو الوفا ص : ٢٥١ .

(٣) يسقط حق المدين في الأجل :

١- إذا أشهر إفلاسه أو إعساره وفقاً لنصوص القانون .

٢- إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين، أما إذا كان

ويجب أن تتوافر هذه الشروط عند البدء في التنفيذ ولا يفيد توافرها بعد البدء فيه ، فإذا اتخذ الدائن إجراءات التنفيذ لاقتضاء دين مؤجل فإن هذه الإجراءات تكون باطلة، ولا يصححها حلول الأجل بعد اتخاذها، ذلك أن إجراءات التنفيذ يترتب عليها آثار خطيرة في جانب المدين، كوضع أمواله تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها والمساس بسمعته الأدبية والمالية^(١).

كما يجب أن يشهد السند التنفيذي علي هذه الشروط بذاته ولذلك لا يجوز التنفيذ بمقتضي حكم قضى بمسئولية المحكوم عليه عن التعويض دون تحديد مقداره حتى ولو حدد هذا المقدار في عقد عرفي بين الخصوم .

ولكن يستكمل السند التنفيذي بسند آخر يصدر عن أطرافه له قوة السند أيضاً، كعقد موثق أو محضر صلح أمام المحكمة؛ عملاً بالمادة ١٠٣ مرافعات، ويمكن تكملة السند التنفيذي بسند عرفي إذا كان السند العرفي سابقاً علي السند التنفيذي، ويشير إليه السند التنفيذي صراحة^(٢).

التنفيذ بمقتضي عقد رسمي بفتح اعتماد :

إذا عقد بنك مع عميل له رسمياً بفتح اعتماد فإن البنك يلتزم بوضع المبالغ المعينة تحت تصرف العميل لمدة معينة، ويقوم العميل بسحب هذه المبالغ بمقتضي إيصالات عرفية وفي هذه الحالة يصبح العميل مديناً برد هذه المبالغ . ومعني هذا أن العقد الرسمي بفتح اعتماد إنما يقرر التزام البنك بدفع المبالغ الواردة به للمدين، ولا يقرر التزام المدين برد هذه المبالغ؛ حيث أنها ثابتة بمقتضي إيصالات عرفية، ولا تعد هذه الإيصالات مكملة للعقد الرسمي؛ لأنها لاحقة عليه ، وليست لها قوة تنفيذية.

إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً .

٣- إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات " المادة ٢٧٣ مدني " .

(١) التنفيذ الجبري أ.د / فتحي والي، ص : ١١٨ .

(٢) مبادئ التنفيذ أ.د / محمد عبد الخالق عمر، ص : ٤٠، ٤١ .

والأصل وفقاً للقاعدة السابقة أنه لا يجوز للبنك أن يستخدم العقد الرسمي كسند تنفيذي للحصول على المبالغ التي سحبها العميل ، وذلك لأن العقد لا يدل بذاته على وجود الحق قبل العميل بصفة قطعية ، ولكن الإيصالات العرفية هي التي تدل على وجود الحق قبله.

ولكن المقنن استثنى العقد الرسمي بفتح اعتماد؛ فأجاز -علي خلاف الأصل- التنفيذ بدليل غير مستمد من العقد الرسمي ذاته هو مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية، وقد قصد المقنن من هذا الاستثناء إقرار العرف القضائي الذي يجيز التنفيذ بهذا العقد ولو لم يتضمن الإقرار بقبض شيء^(١) .

و ضماناً لحق المدين فقد أوجب المقنن على الدائن عند الشروع في التنفيذ بمقتضي عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن مع العقد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية (المادة ٢٨١/٣ مرافعات) .

(١) وقد نصت محكمة النقض على أنه " لما كان المقصود بالعقود الرسمية المشار إليها في المادة ٢٨٠ فقرة ثانية من قانون المرافعات الأعمال القانونية التي تتم أمام مكاتب الشهر العقاري والمتضمنة التزاماً بشيء يمكن اقتضاؤه جبراً مما يجعل لها بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للالتجاء للقضاء، وكان مؤدى المادتين ٢٨٠، ٢٨١ من القانون ذاته وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ... "

وإن كان يجب أن يكون الحق الموضوعي المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبري محقق الوجوب ومعين المقدار وحال الأداء، وأن يكون السند التنفيذي دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه، إلا أن الشارع تقديره منه للاعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان أجاز . استثناءً من الأصل . التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية ولو لم تتضمن الإقرار بقبض شيء .. " نقض مدني جلسة ٢٨/٧/٢٠٠٢ الطعن رقم ٨٧٧٠ لسنة ٦٣ ق " . وانظر نقض مدني جلسة ١/٢/١٩٦٦، الطعن رقم ٢٧٥ لسنة ٣١ ق، جلسة ١٩/١/١٩٧١، الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٣٦ ق، نقض مدني جلسة ١٢/٦/١٩٧٣، الطعن رقم ٢٣١ لسنة ٣٨ ق.

المبحث الثاني

محل التنفيذ (الأموال التي يجوز الحجز عليها)

تمهيد:

محل التنفيذ المباشر هو نفس الشيء أو الحق الذي يجب علي المدين أدائه، فإذا كان المدين ملتزماً بتسليم سيارة معينة مثلاً، فإن هذه السيارة تكون هي محل التنفيذ المباشر.

أما محل التنفيذ بنزع الملكية فهو عبارة عن أموال المدين التي يقع عليها الحجز، وذلك تمهيداً لبيعها وإيفاء حق الدائن من ثمنها، ومحل التنفيذ بنزع الملكية هو المقصود في هذا المبحث.

ونتحدث عن محل التنفيذ بنزع الملكية في ثلاثة مطالب، الأول: في القواعد العامة في حجز الأموال، والثاني في الشروط الواجب توافرها في المال المحجوز عليه، أما الثالث فنتناول من خلاله بيان الأموال التي لا يجوز الحجز عليها في الفقه الإسلامي.

المطلب الأول

القواعد العامة في حجز الأموال

القاعدة الأولى:

الأصل أن كل الأموال المدين يجوز حجزها وذلك لأن "أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه" (المادة ١/٢٣٤ مدني)، وعلي ذلك فالأصل هو جواز الحجز علي أي مال من أموال المدين والاستثناء هو عدم جواز الحجز علي بعض أموال المدين فللدائن الحق في التنفيذ علي أموال مدينه جميعها ولا فرق في ذلك بين مال وآخر إلا ما كان منها غير جائز حجزه^(١).

ويترتب علي ذلك:

١- لا يلزم الحاجز بإثبات أن الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز حجزها وإنما علي من يتمسك بعدم جواز الحجز علي مال معين عبء إثبات أن هذا المال من الأموال التي لا يجوز حجزها.

(١) نقض مدني جلسة ١٧/٥/١٩٧٢، الطعن رقم ٢١٤ لسنة ٣٤ ق .

- ٢- يجب تفسير النصوص التي تمنع من الحجز على مال معين تفسيراً ضيقاً^(١)؛ ذلك أن المنع من الحجز على مال معين هو استثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه.
- ٣- يجوز الحجز على أي عين مملوكة للمدين حتى ولو كانت مثقلة برهن أو امتياز لدائن آخر؛ ذلك أن الرهن أو الامتياز المثقلة به العين يمنح الدائن حق التقدم على غيره من الدائنين في اقتضاء حقه من ثمن العين^(٢)، ولكن لا يخرج العين من الضمان العام للدائنين .
- ٤- يجوز الحجز على حصة شائعة مادامت مملوكة للمدين وتباع ويصبح المشتري مالكا على الشيوع كسلفه.

القاعدة الثانية:

الدائن حر في اختيار ما يشاء من أموال المدين لإجراء الحجز عليه فله أن يحجز على العقار قبل المنقول، وله أن يحجز على عقار دون عقار كما أن له أن يحجز على مال ولو كان أكثر كلفة على المدين من الحجز على غيره.

وعلى ذلك فيجوز للدائن الممتاز أن يحجز على مال آخر غير المال المرهون له، فقد تكون له مصلحة في ذلك نظراً لتأخر مرتبته في الرهن.

وحرية الدائن في اختيار ما يشاء من أموال المدين للحجز يرد عليها استثناء في حالة تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من لائحة الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية على أن "يبدأ بالتنفيذ على النقود الموجودة عيناً ثم على المنقولات ثم على العقار في حالة عدم وجود منقولات".

القاعدة الثالثة:

لا يشترط التناسب بين قيمة الدين المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه .

فللدائن مهما صغرت قيمة دينه أن يحجز على أي مال للمدين مهما كبرت قيمته؛ وذلك لأن الحجز بدين على مال من أموال المدين لا يمنع أي دائن آخر من التدخل

(١) النظرية العامة للتنفيذ أ.د. / وجدي راغب، ص ٢٧٤ .

(٢) إجراءات التنفيذ أ.د. / أحمد أبو الوفا ص : ٢٦٨ .

في الحجز والاشتراك في قيمة ثمن المال المحجوز، ولا يعطي القانون للدائن السابق في الحجز امتيازاً على غيره من الدائنين الحاجزين اللاحقين، فلو اشترط التناسب بين دين الحاجز والمال المحجوز لكان الدائن الحاجز عرضة لعدم استيفاء حقه، وذلك إذا زاحمه غيره من الدائنين مما يضطره إلى توقيع حجوز جديدة^(١).

وإذا كان عدم اشتراط التناسب رعاية لمصلحة الدائن الحاجز في الحصول على حقه كاملاً، فحماية لمصلحة المدين نظم قانون المرافعات وسائل للتخفيف من أثر هذه القاعدة، ونتحدث عن هذه الوسائل في إيجاز على النحو التالي:

أولاً: الإيداع والتخصيص:

يحصل الإيداع والتخصيص بإيداع مبلغ خزانة المحكمة، ويخصص للوفاء بالدائن المحجوز من أجله، والإيداع والتخصيص قد يكون بغير حكم، كما قد يكون بناءً على حكم.

أ- الإيداع والتخصيص بغير حكم:

نصت المادة ٣٠٢ مرافعات على أنه: "يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.

وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ، وعلى ذلك فيجب أن يودع في خزانة المحكمة مبلغاً مساوياً للديون المحجوز من أجلها، ويستوي أن يودعه المدين أو غيره، كما يستوي أن يكون المال المحجوز منقولاً أو عقاراً تحت يد المدين أو تحت يد غيره كما يستوي أن يكون الحجز حجزاً تنفيذياً أو تحفظياً، كما يجب أن يتم تخصيص المبلغ المودع خزانة المحكمة للوفاء بمطلوب الحاجز، وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة. والإيداع مع التخصيص يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع.

(١) النظرية العامة للتنفيذ أ.د. / وجدي راغب، ص : ٢٧٩ .

وإذا تم الإيداع مع التخصيص فإنه يترتب على ذلك زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع خزانة المحكمة، وإذا وقعت حجز جديدة على هذا المبلغ، فلا يكون لها أثر في حق الدائن الحاجز الذي خصص له المبلغ، وذلك إذا آل المبلغ إلى الدائن الحاجز، ولكن إذا آل المبلغ أو جزء منه إلى المحجوز عليه فإن الحجز التي وقعت بعد التخصيص تنتج أثرها بالنسبة لما آل للمحجوز عليه.

ب- الإيداع والتخصيص بناءً على حكم :

نصت المادة ٣٠٣ مرافعات على أنه: "يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع، ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته".

وعلى ذلك فيجوز الإيداع مع التخصيص بناءً على حكم يصدر من قاضي التنفيذ بناءً على دعوى مستعجلة ترفع في مواجهة الحاجزين، ويجوز اختصام المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير، ولا تقبل هذه الدعوى من غير المحجوز عليه، ويجوز رفع هذه الدعوى في أية حالة تكون عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع .
ويصدر قاضي التنفيذ حكماً وقتياً يحدد فيه المبلغ الواجب إيداعه خزانة المحكمة مراعيًا في هذا التقدير ظروف كل دعوى وما يثار فيها من المنازعات ومدى ثبوت دين الحاجز ومقداره وحكم قاضي التنفيذ بتحديد المبلغ الواجب إيداعه هو حكم وفتي لا حجية له أمام محكمة الموضوع .

وبعد صدور الحكم بتحديد المبلغ يجوز للمحجوز عليه أن يودعه كما يجوز لغيره، ولا حاجة إلى كتابة تقرير في قلم الكتاب بتخصيص المبلغ للوفاء بمطلوب الحاجز إذ أن هذا التخصيص يتم هنا بناءً على الحكم^(١).

ويترتب على الإيداع مع التخصيص بناءً على حكم زوال أثر الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقال الحجز إلى المبلغ المودع خزانة المحكمة.

(١) النظرية العامة للتنفيذ أ.د. / وجدي راغب ص : ٢٨٤ .

ثانياً: قصر الحجز:

الوسيلة الأولى (الإيداع والتخصيص) يفترض فيها أن لدى المدين نقوداً يودعها خزنة المحكمة، أما الوسيلة الثانية (قصر الحجز) فقد قدر المقتن أن بعض المدينين قد لا يكون لديهم من النقود ما يساوي المبلغ المحجوز من أجله، وأن الدائن قد أوقع الحجز على أموال للمدين تزيد قيمتها كثيراً عن المبلغ المحجوز من أجله .

ولذا : فقد رأى المقتن أن يمنح مثل هذا المدين وسيلة تخفف من أثر القاعدة السابقة، فنص في المادة ٣٠٤ مرافعات على أنه "إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة، ويختصم فيها الدائنون الحاجزون، ولا يكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بأي طريق، ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها".

وعلى ذلك فيجوز للمدين أن يرفع دعوى مستعجلة أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يطلب فيها قصر الحجز على بعض الأموال المحجوزة، ويختصم في هذه الدعوى الدائنين الحاجزين، ويجوز اختصام المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير، وللمحجوز عليه وحده الحق في رفع هذه الدعوى، ويستوي أن يكون المال المحجوز عليه منقولاً أو عقاراً، كما يستوي أن يكون الحجز تحفظياً أو تنفيذياً.

وينظر قاضي التنفيذ دعوى قصر الحجز باعتباره قاضياً للأمر المستعجلة، ويصدر حكماً وقتياً لا حجية له عند نظر الموضوع ولا يكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بأي طريق.

ويترتب على صدور الحكم بقصر الحجز على بعض الأموال المحجوزة زوال الحجز عن الأموال الأخرى التي رفع عنها، وقصر الحجز على الأموال التي عينها الحكم، وترتب أولوية للدائنين الحاجزين قبل القصر على هذه الأموال، فإذا وقعت حجز أخرى على الأموال التي قصر الحجز عليها فتكون الأولوية في استيفاء الديون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز .

ولكن ما الحل إذا كان الحاجز بعد قصر الحجز من الدائنين الممتازين الذين لهم الأولوية على المال المقصور كالدائن المرتهن للمال المقصور؟.

هنا يستوفي الدائن الممتاز حقه من المال المقصور قبل الدائنين الحاجزين قبل القصر، وذلك لأن الأولوية المقررة للحاجزين بالفقرة الثالثة من المادة ٣٠٤ لا تكون إلا عند التساوي في المرتبة بين الدائنين^(١)، وما يتبقى بعد استيفاء الدائن الممتاز حقه فيخصص للحاجزين قبل القصر، فإذا لم يف بحقهم كان لهم أن يوقعوا حجزاً جديداً على أموال المدين، وتكون مصاريف الحجز على نفقته.

ثالثاً: الكف عن البيع :

إذا لم تكن لدى المدين نقود يودعها خزانة المحكمة، ولم يتمكن من رفع دعوى قصر الحجز، فقد حماه القانون أيضاً من غلواء قاعدة: "عدم اشتراط التناسب بين قيمة الدين المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه"، وذلك بأن أوجب على معاون التنفيذ عند إجراء البيع أن يكف عن المضي في البيع إذا نتج عن البيع مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف.

وإذا وقعت حجوز بعد الكف عن البيع تحت يد معاون التنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن فلا تتناول هذه الحجوز إلا المبالغ التي تزيد على وفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف^(٢).

المطلب الثاني

الشروط الواجب توافرها في المال المحجوز عليه

يجب في المال المحجوز عليه توافر الشروط التالية:

أولاً: أن يكون مالاً مملوكاً للمدين:

وعلى ذلك فلا يجوز الحجز على مال مملوك لغير المدين، مهما كانت الصلة بين

(١) التنفيذ الجبري أ.د. / أمينة النمر ص : ١٦٩، الوجيز أ.د. / عبد العزيز بديوي، ص : ١٧٦، إجراءات التنفيذ أ.د. / أحمد أبو الوفاء، ص : ١٧٩، وانظر غير هذا الأستاذ الدكتور / وجدي راغب، حيث يرى أن الأولوية تكون للحاجزين قبل القصر، النظرية العامة للتنفيذ ص : ٢٨٩، ٢٩٠ .

(٢) المادة : ٣٩٠ مرافعات .

المدين وصاحب المال، كزوجته أو ابنه أو أبيه أو أخيه، كما لا يجوز الحجز على حصة الشريك في الشركة؛ لأن للشركة وجود مستقل عن الشركاء فيها، فتخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة، ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة في نسبة من الأرباح أو نصيب في رأس مال الشركة عند التصفية، لكي يجوز للدائن الشريك أن ينفذ على الأرباح التي يستحقها الشريك قبل الشركة^(١).

وحكمة اشتراط كون المال المحجوز مملوكا للمدين أن المدين إنما يضمن ديونه بأمواله هو وليس بأموال غيره، فضلا عما في الحجز علي مال غير المدين من اعتداء علي حق صاحب المال.

واستثناء من هذا الشرط يجوز الحجز علي العقار المرهون الذي انتقلت ملكيته إلي الحائز وعلي مال الكفيل العيني، وهو الذي يقدم ماله ضمانا للوفاء بدين علي شخص آخر وأيضا يجوز الحجز علي المنقولات التي يضعها المستأجر بالعين المؤجرة ولو كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها. ويكفي أن تكون ملكية المدين ثابتة عند توقيع الحجز فلا يشترط ثبوتها قبل تكوين السند التنفيذي.

ثانيا: أن يكون محل التنفيذ قابلا للتنفيذ:

يشترط في المال المنفذ عليه أن يكون قابلا للتنفيذ؛ وذلك لأن الغرض من التنفيذ بنزع الملكية هو بيع هذا المال وإيفاء الدائن حقه من حصيلة التنفيذ، ولكن هناك أموال لا يجوز التنفيذ عليها^(٢) لتعارض طبيعتها مع التنفيذ، وأموال لا يجوز التنفيذ عليها

(١) نقض مدني، جلسة ١٥/١٠/١٩٨٠، الطعن رقم ٢.

(٢) في الفقه الإسلامي تباع كل أموال المدين في دينه ولا تباع غير أمواله في دينه، فلا يباع مال الصغير وفاء لدين على أبيه (منح الجليل ١٣٢/٣)، ولا يباع ما ادعى أنه ليس له، وقامت بينة أو شهد عرف بذلك، كالصانع يوجد عنده ما يتفق وصنعتة، فإن العرف قاض بأن ما في يد الصانع ليس لهم (نظام الحجز في الإسلام، للشيخ يس شاذلي ص ١٤٨) .

واستثناء من ذلك لا تباع بعض أموال المحجوز عليه، فيترك له بيت يسكن فيه هو ومن تلزمه نفقته حسب حاله ودرجته الاجتماعية (الحجز وأسبابه الشيخ محمود عبد المنعم، ص : ٧٧)، ومن الثياب يترك له دست

لإرادة المتصرف، وأموال لا يجوز التنفيذ عليها رعاية للمدين وأسرته، وأموال لا يجوز الحجز عليها لأهداف اقتصادية أو اجتماعية، ولذلك يمكن تقسيم الأموال التي لا يجوز حجزها إلى أربع طوائف^(١):

- ١- أموال لا يجوز التنفيذ عليها لتعارض طبيعتها مع التنفيذ
- ٢- أموال لا يجوز التنفيذ عليها إعمالاً لإرادة المتصرف
- ٣- أموال لا يجوز التنفيذ عليها رعاية للمدين وأسرته
- ٤- أموال لا يجوز الحجز عليها لأهداف اقتصادية أو اجتماعية .

الطائفة الأولى: أموال لا يجوز التنفيذ عليها لتعارض طبيعتها مع التنفيذ:

التنفيذ على المال يؤدي إلى بيعه بالمزاد، وهناك أموال لا يجوز بيعها ولا النزول عنها ولذلك لا يجوز التنفيذ عليها، من ذلك:

- ١- الأموال العامة للدولة وفروعها؛ لأن "هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليه أو تملكها بالتقادم"^(٢). أما أموال الدولة الخاصة فيثور الخلاف حول جواز التنفيذ عليها، كما سبق بيانه.
- ٢- الحقوق المتصلة بشخص المدين؛ لأن هذه الحقوق روعي فيها حاجات صاحبها الشخصية، ومثالها حق الاستعمال وحق السكني، واشتراكات المواصلات العامة والشهادات الدراسية^(٣) والأوسمة والنياشين.

(غيار) وقيل : دستان وهو المختار ؛ لأنه إذا غسل دستاناً يحتاج لشيء يستره (الهداية بهامش فتح القدير ٧ / ٣٢) .

واختلف في الكتب فقيل : لا تباع، وقيل تباع ؛ لأن العلم يحفظ (منح الجليل ٣ / ١٣١)، ويفهم من كلام الفقهاء في الأموال التي لا يجوز بيعها أنها مسألة نسبية تختلف من شخص لآخر، وإن كان الضابط مدى لزوم هذا المال المحجوز عليه باعتباره مديناً، حتى إنهم يقولون إن كانت له ثياب حسنة باعها القاضي واشترى الكفاية (الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية ٥ / ٢٢٥) والله أعلم .

(١) انظر في هذا التقسيم : التنفيذ الجبري أ.د. / فتحي والي ف ١٠١، ص ١٩٥ / قواعد وإجراءات التنفيذ أ.د. / عبد العزيز بديوي ص : ١٢٤، وانظر : تقسيمات أخرى في التنفيذ الجبري أ.د. / أمينة النمر، ف ١٨٠، ص : ١٧٢، قواعد تنفيذ الأحكام أ.د. / رمزي سيف، ف ١٤٢، ص ١٤٥ .

(٢) المادة ٨٧ / ٢ مدني .

(٣) قواعد تنفيذ الأحكام والعقود أ.د. / رمزي سيف ص ١٤٥، ١٤٦ .

٣- **حقوق الارتفاق والحقوق العينية التبعية:** وهذه الحقوق وإن كانت تدخل في الضمان العام للدائن، إلا أنها نظرا لطبيعتها الخاصة يقل الراغبون فيها، لأن حق الارتفاق لا يشترطه إلا من له عقار مجاور للعقار المرتفق به، ويستفيد عقاره من حق الارتفاق وقد لا يوجد، وحق الرهن أو الامتياز لا يشترطه إلا دائن في حاجة لتأمين دينه وقد لا يوجد، ومن ثم فهذه الحقوق يصعب بيعها بالمزاد لقلّة الراغبين فيها.

٤- **حق الملكية الأدبية والفنية والعلمية:** ويقصد بها حقوق المؤلف في طبع ونشر نتاج فكره، وهذه يختلف حكمها، فإذا كان المؤلف لم يسبق نشره فلا يجوز التنفيذ عليه، أما إذا سبق نشره فيجوز الحجز علي النسخ الموجودة تحت يد الناشر، وإذا نفذت النسخ يجوز طبع المؤلف ونشره، ما لم يعترض المؤلف اعتراضا مقبولا^(١).

٥- **الأعيان الموقوفة:** لا يجوز التنفيذ عليها مادامت موقوفة، لأنها تعتبر محبوسة ما بقي الوقف، والأعيان الموقوفة لا يجوز الحجز عليها لا لدين علي الواقف، أو لدين علي جهة الوقف أو لدين علي مستحق.

الطائفة الثانية: أموال لا يجوز التنفيذ عليها إعمالا لإرادة المتصرف:

هذه الطائفة من الأموال منع المقتن من الحجز عليها إعمالا لإرادة المتصرف، حيث أراد المتصرف أن نتفق في غرض معين أو أن تظل بمنجى من الحجز عليها، أو قصد أن تبقى ملكا للمتصرف إليه مدة من الزمان، وقد احترمت المقتن هذه الرغبة وعمل علي تحقيقها.

١- **الأموال الموهوبة أو الموصي بها لتكون نفقة:** وقد نصت علي عدم جواز الحجز عليها المادة ٣٠٧ مرافعات؛ حيث نصت علي أنه "لا يجوز الحجز علي...ولا علي الأموال الموهوبة أو الموصي بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة".

٢- **الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها:** وقد نصت

(١) التنفيذ الجبري أ.د. / فتحي والي ف ١٠٢، ص : ١٩٦، ١٩٧، قواعد تنفيذ الأحكام والعقود أ.د. / رمزي سيف ف ١٤٥، ص : ١٤٦ .

المادة ٣٠٨ مرافعات علي عدم جواز الحجز علي هذه الأموال حيث نصت علي أن " الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة".

٣- الأموال التي يمتلكها المدين بشرط عدم التصرف فيها: " إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط، ما لم يكن مبنياً علي باعث مشروع ومقصوراً علي مدة معقولة"^(١).

ويترتب علي وجود الشرط المانع من التصرف متى كان صحيحاً، منع الحجز أياً كان الدين المراد التنفيذ اقتضاء له، أن يكون قد نشأ قبل التصرف المقترن بالشرط أم بعده، وذلك لأن التنفيذ علي المال المشترط عدم التصرف فيه يترتب عليه بيعه، وهو يخالف شرط عدم التصرف^(٢).

الطائفة الثالثة: أموال لا يجوز التنفيذ عليها رعاية للمدين وأسرته:

نظر المقتن إلى المدين نظرة إنسانية، ومنع من التنفيذ على أشياء تعد ضرورية لحياته هو وأسرته وهي:

١ - ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره من الفراش والثياب والغذاء.

منع المقتن من الحجز علي هذه الأشياء الضرورية للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره، ولكن المنع ليس مطلقاً، وإنما مقيد بقيود ومحدد بحدود، وقد نصت على ذلك

(١) المادة ٨٢٣ / ١ مدني.

(٢) لكن إذا كانت المصلحة المقصود تحقيقها من الشرط المانع لا تفوت بالحجز فإن الحجز لا يمتنع، كما في حالة ورود الشرط في عقد بيع مؤجل الثمن ضماناً لاستيفائه، فالحجز هنا لا يؤدي إلى ضياع حق البائع ؛ لأن بيع الشيء بالمزاد يستوجب تطهيره من كل الحقوق العينة التبعية المقررة عليه، بما في ذلك امتياز البائع، فيستوفي البائع حقه من ثمن البيع بالمزاد بالأولوية دون أن يضطر إلى تتبع الشيء في يد الراسي عليه المزاد .

راجع موجز في الحقوق العينية الأصلية، د / محمد ليبب شنب ف ٢٥٤ ص ٢٦٦، الحاشية ٥٦، حق الملكية د / عبد المنعم فرج الصدة ف ١١٩ ص ١٨٥، وانظر : التنفيذ الجبري أ.د / فتحي والي ف ٩٩ ص ١٩١ .

المادة ٣٠٥ مرافعات "لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره علي عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب، وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر".

٢- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته:

لا يجوز الحجز على الكتب والأدوات والمهمات اللازمة للمدين لكي يزاول مهنته أو حرفته بنفسه، والمنع ليس مطلقا، حيث يجوز علي هذه الأشياء لاقتضاء ثمنها، أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة .

أ- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه..."

٣- إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين هو وأسرته وما يلزم لغذائها لمدة شهر:

منع المقنن من الحجز على إناث الماشية رعاية للمدين، حتى تدر عليه لبنا يقتات به أو بثمنه أو تعينه في عمله والمنع هنا ليس مطلقا، بل يجوز الحجز على هذه الإناث لاقتضاء ثمنها، أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة، وقد نصت على ذلك المادة ٢/٣٠٦ مرافعات؛ حيث نصت علي أنه: "لا يجوز الحجز علي الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة (أ) ما يلزم... (ب) إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر".

٤- النفقات والمصاريف المحكوم بها:

"لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة، أو للصرف منها في غرض معين...إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة" (١).

٥- الأجور والمرتبات:

يعتمد العاملون اعتمادا كلياً على ما يتقاضون من أجور أو مرتبات ونحوها، ولذلك راعى المقنن ذلك وأحاط هذه المبالغ بضمانات متعددة منها عدم جواز الحجز عليها إلا في حدود معينة (٢) .

(١) المادة ٣٠٧ مرافعات .

(٢) مبادئ التنفيذ أ.د / محمد عبد الخالق عمر ف ٣٥٤، ص : ٣٦٨ .

وقد وردت نصوص مختلفة تحصن هذه المبالغ منها ما يسري على موظفي الحكومة ومستخدميها وفروعها وما يستحقونه هم أو ورثتهم من معاش أو مكافأة، أو ما يقوم مقامها كرأس مال المعاش المستبدل، أو حق في صندوق التأمين أو الادخار، أو تأمين مستحق طبقاً لقوانين التأمين أو المعاش، ويشمل التحصين ملحقات المرتب كالعلاوات والبدلات^(١).

ومن هنا ما يسري على العمال الخاضعين لقانون العمل، وقد منع من الحجز على أجور العمال الذين ينطبق عليهم هذا القانون، وكذلك جميع المبالغ المستحقة لهم طبقاً لأحكام هذا القانون كمكافأة مدة الخدمة أو التعويض المستحق عن مهلة الإنذار^(٢).

ومن هذه النصوص ما يسري على كل من يؤجر نفسه للعمل أياً ما كان مركزه الاجتماعي فيما عدا العمال الذين يخضعون لقوانين خاصة كما سبق، وقد نصت المادة ٣٠٩ مرافعات علي أن "لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع، وعند التزامه يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون".

ويراعي أن منع الحجز على الأجور والمرتبات عموماً ليس مطلقاً، وإنما أجاز المقنن توقيع الحجز اقتضاء لبعض الديون، وينسب معينة.

الطائفة الرابعة: أموال لا يجوز الحجز عليها لأهداف اقتصادية أو اجتماعية:

منع المقنن التنفيذ على مجموعة من الأموال لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية من ذلك:

١ - ودائع صندوق التوفير، وشهادات الاستثمار:

لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة صندوق توفير البريد، عملاً بالمادة ٢٠ من القانون ٨٦ لسنة ١٩٥٤^(٣)، كما لا يجوز الحجز على قيمة شهادات الاستثمار أياً كان نوعها، أو على ما تغله من فائدة أو جائزة أو قيمة استردادها أو استحقاقها، إلا فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه، عملاً بالمادة ٣ من القانون رقم ٨ الصادر في ٣١

(١) التنفيذ الجبري أ.د. / فتحي والي ف ١٠٩ ص : ٢١٥، ٢١٦ .

(٢) المادة ٤١ من قانون العمل ١٣٧ لسنة ١٩٨١م.

(٣) مبادئ التنفيذ أ.د. / محمد عبد الخالق عمر ف ٣٧٢ ص : ٣٨٩ .

مارس ١٩٦٥م^(١)، وعلة منع التنفيذ في الحالتين تشجيع الأفراد علي الادخار.

٢- سندات الجهاد:

منع المقنن من توقيع الحجز على سندات الجهاد وعلى فائدها وقيمة استهلاكها، وذلك بالمادة ٩ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧١ بإصدار سندات الجهاد، وعلة المنع هنا تشجيع الأفراد علي الادخار وشراء سندات الجهاد، لتكوين رصيد الأموال لتمويل المجهود الحربي^(٢).

٣- الملكيات الزراعية الصغيرة^(٣):

منع القانون رقم ٥١٣ لسنة ١٩٥٣ التنفيذ علي خمسة الأفدنة الأخيرة للمزارع وملحقاتها.

شروط المنع من التنفيذ على خمسة الأفدنة:

١- أن يكون المدين زارعاً: والزارع هو من كانت حرفته الأصلية الزراعة^(٤)، سواء كانت حرفته الوحيدة أو كان يحترف حرفة أخرى بالإضافة إليها أو كانت حرفته أصلاً الزراعة ثم تقاعد لمرض أو شيخوخة أو كان منقطعاً للزراعة، ولو كان لا يستطيع مباشرتها، كالأرملة التي تدير أرض زوجها المزارع المتوفى أو أرض القاصر الذي لم يبلغ السن التي يستطيع فيها مباشرة الزراعة.

ولا يلزم أن يباشر الزراعة بنفسه فيعتبر زارعا ولو كان يستخدم عمالاً وإنما يلزم أن تكون الزراعة رزقه الأساسي^(٥).

ويكفي أن يكون المنفذ ضده زارعا وقت التنفيذ حتى ولو لم يكن كذلك عند نشوء

(١) التنفيذ الجبري أ.د. / فتحي والي ف ١١١ ص : ٢٢٩ .

(٢) مبادئ التنفيذ أ.د. / محمد عبد الخالق عمر، ف ٣٧٤، ص : ٣٨٩ .

(٣) راجع هذا الموضوع مفصلاً " عدم جواز التنفيذ على الملكيات الزراعية الصغيرة " أ.د حامد أبوطالب.

(٤) نقض مدني جلسة ١٥/١١/١٩٣٦، الطعن رقم ١٥ لسنة ٦ ق.

(٥) ولكن لا يكفي لاعتبار المدين من الزراع أن يقيم بإحدى القرى أو أحد النجوع أو الكفور، أو أن يكون قد سبق اتهامه بتبديد حاصلات زراعية محجوزة، انظر : نقض مدني جلسة ١٩٤٦/١/٣، الطعن رقم ٣ لسنة ١٥ ق .

الدين فالعبرة بصفة الزارع قبل ابتداء التنفيذ واستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع^(١).

ويمتنع التنفيذ على خمسة الأفدنة الأخيرة سواء كان التنفيذ على الكفيل أو على المدين فالنص عام يمنع التنفيذ على الزارع بصرف النظر عن علاقته بالدين وعلى ذلك فالحماية المستمدة من قانون عدم جواز الحجز على خمسة الأفدنة الأخيرة للزارع تتناول كل مدين تتوافر فيه الشروط والقيود التي نص عليها القانون، يستوي في ذلك أن يكون الزارع مديناً أصلياً أم ضامناً^(٢).

وإذا توفي الزارع جاز التنفيذ على التركة، حتى ولو كانت أقل من خمسة الأفدنة، وكان الوارث زارعاً، ذلك أن منع التنفيذ على خمسة الأفدنة الأخيرة التي يملكها الزارع يعد استثناء من الأصل العام الذي تقرره قاعدة أن "أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه"، ومن ثم لا ينصرف الاستثناء إلا لمن تقرر لمصلحته وهو المدين، وتركة المدين تعتبر منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم، وللدائن حق عيني يخوله تتبع تركة المدين لاستيفاء دينه منها بسبب مغايرة شخصية المورث لشخصية الوارث، وحق الدائن أسبق من حق الوارث الذي لا يؤول له من التركة إلا الباقي، فالملكية لا تنتقل إليهم إلا بعد سداد الديون^(٣).

وتقدير من يعد زارعاً مسألة وقائع تدخل في سلطة قاضي الموضوع دون رقابة محكمة النقض.

٢- أن تكون الأرض المراد التنفيذ عليها تدخل في خمسة الأفدنة الأخيرة: والعبرة بملكية المدين وقت التنفيذ حتى ولو كانت ملكيته أكثر من ذلك وقت نشوء الدين.

وإذا كان المدين يملك أكثر من خمسة أفدنة وقت التنفيذ جاز التنفيذ على ما زاد على خمسة الأفدنة، والعبرة في تقدير ما يملكه بملكته القانونية (المسجلة)، وعلى ذلك فلا يجوز التنفيذ على ما يزيد عن خمسة الأفدنة التي لم تدخل في ملكية المدين

(١) نقض مدني جلسة ١٩٧٠/٤/٣، الطعن رقم ١٤٤ لسنة ٣٦ ق .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٣٦/١١/٥، الطعن رقم ١٥ لسنة ٦ ق .

(٣) التنفيذ الجبري أ.د. / فتحي والي ف ١١٠.

بعد لشرائها بعقود عرفية لم تسجل بعد^(١)، كما أن العبرة دائماً بمساحة الأرض لا بقيمتها.

٤- أن يتمسك المدين بعدم جواز التنفيذ على خمسة الأفدنة الأخيرة مما يملكه قبل فوات ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع:

والحكمة من ذلك منع المدين سيء النية من ترك الدائن يباشر إجراءات التنفيذ حتى آخر مرحلة من مراحل التنفيذ، ثم يتمسك بعدم جواز التنفيذ عند البيع لما في ذلك من تطويل للإجراءات وزيادة المصاريف بلا فائدة.

ولا يسقط حق الزارع في التمسك بعدم جواز التنفيذ بنزوله عن هذا الحق مقدماً، ولكن يسقط حقه بفوات ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع.

ومتى توافرت هذه الشروط امتنع التنفيذ، ولكن على من يقع عبء إثبات أن هذه الأرض جائز عليها التنفيذ أو غير جائز؟

يقع عبء الإثبات على المدين^(٢)، فهو الذي عليه أن يثبت أن الشروط اللازمة للاستفادة من الحماية التي ينص عليها القانون متوفرة فيه؛ لأن الأصل جواز التنفيذ على جميع أموال المدين، وعلى من يدعي عم جواز التنفيذ على مال معين أن يثبت ما يبرر عدم جواز التنفيذ.

(١) من هذا الرأي أستاذنا الدكتور / عبد الباسط جميعي . يرحمه الله . في نظام التنفيذ ص ١٢٠، أ.د. / فتحي والي، التنفيذ الجبري ف ١١٠ حاشية ص ٢٢٣، أ.د. / أحمد سلامة القانون الزراعي ص ٥١، أ.د. / عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ ص : ٢٥٣ .

وانظر غير هذا للأستاذ الدكتور / سامي مازن، قانون خمسة الأفدنة ف ٨، أ.د. / وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ، ص ٣١٤، أ.د. / رمزي سيف، قواعد تنفيذ الأحكام ص : ١٦٩، أ.د. / أحمد أبو الوفا إجراءات التنفيذ الجبري ص ١٨٦، أ.د. / عبد المنعم الشرقاوي، التعديلات التشريعية ف ٧، أ.د. / حسن اللبيدي، أصول التنفيذ، ص : ٢٤٣، حيث يرون أن العبرة بالملكية الفعلية للمزارع، ويعتد بما يملكه الزارع، حتى ولو كانت ملكيته غير مسجلة .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٤٦/١/٣، الطعن رقم ٣ لسنة ١٥ ق .

الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها:

يشمل المنع من التنفيذ إذا توافرت شروطه الأموال الآتية:

١ - الخمسة الأفدنة الأخيرة من الأراضي الزراعية التي يملكها الزارع، أما الأملاك غير الزراعية، كالأراضي المعدة للبناء فيجوز التنفيذ عليها.

٢ - مسكن الزارع وملحقاته، ويقصد به المكان المعد لسكن الزارع وأفراد عائلته . وإن تعدد . ولكن يجوز التنفيذ على المساكن الأخرى التي يملكها الزارع ولا يسكنها، ويقصد بملحقات المسكن ما يتبعه من مرافق كالأماكن التي يضع فيها الزارع مواشيهم ومحاصيلهم وأدوات زراعتهم، والمنع من التنفيذ على المسكن تابع للمنع من التنفيذ على الأراضي، وعلى ذلك فإذا كان الزارع لا يملك أرضاً زراعية صح توقيع الحجز على مسكنه.

٣ - الآلات الزراعية والمواشي اللازمة لاستثمار الأرض غير الجائز التنفيذ عليها، والمراد بها العدد والأدوات التي تلزم المزارع كالمحراث والنورج بشرط أن تكون لازمة للقدر الممنوع التنفيذ عليه من الأرض الزراعية، أما ما يزيد عن ذلك فيجوز التنفيذ عليه.

استثناءات تطبيق قانون الخمسة أفدنة:

المنع من التنفيذ على خمسة الأفدنة وملحقاتها ليس مطلقاً، وإنما يجوز التنفيذ عليها للديون الآتية تقديراً بأن أصحابها أولى بالرعاية من الزارع .

١ - **الديون الممتازة:** وهي الديون التي يكون لأصحابها حق امتياز على الأرض الزراعية كامتياز بائع العقار لاقتضاء ثمنه، أما الدائن المرتهن أو صاحب حق الاختصاص فيمتنع عليه التنفيذ رغم أن رهن خمسة الأفدنة الأخيرة للزارع يكون صحيحاً إلا إذا زالت الحماية عن المنفذ ضده بأن زالت عنه صفة الزارع .

٢ - **الديون الناشئة عن جنائية أو جنحة:** وهي تشمل التعويضات المدنية المترتبة على هذه الجرائم، سواء أكانت مقررة بحكم أو اتفاق، كما تشمل الغرامة التي يحكم بها عليه بسبب جنائية أو جنحة، فيجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ العقاري على الزارع وفاء لأي

من هذه الديون على الزارع، ولو لم تجاوز ملكيته الزراعية خمسة أفدنة، ولا محل لإخراج الغرامة المحكوم بها من هذا الاستثناء، وذلك حتى لا يفلت الزارع الذي يقدم على ارتكاب جناية أو جنحة من نتائج جريمته عن طريق التمسك بمبدأ القانون.

٣- **ديون النفقة:** المترتبة على الزوجية وأجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن، وما يكون مستحقاً من المهر، وذلك لحاجة أصحاب هذه الديون لمعيشتهم، فهم أجدر بالحماية من الزارع المدين بها.

٤- **الديون التي تنص القوانين الخاصة على عدم سريان المنع من التنفيذ عليها:** كالديون المستحقة للحكومة، وبنك التسليف، والجمعيات التعاونية.

٥- **الديون الثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون:** وعلى ذلك فالدائن الذي كان يجوز له التنفيذ وفقاً للقانون القديم على خمسة الأفدنة الأخيرة، وكان دينه ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون الجديد يظل له الحق في التنفيذ على خمسة الأفدنة الأخيرة .

مدى تعلق منع التنفيذ على خمسة الأفدنة بالنظام العام:

المنع من التنفيذ على خمسة الأفدنة الأخيرة لا يتعلق بالنظام العام، وعلى ذلك فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويجب على المدين أن يتمسك به؛ لأنه مقرر لمصلحته، خصوصاً وأن المفروض أن القاضي لا يعلم إن كان المدين يملك خمسة أفدنة أو أقل أو أكثر.

ويؤيد هذا الرأي أن المقنن أوجب التمسك بعدم جواز التنفيذ قبل فوات ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع، وإلا سقط الحق فيه مع أن الدفوع المتعلقة بالنظام العام يجوز التمسك بها في أي مرحلة من مراحل التنفيذ^(١).

(١) راجع في محل التنفيذ قواعد تنفيذ الأحكام للدكتور / رمزي سيف، ص ١٤١ وما بعدها، النظرية العامة للتنفيذ القضائي للدكتور / وجدي راغب، ص ٢٧٣ وما بعدها، الوجيز في قواعد وإجراءات التنفيذ للدكتور / عبد العزيز بديوي ص ١١٦ وما بعدها، التنفيذ علماً وعملاً للأستاذين / أحمد قمحة، وعبد الفتاح السيد، ص

تقدير عدم جواز التنفيذ على خمسة الأفدنة الأخيرة:

رأينا كيف أن المقنن في قانون "منع التنفيذ على خمسة الأفدنة" فضل فئة من المدينين وهم الزراع على الدائنين، وأخرج قدراً كبيراً من أموال هؤلاء الزراع من الضمان العام الذي للدائنين، وتدخل المقنن على هذا النحو إن كان له ما يبرره في بداية القرن الحالي أو في وسطه، فليس له أي مبرر في نهاية هذا القرن، بل أصبح هذا التدخل يمثل خللاً في العلاقات بين الأفراد، حيث يسلب وسائل الدفاع عن الحقوق عن طائفة لصالح فئة من طائفة أخرى.

وهذا التدخل يعود بأثر عكسي على فئة الفلاحين، حيث يحجم الناس عن التعامل معهم بالأجل، لعدم توافر الحماية القانونية للحقوق قبلهم، وهذا ما حدث فعلاً، ولم يعد للفلاح ملجأ إلا بنوك الائتمان والجمعيات الزراعية، التي تمكنت بنفوذها من الحد من أثر هذا القانون إلى حد بعيد جداً؛ حيث أبطلت مفعوله في مواجهتها بعد فترة وجيزة من صدوره، فقد صدر القانون ٥١٣ لسنة ١٩٥٣ في ٢٩/١٠/١٩٥٣م يمنع التنفيذ على خمسة الأفدنة الأخيرة، وفي ٢٢/٧/١٩٥٤م، وبعد أقل من تسعة أشهر صدر القانون ٤٢٠ لسنة ١٩٥٤م، ونص في مادته الأولى على أنه لا تسري أحكام القانون رقم ٥١٣.... على الديون المستحقة للحكومة، والبنك الزراعي، والجمعيات التعاونية".

وفي رأيي أن هذا يعد اعترافاً من المقنن بخطورة بقاء القانون ٥١٣ على التعامل بالأجل، ومن ثم ألغاه في مواجهة المتعامل الرئيسي والأساسي مع الفلاح. ومن ثم لنا أن نتساءل ما قيمة بقاء هذا القانون الآن؟

نبادر بالإجابة بأنه لم تعد له قيمة أساسية إلا في مواجهة عامة الشعب، وقد أحجموا عن التعامل بالأجل مع الفلاح. ومن هنا فإننا نرى ضرورة تدخل المقنن وإلغاء هذا القانون كلية حتى يعود التوازن في التعامل بالأجل بين الفلاح وغيره^(١).

٨١ وما بعدها، مبادئ التنفيذ القضائي للدكتور/ عبد الخالق عمر، ص ٢١٦، وما بعدها، التنفيذ الجبري للدكتور / فتحي والي ف ٩٢ وما بعدها.

(١) عدم جواز التنفيذ على الملكيات الزراعية الصغيرة، أ د حامد أبوطالب، ص ١١١، ١١٢.

المطلب الثالث

الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها في الفقه الإسلامي^(١)

إذا كان قانون المرافعات - وعلى النحو الذي سبق بيانه - لا يجيز الحجز على بعض أموال المدين، بحيث يخرجها من الضمان العام في أموال المدين، ويستثنى منها القاعدة العامة التي تقضي بأن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، فيحظر الحجز على هذه الأموال المستثناة، فإن الفقه الإسلامي - وكعادته دائماً - كان أسبق من القانون في هذا الشأن، حيث نص فقهاء الشريعة الإسلامية على أن هناك أموالاً لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها لاستيفاء دين الدائن، وهذه الأموال هي:

أولاً: آلات الحرفة والصناعة:

اختلف الفقهاء في مدى جواز بيع آلات الحرفة التي يستعملها المدين، وللفقهاء في هذه المسألة قولان:

الأول: عدم جواز الحجز على آلات الصانع، بل تترك له ليتكسب بها ولا تحجز ولا تباع، وهذا مذهب الشافعية في قول، والحنابلة، والمالكية في قول^(٢).

قال أبو حفص "الصانع إذا أفلس ترك له آلة البناء إن كان بناء، وكذلك جميع الصانع تترك لهم الآلة لأنهم بها يتمتعون"^(٣).

واستدل أصحاب هذا القول بأن آلات الصانع هي مصدر رزقهم، ولا يستطيعون الاستغناء عنها، ولأنها هي وسيلة لسداد ديونهم.

الثاني: جواز بيع آلات الصانع والمحترفين لصالح الغرماء، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، في الراجح عندهما^(٤).

ونتفق مع البعض^(٥) في عدم جواز بيع آلة الصانع سواء أكانت زهيدة الثمن أم

(١) د. أحمد علي يوسف جرادات، مرجع سابق، ص ٣٤٩ وما بعدها.

(٢) مغنى المحتاج للشربيني ج ١٤٥/٢، المغني لابن قدامة، ٤٩٣/٤، مواهب الجليل للحطاب، ج ٦/٦٠٥.

(٣) مواهب الجليل للحطاب، ج ٦/٦٠٥.

(٤) شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج ٤٨٥/٥، مغنى المحتاج للشربيني، ١٥٤/٢.

(٥) د. أحمد علي يوسف جرادات، مرجع سابق، ص ٣٥٣.

باهظة الثمن لأن هذه الآلة هي مصدر رزق المدين، ولا يستطيع الاستغناء عنها، لأنها وسيلة مهمة لسداد الدين المترتب عليه.

ثانياً: دار السكنى:

اختلف الفقهاء في بيع دار السكنى للمدين على قولين:

الأول: عدم بيع دار السكنى إلا ما زاد عن الحاجة، أو كانت الدار عين مال الغرماء، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وقول مرجوح لدى المالكية والشافعية^(١).

- جاء في المغني "وإن كان مسكنه واسعاً لا يسكن مثله في مثله، بيع واشترى له مسكن مثله، ورد الفضل على الغرماء"^(٢).

واستدل هذا المذهب بما يلي:

- قوله صلى الله عليه وسلم «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»^(٣). وهذا لم تطب به نفسه^(٤).

- لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه عندما جر على معاذ وباع عليه ماله، أخرجه من داره وجرده من ملابسه وثيابه لبيعها، فدل ذلك على أن للغرماء أخذ ما وجدوا من أموال لدى الغريم غير اللباس والمسكن.

- أن الدار التي يسكنها المدين هي من الأشياء الضرورية لحياته، فيها تستر عورته صيفاً وشتاء فلا يستطيع الاستغناء عنها كعدم استغنائه عن اللباس^(٥).

الثاني: أنها تباع ويستأجر غيرها، لأن هذه الأمور يمكن تحصيلها بالأجرة، وهذا مذهب المالكية والشافعية في الراجح عندهما^(٦).

واستدل أصحاب هذا المذهب بما يلي :

(١) رد المحتار لابن عابدين، ج ٩٥/٥، المغني لابن قدامة، ج ٤٩٣/٤، الإنصاف للمرداوي، ج ٢٢٥/٥، شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج ٤٧٧/٥.

(٢) المغني لابن قدامة، ج ٤٩٣/٤.

(٣) مسند الإمام أحمد، ج ٤٢٣/٣.

(٤) الزخيرة للقرافي، ج ١٣/٧.

(٥) د. أحمد علي يوسف جرادات، مرجع سابق، ص ٣٥٠.

(٦) الزخيرة للقرافي، ج ٧/، مغني المحتاج للشربيني، ج ١٤٥/٢.

- ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال "أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فقال صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك" (١).
- ووجه الدلالة من الحديث: أنه يجوز للغرماء أن يأخذوا ما وجدوا من أموال المدين، والدار التي يسكنها هي من صنف ماله (٢). قال الشوكاني: استدل بالحديث على أن المفلس إذا كان له من المال دون ما عليه من الدين، كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال، ولا يجب عليه لهم شيء غير ذلك (٣).
- أن المدين في حال بيع داره يمكنه استئجار غيرها بثمان أقل، وفي هذا تحقيق لمصلحة الغرماء الذين حجب عليه لأجلهم عندما يأخذون الفارق بين ثمن الدار وقيمة الاستئجار (٤).
- ويرجح البعض (٥) بيع دار السكنى في حالتين: إذا كانت هي عين مال الغرماء، أو كانت كبيرة وزائدة عن حاجة المدين، وتنفق مع هذا الرأي.

ثالثاً: الأثاث الذي يستعمله المدين في منزله وثيابه وكسوته ونفقته:

اتفق الفقهاء على أن المدين إذا بيع ماله يترك له من الملابس والأثاث الضروري له (٦). قال فقهاء الحنفية "ويترك عليه دست من ثياب بدنه وبيع الباقي لأن به كفاية، وقيل دستان لأنه إذا غسل ثيابه لا بد له من ملابس" (٧). وقال فقهاء المالكية "ويترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام" (٨). كما أوجب جمهور الفقهاء الإنفاق على المدين

(١) سبق تخريجه.

(٢) نيل الأوطار للشوكاني، ج ٥/٢٤٢.

(٣) المرجع السابق، ج ٥/٢٤٢.

(٤) د. أحمد علي يوسف جرادات، مرجع سابق، ص ٣٥٠.

(٥) المرجع السابق، ص ٣٥١.

(٦) الزخيرة للقرافي، ج ٧/١٤٥ - المغني لابن قدامة، ج ٤/٤٩٠.

(٧) الهداية للمرغاني، ج ٣/٣٢٠. والدست ما يلبسه الإنسان من الثياب ويكفيه لترده في حوائجه (المصباح

المنير ج ١/٢٦٣).

(٨) مواهب الجليل للحطاب، ج ٦/٦١٣.

وزوجته وأولاده الصغار، لأن ذلك لا بد منه ولا تقوم النفس بدونه^(١).

رابعاً: كتب العلم:

اختلف الفقهاء في جواز حجز وبيع كتب العلم التي يستخدمها المدين لكونه طالب علم، أو يستخدمها للمطالعة والاستعمال الشخصي على قولين؛ الأول: عدم جواز الحجز على هذه الكتب وبيعها. وهذا مذهب الشافعية، ورأي مرجوح عند المالكية. جاء في مغنى المحتاج "ويترك للعالم كتبه"^(٢)، وقال المالكية إذا كان محتاجها فلا يجوز بيعها^(٣). والثاني: أنه يجوز الحجز على كتب العلم وبيعها، وإلى هذا ذهب المالكية في الراجح عندهم.

(١) مواهب الجليل للحطاب، ج ٦/٦١٣، المغني لابن قدامة، ج ٤/٤٩٠.

(٢) مغني المحتاج للشرييني، ج ٢/١٥٤.

(٣) شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج ٥/٤٨٤ - ٤٨٥ .

الفصل الرابع

مقدمات التنفيذ ومنازعاته

الفصل الرابع

مقدمات التنفيذ ومنازعاته

القاعدة العامة أنه لا يجوز التنفيذ على أموال المدين؛ إلا بعد اتخاذ المقدمات التي أوجبها المشرع، وهي تقديم طلب التنفيذ، وإعلان السند التنفيذي، ومضي مدة معينة بعد الإعلان. وقد تثار بعض المنازعات قبل البدء في التنفيذ أو أثناءه أو بعد تمامه، وهذه المنازعات قد تكون موضوعية، وقد تكون وقتية يقصد بها تقرير حماية مؤقتة لحين الفصل في موضوع التنفيذ، وفي جميع الأحوال؛ فإن قاضي التنفيذ هو المختص كقاعدة بالفصل في هذه المنازعات.

ونتناول في هذا الفصل بيان مقدمات التنفيذ في مبحث أول، ثم نتحدث عن منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في مبحث ثان.

المبحث الأول

مقدمات التنفيذ

يوجب المشرع اتخاذ مقدمات التنفيذ قبل البدء في إجراءاته، ولا تعد هذه المقدمات من إجراءات التنفيذ؛ وإنما هي سابقة عليها، وضرورية ولازمة لها، فلا يجوز التنفيذ كقاعدة إلا بعد مباشرة هذه المقدمات أيا كان نوع التنفيذ، أي سواء كان تنفيذا مباشرا، أو تنفيذا بنزع الملكية، وفي بعض الأحيان يجيز المشرع التنفيذ دون اتخاذ هذه المقدمات، وهذه المقدمات هي: تقديم طلب التنفيذ، وإعلان السند التنفيذي، ومضي يوم بعد إعلان السند التنفيذي وقبل التنفيذ، وبين ذلك فيما يلي:

أولا: تقديم طلب التنفيذ:

وفقا لنص المادة (٢٧٨) مرافعات؛ فإنه يجب أن يقوم طالب التنفيذ بتقديم طلب إلى إدارة التنفيذ يطلب فيه اتخاذ إجراءات التنفيذ، ولا يملك معاون التنفيذ أن يباشر أي إجراء من إجراءات التنفيذ قبل تقديم هذا الطلب إلى مدير إدارة التنفيذ وفقا لنص المادة (٢٧٩) مرافعات.

بحيث يكون معاوني التنفيذ ملزمون بالبدء في الإجراءات بعد صدور أمر بذلك من مدير إدارة التنفيذ الذي قدم إليه الطلب أو من يقوم مقامه من قضاتها. ولم يوجب المشرع شكلا معيناً لطلب التنفيذ، ومن ثم يجوز أن يقدم إلى معاون التنفيذ، شفويا أو مكتوبا، وإذا قدم الطلب مكتوبا فيجب أن يتضمن البيانات اللازمة للتنفيذ، كبيانات طالب التنفيذ، والمنفذ ضده، ونوع التنفيذ المطلوب، وما يفيد طفاة الطلب في إجراءاته.

ويجب على معاون التنفيذ بعد تقديم هذا الطلب والتحقق من اتخاذ مقدمات التنفيذ الأخرى، أن يباشر إجراءات التنفيذ في دائرة اختصاصه، تحت إشراف ورقابة مدير إدارة التنفيذ أو من يقوم مقامه من قضاتها.

ثانيا: إعلان السند التنفيذي قبل مباشرة إجراءات التنفيذ:

يجب قبل البدء في إجراءات التنفيذ أن يقوم الدائن بإعلان المدين بالسند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بمقتضاه وتكليفه بالوفاء بالدين، حيث تنص المادة (٢٨١) مرافعات على أنه "يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلا. ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة. ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية. ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي".

وإعلان السند التنفيذي ليس عملا من أعمال التنفيذ؛ وإنما من الأعمال التي تعد مقدمات التنفيذ، ويترتب على إغفاله بطلان إجراءات التنفيذ، غير أن هذا البطلان مقرر لمصلحة المدين الذي يكون له الحق أن يتنازل عن التمسك بهذا البطلان ومن ثم يصبح التنفيذ صحيحا بغير مقدماته^(١).

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "إعلان الحكم أو السند الواجب التنفيذ للمدين والتنبيه عليه بالوفاء وأن كان من الإجراءات التي رتب القانون على إغفالها البطلان

(١) المستشار. سيد حسن البغال، المطول، المجلد الثاني، ص ٦٠٧.

إلا أن هذا البطالان لا يتعلق بالنظام العام؛ إذ هو قد شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به؛ فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن هذا الاعتراض لم يبد من الطاعن الحائز وهو غير المدين فإن النتيجة التي انتهى إليها الحكم برفض هذا الاعتراض تكون صحيحة في القانون^(١).

ويجب إعلان السند التنفيذي أيا كان نوع هذا السند سواء كان حكما أو محررا موثقاً أو محضر صلح مصدق عليه من المحكمة أو غير ذلك من السندات التنفيذية، كما يجب إعلان السند التنفيذي أيا كان مضمون الإلزام الوارد به، كما لو كان صادر بتسليم منقول أو بإخلاء عقار أو بهدم بناء أو إقامته أو بفتح مروي أو مصرف أو سد مطل أو بتسليم صغير أو بطاعة زوجة لزوجها. مع ملاحظة أنه إذا تعدد المدينين فيجب إعلان كل منهم بصورة من السند عليها التنفيذي فلا يكفي إعلان أحدهم أو بعضهم فقط^(٢).

(١) الطعن رقم ٢٧٥ لسنة ٢٥ قضائية - جلسة ١٩/١١/١٩٥٩.

(٢) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني: التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية، ص ١٨٤.

وإذا كانت القاعدة العامة في هذا الصدد هي وجوب إعلان السند التنفيذي قبل البدء في إجراءات التنفيذ إلا أن هذه القاعدة يرد عليها بعض الاستثناءات، من ذلك:

١- ما تنص عليه المادة (٢٨٦) مرافعات من أنه "يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ". فطبقا لهذا النص يمكن البدء في التنفيذ فوراً دون حاجة إلى الإعلان أو الانتظار يوم كامل من تاريخ الإعلان، إذا كان الحكم صادرا في مادة مستعجلة أو في الحالة التي يكون فيها التأخير ضارا، إلا أنه يشترط لذلك أن تأمر المحكمة في حكمها بتنفيذه بموجب مسودته بناء على طلب المحكوم له.

٢- ما تنص عليه المادة (٤٤٩) مرافعات من أنه "لا يعلن حكم إيقاع البيع". حيث يجوز للمشتري بالمزاد طبقا لهذا النص تنفيذ حكم إيقاع البيع دون حاجة إلى إعلانه للمدين، وذلك بهدف التيسير على المشتري بالمزاد.

٣- كذلك لا يلزم اتخاذ مقدمات التنفيذ بالنسبة للأحكام التي لا تتطلب تنفيذا جبريا. كما لا يتصور اتخاذ مقدمات التنفيذ بالنسبة للحجوز التحفظية لأن هذه المقدمات لازمة فقط للحجوز التنفيذية.

(د. أحمد مليجي، مرجع سابق، ج ٩٨٩/٥ - أستاذي د. الأنصاري النيداني، التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية، ص ١٨٧-١٨٨).

الهدف من إعلان السند التنفيذي:

يهدف إعلان السند التنفيذي إلى المدين كإجراء من مقدمات التنفيذ إلى تمكين المدين من مراجعة السند التنفيذي والتأكد من صلاحيته لإجراء التنفيذ بمقتضاه واستيفائه لكافة الشروط التي تطلبها المشرع في السند الذي يتم تنفيذه . كذلك فإن إعلان السند التنفيذي للمدين يتضمن الإفصاح عن رغبة الدائن في الحصول على حقه ونفي شبهة التسامح في الحصول على هذا الحق، بحيث يتأكد المدين أن الدائن مصر على إجراء التنفيذ الجبري أن لم يقم المدين اختياراً بأداء ما هو مطلوب منه^(١).

السلطة المختصة بإعلان السند التنفيذي:

وفقاً لتعديل المادة (٢٨٢) مرفعات بمقتضى القانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ فإن المختص بإعلان السند التنفيذي هو معاون التنفيذ، حيث نصت المادة المشار إليها على أنه "على معاون التنفيذ عند إعلانه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطائه المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص". وذلك على خلاف القاعدة العامة في إعلان الأوراق القضائية والتي ورد النص عليها في المادة السادسة من قانون المرافعات بنصها على أن "كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلائهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها...".

كيفية إعلان السند التنفيذي:

يجب أن يعلن المدين بالصورة التنفيذية للسند التنفيذي، بحيث يتم الإعلان بصورة من السند المزيل بالصيغة التنفيذية، بحيث إذا أعلن المدين بصورة من السند خالية من الصيغة التنفيذية؛ فإن الإعلان يكون باطلاً ولا يرتب أثراً، ذلك أن إعلان المدين بصورة من السند مزيل بالصيغة التنفيذية يؤكد حق الدائن في التنفيذ الجبري، ويؤكد

(١) د. أحمد هندي: أصول التنفيذ الجبري، ص ٢٣٥ - د. أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ، ص ٣٢٤ - المستشار. محمد عزمي البكري: الحجز القضائي على المنقول في ضوء الفقه والقضاء، دار محمود للنشر والتوزيع، (د.ت)، ص ١٥٤.

جدية الإجراءات، وعزم الدائن على المضي في إجراءات التنفيذ الجبري؛ إن لم يقم المدين بالتنفيذ الاختياري.

كما يجب أن يتم الإعلان لشخص المدين أو في موطنه الأصلي، حيث لا يجوز الإعلان في الموطن المختار الذي كان له أثناء نظر الدعوى التي صدر فيها الحكم، ولا الموطن المختار في العقد الرسمي المطلوب تنفيذه.

كما يجب أن يتضمن الإعلان تكليف المدين بالوفاء، وفي هذا الشأن يجب أن يشتمل هذا التكليف على ثلاثة بيانات:

١- بيان الأداء المطلوب من المدين القيام به، وما إذا كان مبلغا نقديا أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

٢- إنذار المدين بالوفاء بالدين.

٣- إنذاره بأنه إذا لم يقم بالوفاء اختيارا فإن الدائن سيضطر إلى البدء في إجراءات التنفيذ في مواجهته.

ولا يترتب على انعدام التكليف بالوفاء أو بطلانه بطلان الإعلان، وإنما يكون الإعلان صحيحا ويجب على الدائن أن يقوم بتكليف المدين بالوفاء بورقة مستقلة قبل البدء في إجراءات التنفيذ، إلا أنه يجب في جميع الأحوال أن يكون التكليف بالوفاء لاحقا على إعلان السند التنفيذي وليس سابقا عليه^(١). ويترتب على تكليف المدين بالوفاء انقطاع التقادم الساري لمصلحته.

كما يجب أن يتضمن الإعلان بيان موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ وذلك حتى يعلنه فيه المدين بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ .

ثالثا: ضرورة منح المدين مهلة قبل التنفيذ^(٢):

يجب على الدائن بعد إعلان السند التنفيذي للمدين أن يمنحه مهلة قبل الشروع في التنفيذ، وهذه المهلة طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٨١) مرافعات هي يوم واحد من تاريخ إعلان المدين بالسند التنفيذي. حيث نصت الفقرة المشار إليها على أنه "ولا

(١) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني، التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية، ص ١٨٦ - ١٨٧.

(٢) المرجع السابق، ص ١٩٨.

يجوز إجراء التنفيذ لإلأبعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي".

فلا يكفي لصحة التنفيذ أن يقوم طالب التنفيذ بإعلان المدين بالسند التنفيذي وإنما يجب عليه أن ينتظر مضي يوم كامل بين إعلان السند التنفيذي اتخاذ إجراءات التنفيذ، وذلك لعدم مباغته المدين بالإعلان والتنفيذ فوراً.

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (١/٢٨٤) مرافعات والتي نصت على أنه "إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذي".

المبحث الثاني

منازعات التنفيذ

كثيراً ما تنثور أثناء التنفيذ عقبات قانونية قد يثيرها المدين بدافع حماية حقه، أو لرداً منه وكيداً للدائن وكسباً للوقت، وقد يثيرها الدائن لدفع عجلة التنفيذ إن وقفت، كما يثيرها غيره حماية لحقه أو لتحقيق غرض للدائن أو للمدين.

وتختلف هذه المنازعات عن العقبات المادية التي يقيمها المدين أو غيره في طريق التنفيذ كغلق الأبواب أو التجمهر، تلك العقبات التي يزيلها معاون التنفيذ بنفسه أو عن طريق الاستعانة بالقوة العامة والسلطة المحلية.

أما العقبات القانونية فنظراً لأنها قد تكون مبنية على أسباب قانونية فمن العدل أن يقف التنفيذ معها . كما إذا كان الدين الذي جرى التنفيذ اقتضاء له مؤجلاً أو معلقاً على شرط لم يتحقق، أو كما لو كان الحجز قد وقع على مال مملوك لغير المدين، لذلك فقد اهتم المقنن بهذه العقبات فبين المحكمة المختصة بها وقواعد قبولها وإجراءاتها وحدد أثرها على التنفيذ، وذلك حتى يوازن ما بين مصلحة دائن ينفذ

بمقتضى سند تنفيذي في يده ومدين يعارض في وجود الحق مثلاً. ويمكن تعريف منازعات التنفيذ بأنها: الاعتراضات القانونية التي تنشأ عن التنفيذ.

ولكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ يتعين أن يكون التنفيذ جبرياً، وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سيره وإجراءاته، أما المنازعات التي لا تمس التنفيذ أو تتصل بإجراء من إجراءاته، أو لا تؤثر في سيره، فلا تعد منازعة من منازعات التنفيذ.

وتنقسم فيما بينها إلى أقسام عدة، وفقاً لاعتبارات مختلفة، ونوضح ذلك على النحو التالي:

أ- تقسيم المنازعات بحسب الوقت الذي تثار فيه:

يتصور أن تثار منازعة التنفيذ قبل البدء فيه، وذلك كما إذا نازع المدين في إنكار القوة التنفيذية للسند التنفيذي أو في انقضاء التزامه دون أن ينتظر توجيه إجراءات التنفيذ إلى جزء من ماله، وقد تثار المنازعة أثناء التنفيذ، وهي الصورة الغالبة، وقد تثار بعد تمام التنفيذ، كما هو شأن الدعوى بطلب بطلان البيع، أو بطلب بطلان التوزيع.

وتظهر أهمية هذا التقسيم بصدد الإشكالات الوقتية فهي لا تقبل إلا إذا أثبتت قبل تمام التنفيذ، وإذا كان التنفيذ قد تم وجب الحكم بعدم قبولها.

٢- تقسيم المنازعات بحسب موضوعها:

قد تنصب المنازعة على السند التنفيذي، كالمنازعة في أن الحكم المراد تنفيذه غير نافذ قانوناً، وقد تنصب على الحق الذي يجري التنفيذ اقتضاء له، ككون الحق مؤجلاً أو سقط بالتقادم، وقد تنصب على المال محل التنفيذ، ككون الأموال المراد توقيع الحجز عليها مما لا يجوز حجزه أو هي ملك للغير، وقد تنصب على إجراءات التنفيذ، كما إذا كان الدائن قد أغفل مقدمات التنفيذ، أو أوقع الحجز قبل مضي يوم من الإعلان.

وفي الواقع يمكن القول بأن المنازعة الموضوعية كل منازعة ناشئة عن التنفيذ يُطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية خلاف ذلك فهي كل منازعة يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق.

٣- تقسيم المنازعات بحسبان أطرافها:

قد تنثار المنازعة من المدين وهي الصورة الغالبة، وقد تنثار من الدائن بطلب السير في إجراءات التنفيذ عند امتناع معاون التنفيذ عن مباشرة الإجراءات بحجة قيام مانع قانوني يمنع من السير في الإجراءات، وقد تنثار المنازعة من جانب الغير في مواجهة طرفي التنفيذ، كادعائه بأنه يملك الأشياء المحجوزة.

٤- تقسيم المنازعات بحسبان طبيعة الحكم الصادر فيها:

قد يطلب الحكم في المنازعة بوقف التنفيذ أو يطلب الاستمرار فيه، فهذه منازعة وقتية (إشكال)، وهنا يوصف الحكم بأنه حكم وقتي ، وقد يطلب في المنازعة الحكم في موضوعها بحكم يحسم صحته أو عدم صحته، فهذه منازعة موضوعية، وهنا يوصف الحكم بأنه حكم موضوعي.

هذا، ويلاحظ : أن العبرة بوصف الطلب طبقاً للقانون ولا يعتد بتكييف الخصم له إذا كان مخالفاً للقانون ولكن الخصم يبدأ إجراءاته معتداً بالوصف القانوني الذي يراه هو صحيحاً ويتمسك بالآثار القانونية المترتبة على ذلك وهنا يتحمل مغبة هذا التصرف بحيث إذا رأت المحكمة أن وصفه لا يتطابق مع القانون فإنها تعتد بالوصف الصحيح وعندئذ يكون لخصمه أن يطالب بتصحيح الإجراءات والأوضاع القانونية المترتبة على ذلك .

ونتناول الحديث فيما يلي عن المنازعات الوقتية فق مطلب أول، ثم الحديث عن المنازعات الموضوعية في مطلب ثان.

المطلب الأول المنازعات الوقتية (إشكالات التنفيذ)

تعريفها:

قد يثير المنفذ أو المنفذ ضده أو الغير عقبة قانونية؛ دفاعاً عن حق له كأن يطلب المنفذ ضده من المحكمة الحكم ببطلاق إجراءات التنفيذ، أو كأن يطلب طالب التنفيذ الحكم بصحة إجراءات الحجز، أو كأن يطلب الغير الحكم ببطلاق الحجز، وقد يطول نظر الدعوى أمام القضاء، بينما تكون إجراءات التنفيذ سائرة في طريقها مما يؤدي إلى بيع الأموال المحجوز عليها، مما يترتب عليه ضرر جسيم لا يمكن تداركه، أو قد تكون الإجراءات متوقفة مما يصيب طالب التنفيذ بضرر جسيم.

وأياً ما كان سبب المنازعة الموضوعية للمدين وللغير أن يطلب من القضاء اتخاذ وقتي في وقف التنفيذ مؤقتاً، كما أن للدائن إذا وقف التنفيذ أن يطلب اتخاذ إجراء وقتي يتمثل في إجراء التنفيذ مؤقتاً. وعلى ذلك يمكن تعريف المنازعة الوقتية بأنها: "طلب اتخاذ إجراء مؤقت يتعلق بالتنفيذ".

شروط قبول المنازعة الوقتية (الإشكال):

إذا رفع الإشكال وكان الطلب وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتاً دون التعرض لأصل الحق وجب أن يتوافر فيه شروط معينة وإذا فقد شرط من هذه الشروط تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة في رفعها، وهذه الشروط هي:

الشرط الأول: أن يكون الإشكال قد رفع قبل تمام التنفيذ:

فإذا كان التنفيذ قد تم فلا يتصور وقفه أو الاستمرار فيه مؤقتاً، ومن ثم إذا كان التنفيذ قد تم وطلب ذلك فيجب على قاضي التنفيذ أن يحكم بعدم قبول الطلب العام المصلحة فيه، ولا يحكم بعدم اختصاصه، لأنه مختص فعلاً بنظره سواء كان التنفيذ قد تم أو لم يتم، ولكن إذا كان التنفيذ قد تم في مرحلة من مراحله فلا مانع يمنع من قبول الإشكال عن مرحلة أخرى لم تتم.

وعلى ذلك يجوز رفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ ويكون مقبولا؛ حيث لا يشترط لقبول الإشكال أن يكون التنفيذ قد بدأ فعلاً، ويكون الغرض من الإشكال توقي ما يلحق المدين من ضرر إن انتظر حتى يتم التنفيذ.

ولكن ما الحكم إذا رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ ثم تم التنفيذ قبل الحكم في الإشكال؟ ثار خلاف حول قبول الإشكال في هذه الحالة، فذهب بعض الشراح^(١) إلى عدم قبول الإشكال في هذه الحالة، وذلك لاستحالة تنفيذ الحكم الذي يصدر، وبذلك تتنفي المصلحة في الطلب.

وذهب رأى آخر^(٢) إلى قبول الإشكال في هذه الحالة، وللقاضي أن يوقف التنفيذ، ذلك أن العبرة في قبول الدعوى يوم رفعها، حتى لا يضار المدعي من تأخير الفصل في دعواه فما دامت كانت مقبولة يوم رفعها فإنها تظل كذلك ولو زالت بعض شروط قبولها أثناء نظرها .

وينبغي الأخذ بالرأي الثاني أن الإشكال ما دام قد رفع قبل تمام التنفيذ يمكن الحكم بالوقف، حتى ولو ظهر للمحكمة أن التنفيذ قد تم في الفترة ما بين رفع الإشكال والنظر فيه، وذلك لأن القاعدة العامة هي أن المحكمة تنظر الطلبات المقدمة إليها من حيث صحتها وقبولها باعتبار يوم تقديمها، حتى لا يضار أحد الخصوم من جراء تأخير القضاء في نظر الطلبات والفصل فيها.

وأما تنفيذ الحكم الذي يصدر بوقف التنفيذ الذي تم فهو يكون بعدم الاعتداد بالإجراءات التي اتخذت بعد رفع الإشكال ويتعين إعادة الحال إلى ما كانت عليه وقت رفع الإشكال.

(١) الدكتور / أحمد أبو الوفا في إجراءات التنفيذ . ص ٣٨٥ .

(٢) الدكتور / فتحي والي في التنفيذ الجبري ص ٦٨٥، أستاذنا الدكتور / عبد الباسط جميعي . يرحمه الله .
في طرق وإشكالات التنفيذ . ١٨٤ .

الشرط الثاني: أن يحكم في الإشكال قبل صدور حكم في المنازعة الموضوعية:

لأن الغرض من رفع الإشكال هو اتخاذ إجراء مؤقت لحين صدور حكم موضوعي، فإذا كانت المنازعة الموضوعية قد صدر فيها حكم نهائي فإن مراكز الخصوم تكون قد تحددت تحديداً نهائياً، ومن ثم فلا حاجة لتحديدتها تحديداً مؤقتاً والحكم الموضوعي الصادر في ذات موضوع الإشكال يغني عن الحكم المستعجل المؤقت.

الشرط الثالث: توافر ركن الاستعجال:

يجب أن يكون الإشكال مبنياً على الخشية من فوات الوقت، فالاستعجال هو الذي يبرر اتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية مصلحة الطالب نظراً لبطء الحماية الموضوعية، ومن ثم ينبغي أن يتوافر ركن الاستعجال، وذلك بالرغم من عدم النص على هذا الشرط في المادة (٢٧٥) مرافعات، التي نصت على اختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ الوقتية، بينما تطلبت المادة (٤٥) مرافعات التي تنص على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة أن تكون المسائل التي ينظرها هي المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

فهذا لا يعني أن الاستعجال غير مشروط، وإنما يعني أن إشكالات التنفيذ مستعجلة دائماً والاستعجال فيها مفترض ؛ لأنها تهدف إلى رفع خطر يهدد رافعها، ويتمثل هذا الخطر في التنفيذ عليه إن كان الإشكال مرفوعاً من المدين أو الغير، كما يتمثل في تأخير اقتضاء الحق الثابت بالسند التنفيذي إن كان الإشكال مرفوعاً من طالب التنفيذ.

ومن ثم فإن من يرفع إشكالاً لا يحتاج إلى إثبات ركن الاستعجال ولا يطلب منه القاضي ذلك فالاستعجال مفترض بحكم القانون.

ولكن افتراض الاستعجال في الإشكال ليس مطلقاً، بل هو قابل لإثبات العكس، وإذا ثبت المستشكل ضده انتفاء الخطر وانعدام الاستعجال فإن ذلك يؤدي إلى عدم

قبول الإشكال وعدم اختصاص قاضي التنفيذ به بوصفه قاضياً للأمر المستعجلة، ولا شك أن هذا فرض نادر الوقوع ويصعب تصوره.

اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الإشكالات :

يختص قاضي التنفيذ بنظر الإشكالات (المنازعات الوقتية) بوصفه قاضياً للأمر المستعجلة (٢٧٥) مرافعات، وهو يختص بكافة إشكالات التنفيذ إلا ما جعله نص خاص من اختصاص جهة أخرى، وترفع الإشكالات إلى قاضي التنفيذ الذي يقع المال محل التنفيذ في دائرته.

إجراءات رفع الإشكال وأثره :

لرفع الإشكال طريقتان:

الأولى: وتتلخص في إعداد صحيفة دعوى تقدم إلى القضاء بالإجراءات المعتادة بإيداعها في قلم كتاب محكمة التنفيذ ثم تعلن للخصوم بعد تحديد جلسة يكلفون بالحضور إليها، وقد جرت العادة على إعلان إدارة التنفيذ بالإشكال لكي توقف التنفيذ.

الثانية: عند التنفيذ بإبداء الإشكال شفويّاً أمام معاون التنفيذ، مع دفع الرسم المقرر له ويثبت معاون التنفيذ الإشكال في محضر التنفيذ ويحدد جلسة لنظر الإشكال أمام قاضي التنفيذ ويكلف الخصوم بالحضور إليها ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برفع الإشكال، ويحيز القانون لمعاون التنفيذ أن يجعل ميعاد الحضور ساعة واحدة وفي منزل القاضي عند الضرورة .

ويعتبر الإشكال مرفوعاً من وقت إبدائه أمام معاون التنفيذ لا من وقت إعلانه للمستشكل ضده بمعنى أنه إذا أغفل معاون التنفيذ الإشكال ولم يحفل به ولم يرفعه إلى القاضي مما اضطر المستشكل إلى تكليف خصمه بالحضور أمام القاضي لنظر الإشكال فإن قيامه بذلك لا يعدو أن يكون تحريكاً أمام القاضي لنظر الإشكال فإن قيامه بذلك لا يعدو أن يكون تحريكاً لإشكال سبق رفعه ولكن نظره موقوف.

وقد نصت المادة ١/٣١٢ مرافعات على أنه "إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط ... وفي جميع الأحوال لا يجوز له أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر لقاضي حكمه". ولتوضيح ذلك يجب أن نفرق بين حالتين في التنفيذ.

الأولى : إذا كان التنفيذ مما يتم على مرحلة واحدة، كالطرد أو الإزالة أو التسليم ففي هذه الحالة لا يكون أمام معاون التنفيذ إلا التوقف عن التنفيذ.

الثانية: إذا كان التنفيذ يتم على أكثر من مرحلة، فهنا يجوز لمعاون التنفيذ أن يمضي إلى نهاية المرحلة الأولى ثم يتوقف، كما في حالة الحجز على المنقول إذ يجوز أن يتم الحجز بمعنى أنه إذا كان قد أوقع الحجز على بعض المنقولات ثم قدم له المنفذ ضده إشكالاً فلمعاون التنفيذ أن يتوقف أو أن يمضي في حجز بقية المنقولات، ولكن لا يجوز له أن يمضي بعد ذلك في إجراءات البيع إلا بعد صدور حكم من القاضي في الإشكال وتعتبر الإجراءات التي قام بها معاون التنفيذ بعد تقديم الإشكال قد تمت على سبيل الاحتياط فإذا حكم بقبول الإشكال سقطت هذه الإجراءات بأثر رجعي وتعتبر كأنها لم تحدث أصلاً أما إذا حكم برفض الإشكال فإنها تستقر وتعتبر إجراءات تنفيذية صحيحة ومنتجة لآثارها.

كما نصت المادة ٢/٣١٢، ٣ على أنه "وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة في السجل الخاص بذلك.

ويجب اختصاص الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام معاون التنفيذ على النحو المبين بالفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال".

وعلى ذلك فإذا أبدى الإشكال أمام معاون التنفيذ فيجب عليه أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم بالإضافة إلى صورة لقلم الكتاب ويرفق معاون التنفيذ بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها المستشكل كما يجب على قلم الكتاب أن يقوم بقيد الإشكال في السجل الخاص بذلك يوم تسليم الصورة.

وأوجب القانون اختصاص الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال يجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرته به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.

أثر الإشكال على التنفيذ:

يترتب على رفع الإشكال الأول وقف التنفيذ أما الإشكال الثاني فلا يوقف التنفيذ إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بالوقف.

ولكن متى يعتبر الإشكال إشكالاً ثانياً ؟

يعتبر الإشكال إشكالاً ثانياً إذا قُدم بعد رفع الإشكال الأول، ولا يشترط لذلك أن يكون قد حكم في الإشكال الأول، وسواء كان الإشكال الثاني مرفوعاً من نفس المستشكل الأول أو من شخص آخر.

ولا يعتبر إشكالاً ثانياً الإشكال الذي يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق، وعلى ذلك فالمدين إذا لم يختصم في الإشكال السابق، فإنه لا يعتبر حجة عليه، ويكون من حقه أن يرفع إشكالاً ويعتبر إشكالاً أولاً موقفاً للتنفيذ.

ويراعي أن لكل حجز إشكالاته الخاصة، ومن ثم لو رفع إشكال عن حجز ثم وقع حجز آخر لذات الدائن واقتضاء لذات الدين ووقع على ذات المال فرفع المحجوز عليه إشكالاً يعتبر إشكالاً أولاً، ومن باب الأولى لو اختلف الحجزان في واحد مما ذكر.

والإشكال الذي يرفع لأول مرة له أثر موقوف للتنفيذ، يستوي في ذلك أن يكون قد رفع إلى محكمة مختصة بنظره أو إلى محكمة غير مختصة به، ويظل هذا الأثر باقياً

ما بقيت صحيفته قائمة، ذلك أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا يترتب عليه إنهاء الخصومة في الإشكال، وليس من شأنه أن يزيل صحيفته، وإنما هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها، التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها، ويعتبر صحيحاً أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة بما في ذلك صحيفة الإشكال وأثرها الواقف للتنفيذ^(١). ويظل التنفيذ واقعاً لحين صدور الحكم في الإشكال، أو إلى أن تزول الخصومة فيه لأي سبب من الأسباب.

أثر شطب الإشكال :

شطب الإشكال لا يعني انقضاء الخصومة فيه، وإنما يعتبر الإشكال كأن لم يكن إذا بقي مشطوباً شتين يوماً ولم يطلب أحد السير فيه، ومقتضى القواعد العامة أن شطب الإشكال لا يؤدي إلى إبطال أثره، ومعنى ذلك بقاء التنفيذ واقعاً حتى تنتقض الستون يوماً واعتبار الإشكال كأن لم يكن، ولما كان في هذا تعطيل للتنفيذ بلا مبرر خرج المقتن عن القواعد العامة وقرر في المادة "٣١٤" أنه: "إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه".

العرض الحقيقي:

قلنا إن معاون التنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ مفوض بقبض الدين وإعطاء مخالصة ولكن قد يعرض المدين أقل من الدين المطالب به أو يكون العرض محل نزاع فهنا يقبض معاون التنفيذ ما يدفعه المدين من الدين ويستمر في التنفيذ بباقي المطلوب أما إذا كان العرض محل نزاع فلا يترتب عليه وقف التنفيذ، ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه (المادة ٣١٣ مرافعات).

(١) نقض مدني جلسة ١/٨ / ١٩٨٠، الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٤٤ ق، أحكام وآراء في القضاء المستعجل والتنفيذ الوقي للمستشار مصطفى مجدي هرجة . ص ٥٨٦، ٥٨٧ .

الحكم في الإشكال:

ينظر قاضي التنفيذ الإشكالات بوصفه قاضياً للأمر المستعجلة وممنوع على قاضي الأمور المستعجلة التعرض لأصل الحق المتنازع عليه فلا يجوز أن يحكم فيه ولا يتعرض له لتكوين رأي قاطع يبني عليه حكمه في الإجراء الوقتي وإنما له أن يبحث موضوع النزاع بحثاً عرضياً يتحسس فيه ما يحتمل أن يكون هو وجه الصواب في الطلب المعروض عليه وله في سبيل ذلك بحث ما يتصل بالنزاع من مستندات الخصوم^(١).

والحكم في الإشكال حكم وقتي ولا يحول دون عرض النزاع أمام قاضي التنفيذ في صورة منازعة موضوعية، ولا يتقيد قاضي التنفيذ بما حكم به في الإشكال. ويجيز القانون الحكم على المستشكل الذي خسر دعواه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه^(٢)، وذلك حتى لا تتخذ الإشكالات وسيلة لتعطيل التنفيذ ولذلك فقد قصرها المقتن على الإشكالات فهي التي يؤدي رفعها إلى وقف التنفيذ دون المنازعات الموضوعية، والحكم بالغرامة جوازي للقاضي وفقاً لتقديره لحسن نية المستشكل أو سوء نيته. ويلاحظ: أن الحكم الصادر في الإشكال مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وفقاً للمادة ٢٨٨ مرافعات وبدون كفالة إلا إذا تطلبها قاضي التنفيذ.

استئناف الحكم الصادر في الإشكال الوقتي:

الحكم في الإشكال يقبل الطعن فيه بالاستئناف في جميع الحالات أياً كانت قيمة النزاع ويكون استئنافه أمام المحكمة الابتدائية التابع لها قاضي التنفيذ.

(١) نقض مدني جلسة ١٩٥/١/٥ الطعن رقم ١٣٦٨ لسنة ٦٠ ق .

(٢) عدلت الغرامة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ .

المطلب الثاني

المنازعات الموضوعية

المقصود بالمنازعة الموضوعية:

المنازعة الموضوعية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق ومن أمثلتها، دعوى رفع الحجز، ودعوى استرداد المنقولات المحجوزة، ودعوى الاستحقاق الفرعية، ودعوى صحة أو بطلان الحجز.

اختصاص قاضي التنفيذ بالمنازعات الموضوعية:

يختص قاضي التنفيذ بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ فإذا كانت المنازعة وقتية (إشكالية) نظرًا باعتباره قاضيًا للأمور المستعجلة، أما إذا كانت المنازعة موضوعية نظرًا باعتباره قاضي الموضوع.

وتدخل المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ في اختصاص قاضي التنفيذ أيًا كانت قيمة الدعوى ولو تجاوزت نصاب اختصاص القاضي الجزئي . كقاعدة^(١).

طريقة رفع المنازعة الموضوعية :

ترفع المنازعة الموضوعية بالطريق العادي لرفع الدعوى . بإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة . ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام وهو الميعاد المقرر للحضور أمام المحكمة الجزئية حتى ولو تجاوزت قيمة الدعوى نصاب المحكمة الجزئية^(٢).

ولا يترتب على رفع المنازعة الموضوعية وقف التنفيذ، كما الشأن في المنازعة الوقتية (الإشكالية). وإنما يترتب هذا الأثر على صدور الحكم ومع ذلك فقد ينص المقتن صراحة على وقف التنفيذ كأثر لرفع المنازعة الموضوعية كمال هو الشأن في المادة ٣٩٣ مرافعات والخاصة بدعوى الاسترداد.

(١) استثنى المقتن دعوى صحة الحجز وأسند الاختصاص بها لقاض آخر (أنظر المواد ٣٢٠، ٢١٠ / ٣، ٣٣٣ مرافعات).

(٢) نقض مدني جلسة ٢٣ / ٥ / ١٩٩٥ الطعن رقم ٣١٠٧ لسنة ٦٠ ق .

الحكم في المنازعة الموضوعية:

تعتبر المنازعة الموضوعية دعوى عادية ينظرها قاضي التنفيذ، وتكون له السلطة التي للقاضي عند الفصل في الدعوى العادية، بمعنى أنه لا يتقيد بعدم المساس بالحق؛ لأن موضوع الطلب في المنازعة الموضوعية هو حسم النزاع في أصل الحق. وإذا تخلف الخصوم عن الحضور وقضت المحكمة بالشطب فإن هذا الحكم لا يترتب عليه استمرار التنفيذ إذا كان قد حكم بوقفه مؤقتاً من قاضي التنفيذ. ولا محل للحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة ٣١٥ مرافعات على من خسر دعواه في المنازعة الموضوعية.

والحكم الصادر في المنازعة الموضوعية ينفذ وفقاً للقواعد العامة في تنفيذ الأحكام، فلا يجوز تنفيذه إلا إذا كان حائزاً لقوة الأمر المقضي، أو كان مشمولاً بالنفاذ المعجل بحكم من قاضي التنفيذ، كما لو صدر لمصلحة طالب التنفيذ.

مدى حجية الحكم الصادر في المنازعة الموضوعية:

الحكم الصادر في المنازعة الموضوعية يحدد مركز الخصوم تحديداً نهائياً بحكم قطعي، وعلى ذلك فلا يقبل طلب وقف التنفيذ الذي صدر حكم بصحته، كما لا يقبل طلب الاستمرار في التنفيذ الذي صدر حكم ببطلانه إجراءاته.

استئناف الحكم الصادر في المنازعة الموضوعية:

يستأنف الحكم الصادر في المنازعة الموضوعية أيّاً ما كانت قيمة النزاع.

الباب الثاني

إجراءات الحجز والتنفيذ على المنقول

تمهيد

ماهية الحجز وقواعده

أولاً: ماهية الحجز وأنواعه وطبيعته القانونية:

الحجز هو طريق من طرق التنفيذ يهدف إلى وضع أموال المدين تحت يد القضاء بقصد بيعها لصالح الدائنين الذين يقتضون حقوقهم من ثمن بيع هذه الأموال^(١).
والتنفيذ بطريق الحجز -كما أشرنا في المبحث التمهيدي- لا يكون إلا في حالة الالتزام بدفع مبلغ مالي، يستوي في ذلك أن يكون الالتزام مبلغاً مالياً في الأصل، أو كان التزاماً عينياً استحال إلى مبلغ مالي نتيجة لتعذر التنفيذ العيني.
وفي هذه الوسيلة من وسائل التنفيذ الجبري، يجبر المدين على الوفاء بالتزاماته عن طريق الحجز على أمواله المملوكة له، وبيعها ليحصل الدائن على حقه من حصة البيع، وهذا الحجز قد يكون حجزاً تنفيذياً، أو حجزاً تحفظياً، أو حجزاً ما للمدين لدى الغير.

فالأثر الجوهري للحجز؛ هو تحديد وحصر مال معين من أموال المدين، من ضمن أموال الضمان العام، ومنع المدين من التصرف في هذا المال تصرفاً يتعارض مع حق الدائن الحاجز في تحويل هذا المال إلى مبلغ نقدي، وذلك بالحجز ونزع الملكية ليستوفي منه حقه^(٢).

والفارق الجوهري بين الحجز التنفيذي والحجز التحفظي؛ أن الأول يهدف الدائن من ورائه اقتضاء حقه من المدين عن طريق الحجز على أمواله وبيعها، أما الثاني فلا يهدف من ورائه مباشرة اقتضاء حقه؛ وإنما اتخاذ إجراءات تحفظية تحافظ على أموال مدينه - باعتبارها الضمان العام لديونه - ووضعها تحت يد القضاء حماية لحقوقه، واتخاذ ما يكون لازماً بعد ذلك لتحويل هذا الحجز إلى حجز تنفيذي يقتضي به حقه بعد بيع هذه الأموال.

(١) د. أمينة النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الثالث (التنفيذ)، ص ٣١٩.

(٢) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٣٦١.

ولهذا لا ينتشدد المشرع كثيرا في الشروط اللازمة لإجراء الحجز التحفظي؛ كونه لا يؤدي بذاته إلى بيع أموال المدين، فهو على عكس الحجز التنفيذي لا يشترط لإجرائه أن يكون بيد الدائن سنداً تنفيذياً، وليس معنى عدم التشدد في شروط إجرائه أن الدائن يستطيع الحجز على أموال مدينه حجزاً تحفظياً وقتما شاء وكيفما شاء؛ وإنما لا بد لإجرائه أن تتوفر حاله من الحالات التي نص عليها المشرع لإجراء هذا الحجز.

أما حجز ما للمدين لدى الغير؛ فإنه يجمع بين طبيعة النوعين السابقين-الحجز التنفيذي والحجز التحفظي- ذلك أنه يبدأ حجزاً تحفظياً يهدف إلى المحافظة على منقولات المدين لدى الغير، ثم يتحول إلى حجز تنفيذي يهدف إلى بيع هذه الأموال واقتضاء حق الحاجز منها، ومن ثم فهو ذا طبيعة مختلطة.

وفي جميع الأحوال وأياً ما كان طريق الحجز من هذه الأنواع الثلاثة؛ فإنه لا خلاف في أن الحجز لا يخرج المال من ملك المحجوز عليه؛ وإنما يبيع هذا المال كإجراء تال للحجز هو الذي يؤدي إلى هذا الأثر، فيظل المدين المحجوز على أمواله، مالكا لهذه الأموال المحجوزة وله عليها سلطات المالك لا يقيد به شيء في ذلك إلا ما يترتب على الحجز من قيود قصد بها المشرع حماية حق الدائن الحاجز- وسيأتي تفصيل ذلك- وعلى الرغم من عدم خروج المال المحجوز من ملكية المدين المحجوز عليه؛ إلا أن مجرد الحجز يترتب آثاراً مهمة، بالنسبة لجميع أطرافه؛ سواء في ذلك الدائن الحاجز، أو المدين المحجوز عليه، أو الغير المحجوز لديه.

"ويراعى أن الحجز ما هو إلا مرحلة من مراحل التنفيذ الجبري، فهو يمثل المرحلة الأولى، ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية (البيع) حيث يقوم القضاء ببيع المال المحجوز لتحويله إلى مبلغ نقدي، ثم تأتي المرحلة الثالثة (التوزيع) وهو المرحلة النهائية، حيث يحصل الدائنون بالفعل على حقوقهم من قيمة المال المحجوز الذي تم بيعه، فمراحل التنفيذ الجبري (بالحجز ونزع الملكية) تتمثل في الحجز، والبيع، والتوزيع"^(١).

(١) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٢٤٩.

ثانيا: قواعد تحكم إجراءات الحجز وتحدد آثاره:

ثمة قواعد تحكم عملية الحجز وتحدد آثاره، وهذه القواعد بصفة عامة تسري على جميع أنواع الحجز، وأيا كانت طبيعة الأموال المحجوزة (منقولات أو عقارات)، ويمكننا أن نشير إلى هذه القواعد على النحو الآتي^(١):

القاعدة الأولى: أن حرية الدائن في اختيار طريق الحجز الذي يجريه، لا تحول دون وجوب التزامه باتباع إجراءات الحجز المقررة قانونا بالنسبة لنوع الحجز الذي يجريه، فإذا خرج عن هذه الإجراءات؛ فإن الحجز يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام، وذلك لأن الحجز يتعلق بالطرق المقررة قانونا للحصول على الحماية القانونية.

القاعدة الثانية: أن الحجز لا يؤدي إلى إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه، فيظل المحجوز عليه مالكا لهذا المال رغم الحجز، حتى يتم بيعه وفقا لإجراءات التنفيذ، ويترتب على هذه القاعدة أنه يجوز لأي دائن آخر غير الحاجز؛ أن يجري حجزا على المال المحجوز وإن تعدد الدائنون الحاجزون، وفقا للإجراءات المقررة في ذلك. هذا من ناحية.

ومن ناحية ثانية؛ فإن سلطات المالك تتقيد على أمواله المحجوز عليها (وتابعها وملحقاتها، كالثمار والفوائد وغيرها)؛ فلا يكون له حق التصرف في هذه الأموال، ولا يستطيع استعمالها أو استغلالها بأي وجه يضر بالمال المحجوز أو بحقوق الحاجزين، ولا تسري تصرفاته على هذا المال في مواجهة الدائنين الحاجزين، وإن اعتبرت سارية فيما بينه وبين من تصرف إليه.

ومقتضى كون المال المحجوز عليه لا يخرج من ملك صاحبه بمجرد الحجز؛ أن يبيعه بعد ذلك وفقا لإجراءات التنفيذ؛ يقتضي رد ما زاد عن وفاء ديون الحاجزين إلى ذمة المالك.

(١) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٢٠ - د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٣٦٦-٣٧١.

القاعدة الثالثة: أن الحجز إجراء نسبي لا يفيد إلا الدائن الذي أوقعه، أو غيره من الدائنين الذين تدخلوا في الحجز -وفقا لإجراءات التدخل التي سيأتي بيانها- أما غير ذلك من الدائنين الذين لم يكونوا طرفا في إجراءات الحجز على المال فلا يفيدوا من الحجز. ومن ناحية ثانية؛ أن أثر الحجز يقتصر على المال المحجوز عليه فقط، ولا يمتد إلى غيره من أموال المدين التي لم يتم الحجز عليها؛ فيكون له على هذه الأخيرة مطلق السلطات من حيث استعمالها واستغلالها أو التصرف فيها أو غير ذلك.

ويترتب على هذا الأثر النسبي للحجز؛ أنه إذا حصل وفاء أو تصرف بعد الحجز؛ فإن الحاجز قبل حصولهما هو وحده الذي يكون له الحق في التمسك بعدم نفاذ الوفاء أو التصرف في مواجهته، وفي الوقت نفسه، يسري هذا التصرف أو هذا الوفاء في مواجهة كل دائن للمحجوز عليه إذا لم يكن هذا الدائن قد وقع حجزا.

القاعدة الرابعة: الأثر الكلي للحجز: ومعناه أن الحبس الناشيء عن الحجز يشمل جميع المال المحجوز عليه، ولا يقتصر على جزء منه مساو لقيمة الدين المحجوز لأجله، وذلك لأن الحجز على مال المدين لا يمنع الدائنين الآخرين غير الدائن الحاجز من التدخل في الحجز على المال المحجوز عليه؛ فحماية للحاجز الأول - الذي لا يعطيه الحجز امتيازاً خاصاً باعتباره حاجز أول- يكون للحجز أثراً كلياً يشمل جميع المال المحجوز عليه، حتى وإن زادت قيمة هذا المال على قيمة الدين بكثير^(١).

القاعدة الخامسة: أن الحجز يؤدي إلى قطع التقادم، وذلك أياً كان طريق الحجز أو نوعه، أي سواء كان حجراً تنفيذياً أو تحفظياً أو حجزاً ما للمدين لدى الغير، وأياً كانت طبيعة المال المحجوز عليه، منقولاً أو عقاراً.

وبعد بيان هذه القواعد؛ فإننا نتناول طرق الحجز على المنقول، في ثلاثة فصول، الأول: الحجز التنفيذي على المنقول. والثاني: الحجز التحفظي. والثالث: حجز ما للمدين لدى الغير.

(١) وقد سبقت الإشارة إلى وسائل الحد من المغالاة في الحجز على أموال المدين في الباب الأول من هذا المؤلف.

الفصل الأول

الحجز التنفيذي على المنقول

الفصل الأول

الحجز التنفيذي على المنقول

محل هذا الحجز:

للدائن أن يختار ما شاء من منقولات مدينه الموجوده في حيازته أو جميعها، ويقوم بالحجز عليها حجزا تنفيذيا لبيعها بعد ذلك واقتضاء دينه من حصيلة هذا البيع، وإجراءات التنفيذ على المنقول بصفة عامة تتسم بالبساطة والبعد عن التعقيد، بخلاف إجراءات الحجز على العقار، وذلك لأن ملكية المنقول وحيازته لا تخضع كقاعدة عامة لنظام الشهر أو التسجيل^(١).

والمنقول الذي نتناول إجراءات حجزه حجزا تنفيذيا هنا، هو المنقول المادي وليس المعنوي، وهو وفقا لما نصت عليه المادة (٢/٨٢) من القانون المدني، الشيء الذي يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف، ويأخذ حكمه المنقول بحسب المآل كالثمار المتصلة والمحصولات القائمة.

مع الأخذ في الاعتبار أن هناك نوع من المنقولات لا يمكن اتباع هذا الطريق من طرق الحجز بشأنه؛ وإنما يحجز عليه بطريق الحجز على العقار، وهو المنقول المخصص لخدمة عقار، حيث يعد عقارا بالتخصيص.

وهناك قواعد يجب مراعاتها قبل الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين، وهذه القواعد هي:

- ١- يجب أن يكون المنقول منقولا ماديا: فهذا الطريق من طرق التنفيذ على المنقول -الحجز التنفيذي- لا يتبع إلا بشأن المنقولات المادية فقط، ويأخذ حكم المنقول المادي؛ الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير، فهذه يتبع بشأنها إجراءات الحجز على المنقول لدى المدين (مادة ٣٩٨ مرافعات)^(٢).

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/٢٦٣.

(٢) وتتص على أن "الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول".

أما إذا كان المنقول منقولاً معنوياً، أي ديناً من الديون في ذمة الغير؛ فإن الحجز عليه يكون بطريق حجز ما للمدين لدى الغير، ولو كان بيد المدين (المحجوز عليه) ورقه تثبت حقه كدائن بهذا الدين، فإن ذلك لا يحول دون اعتباره منقولاً معنوياً، بخلاف ما لو كانت هذه الورقة من السندات التي يتجسد فيها الحق، كأوراق البنكنوت والسندات لحاملها أو القابلة للتطهير، فيسري بشأنها نص المادة (٣٩٨) مرافعات^(١). وتعد النقود والعملات سواء كانت معدنية أو ورقية وطنية أو أجنبية، من المنقولات المادية التي يكون الحجز عليها بطريق حجز المنقول لدى المدين.

٢- يجب أن يكون المنقول مملوكاً للمدين وفي حيازته: فالحجز لا يكون إلا على مال مملوك للمدين؛ أما إذا كان مملوكاً للغير فلا يصح الحجز عليه؛ لأن أموال المدين فقط هي الضامنة للوفاء بالتزاماته؛ فلا يجوز الحجز على أموال ورثة المدين -مثلاً- لسداد التزامات مورثهم^(٢).

ومن جهة ثانية يشترط لاتباع طريق الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين؛ أن يكون هذا المنقول في حيازة المدين؛ فإذا كان مملوكاً للمدين ولكن في حيازة الغير؛ فإن الحجز عليه يكون بطريق حجز ما للمدين لدى الغير.

ويقصد بكون المنقول في حيازة الغير؛ أن يكون للغير حق في استعماله أو استغلاله أو سلطة في المحافظة عليه وإدارته، وأن تكون لهذا الشخص السيطرة على المنقول نتيجة للحق أو السلطة المذكورة. وتطبيقاً لهذا؛ يكون الحجز على المنقول

(١) وذلك بخلاف الإيرادات المرتبة والأسهم الإسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين فإنها تحجز وفقاً لما أوجبه المادة (١/٣٩٩) مرافعات، بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.

(٢) وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "من المقرر أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتتفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تتشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة فلا يصح توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته" (الطعن رقم ٣١٨ لسنة ٤٢ قضائية - جلسة ١٩٨١/٢/١٦).

المادي لدى المستأجر، والمستثمر، والمودع لديه، والحارس، والصراف، ومعاون التنفيذ، بالنسبة لحصيلة التنفيذ، والبنك والسندات المودعة به، والماهيات، والمرتببات، والأجور المحولة إليه، بطريق حجز المنقول لدى الغير^(١).

أما إذا كان المنقول مملوكا للمدين وليس في حيازته أو حيازة غيره، كما لو كان موجودا في الطريق العام؛ فإن الحجز عليه يتم بطريق الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين.

وفي ضوء هذا التحديد للمنقول الذي يجوز حجزه جزئا تنفيذيا لدى المدين، يمكننا تعريف هذا النوع من أنواع الحجز بأنه: ضبط منقولات المدين المادية المملوكة له والموجودة في حيازته ووضعها تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها ثم بيعها لوفاء دين الدائن الحاجز من حصيلة بيعها.

ووفقا لهذا التحديد للمنقول محل الحجز التنفيذي وللتعريف الذي بيناه، يمكننا القول أن هذا الحجز -باعتباره أحد طرق التنفيذ الجبري على أموال المدين- يمر أولا بمرحلة الحجز، ثم بمرحلة البيع بعد ذلك، ليتم توزيع حصيلة البيع في مرحلة أخيرة، وبذلك تكون مراحل هذا الحجز ثلاثة مراحل، هي الحجز، والبيع، والتوزيع.

ونتناول في هذا الفصل مرحلتَي الحجز والبيع، ونرجى الحديث عن التوزيع إلى حين حديثنا عن توزيع حصيلة التنفيذ في نهاية هذا المؤلف بإذن الله تعالى. ومن ثم نقسم هذا الفصل إلى مبحثين، نتناول في الأول منهما: إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول، وفي الثاني: بيع المنقولات المحجوز عليها.

(١) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٣٥.

أما بالنسبة للخزينة الحديدية التي يستأجرها الشخص من البنك ليودع بها نقودا أو غيرها من الأوراق والمصوغات وغير ذلك، وتكون في حيازة البنك؛ فإن الحجز عليها يكون بطريق الحجز على المنقول لدى المدين، ولا يحول دون ذلك أن تكون الخزينة الحديدية مغلقة لا يمكن فتحها إلا بواسطة المدين الذي يحمل أحد مفاتيحها؛ إذ لا يكون هذا الأمر عقبة مادية تعترض الحجز؛ إذ يمكن تذليلها كغيرها من العقبات المادية عن طريق استصدار أمر من إدارة التنفيذ وحضور أحد مأموري الضبط القضائي وفقا للمادة (٣٥٦) مرافعات.

المبحث الأول

إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول

ضرورة اتخاذ مقدمات التنفيذ: (إحالة):

سبق أن بينا أن المشرع يوجب اتخاذ مقدمات التنفيذ قبل البدء في إجراءاته، ولا تعد هذه المقدمات من إجراءات التنفيذ؛ وإنما هي سابقة عليها، وضرورية ولازمة لها، فلا يجوز التنفيذ كقاعدة إلا بعد مباشرة هذه المقدمات أيا كان نوع التنفيذ، أي سواء كان تنفيذا مباشرا، أو تنفيذا بنزع الملكية، وفي بعض الأحيان يجيز المشرع التنفيذ دون اتخاذ هذه المقدمات، وهذه المقدمات هي: تقديم طلب التنفيذ، وإعلان السند التنفيذي، ومضي يوم بعد إعلان السند التنفيذي وقبل التنفيذ. ويجب اتخاذ هذه المقدمات قبل الحجز التنفيذي على المنقول، وقد بينا هذه المقدمات تفصيلا في الفصل الرابع من الباب الأول، فنحيل إلى ما سبق بيانه.

وبعد اتخاذ هذه المقدمات ينتقل الحاجز إلى مرحلة الحجز على المنقول المادي المملوك للمدين والموجود في حيازته، وفقا للقواعد التي تضمنها الفصل الأول من الباب الثالث في الكتاب الثاني لقانون المرافعات، وقد يحدث تدخل في الحجز من دائن آخر، ونتناول ذلك في مطلبين على النحو الآتي:

المطلب الأول

إجراء الحجز وتعيين الحارس

الفرع الأول

إجراء الحجز والآثار المترتبة عليه

يتولى معاون التنفيذ إجراء الحجز التنفيذي على منقولات المدين الموجودة في حيازته، وعليه أن يراعي في ذلك اتباع القواعد المقررة في هذا الشأن، وأهمها: انتقال معاون التنفيذ إلى مكان وجود المنقولات المراد حجزها، وأن يحرر محضر الحجز في مكان توقيعه، وأن يجرى الحجز بدون حضور الدائن الحاجز مع جواز حضور مندوب

عنه، وألا يتم كسر الأبواب أو فض الأقفال لمباشرة الحجز إلا في حضور أحد مأموري الضبط القضائي، وألا يقوم بتفتيش المدين للحجز على ما في جيبه إلا إذا كان مأذونا له بذلك من إدارة التنفيذ، وأن يتخذ ما يراه ضروريا ولازما من إجراء الحجز في يوم واحد أو أيام تالية أو في غير المواعيد المقررة قانونا. ونشير إلى ذلك بإيجاز فيما يلي:

١- أوجبت المادة (٣٥٣) مرافعات؛ أن يجرى الحجز بموجب محضر محرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلا، ويقتضي ذلك بطبيعة الحال انتقال معاون التنفيذ إلى مكان وجود المنقولات المراد حجزها، ويحرر محضر الحجز في هذا المكان، فلا يجوز له أن يحرر المحضر في أي مكان آخر، ولو بعد انتقاله إلى مكان المنقولات المراد حجزها، وحكمة ذلك منع تحرير محاضر حجز دون انتقال معاون التنفيذ إلى المحل الذي توجد فيه هذه المنقولات؛ فإذا لم يتم تحرير هذا المحضر أو تم تحريره في مكان آخر؛ فإن الحجز يكون باطلا، وهو بطلان متعلق بمصلحة المدين يجب عليه أن يتمسك به.

٢- لا يجوز توقيع الحجز في حضور الدائن طالب التنفيذ (مادة ٣٥٥ مرافعات)، ومن ثم يجب عدم حضوره أثناء إجراء الحجز وتحرير محضره، وذلك محافظة على شعور المدين ومنع استفزازه وتجنب ما قد يحدث من تلاقي الخصمين من احتكاك في مكان الحجز، والمنع هنا قاصر على طالب التنفيذ نفسه؛ ومن ثم يجوز حضور نائب عنه، كوكيل أو قريب.

وعلى معاون التنفيذ إذا حضر الحاجز أن يطلب منه مغادرة المكان؛ فإذا حضر إجراءات الحجز وكان ذلك في حضور المدين ولم يعترض؛ فإن الحجز لا يكون باطلا، ذلك أن البطلان متعلق بمصلحته، ومن ثم له أن يتمسك به أو ينزل عنه صراحة أو ضمنا^(١).

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/٢٧٦- د. أمينة النمر، التنفيذ، ص٣٣٩.

٣- يجب على معاون التنفيذ أن يستعين بأحد رجال الضبط القضائي إذا رأى أن من اللازم لتوقيع الحجز كسر باب أو فض قفل، وذلك إعمالاً لنص المادة (١/٣٥٦) والتي نصت على أنه "لا يجوز لمعاون التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً".

٤- ضرورة الحصول على إذن إدارة التنفيذ لتفتيش المدين وتوقيع الحجز على ما في جيبه (مادة ٢/٣٦٥)، ولا عبء بالإذن اللاحق على إجراء التفتيش، ولا برضاء المدين بتفتيشه بغير إذن.

ولا نتفق مع ما يراه البعض^(١) من أن لمعاون التنفيذ تفتيش زوجة المدين أو أي من أفراد أسرته أو التابعين له، إذا كان لديه إذن بذلك من إدارة التنفيذ؛ ذلك أن النص قاصر على جواز تفتيش المدين فقط، فلا يجوز التوسع فيه احتراماً لحريات الأفراد، ولا يقدح في ذلك ما قد يقال من اعتبارات تبرر ذلك، كتهريب المدين أمواله عن طريق ذويه. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من عدم نص المشرع في هذه المادة على ندب أنثى لتفتيش المدين إذا كانت أنثى؛ إلا أننا نرى ضرورة ذلك إعمالاً لما أوجبه القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن المستحسن تعديل نص المادة (٢/٣٦٥) بحيث ينص صراحة على ذلك.

٥- إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط تتابع هذه الأيام، وعلى معاون التنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. وإذا اقتضى الحال استمرار معاون التنفيذ في إجراءات الحجز

وعلى المدين حين يتمسك بالبطان أن يثبت حصول العيب الذي لم تتحقق الغاية من الإجراء بسببه، وذلك لأن المشرع لم ينص على البطان صراحة إذا حضر الحاجز؛ ومن ثم يعمل بالقاعدة العامة المقررة في المادة (٢٠) مرافعات.

(١) د. أحمد أبو الوفاء، التعليق على قانون المرافعات، ص ١٣٥٤.

بعد المواعيد المقررة في المادة السابعة مرافعات أو في أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء (م ٣٦٠ مرافعات)^(١). ولما كان محضر الحجز هو الإجراء الذي يتم الحجز بمقتضاه، وبموجبه تعتبر المنقولات محجوزة حجزاً تنفيذياً ولو لم يعين عليها حارس (مادة ٣٦١) ويرتب آثاراً مهمة وبحول دون تصرف المدين في المنقولات المحجوزة على الرغم من عدم خروجها من ملكيته؛ فإن المشرع حرص على بيان مشتملات هذا المحضر، وما يتبع في شأن تحريره، وما يقتضيه من إجراءات لحجز المنقولات، وما يترتب عليه من آثار، ونبين ذلك على النحو الآتي:

أولاً: تحرير محضر الحجز:

تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس (مادة ٣٦١)، ونظراً لهذه الأهمية للمحضر؛ فإن المشرع حرص على تخصيص مادة تضمنت ما يجب أن يشتمل عليه من بيانات (مادة ٣٥٣) فضلاً عن البيانات التي تضمنتها نصوص أخرى -سيأتي بيانها- إضافة إلى البيانات التي نصت عليها المادة (٩) مرافعات باعتباره ورقة من أوراق المحضرين وبما يتفق وطبيعة هذا المحضر؛ والبيانات التي نصت عليها المادة (٣٥٣) هي:

١- السند التنفيذي الذي يجرى التنفيذ بمقتضاه؛ لأن هذا الحجز -كما أشرنا- حجزاً تنفيذياً لا يجرى إلا إذا كان بيد الدائن سنداً تنفيذياً، ولا يغني عن ذكر السند سبق

(١) ورد بالمذكرة الإيضاحية عن هذه المادة أنه "عدل المشروع في المادة ٣٦٠ منه حكم المادة ٥٠٧ من القانون القائم إذ كان الأصل أن المحضر لا يجوز أن يقوم بإعلان أو تنفيذ في غير الساعات التي يجوز فيها الإعلان أو في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من قاضي الأمور الوقفية ومن مقتضى هذا أن المحضر إذا بدأ التنفيذ في الوقت المسموح له به أو في يوم من أيام العمل ولم يستطع إتمامه قبل نهاية ساعات العمل أو قبل حلول العطلة الرسمية فإنه يجب عليه أن يوقف الحجز حتى يحصل على إذن من قاضي الأمور الوقفية وقد يؤدي هذا إلى تبديل المال قبل الحجز عليه وتعطيل إجراءات التنفيذ بغير موجب. لهذا رأى المشروع أن يجيز للمحضر تجاوز الوقت المسموح به طالما كان قد بدأ إجراء الحجز أو التنفيذ في المواعيد المقررة دون حاجة إلى استصدار إذن من قاضي التنفيذ المختص".

إعلانه للمدين، كما لا يغني ذكره في المحضر عن ضرورة سبق إعلانه قبل الحجز؛ فإذا خلا المحضر من ذكر هذا السند؛ فإن المحضر يكون باطلاً، ويبطل الحجز تبعاً لذلك^(١).

٢- موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التي يقع التنفيذ بدائرتها؛ فإذا كان موطنه الأصلي بها؛ فلا حاجة للموطن المختار؛ وإذا لم يكن له موطن بها ولم يتضمن المحضر موطناً مختاراً؛ فلا بطلان وإنما يعمل بالقاعدة العامة في المادة (١٢) مرافعات، ويتم إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار.

٣- مكان الحجز، ولا شك أنه المكان الذي توجد به المنقولات محل الحجز؛ إذ لا يصح أن يجري الحجز أو يحرر المحضر في مكان آخر؛ فإذا لم يذكر معاون التنفيذ هذا المكان وأنه حرر المحضر فيه؛ فإن الحجز يكون باطلاً.

٤- ما قام به معاون التنفيذ من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذته في شأنها. ويقصد بذلك العقبات المادية والاعتراضات القانونية التي أثارها المدين أو غيره عند توقيع الحجز.

٥- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب، وهذه القيمة التقريبية يقدرها معاون التنفيذ، إلا إذا كانت من الأشياء التي يحتاج تقويمها إلى خبير، وكانت إدارة التنفيذ قد عينت هذا الخبير إعمالاً للمادة (٣٥٨)؛ فإنه يتولى تقويم هذه المنقولات، ويقدم عن ذلك تقريراً يرفق بمحضر الحجز، ولا يجوز أن يقتصر المحضر على عبارة أو عبارات عامة بشأن المنقولات محل الحجز دون ذكرها تفصيلاً؛ فإن تضمن المحضر ذلك فإنه يكون باطلاً ويكون الحجز باطلاً كذلك.

٦- تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه، ومعاون التنفيذ هو المنوط به تحديد هذا اليوم، وعليه أن يراعي في ذلك ما أوجبه المادة (٣٧٦)، وسنبين ذلك

(١) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٤٢.

لاحقا. ولا يترتب البطلان على إغفال هذا التاريخ؛ وإنما يمكن تحديده في وقت لاحق وإخطار المدين به، على أن يحتسب ميعاد البيع في هذه الحالة من تاريخ الإخطار وليس من تاريخ الحجز.

٧- تحديد المكان الذي يجري فيه البيع، وهذا المكان وفقا للمادة (٣٧٧) هو المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة، أو في أقرب سوق، أو أي مكان آخر يأمر قاضي التنفيذ بإجراء البيع فيه بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن^(١).

٨- توقيع كل من معاون التنفيذ والمدين على المحضر، وذلك لأن توقيع معاون التنفيذ هو الذي يكسب المحضر صفة الرسمية؛ فيبطل المحضر إذا خلا منه، أما توقيع المدين فلا يترتب البطلان على تخلفه، ولا يعتبر توقيع رضاء من بالحجز يسقط حقه في التمسك ببطلان الإجراءات؛ وإنما يكون له التمسك ببطلانها بعد ذلك إن كانت معيبة.

وتجب الإشارة إلى أن المشرع لم ينص صراحة على البطلان إذا خلا المحضر من هذه البيانات؛ وإنما يترتب البطلان على النحو الذي أشرنا إليه؛ إعمالا للقاعدة العامة في البطلان وفق ما قرره المادة (٢٠) مرافعات من بطلان الإجراءات إذا لم تتحقق الغاية منه.

ثانيا: ضرورة اتباع إجراءات خاصة في حجز بعض المنقولات^(٢):

رأينا أن المشرع يوجب إجراء الحجز على المنقولات في مكانها دون نقلها (مادة ٣٥٧)، وأن يتولى معاون التنفيذ تقدير قيمتها بالتقريب، وأن يذكر بيانات محددة في

(١) وقد سبق أن أشرنا عند حديثنا عن السلطة المختصة بإجراء التنفيذ؛ إلى اضطراب موقف المشرع في تحديد الاختصاص بأوامر التنفيذ بين إدارة التنفيذ وقاضي التنفيذ، وهذه الحالة صورة من صور هذا الاضطراب، حيث نعتقد أنه كان يجب اسناد الاختصاص بالإذن إلى إدارة التنفيذ وليس إلى قاضي التنفيذ، حتى يقتصر اختصاص هذا الأخير على الفصل في المنازعات الموضوعية والوقتية، على النحو الذي هدف إليه المشرع من تعديل القانون بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٢) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ، ص ٢٦٢.

المحضر؛ إلا أنه وضع بعض القواعد التي تتضمن إجراءات خاصة لحجز بعض المنقولات أو تقديرها أو ذكر بيانات إضافية خاصة بها، ومن ذلك:

١- أنه لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوماً، وذلك حتى لا يرهق المدين بمصاريف الحراسة، وحتى لا يؤدي ذلك إلى إهماله لهذه الثمار أو الحاصلات. ولا يترتب البطلان على مخالفة هذا الميعاد (مادة ٣٥٤ مرافعات)^(١).

وعلى معاون التنفيذ عند إجراء الحجز على هذا النوع من المنقولات بحسب المآل (الثمار المتصلة والمزروعات القائمة) أن يبين في المحضر بالدقة، موضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمتها على وجه التقريب.

٢- إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية مصرية أو أجنبية؛ فإن معاون التنفيذ لا يكتفي بذكرها في محضر الحجز كسائر المنقولات ويتركها تحت حراسة المدين أو غيره؛ وإنما عليه أن يودعها خزانة المحكمة (مادة ٣٥٩ مرافعات).

٣- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة؛ فعلى معاون التنفيذ أن يقوم بوزن هذه الأشياء وأن يبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز، وإذا اقتضى الحال نقل هذه النفائس لوزنها أو تقويمها، فعلى معاون التنفيذ أن يضعها في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام، وينتقل بصحبة المدين إلى أحد المحال المختصة لوزن هذه النفائس وأن يذكر ذلك أيضاً في المحضر.

ولا يقوم معاون التنفيذ بتقويم هذه الأشياء؛ وإنما تقوم بمعرفة خبير تعيينه إدارة التنفيذ بناء على طلب معاون التنفيذ. كما يجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى

(١) ورد بالمذكرة الإيضاحية عن هذه المادة أنه "أنقص المشروع في المادة ٣٥٤ منه الميعاد الوارد في المادة ٤١٩ من القانون القائم إلى خمسة وأربعين يوماً ليتناول حكمها معظم المزروعات التي لا تمكث في الأرض إلى فترة قصيرة وحذف جزء البطلان الوارد فيها للتقليل من حالاته".

بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. وعلى معاون التنفيذ في جميع الأحوال أن يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز (مادة ٣٥٨ مرافعات).

ثالثا: تسليم محضر الحجز للمدين أو إعلانه بها إذا لم يكن حاضرا:

١- إذا تم توقيع الحجز في حضور المدين، أو كانت المنقولات المحجوزة في موطنه، يقوم معاون التنفيذ بتسليمه صورة من محضر الحجز.

٢- إذا لم يكن المدين حاضرا عند توقيع الحجز على أمواله؛ وجب على معاون التنفيذ تسليم صورة محضر الحجز إلى من يقرر أنه وكيله، أو أنه يعمل في خدمته، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وفقا لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات.

٣- إذا تم الحجز في غياب المدين وفي غير موطنه؛ فإنه يجب على معاون التنفيذ إعلانه بمحضر الحجز في موطنه في اليوم التالي للحجز على الأكثر، ولا يترتب على تأخير الإعلان عن هذا الميعاد بطلان الحجز؛ وإنما يترتب على ذلك تأخير البيع، حيث يحتسب ميعاد البيع في هذه الحالة من تاريخ إعلان محضر الحجز وليس من تاريخ إجرائه.

وإذا لم يتم تسليم الإعلان إلى المدين أو لم يعلن به أو كان الإعلان معيبا بعبء يبطله؛ فإن للمدين أن يتمسك بهذا البطلان، وإذا حكم ببطلان الإعلان؛ فإن ذلك لا يبطل الحجز، لأن الحجز سابق على الإعلان؛ وإنما يكون البيع الذي جرى بناء على هذا الإجراء الباطل باطلا باعتباره لاحقا عليه^(١).

رابعا: الآثار المترتبة على حجز المنقول لدى المدين:

بمجرد تحرير محضر الحجز على النحو الذي بيناه؛ تصبح المنقولات محجوزة ولو لم يتم تعيين حارس عليها، ومؤدى ذلك: أن تنقيد سلطات المالك عليها، سواء عين حارسا عليها أم لم يتم تعيينه؛ فتتقيد سلطاته على النحو الآتي:

(١) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٤٤.

١- تتقيد سلطة المالك المحجوز عليه في التصرف في المنقولات المحجوزة؛ فلا يملك التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات، وسواء كان ذلك بعوض أم بغير عوض، ولا يكون تصرفه نافذا في حق الدائنين الحاجزين، ولو كان نافذا فيما بينه وبين المتصرف إليه وفي مواجهة الدائنين الآخرين الذين لم يكونوا طرفا في إجراءات الحجز، بمعنى أنه إذا بطل الحجز؛ صار التصرف صحيحا وناظا.

وإذا قام المدين بتسليم المنقول إلى المتصرف إليه رغم توقيع الحجز؛ فإنه يعاقب بعقوبة التبيد أو السرقة، بحسب ما إذا كان هو الحارس على الأموال المحجوزة أو لم يكن كذلك وفقا لنصوص قانون العقوبات. ويعتبر تسليم المدين للمال المحجوز إلى المتصرف إليه مخالفا للقانون حتى ولو كان الحجز باطلا أو كان المدين معتقدا بطلانه طالما لم يصدر حكم من القضاء بهذا البطلان يزيل أثر الحجز على الأموال.

٢- تتقيد سلطة المالك المحجوز عليه في استعمال الأشياء المحجوزة واستغلالها؛ فإذا كان قد عين حارسا عليها؛ فإن له استعمالها فيما خصصت له فقط، وله أن يستغلها ويحصل على ما ينتج منها. وإذا لم يكن هو الحارس عليها؛ فإن الحارس يستغلها ويديرها متى كان الاستغلال أو الإدارة لازما، ويكون عائد الاستغلال أو الإدارة حقا للمدين المحجوز عليه^(١).

الفرع الثاني

تعيين الحارس على المنقولات المحجوزة

أولا: حراسة المنقولات المحجوزة:

قلنا إن المنقولات تصير محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز، ولو لم يتم تعيين حارس عليها، وهذا ما نص عليه المشرع صراحة في المادة (٣٦١) مرافعات، ومؤدى ذلك أن تعيين الحارس لا يعتبر شرطا لتمام الحجز أو لصحته^(٢)، وذلك عكس ما كان ينص عليه قانون المرافعات القديم، والذي كان يعتبر تعيين الحارس من

(١) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٤٤.

(٢) د. فتحي والي، التنفيذ، ص ٣٥٨.

الإجراءات اللازمة لتوقيع الحجز وبغيره لا يتم الحجز ولا ينتج أثره^(١)، وعكس ما تنص عليه بعض التشريعات الأخرى غير القانون المصري، والتي تعتبر أن تعيين الحارس إجراء مكملًا للحجز وبدونه لا ينتج الحجز أثره^(٢).

ويقصد بالحراسة في مجال الحجز: ما يتخذ من الإجراءات بعد توقيع الحجز، بهدف المحافظة على المال المحجوز، ويرتبط استلزام الحراسة بوجود الخشية من تصرفات المدين المحجوز عليه في المال المحجوز؛ فإذا لم يكن هناك داع لهذه الخشية، فليس ثمة ما يدعو إلى استلزام الحراسة، كما في حالة حجز ما للمدين لدى الغير^(٣).

والنصوص المنظمة للحراسة في حجز المنقول لدى المدين، تنظر إليها لا باعتبارها إجراء لا يتم الحجز بدونه؛ وإنما باعتبارها إجراء لاحقًا لتوقيع الحجز والغرض منه المحافظة على الأشياء المحجوزة، وذلك حتى لا يعتمد المدين إلى تعطيل تعيين الحارس ليؤخر توقيع الحجز^(٤). وعلى الرغم من ذلك تجب المحافظة على الأشياء المحجوزة أثناء فترة الحجز -والتي قد تطول لبضعة أشهر- وحتى يتم بيعها، وذلك بأن يعهد إلى شخص أو أكثر لحراستها^(٥).

ثانياً: كيفية تعيين الحارس:

أوجبت المادة (٣٦٤) على معاون التنفيذ أن يعين حارساً على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقدر. ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر في المحضر. ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو معاون التنفيذ ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهرًا لأيهما إلى الدرجة الرابعة.

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٤٢٠.

(٢) د. رمزي سيف، إجراءات التنفيذ، ص ٢٣٦.

(٣) د. محمود التحيوي: النظام القانوني للحجز، ص ٣٣.

(٤) د. رمزي سيف، إجراءات التنفيذ، ص ٢٣٦.

(٥) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٢٦٨.

ووفقا لما أوجبه هذه المادة؛ فإنه إذا اتفق الحاجز والمحجوز عليه على تعيين شخص حارسا على المحجوزات، وجب على معاون التنفيذ تعيينه، ولو كان غير مقتدر، وهنا تنتفي مسؤولية معاون التنفيذ. أما إذا لم يتفق طرفي التنفيذ على شخص معين، وأتى أحدهما بشخص مقتدر التزم معاون التنفيذ بتعيينه حارسا. وإذا لم يأت أحدهما بشخص ما؛ قام معاون التنفيذ بتعيين الحارس. ويجوز تعيين أكثر من حارس واحد على الأشياء المحجوزة إذا اقتضت الضرورة ذلك؛ كأن تكون المحجوزات كثيرة، أو كان يخشى تهريبها، فيعين حارسا أو أكثر بحسب اللزوم^(١).

متى يعين المحجوز عليه حارسا:

إذا لم يتفق الدائن الحاجز والمحجوز عليه على تعيين حارس، وكان المدين المحجوز عليه حاضرا وقت الحجز؛ فإن الأمر هنا لا يخرج عن أحد فرضين:

الأول: أن يطلب المدين تعيينه حارسا على منقولاته المحجوزة، أو يقبل تكليفه بالحراسة؛ فإذا طلب تعيينه حارسا على أمواله، وجب على معاون التنفيذ إسناد الحراسة إليه دون غيره؛ إلا إذا خشى تبديده للأموال بناء على أسباب معقولة، فيرفض تعيينه، ويجب ذكر هذه الأسباب في محضر الحجز^(٢).

والثاني: أن يرفض المدين المحجوز عليه تعيينه حارسا؛ فإن على معاون التنفيذ أن يعين شخصا غيره؛ فإذا لم يجد شخصا آخر يصلح تعيينه حارسا أو وجده ولكن رفض قبول الحراسة، فإن المدين المحجوز عليه يجبر على قبول الحراسة ولا يعتد برفضه إياها^(٣) (مادة ٣٦٥ مرافعات).

(١) المستشار. محمد عزمي البكري: الحجز القضائي على المنقول، ص ١٩٥.

(٢) وقد شاء المشرع بذلك أن يبيح للمحجوز عليه مالك الأشياء المحجوزة، أن يستعملها فيما خصصت له إذا كان هو الحارس عليها (مادة ٣٦٨) كما أن له أن يملك ثمارها إن كانت مما ينتج ثمارا وله تأجيرها إن كانت معدة للتأجير كعربات النقل، ولهذا قرر قرر إيجاب تعيين المحجوز عليه حارسا إذا طلب ذلك. (د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٤٢٢).

(٣) د. محمود السيد التحيوي، النظام القانوني للحجز، ص ٣٤-٣٥.

عدم وجود من يقبل الحراسة في غيبة المدين:

إذا لم يجد معاون التنفيذ من يقبل الحراسة وكان المدين غائبا؛ وجب على معاون التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة، وأن يرفع الأمر فورا لإدارة التنفيذ، لتأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو معاون التنفيذ، وإما بتكليف أحد رجال الإدارة في المنطقة بالحراسة مؤقتا..

ثالثا: توقيع الحارس على محضر الحجز:

أوجبت المادة (٣٦٦) مرافعات على الحارس أن يوقع على محضر الحجز وتسلم له صورة منه؛ فإن امتنع عن التوقيع على المحضر أو رفض استلام صورته، وجب على معاون التنفيذ أن يسلم صورة محضر الحجز في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل، وعلى معاون التنفيذ إثبات كل ذلك في حينه في المحضر.

رابعا: المركز القانوني للحارس:

يعتبر الحارس من أعوان القضاء، فهو ليس وكيلًا عن الحاجز أو المحجوز عليه، ويؤدي الحارس خدمة عامة ويأخذ حكم الحارس القضائي، وإذا كان المحجوز عليه هو الحارس؛ فإنه في هذه الحالة يحوز المحجوزات بصفة جديدة، أي باعتباره من أعوان القضاء، ولذلك يلتزم بالواجبات التي يفرضها القانون على الحارس بصرف النظر عن كونه محجوزا عليه^(١).

خامسا: واجبات الحارس:

تتمثل مهمة الحارس وواجباته في المحافظة على الأشياء المحجوزة إلى أن ينتهي الحجز بالبيع أو بأي سبب آخر، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي، وأن يقدم الأشياء المحجوزة كلما طلب منه ذلك وكذلك يوم البيع، وألا يستعمل الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يغيرها، إلا وفقا للاستثناءات المقررة قانونا، ونبين ذلك فيما يلي:

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/٢٨٩.

١- المحافظة على المال المحجوز وثماره:

يتمثل الواجب الأساسي للحارس في المحافظة على الأشياء المحجوزة وما تنتجها من الثمار إلى أن ينتهي الحجز ببيعها أو أي سبب آخر، وتجري على الحراسة أحكام الوديعة؛ فإذا كانت الحراسة بغير أجر، وجب على الحارس أن يبذل في العناية بالمحجوزات وحفظها، ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد. أما إذا كانت الحراسة بأجر؛ فإن على الحارس بذل عناية الرجل المعتاد في حفظ المال المحجوز (مادة ٧٢٠ مدني)، ويكون مسئولاً عن هلاكه؛ إلا إذا كان الهلاك بقوة قاهرة^(١).

وإذا بدد الحارس الأشياء المحجوزة عوقب بعقوبة خيانة الأمانة ولو كان هو المالك (المادتان ٣٤١-٣٤٢ عقوبات)، ويتطلب القانون في هذه الجرائم قصدا جنائيا خاصا هو نية عرقلة التنفيذ، لأن الغرض من حماية قانون العقوبات للمال المحجوز عليه، ليس حماية الملكية؛ وإنما المحافظة على المال المحجوز لأغراض التنفيذ^(٢).

٢- عدم استعمال المحجوزات أو استغلالها أو تغييرها:

وهذا ما أوجبه المادة (١/٣٦٨) مرافعات، بنصها على أنه لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها؛ وإلا حرم من أجر الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات، وقد أوردت المادة استثناءان على هذا الحظر:

الأول: إذا كان الحارس هو صاحب الأشياء المحجوزة أو صاحب حق الانتفاع بها؛ فإنه يجوز له أن يستعملها فيما خصصت له، وتكون ثمار الاستعمال في هذه الحالة من حق الحارس فلا يشملها الحجز.

الثاني: إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو آلات لازمة لإدارة استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة^(٣) جاز لقاضي التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن

(١) المستشار. محمد عزمي البكري: الحجز القضائي على المنقول، ص ٢٠٠.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٦/٢٩٠.

(٣) وبطبيعة الحال يجب ألا تكون هذه الأشياء مملوكة لمالك الأرض أو المصنع؛ لأنها إذا كانت مملوكة له؛ فإنها تصبح عقارا بالتخصيص ولا يحجز عليها مع العقار المخصصة لخدمته بطريق التنفيذ على العقار.

أن يكلف الحارس الإدارة ، أو الاستغلال، أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك (مادة ٢/٣٦٨).

ومفاد ذلك أن الاستغلال المحظور في المادة؛ هو الذي يتم بغير إذن من القضاء، ومن ثم يجوز للحاجز أو المحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ تكليف الحارس بالإدارة أو الاستغلال في الحالات المذكورة بالنص أو يستبدل به حارس آخر إذا كان لا يمكنه الإدارة أو الاستغلال^(١). وقد أكدت ذلك المادة (٣٧٠) بنصها على أنه "يجوز طلب الإذن بالجني والحصاد من قاضي التنفيذ بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من أحد ذوي الشأن".

٣- الاستمرار في الحراسة حتى يوم البيع:

حيث أوجب القانون على الحارس أن يستمر في حراسة الأشياء المحجوزة منذ تسلمه مهمة الحراسة وحتى يوم بيع المحجوزات، ولا يجوز له أن يطلب إعفاه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب تقتضي ذلك، ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضي التنفيذ (مادة ٣٦٩ مرافعات).

ويختص قاضي التنفيذ بالفصل في طلب الإعفاء من الحراسة، باعتباره مسألة مستعجلة من مسائل التنفيذ التي يختص بها، ولذلك نصت المادة المشار إليها على أن ميعاد الحضور في هذه الدعوى يوم واحد. وقد جعل المشرع الحكم الصادر في هذا الطلب سواء بقبول إعفاء الحارس من الحراسة أو رفض طلبه، حكما نهائيا غير قابل للطعن.

٤- تقديم الأشياء المحجوزة وإبراز صورة محضر الحجز عند إعادة الحجز عليها:

إذا انتقل معاون التنفيذ لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها، وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة (مادة ١/٣٧١ مرافعات)، وإذا استمر الحجز قائما حتى التاريخ المحدد للبيع التزم الحارس بتقديم المحجوزات لمعاون التنفيذ لبيعها؛ وإلا كان مرتكبا لجريمة التبديد، كما يلتزم

(١) المستشار. محمد عزمي البكري: الحجز القضائي على المنقول، ص ٢٠١.

الحارس بتقديم المحجوزات إلى المحجوز عليه إذا كان الحجز قد رفع بناء على طلبه، أو يسلمها إلى المسترد في دعوى الاسترداد إذا حكم له بها في هذه الدعوى.

٥ - تقديم كشف حساب:

توجب المادة (٧٣٧) مدني، أن يمسك الحارس دفاتر حساب منتظمة، ولقاضي التنفيذ إلزامه بإمسك دفاتر يكون موقعا عليها من المحكمة، ويلتزم الحارس أن يقدم كل سنة على الأكثر حسابا معززا بالمستندات، وإذا كان قاضي التنفيذ هو الذي عينه؛ فإنه يلتزم فضلا عن ذلك بإيداع صورة من هذا الحساب في قلم كتاب محكمة التنفيذ المختصة (مادة ٢/٧٣٥ مدني)، فإذا لم يقدم الحارس حسابا سنويا؛ فإنه يلتزم بتقديمه بصفة خاصة عند انتهاء الحراسة^(١).

سادسا: انتهاء مهمة الحراسة:

يظل الحارس مكلفا بالحراسة إلى أن تنتهي الحراسة بتقديم الأشياء المحجوزة لمعاون التنفيذ في يوم البيع، أو إلغاء الحجز نتيجة سقوطه أو بطلانه، أو بانقضاء الحجز بسبب الإيداع مع التخصيص، أو وفاة الحارس أو استبداله بغيره للقيام بالإدارة أو الاستغلال، أو إعفاؤه من الحراسة بناء على طلبه^(٢). وكذلك تنتهي الحراسة بالحكم في دعوى الاسترداد بملكية الأشياء المحجوزة إلى للمسترد^(٣).

سابعا: أجر الحارس:

نصت المادة (٣٦٧) مرافعات، على حق الحارس في الأجر نظير الحراسة، وقيدت ذلك بألا يكون الحارس هو المدين المحجوز عليه، أو الحائز للمنقولات المحجوز عليها؛ فإذا كان كذلك فلا يستحق أجرا عن الحراسة. وتختص إدارة التنفيذ بتحديد مقدار هذا الأجر، بحسب ما تراه من أمور تدخل في تقديره، كقدر عمل الحارس ومدة الحراسة وأهمية الأشياء المحجوزة وما تتطلبه من العناية وبذل الجهد في حراستها.

(١) د. محمود السيد التحيوي، النظام القانوني للحجز، ص ٣٨.

(٢) د. رمضان عبدالكريم علام، الوجيز في قواعد التنفيذ الجبري، ص ٣٤٠.

(٣) د. أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ، ص ٤٢٤.

وقد منح المشرع لهذا الأجر امتيازاً على غيره من الديون، وهو امتياز المصروفات القضائية، باعتبار أن الحارس كما أشرنا يعتبر من أعوان القضاء في القيام بواجب الحراسة، ومن ثم يقدم أجره على غيره من الديون المحجوز لأجلها، فيستوفيه أولاً.

المطلب الثاني

التدخل في الحجز

رأينا أن الحجز لا يؤدي إلى إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه، فيظل مالكا له رغم الحجز، حتى يتم بيعه، ويترتب على ذلك أنه يجوز لأي دائن آخر غير الحاجز؛ أن يجري حجزاً على المال المحجوز وإن تعدد الدائنون الحاجزون. بمعنى أن لأي دائن آخر أن ينفذ على ذات المال المحجوز من دائن سبقه في اتخاذ إجراءات الحجز، ويشارك مع هذا الحاجز الأول في قسمة ثمن المنقولات المحجوزة، لأن الحجز لا يمنح الحاجز الأول امتيازاً في استيفاء حقه من قيمة المحجوزات أولاً، بل يشترك معه في ذلك من يتدخل في الحجز بعده من الدائنين الآخرين.

وفي ذلك أخذ المشرع المصري بالقاعدة المقررة في القانون الفرنسي، والتي تقضي بأن "الحجز لا يرد على الحجز"، وليس المقصود بذلك منع الدائنين من توقيع حجز آخر على نفس مال المدين الذي سبق توقيع الحجز عليه؛ وإنما المقصود تنظيم إجراءات خاصة في حالة حجز ثان لمصلحة دائن آخر غير الحاجز الأول، وهذا التنظيم يهدف إلى توحيد إجراءات التنفيذ عند تعدد الحجز، بحيث لا يبدأ الحاجز الثاني إجراءات الحجز من جديد بل يتدخل في إجراءات الحجز القائم^(١). ويكون تدخل الدائنين الآخرين بموجب سند آخر بأحد طريقتين؛ الأول: جرد الأشياء المحجوزة، والثاني: توقيع الحجز على الثمن تحت يد معاون التنفيذ^(٢).

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ٢٩٩/٦.

(٢) ولا شك أن في ذلك توحيد لإجراءات التنفيذ إذا تعددت الحجز، والتوفير في مصاريف التنفيذ، ثم إن وضع المال تحت يد القضاء منذ إجراء الحجز الأول وتعيين الحارس عليه، تتنفي معه الحاجة إلى تعدد إجراءات التنفيذ. (د. محمود السيد التحيوي، النظام القانوني للحجز، ص ٣٠٧).

والطريق الأول مقرر لكل دائن آخر بيده سند تنفيذي، والثاني مقرر لمن بيده سند تنفيذي، ولمن لم يحصل على هذا السند بعد، باعتبار أن الطريق الثاني هو حجز ما للمدين لدى الغير (معاون التنفيذ) وهو حجز تحفظي كما قدمنا. ونبين ذلك فيما يلي:

الفرع الأول

التدخل في الحجز عن طريق جرد الأشياء المحجوزة

يسمح القانون للدائنين الآخرين الذين لم يشتركوا مع الحازر الأول في اتخاذ إجراءات الحجز أن يتدخلوا في هذا الحجز عن طريق جرد الأشياء المحجوزة، وهذا الطريق لا يكون إلا للدائن الذي بيده سند تنفيذي، فهذا وحده الذي يستطيع أن يتدخل في الحجز عن طريق جرد الأشياء المحجوزة^(١).

ومعنى جرد الأشياء المحجوزة هو تحرير محضر بواسطة معاون التنفيذ يذكر فيه الأشياء التي تم حجزها من قبل، وينتج محضر الجرد ذات الآثار التي ينتجها محضر الحجز، أي تكون الأشياء الوارد ذكرها في محضر الجرد موضوعة تحت يد القضاء^(٢).

وفي ذلك نصت المادة (١/٣٧١) مرافعات على أنه "إذا انتقل معاون التنفيذ لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى معاون التنفيذ أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها إن كانت في نفس المحل".

فإذا أراد دائن للمحجوز عليه أن يفيد من حجز قائم أو أن يوقع - فضلا عن ذلك - حجزا على ما لم يشملته الحجز الأول من أموال المدين؛ وجب على معاون التنفيذ أن ينتقل إلى مكان وجود المنقولات السابق حجزها ويحرر محضرا بذلك يسمى محضر الجرد، ويجب على حارس الحجز الأول أن يبرز له صورة محضر الحجز

(١) د. أحمد مليجي، الموسوع الشاملة، ج ٦/٣٠٠.

(٢) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٤٢٣.

ويقدم الأشياء المحجوزة^(١). فإذا تعدد الحارس عدم إبراز صورة محضر الحجز وتضرر الحاجز الجديد عوقب الحارس بالتبديد (مادة ٣٧٣ مرافعات)^(٢).

أولاً: مشتملات محضر الجرد:

يجب أن يشتمل محضر الجرد على البيانات العامة التي يتعين توفرها في أوراق المحضرين، ويشتمل على بيان الأشياء التي سبق الحجز عليها، وعلى ما لم يسبق حجزه من منقولات المدين (إذا وجد أثناء الجرد منقولات لم يسبق حجزها وطلب الحاجز المتدخل الحجز عليها)، ويعين حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في نفس المحل، مع الاكتفاء بالنسبة لبيان الأشياء المحجوزة ووصفها وتقدير قيمتها على نقل ما جاء بالمحضر الأول بعد التأكد من صحتها. ويذكر في محضر الجرد نفس يوم البيع الذي سبق تحديده في محضر الحجز الأول؛ إذ الهدف الأساسي من التدخل في الحجز عن طريق الجرد؛ هو بيع ذات المال المحجوز في يوم واحد بالنسبة لجميع الحاجزين، ولا يلزم تعيين حارس جديد وإنما يكفي بالحارس الأول^(٣).

ثانياً: الحجز على المنقولات التي لم يشملها الحجز الأول:

يتضح من ذلك أن معاون التنفيذ أثناء قيامه بجرد الأشياء المحجوزة، قد يجد منقولات لم يشملها محضر الحجز الأول، وبالتالي ليست محجوزة، وفي هذه الحالة إذا طلب الحاجز الجديد (المتدخل) الحجز على هذه المنقولات؛ فإن معاون التنفيذ يقوم بحجزها حجزاً أولاً لصالحه، سواء بذكرها في محضر الجرد وتقدير قيمتها أو بتحرير محضر حجز جديد مستقل بها. فإذا تم حجزها بمحضر الجرد؛ فإنها تعلن مع إعلان هذا المحضر إلى الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (٣٧١)، أما إذا حرر بها محضر حجز جديد، فلا داعي لإعلانها بهذا الشكل؛ وإنما تراعى في هذا الحجز الإجراءات التي بينها في المطلب الأول.

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٤٤٥.

(٢) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٤٩.

(٣) د. أحمد أبو الوفا، ص ٤٤٥ - م. محمد عزمي البكري، ص ٢٨١.

ويلاحظ أن الحجز على المنقولات التي لم يسبق حجزها يتم لصالح الحاجز الثاني فقط، ومع ذلك يجوز للحاجز الأول أن يطلب التدخل في هذا الحجز عن طريق محضر جرد جديد وفقا للمادة (٣٧١)^(١).

ثالثا: تعلق هذا الإجراء بالنظام العام:

لما كان المشرع قد قرر اتباع هذا الطريق عند توقيع الحجز على أموال سبق حجزها؛ فإنه يكون شرطا شكليا لازما لصحة الإجراءات، وهو شرط من النظام العام باعتبار أنه يتعلق بالطرق المقررة قانونا لاقتضاء الحقوق أي الحصول على الحماية القضائية، ومن ثم يترتب البطلان إذا خالف معاون التنفيذ هذا الطريق وقام بحجز الأموال المحجوز عليها بمحضر حجز جديد، وتحكم المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها^(٢).

رابعا: عدم معرفة معاون التنفيذ بسبق الحجز على المنقولات:

البطلان الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة، جزاء على مخالفة الطريق الذي أوجبه المشرع للتدخل في الحجز عن طريق الجرد، ولكن قد لا يكون معاون التنفيذ على علم بسبق الحجز على المنقولات التي يطلب الحاجز الثاني حجزها، كما لو كان المدين هو الحارس على هذه المنقولات وأخفى محضر الحجز الأول.

ففي هذه الحالة إذا قام معاون التنفيذ بحجزها جزاء مبتدأ وعين حارسا عليها؛ فإن إجراءاته تكون صحيحة، وغاية الأمر أنه سيحصل التعارض نظرا لاختلاف موعد البيع بين الحجزين الأول والثاني، فيكون ذلك مثارا لاعتراض الحاجز الذي لم يحل

(١) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٤٢٧.

(٢) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٥٠.

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه "تقضي المادة ٥١٧ من قانون المرافعات -السابق ويقابلها المادة ٣٧١ من القانون الحالي- بأن توقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لا يجرى بالإجراءات المعتادة في الحجز؛ وإنما يكون بجرد الأشياء السابق حجزها، فهو بهذه المثابة طلب بإيقاف الحجز الأول ليشارك فيه سائر الدائنين الحاجزين، ويكون إعلان محضر الجرد إلى الحارس معارضة في رفع الحجز وتثبيت عبء الحراسة على عاتقه، فلا ترفع عنه ويظل مكلفا بالحراسة على المحجوزات لمصلحة المعارض والحاجز الأول على السواء، ويمتنع عليه التصرف في المحجوزات لأي سبب من الأسباب بغير الطريق الذي رسمه القانون". (نقض جنائي ١٨/٣/١٩٦٣، سنة ١٤ ص ١٩١).

موعد بيعه، ومن ثم يرفع إشكال بالأمر، ويؤدي هذا الإشكال إلى إيقاف البيع إلى حين توحيد ميعاده، أو إلى الاستمرار في البيع مع إيداع حصيلته خزانة المحكمة، ويكون للدائن المعارض إيقاع الحجز على هذا الثمن^(١).

خامسا: إعلان محضر الجرد:

أوجبت المادة (٢/٣٧١) على معاون التنفيذ أن يعلن محضر الجرد خلال اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا ومعاون التنفيذ الذي أوقع الحجز الأول.

ولا ينتج محضر الجرد أثره في مواجهة هؤلاء الأشخاص إلا بإعلانه إليهم إعلانا صحيحا؛ فإذا لم يتم الإعلان أو وقع باطلا؛ فإنه لا ينتج أي أثر في مواجهتهم، أي يعتبر التدخل بمقتضى محضر الجرد كأن لم يكن^(٢).

ويترتب على إعلان محضر الجرد: المعارضة في رفع الحجز الأول؛ أي مطالبة الحاجز الأول بإبقاء الحجز قائما وعدم النزول عنه وتكليفه السير في إجراءات البيع حتى يتم في اليوم المعين له، وتكليف الحارس بالمحافظة على الأشياء المحجوزة لمصلحة الحاجز الثاني، فضلا عن مصلحة الحاجز الأول. ويترتب على هذا الإعلان أيضا، تكليف معاون التنفيذ ببيع الأشياء المحجوزة في اليوم المحدد لذلك، مع منعه من الكف عن البيع إلا إذا أصبح المتحصل من البيع كافيا لأداء حق المتدخل فضلا عن حق الحاجز الأول. وكذلك منع معاون التنفيذ من أداء حق الحاجز الأول من ثمن البيع؛ إذا لم يكف هذا الثمن للوفاء بحقه مع الدائن المتدخل، وفي هذه الحالة يجب إيداع الثمن خزانة المحكمة لتقسيمه بين الحاجزين قسمة غرماء.

سادسا: الآثار المترتبة على التدخل في الحجز عن طريق محضر الجرد:

يترتب على التدخل في الحجز عن طريق محضر الجرد، أثاران مهمان:

الأول: الاستمرار في البيع حتى الوفاء بحقوق جميع الدائنين الحاجزين:

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/٣٠٣.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/٣٠٣.

فيلتزم معاون التنفيذ بالاستمرار في البيع وعدم الكف عنه حتى يتحصل من ثمن البيع ما يكفي وفاء ديون الدائنين الحاجزين والمتدخلين؛ فإذا كانت حصيلة البيع لا تكفي ذلك؛ فإن عليه إيداع حصيلة البيع خزانة المحكمة المختصة، ليتم توزيعها على جميع الدائنين الحاجزين.

الثاني: إمكانية الحلول في مباشرة إجراءات التنفيذ:

ذلك أن الحاجز الأول يظل دائماً صاحب الحق في مباشرة إجراءات التنفيذ ومتابعتها، وهو ما قد يؤدي إلى الإضرار بالدائن المتدخل إذا أهمل الحاجز الأول في مباشرة الإجراءات أو تقاعس أو تواطأ مع المحجوز عليه إضراراً بالحاجز الثاني. وحماية لحقوق الحاجز المتدخل، نص القانون على حق الحلول في مباشرة الإجراءات محل الحاجز الأول؛ إذا كان بيد الحاجز المتدخل سنداً تنفيذياً، وقام بإنذار الحائز الأول (مادة ٣٩٢). وذلك بناء على عريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ.

سابعاً: لا أثر لزوال الحجز أو بطلانه على الحجز اللاحقة عليه:

لا يخل تعاقب الحجز على ذات المال باستقلال كل حجز منها عن الآخر، فكل حجز تم صحيحاً يظل قائماً بذاته عما سبقه أو لحق به من حجز، ولذلك إذا نزل الحاجز الأول عن حجزه فإن الحجز يظل قائماً لمصلحة الحاجز الثاني (مادة ٣٧١/٢)، كما أن الحجز لا يتأثر ببطلان الحجز السابق عليه، ولذلك نصت المادة (٣٧٢) على أنه إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة في ذاتها^(١).

(١) وبهذا حسم المشرع في المادة ٣٧٢ الخلاف الذي كان سائداً في الفقه حول أثر بطلان الحجز الأول على الحجز الثاني فقد ذهب رأى إلى بطلان الحجز الثاني كأثر لبطلان الحجز الأول وذهب رأى آخر إلى التفرقة بين البطلان الشكلي والبطلان الموضوعي أو بين البطلان الظاهر وغير الظاهر والقول بأن البطلان الشكلي أو الظاهر يؤدي إلى بطلان الحجز الثاني بعكس البطلان الموضوعي أو غير الظاهر وقد رأى المشروع تقنين الرأي الغالب في الفقه وهو الذي يذهب إلى أن الحجز متى تم صحيحاً في ذاته لا يتأثر ببطلان الحجز السابق عليه اعتباراً بأن كل حجز يكون عملاً إجرائياً مستقلاً تتوافر فيه عناصر العمل الإجرائي ولا يعتمد في صحته على الحجز السابق. (المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات عن المادة ٣٧٢).

الفرع الثاني

التدخل عن طريق الحجز على الثمن تحت يد معاون التنفيذ

الصورة السابقة للتدخل في الحجز (التدخل عن طريق الجرد) لا تكون إلا للدائن الذي بيده سندا تنفيذيا، وأراد توقيع الحجز على منقولات مدينه التي سبق حجزها من دائن آخر؛ أما إذا أراد الدائن التدخل في الحجز ولم يكن بيده سندا تنفيذيا؛ فإن المشرع أوجد له طريقا آخر لهذا التدخل، وهو التدخل عن طريق الحجز على الثمن المتحصل من البيع تحت يد معاون التنفيذ، وهو صورة من صور حجز ما للمدين لدى الغير، باعتبار معاون التنفيذ من الغير في هذه الصورة.

وقد نصت على هذا الطريق من طريقي التدخل المادة (٣٧٤) مرافعات، بنصها على أنه "للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد معاون التنفيذ على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى الحكم بصحة الحجز". ويتضح من هذا النص أن المشرع نظم إجراءات التدخل بالحجز على الثمن تحت يد معاون التنفيذ على النحو الآتي:

- ١- يجوز التدخل بالحجز على الثمن تحت يد معاون التنفيذ للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي، ومن باب أولى يجوز ذلك لمن بيده هذا السند، وإن كانت عبارة المادة توحى بأن هذا الطريق خاص بمن ليس بيده سند تنفيذي^(١).
- ٢- هذا الطريق صورة من صور حجز ما للمدين لدى الغير، ولذا يجب لمباشرته اتباع الإجراءات المقررة في حجز ما للمدين لدى الغير، ومن ثم لا يجوز هنا اتباع إجراءات حجز المنقول لدى المدين^(٢)، ولا يجب في هذا الحجز سبق إعلان

(١) د. أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ، ص ٤٥٣. ويرى سيادته أنه ما كان يجب أن يورد المشرع النص بصورته هذه، لأنه يفهم منها أن هذا الطريق مقرر فقط لمن ليس بيده سند تنفيذي، والأمر على خلاف ذلك. ونؤيده في هذا الرأي.

(٢) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٥٢.

السند التنفيذي من الدائن الذي يكون بيده هذا السند، ويكون للدائن الذي بيده سند تنفيذي حرية اختيار هذا الطريق أو التدخل عن طريق محضر الجرد.

٣- يعفى الحاجز في هذا الحجز من رفع دعوى صحة الحجز حتى ولو لم يكن بيده سند تنفيذي^(١)، وذلك لصريح عبارة المادة "بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز"، وهو استثناء قاصر على هذه الدعوى فقط وفي هذه الصورة من صور حجز ما للمدين لدى الغير؛ ومن ثم لا يحول دون القول بوجوب الحصول على إذن من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز على الثمن تحت يد معاون التنفيذ؛ فإذا تم هذا الحجز بدون سند تنفيذي وبدون إذن من القاضي؛ فإنه يكون باطلا^(٢).

٤- يجوز التدخل بهذا الطريق قبل البيع أو بعده، إلى أن يسلم الثمن إلى الدائن الحاجز، وإذا كان الحجز قد تم قبل البيع؛ فيجب على معاون التنفيذ أن يمضي في البيع إلى أن يتحصل منه ما يكفي للوفاء بدين الحاجز والمتدخل بهذا الطريق، وذلك إعمالاً لنص المادة (٣٩٠) مرافعات، والتي توجب على معاون التنفيذ ألا يكف عن البيع إلا إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف، وما يوقع بعد ذلك من الحجز تحت يد معاون التنفيذ أو غيره. وإذا لم تكف حصيلة البيع لوفاء ديون جميع الدائنين الحاجزين؛ وجب على معاون التنفيذ إيداع المتحصل من البيع خزانة المحكمة ليقسم بينهم.

٥- إذا وقع هذا الحجز قبل البيع ورد على كل الثمن، وإذا وقع بعد البيع فلا يتناول من الثمن إلا ما زاد على وفاء الديون المحجوز من أجلها قبل البيع (المادتان ٣٩٠ و ٤٦٩ مرافعات)^(٣).

٦- يترتب على هذا الحجز ما يترتب على التدخل بالجرد، من حلول المتدخل محل الحاجز الأول، إذا تنازل عن الحجز أو أهمل أو تباطأ في الإجراءات؛ وذلك إذا كان بيد المتدخل بالحجز على الثمن سنداً تنفيذياً.

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/٣١٢.

(٢) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص٣٥٣.

(٣) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/٣١٣.

٧- إذا زال الحجز الأصلي لأي سبب من الأسباب؛ فإن الحجز على الثمن يسقط بالتبعية ولو كان بيد الحاجز سنداً تنفيذياً؛ وذلك لأن بطلان الحجز على المنقول أو زواله لأي سبب يؤدي إلى زوال أي احتمال لإجراء بيعه، وبالتالي يصبح الحجز على الثمن بغير محل^(١). وإذا وقع الحجز على المتحصل من البيع بعد أن تم البيع، ثم حكم بطلان الحجز الأول وأبطل البيع بالتالي؛ فإن هذا البطلان يؤثر على الحجز على حصيلة التنفيذ، لعدم وجود بيع في هذه الحالة، حتى يقال بأنه تم توقيع الحجز على المتحصل منه^(٢).

المطلب الثالث

الاعتراض على الحجز

(دعوى استرداد المنقولات المحجوزة)

لا شك أنه قد يحدث اعتراض على الحجز أثناء إجرائه أو بعده، وهذا الاعتراض قد يأتي من المدين المحجوز عليه أو من الغير، وقد يبدى أمام معاون التنفيذ كإشكال في التنفيذ، أو يرفع بدعى عادية أمام قاضي التنفيذ المختص، وقد يكون مضمون الاعتراض طلب إجراء وقتي يوقف التنفيذ، أو أمراً متعلقاً بموضوع النزاع، وجميع هذه الاعتراضات تعتبر إشكالاً في التنفيذ، سواء كانت إشكالات موضوعية أو إشكالات وقتية، وقد تناولنا هذه الإشكالات في الفصل الرابع من الباب الأول. غير أن القانون اهتم بنوع معين من هذه الاعتراضات على حجز المنقول لدى المدين فنظمه بنصوص خاصة؛ وهو دعوى استرداد المنقولات المحجوزة^(٣).

أولاً: تعريف دعوى الاسترداد:

دعوى استرداد المنقولات المحجوزة هي دعوى موضوعية يرفعها شخص له صلة بالمنقول المحجوز عليه لدى المدين، ويطلب فيها الحكم لنفسه بملكية هذا المنقول، وبطلان إجراءات الحجز والغائه في مواجهة الحاجز والمحجوز عليه.

(١) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٤٣٨.

(٢) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٥٤.

(٣) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٤٣٩.

ذلك أن المنقولات الموجودة في حيازة المدين والتي يجرى الحجز عليها، قد لا تكون مملوكة له؛ وإنما للغير، وحيازة المدين لها لمجرد كونه مستأجراً أو مستعيراً أو منتفعاً أو مودعاً عنده، وقد لا تكون هذه المنقولات مملوكة للغير؛ وإنما له عليها حق انتفاع، فتدخل المشرع بإيجاد طريق خاص يلجأ إليه هذا الغير للاعتراض على حجز هذه المنقولات، وهذا الطريق هو دعوى الاسترداد، والتي قد تنصب على ملكية المنقولات المحجوزة أو أي حق يتعلق بها كحق الانتفاع بغرض التمكن من حيازة هذه المنقولات للممارسة حق الانتفاع أو أي حق آخر عليها^(١).

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المدعي في دعوى الاسترداد؛ وإن عبرنا عنه هنا بالغير، إلا أنه لا يأخذ المركز القانوني للغير الذي يعد من أطراف التنفيذ، ذلك أنه على الرغم من وجود صلة للمسترد بالمال المحجوز عليه؛ إلا أنه لا يلزم بالاشتراك في التنفيذ^(٢).

ثانياً: موضوع دعوى الاسترداد والطلبات فيها:

يتضح مما سبق أن موضوع هذه الدعوى قد يكون الحكم بملكية المنقولات المحجوزة، أو أي حق يتعلق بها كحق الانتفاع، أو حق من حقوق الامتياز؛ إلا أنه يجب فضلاً عن طلب الحكم بالملكية أو أي حق آخر من هذه الحقوق، أن يطلب المدعي (المسترد) بطلان إجراءات الحجز وإلغائه في مواجهة كل من المدين، والحاجز، والحاجزين المتدخلين (إن وجدوا)، فإذا اقتصر طلبه في الدعوى على الملكية دون طلب بطلان إجراءات الحجز وإلغائه؛ فإنها تكون في هذه الحالة دعوى ملكية عادية، وليست دعوى استرداد، ومن ثم لا يختص بها قاضي التنفيذ؛ وإنما المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة.

فيجب على المسترد إذا؛ أن يطلب في دعوى الاسترداد الحكم بملكية المنقولات وبطلان إجراءات الحجز، وهنا يختص القاضي بالدعوى ويفصل في طلب الملكية ولو

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/٣٤٧.

(٢) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٦٨.

لم يكن من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ التي ينعقد له الاختصاص بها، باعتباره فصلا في مسألة أولية لازمة للحكم في طلب بطلان الحجز، الذي يختص به اختصاصا نوعيا لا يشاركه فيه غيره.

ويعتبر طلب بطلان الحجز طلبا مندمجا في الطلب الأصلي في هذه الدعوى وهو الملكية، ويختص بهما قاضي التنفيذ، وإذا رفعت دعوى الملكية أمام المحكمة المختصة، ورفعت إلى القاضي دعوى بطلان إجراءات الحجز؛ فيجوز الدفع بالإحالة للارتباط، وتكون الإحالة في هذه الحالة إلى قاضي التنفيذ؛ لأن بطلان الإجراءات لا يختص به غير قاضي التنفيذ^(١). بخلاف الحال إذا رفعت إلى قاضي التنفيذ دعوى الملكية وحدها؛ فإنه يحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، لخروج هذه الدعوى عن الدعاوى التي يختص بها نوعيا^(٢).

ثالثا: ميعاد رفع دعوى الاسترداد:

لم ينص المشرع على رفع الدعوى خلال ميعاد محدد؛ وإنما نص في المادة (٣٩٣) مرافعات على أنه "إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه". ويتضح من ذلك أن هذه الدعوى يجب أن ترفع قبل بيع المنقولات المحجوزة، لأنها إذا رفعت بعد ذلك فلا تكون دعوى استرداد وإنما دعوى ملكية عادية، كما يجب أن ترفع بعد الحجز على المنقولات، لأن رفعها قبل الحجز لا محل له، باعتبار أن المنقولات ليست محلا لحجز، فترفع حينئذ دعوى الملكية أمام المحكمة المختصة.

(١) وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "دعوى استرداد المنقولات المحجوزة باعتبارها منازعة موضوعية في التنفيذ يختص قاضي التنفيذ بنظرها، وذلك أيا كانت قيمة الأشياء المحجوز عليها، وذلك عملا بالمادة ٢٧٥ من قانون المرافعات، على أن يستأنف الحكم الصادر فيها وحسبما يقضي نص المادة ٢٧٧ من ذات القانون إما إلى محكمة الاستئناف أو إلى المحكمة الابتدائية بحسب قيمتها". (الطعن رقم ٥٤٣٩ لسنة ٦١ قضائية - لسة ١٩٨٢/٢/١٩).

(٢) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٦٩.

رابعاً: الخصوم في دعوى الاسترداد:

حدد المشرع خصوم هذه الدعوى في المادة (٤٩٤) مرافعات وأوجب رفعها على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين في الحجز. ذلك أن طلب ملكية المنقولات المحجوزة يقتضي توجيه طلب الملكية إلى المدين المحجوز على المنقولات في حيازته وصدور حكم الملكية في مواجهته^(١)، كما أن طلب بطلان إجراءات الحجز وإلغائه يقتضي صدور الحكم فيه في مواجهة الدائن الحاجز المباشر لإجراءات الحجز، كما يجب اختصاص الحاجزين المتدخلين محافظة على حقوقهم^(٢).

خامساً: إجراءات رفع دعوى الاسترداد:

يتضح من نص المادة (٤٩٤) مرافعات، أن هذه الدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة، بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التنفيذ المختصة، وتقيد وتعلن وفق إجراءات الدعاوى العادية، ويختص بها نوعياً: قاضي التنفيذ باعتبارها منازعة موضوعية في التنفيذ -كما سبقت الإشارة- ومحلياً: قاضي التنفيذ الذي وقع الحجز في دائرته، باعتبار أن الدعوى رفعت بعد الحجز فعلاً وانعقاد الاختصاص بالمنازعات الناشئة عنه لقاض معين.

وإذا كانت هذه الدعوى ترفع بصحيفة وفق الإجراءات المعتادة؛ إلا أن المشرع مراعاة منه لأهمية ما يترتب على رفعها من آثار، أوجب أن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية، وأن يودع المسترد عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات، وذلك حتى يتمكن الخصوم من معرفة دليله.

(١) لم يرتب قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم اختصاص المدين في دعوى الاسترداد. (نقض ١٩٥٩/٣/١٩ لسنة ١٠ ص ٢٣٢).

(٢) وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا كان الحاجز المتدخل قد تدخل عن طريق الحجز على الثمن تحت يد معاون التنفيذ، فلا يتعلق حقه في هذه الحالة بالمال محل الحجز، ومن ثم لا يكون هناك داع لاختصاصه. (د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٧١).

وتجدر الإشارة إلى أن مخالفة هذا الشكل الذي أوجبه المشرع في رفع دعوى الاسترداد، لا يترتب عليه البطلان؛ وإنما يترتب عليه وفق صريح نص المادة (٣٩٤) وجوب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى، أي تعطيل الأثر الموقوف لهذه الدعوى، على نحو ما سنرى، والحكم الصادر في هذه الحالة غير قابل للطعن فيه.

سادسا: الأثر المترتب على رفع دعوى الاسترداد:

استثناء مما تقضي به القواعد العامة من أنه لا أثر لمنازعات التنفيذ الموضوعية على إجراءات التنفيذ؛ فإن المشرع نص في المادة (٣٩٣) مرافعات، على أثر خاص على رفع هذه الدعوى، وهو وجوب وقف بيع المنقولات المحجوزة؛ إلا إذا أمر قاضي التنفيذ الذي ينظر الدعوى باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن خزانة المحكمة أو بدون اشتراط إيداعه.

وذلك مشروط بدعوى الاسترداد الأولى، أما إذا كانت دعوى الاسترداد دعوى ثانية، فإنها لا توقف البيع؛ إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بوقفه لأسباب مهمة (مادة ٣٦٩). معنى ذلك أن وقف البيع يترتب بقوة القانون على دعوى الاسترداد الأولى فقط، وللقاضي سلطة الحكم باستمرار هذا البيع، ولا يترتب هذا الوقف بقوة القانون إذا رفعت دعوى استرداد ثانية، وإنما يحكم به القاضي إذا رأى لذلك أسبابا مهمة. ولكن السؤال الذي يثار هنا، متى تعتبر دعوى الاسترداد دعوى ثانية؟

تعتبر دعوى الاسترداد دعوى ثانية وفقا لنص المادة (٣٩٦) مرافعات، في حالتين:

الأولى: في حالة رفعها من مسترد آخر غير المسترد في الدعوى الأولى.

والثانية: رفعها من نفس المسترد في الدعوى الأولى، بعد أن اعتبرت الدعوى التي رفعها كأن لم تكن، أو صدر حكم باعتبارها كذلك، أو بشطبها، أو بعدم قبولها، أو بعدم الاختصاص، أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها، أو بتركها، وبصفة عامة دون حكم في الموضوع. وفي هذه الحالات يزول بقوة القانون الأثر

الموقف لدعوى الاسترداد وفقا للمادة (٣٩٥) والتي نصت على أنه للحاجز أن يمضي في التنفيذ في حالات معينة، من بينها هذه الحالات^(١).

سابعا: إثبات دعوى الاسترداد:

يقع على المسترد عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة في جميع الأحوال، ولو كان المسترد يشارك المحجوز عليه في حيازة المنقولات، كما هو الشأن في حالة الزوج والزوجة والأخوة الذين يقيمون في معيشة واحدة^(٢).

ذلك أن المسترد هو الذي يطلب الحكم بملكية المنقولات المحجوزة وبطلان الحجز، وبالتالي يتعين عليه إثبات ملكيته أو حقوقه على الأشياء المحجوزة. ويتفق ذلك مع ما نصت عليه المادة (٩٦٤) من القانون المدني، بنصها على أن "من كان حائزا للحق

(١) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٧٦.

(٢) وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "توقيع الحجز على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث. ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وإقرار زوجها بملكيتها لها وطلبها الإحالة للتحقيق. إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيسا على قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها تتعارض مع المادة ٣٩٤ مرافعات. خطأ. علة ذلك: أن واقع الحال في الدعوى أن الحجز يوقع على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث وادعت الطاعنة ملكيتها لتلك المنقولات وقدمت بعض المستندات للتدليل على ذلك وأقر الزوج بملكيتها لها، كما طلبت الإحالة للتحقيق لإثبات ملكيتها لها، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرحت المستندات المقدمة منها ولم يعول عليها وامتد إلى قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها ورفض الإحالة إلى التحقيق رغم أن الطاعنة تدعي ملكيتها لتلك المنقولات وانها وزوجها المحجوز عليه في معيشة مشتركة بما كان لازمه أن يمكنها من إثبات دعواها بالبينة التي ركنت إليها في الإثبات، لا سيما أن إقرار الزوج بملكيتها للمنقولات قد استبعدته المحكمة لأنه ليس حجة على الدائن الحاجز، مما كان يتعين معه على المحكمة الاستجابة إلى طلب تمكينها من إثبات دعواها بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وإذا رفضت ذلك بمقولة أن الأوراق صالحة للفصل في موضوع الدعوى وأن الإحالة إلى التحقيق تتعارض مع نص المادة ٣٩٤ من قانون المرافعات، رغم أن الأوراق خالية من الدليل على ملكية المنقولات، ورغم أن الإحالة للتحقيق لا تتعارض مع حكم تلك المادة، الأمر الذي يكون معه الحكم قد تحجب عن بحث دفاع الطاعنة مما يعيبه". (الطعن رقم ٦٣٧٥ لسنة ٦٢ قضائية - جلسة ٢٠٠٠/٤/١٢).

اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس، ولما كانت المنقولات المحجوزة في حيازة المدين، فيعتبر مالكا لها إلى أن يثبت المسترد عكس ذلك^(١).

ثامنا: الحكم في دعوى الاسترداد:

لما كانت دعوى الاسترداد من منازعات التنفيذ الموضوعية؛ فإن الحكم الصادر فيها يكون حكما موضوعيا يحسم النزاع على أصل الحق، ويستأنف الحكم الصادر فيها وفقا للقواعد العامة. ويجوز للقاضي الحكم على المسترد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

(١) المرجع السابق، نفسه.

المبحث الثاني

بيع المنقولات المحجوز عليها

المرحلة الثانية من مراحل الحجز التنفيذي على المنقول، هي مرحلة بيع هذا المنقول بيعاً جبرياً بالمزاد العلني، إذ يهدف هذا الحجز إلى بيع المنقول المحجوز عليه بغرض استيفاء الدائن الحاجز حقه من حصيلة بيع المنقول المحجوز عليه.

وإذا كان الأصل أن كل حجز تنفيذي يتبعه بالضرورة بيع جبري للمال المحجوز عليه؛ إلا أن هناك حالات لا توجد فيها حاجة إلى بيع المال المحجوز عليه، وهذه الحالات هي^(١):

١- إذا كان محل الحجز مبلغاً من النقود: ففي هذه الحالة يستوفي الدائن الحاجز حقه مباشرة من هذه النقود، ولا محل حينئذ لإجراء بيع، ويكون الأمر كذلك إذا كان محل الحجز بداية على مبلغ من النقود (مادة ٣٥٩)، أو كان شيئاً آخر تحول إلى مبلغ من النقود عن طريق الإيداع مع التخصيص (المادتان ٣٠٢ و ٣٠٣).

٢- إذا كان محل الحجز حقاً نقدياً حال الأداء للمدين لدى الغير (حجز ما للمدين لدى الغير)؛ فإن الحاجز يستوفي حقه مباشرة بقبضه من الديون التي يدفعها المحجوز لديه وفاء لدينه.

٣- الحالات التي يستوفي فيها الدائن الحاجز حقه من نفس المال المحجوز، ولو لم يكن مبلغاً من النقود، كما في حالة الحجز على المصوغات، وسبائك الذهب والفضة؛ فإن الحاجز يستوفي حقه منها عينا إذا لم يتقدم أحد لشرائها بالثمن الذي قدره أهل الخبرة (مادة ٣٨٥)، ولا خيار للحاجز في ذلك بل يلزم باستيفاء حقه منها عينا، ولا يجوز بيعها بأقل من ثمنها^(٢).

(١) د. محمود السيد التحيوي، النظام القانوني للحجز، ص ٣١٧- محمد عزمي البكري، الحجز القضائي على المنقول، ص ٢١٠.

(٢) أما غير ذلك من المنقولات التي لم تقوم بمعرفة أهل الخبرة ولم يتقدم أحد لشرائها؛ فإن الحاجز يكون بالخيار بين أخذها استيفاء لحقه أو عدم أخذها، وذلك بعد أن تقدر بمعرفة خبير يعينه معاون التنفيذ ويذكر اسمه في المحضر (مادة ٣٨٧).

٤- إذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التي يتعين تسليمها إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها؛ فإن المادة (٣١٠) مرافعات، أوجبت على حارس هذه المنقولات، تقديم محضر الحجز إلى من يتسلمها؛ وعندئذ ينتقل الحجز إلى الثمن الذي يستحقه المدين، دون حاجة إلى إجراء آخر.

وفي غير ذلك من حالات الحجز يتم بيع المنقولات المحجوزة، ويتم الوفاء بديون الحاجزين من حصيلة هذا البيع وفق الإجراءات المقررة قانوناً. وننتقل الآن إلى بيان القواعد التي تحكم هذا البيع، ثم بيان إجراءات البيع، وذلك في المطلبين التاليين:

المطلب الأول

قواعد بيع المنقول المحجوز عليه

أولاً: المبادئ التي تحكم بيع المنقول:

١- إجراء البيع بالمزاد العلني تحت إشراف القضاء:

أوجبت المادة (٣٨٤) مرافعات أن يتم بيع المنقولات المحجوزة عن طريق المزاد العلني، وذلك لضمان إتاحة الفرصة لكل من يتقدم إلى الشراء، حتى يتقدم أكبر عدد من الأشخاص في المزاد العلني، وبما يزيد المنافسة بينهم، ومن ثم ارتفاع ثمن المبيع. ومن ناحية ثانية؛ فإن خطورة الآثار المترتبة على نزع ملكية المال وبيعه جبراً عن المدين المحجوز عليه ووفاء ديون الحاجزين من ثمن البيع، يقتضي تدخل القضاء بالإشراف على هذا البيع، ضماناً لإتمامه بعيداً عن أية شبهة، وإحاطته بالوسائل التي تكفل البيع بأعلى ثمن. ولهذا يتم البيع بالمزاد العلني بمساعدة معاون التنفيذ (مادة ٣٨٤) وتحت إشراف إدارة التنفيذ (مادة ٣٧٤).

٢- وجوب توفر الأهلية فيمن يتقدم للشراء:

وذلك لأن البيع الجبري يترتب عليه انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، فيشترط في هذا الأخير توفر أهلية الشراء، والتي تتوفر في كل شخص كامل الأهلية، أما ناقص

الأهلية أو عديمها، فلا بد أن يمثلته نائبه القانوني في الشراء، واستئذان المحكمة المختصة في الأحوال التي تتطلب هذا الإذن^(١).

٣- منع بعض الأشخاص من دخول المزاد العلني:

وهؤلاء الأشخاص ورد النص عليهم في المادة (٣١١) مرافعات، وهم: المدين المحجوز عليه، والقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المنفرعة عنه، والمحامين الوكلاء الدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه. وقد رتب المشرع على تقدم أيا من هؤلاء إلى المزايدة بنفسه أو بطريق تسخير غيره، بطلان البيع.

ولا شك أن في هذا المنع وما يترتب على مخالفته من البطلان، يحقق غايات مهمة، تتعلق بالمدين الذي يكون مسئولا عن الدين المحجوز لأجله، وبما يجب أن يتوفر في القضاة من الحيادة والنزاهة والبعد عن الشبهات، وأيضا حتى لا يغلب الوكيل مصلحته الشخصية على مصلحة موكله.

وتجدر الإشارة إلى أن المنع قاصر على المذكورين في المادة، ولذلك فإن أقارب المدين المحجوز عليه أو زوجه -مثلا- يكون لهم حق التقدم للمزايدة؛ لأن أيا منهم لا يكون مسئولا عن الدين، وذلك بشرط ألا يكون مسخرا للشراء من قبل المدين.

ثانيا: تحديد ميعاد البيع:

بين المشرع كيفية تحديد هذا الميعاد في المادة (٣٧٦) مرافعات، بالنص على عدم جواز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به، ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضي يوم على الأقل من تاريخ اتمام إجراءات اللصق والنشر؛ إلا إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار. كما حرص على تحديد مدة زمنية قصوى يجب إجراء البيع خلالها حتى لا يظل المدين مهددا بالحجز وتعطيل أمواله مدة طويلة دون أن يتم

(١) د. محمود السيد التحيوي، النظام القانوني للحجز، ص ٣٢٠.

البيع، فنص على اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه؛ إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون (مادة ٣٧٥/١) مرافعات.

ويتضح من ذلك أنه يجب على معاون التنفيذ عند تحديد ميعاد بيع المنقولات المحجوزة مراعاة عدة أمور، هي:

١- لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم محضر الحجز للمدين أو إعلانه به، وهو ميعاد كامل يجب أن ينقضي كاملاً قبل إجراء البيع^(١).

٢- لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام اللصق والنشر (الإعلان عن البيع).

٣- يجب أن يتم بيع المنقولات المحجوزة خلال ثلاثة أشهر^(٢) من تاريخ توقيع الحجز؛ وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. ولا يتعلق هذا الجزاء بالنظام العام^(٣).

٤- قد يمتد ميعاد الثلاثة أشهر الذي يجب أن يتم البيع خلاله؛ إذا أوقف البيع باتفاق الخصوم، أو بحكم المحكمة، أو بمقتضى القانون.

٥- إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار؛ فلا إدارة التنفيذ أن تأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة.

(١) والميعاد الكامل هو الذي يجب أن ينقضي كله قبل اتخاذ الإجراء؛ إذ لا يجوز مباشرة الإجراء قبل انتهاء هذا الميعاد، باعتباره فترة زمنية يجب أن تنقضي قل مباشرة الإجراء، ولا يصح الإجراء إلا بعد انقضائها .

(٢) وهذا الميعاد ميعاد ناقص، والميعاد الناقص هو الذي يجب القيام بالإجراء خلاله، وهو يعتبر ظرفاً زمنياً يجب أن يتم الإجراء خلاله؛ فيكون اليوم الأخير من الميعاد هو آخر فرصة لاتخاذ الإجراء؛ فإذا انقضى الميعاد سقط الحق في اتخاذ الإجراء.

(٣) وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "اعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع في خلال الأجل لا يتعلق بالنظام العام، ويسقط حق المدين في الدفع إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً". (الطعن رقم ٤٩٤ لسنة ٤٥ قضائية - جلسة ١٩٧٨/٣/٢١).

وقد سبقت الإشارة إلى وجوب ذكر ميعاد البيع في محضر الحجز؛ وإلا ترتب على إغفاله تأخير البيع، حتى يتم تحديده في وقت لاحق وإخطار المدين به، ويحتسب ميعاد البيع في هذه الحالة من تاريخ الإخطار وليس من تاريخ الحجز، مع مراعاة اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه.

وقد أراد المشرع بتحديد ميعاد البيع على هذا النحو، منح المدين مهلة جديدة لتقاضي بيع أمواله، وليتمكن هو وغيره من الاعتراض على التنفيذ ورفع الأمر إلى القضاء، إذا عن لهم ذلك، ولإتاحة الإعلان عن البيع حتى يكثر الراغبون في الشراء فيرتفع الثمن عند البيع في المزاد ويستفيد من ذلك المدين ودائنتوه.

كما حرص المشرع على ألا يترك المدين مهدها بإجراءات الحجز، فتتأبد الحجز ويتخذها الدائنون وسيلة تهديد مستمر للمدينين، فأوجب أن يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من إجراء الحجز؛ وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن^(١).

ثالثاً: الإعلان عن البيع:

يقتضي البيع بالمزاد العلني الإعلان عن هذا البيع حتى يعلم به أكبر عدد من الراغبين في الشراء، ومن ثم يؤدي ذلك إلى زيادة ثمن المنقولات المحجوزة (محل البيع)، ولذلك أوجب المشرع أن يجرى الإعلان عن البيع قبل اليوم المحدد له، وحدد وسيلتين لهذا الإعلان، هما الإعلان باللصق والنشر:

١- الإعلان باللصق:

أوجب المشرع على معاون التنفيذ عقب إقفال محضر الحجز مباشرة؛ وأيا كانت قيمة الأشياء المحجوزة، أن يلصق على باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان وفي اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية، إعلانات موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته، ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر

(١) د. أحمد أبو الوفا إجراءات التنفيذ، ص ٤٢٧-٤٢٨.

الحجز (مادة ٣٦٣ مرافعات). ولكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم إلى إدارة التنفيذ، لصق عدد أكبر من الإعلانات (مادة ٣٧٩).

ولا يترتب البطلان على مخالفة إجراءات اللصق التي نظمها المشرع؛ ولكن يكون للحاجز أو المحجوز عليه، أن يطلب من إدارة التنفيذ تكليف معاون التنفيذ بهذه الإجراءات^(١).

ويتم إثبات لصق الإعلانات بشهادة محررة من معاون التنفيذ، أو من رجال الإدارة إذا تم اللصق بواسطتهم (مادة ٣٨١)، وتكون هذه الشهادة مصحوبة بنسخة من الإعلان الذي تم لصقه، أما الإعلان في لوحة المحكمة فيكون إثباته بذكره في السجل المعد لذلك في المحكمة^(٢).

٢- الإعلان بالنشر:

ويقصد به الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية. وقد أوجبه المشرع، بالإضافة إلى الإعلان باللصق؛ إذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة والمطلوب بيعها، تزيد قيمتها المقدرة في محضر الحجز عن عشرة آلاف جنيه، وفي هذه الحالة يجب أن يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال (مادة ١/٣٧٨ مرافعات). ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه؛ إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنيه؛ أن يطلب في قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة (مادة ٢/٣٧٨).

الإعلان عن بيع المصوغات والسبائك والمجوهرات:

ذكرنا أن المصوغات والسبائك والمجوهرات والأحجار الكريمة، تقدر بمعرفة خبير، يرفق تقريره بتقدير قيمتها بمحضر الحجز، وقد أوجب المشرع بشأن الإعلان عن بيعها قاعدة خاصة إذا زادت قيمتها على عشرين ألف جنيه.

(١) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ، ص ٢٩٣.

(٢) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٥٦.

فأوجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة، إذا زادت القيمة المقدرة لها عن عشرين ألف جنيه، أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع (مادة ٣٨٠ مرافعات). وبهذا يكون المشرع قد أوجب زيادة نشر إعلان عن بيعها، إعلانا إضافيا قبل يوم البيع.

رابعا: مكان البيع:

يجرى البيع وفقا لنص المادة (٣٧٧) مرافعات، في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة، ولمعاون التنفيذ أن يأمر بنقل هذه الأشياء إلى أقرب سوق بناء على تقديره ودون اشتراط إذن من قاضي التنفيذ، ولقاضي التنفيذ أن يحدد مكانا آخر للبيع غير المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة أو أقرب سوق. بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوي الشأن^(١).

خامسا: طلب البيع:

لا يجوز لمعاون التنفيذ عند حلول ميعاد البيع أن يجري البيع من تلقاء نفسه؛ وإنما يجب أن يطلب منه الدائن الحاجز ذلك، ويستفاد ذلك من المادة (٣٩٢) مرافعات، والتي نصت على أنه "إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع في التاريخ المحدد في محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبقا للمادة ٣٧١ أن يطلبوا إجراء البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر...".

وذلك على تقدير أن الحاجز إذا لم يطلب إجراء البيع مع حلول اليوم المحدد له، فلعله استوفى الدين المحجوز من أجله أو لعله اتفق مع المدين على تأجيل البيع.

وإذا تعددت الحجز على المنقول؛ فإن الحاجز الأول هو الذي يباشر الإجراءات حتى لا تتعارض؛ فإذا لم يقم بذلك لاستيفائه حقه من المدين أو تواطؤا مع المدين أو لإهمال منه، ثبت الحق لكل حاجز آخر أن يحل محله في هذا الطلب، وعندئذ يلتزم

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/٣٢٣.

الأخير بإجراءات إعلان البيع كما يقرها القانون، وعليه أن يعلن الشهادة المثبتة لحصول اللصق إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل (مادة ٣٩٢ مرافعات)^(١).

المطلب الثاني

إجراءات البيع

أولاً: جرد الأشياء المحجوزة قبل البيع:

بعد أن يتقدم الدائن الحاجز بطلب إجراء البيع (مادة ٣٩٢)، تبدأ إجراءات البيع في الميعاد والمكان المحدد له، ويجب على معاون التنفيذ ألا يبدأ في البيع إلا بعد أن يجرّد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها (مادة ٣٨٤). ويعفى الحارس من مسؤوليته إذا تبين من الجرد أن الأشياء المحجوزة كما هي لم يحدث فيها تغيير أو نقصان، ولا يترتب البطلان على عدم إجراء معاون التنفيذ لهذا الجرد؛ وإنما يكون لذوي الشأن الحق في الرجوع عليه بالتعويض إن لذلك مقتضى^(٢).

ثانياً: لا تبدأ المزايدة بالمناداة على ثمن أساسي:

يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة معاون التنفيذ (مادة ٣٨٤)، ولا يبدأ معاون التنفيذ المزايدة بالمناداة على ثمن أساسي، بل يترك الأمر لراغبى الشراء، وعلى ذلك يبدأ أول شخص بأي ثمن ثم يليه باقي المزايدون، ولا يشترط أن يكون الثمن الذي تبدأ به المزايدة مساوياً للثمن المحدد في محضر الحجز، كذلك لم يحدد القانون الفترة الزمنية التي يبقى فيها العطاء لكي يقرر رسوه، بل يرجع ذلك إلى تقدير معاون التنفيذ، ولا يجب أن يرسو المزاد بثمن معين؛ بل يوقع البيع بأكبر عطاء أيا كان^(٣).

(١) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٥٦.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٦/٣٢٨.

(٣) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٤٧٩. ويجب ملاحظة أنه تجاوز الثمن المحدد للسلع المسعرة تسعيراً جبرياً، فعلى معاون التنفيذ إرساء المزاد بمجرد تقديم عطاء بالسعر الجبري، حتى لا تشارك الدولة في مخالفة التسعيرة الجبرية. (د. فتحي والي، التنفيذ، ص ٤١٦).

ثالثاً: إجراءات خاصة ببيع بعض المنقولات المحجوزة:

١- إذا تعلق البيع بمصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة؛ فلا يجوز لمعاون التنفيذ أن يبيعها بأقل من قيمتها بحسب ما قدره أهل الخبرة؛ فإذا لم يتقدم أحد لشرائها بهذه القيمة، وجب على معاون التنفيذ إيداعها خزانة المحكمة، ويستوفي الحاجز حقه منها عينا (مادة ٣٨٥).

٢- إذا تعلق البيع بالحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة، وغيرها من الأشياء التي سبق تقديرها بمعرفة خبير؛ فلا يجوز بيعها بأقل من القيمة المقدرة؛ فإذا لم يتقدم أحد لشرائها بهذه القيمة في أول جلسة مزايمة؛ وجب على معاون التنفيذ تأجيل البيع إلى يوم آخر، ويعلن عن البيع في هذا اليوم باللصق والنشر؛ وتباع هذه المحجوزات في ذلك اليوم لمن يرسو عليه المزاد ولو بأقل من قيمتها المقدرة (مادة ٣٨٦)^(١).

٣- إذا تعلق الأمر ببقية المحجوزات التي لم تقوم؛ فإنه إذا لم يتقدم أحد لشرائها كلها أو بعضها؛ فإن على معاون التنفيذ أن يعرض على الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها خبير يعينه معاون التنفيذ، ويذكر اسمه في محضر البيع؛ فإذا رفض الحاجز، يؤجل بيعها إلى اليوم التالي، فإن لم يتقدم أحد لشرائها، وجب على معاون التنفيذ عرض الأمر على إدارة التنفيذ لتأمر بما تراه لازماً (مادة ٣٨٧).

ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله في جميع الأحوال؛ أن يذكر معاون التنفيذ ذلك علانية ويثبتته في محضر البيع (مادة ٣٨٨ مرافعات).

٤- إذا تعلق البيع بالأسهم والسندات (مادة ٣٩٨)، أو بالإيرادات المرتبة، والأسهم الإسمية، وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين (مادة ٣٩٩)؛ فإنها تباع بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف، يعينه قاضي التنفيذ، بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز، ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان (مادة ٤٠٠).

(١) د. أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، ص ٣٠٣.

رابعاً: دفع الثمن الذي رسي به المزاد:

يجب على المشتري الراسي عليه المزاد أن يدفع الثمن فوراً؛ وإلا وجب إعادة البيع في الحال على ذمته بأي ثمن كان، ويكون ملزماً بالفرق بين الثمنين إذا قل ثمن البيع الثاني عن الأول، ولا يفيد من زيادة ثمن البيع الثاني إن كان، بل تدخل الزيادة في ذمة المحجوز عليه، ويعتبر محضر الحجز سنداً تنفيذياً بفرق الثمن، بالنسبة للراسي عليه المزاد الذي لم يدفع الثمن (مادة ٣٨٩)^(١).

خامساً: الكف عن البيع:

قلنا إنه لا يشترط في المال المحجوز عليه أن يكون مساوياً للديون المحجوز من أجلها، ومن ثم قد تزيد قيمة المنقولات المحجوزة عما للدائنين الحاجزين من ديون، وفي مثل هذه الحالة لا يستطيع معاون التنفيذ أن يستمر في بيع جميع هذه المنقولات طالما تحصل من البيع قيمة الديون المحجوز من أجلها والمصاريف؛ بل إن عليه أن يكف عن البيع إذا تحصل منه هذه القيمة، بمعنى أنه يجب ألا يتجاوز التنفيذ مقدار الحق المطلوب التنفيذ به.

ولذلك نص المشرع في المادة (٣٩٠) مرافعات على أنه "يكف معاون التنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف، وما يوقع بعد ذلك من الحجز تحت يد معاون التنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد عن وفاء ما ذكر".

ومن ثم يترتب على تحصيل قيمة الديون المحجوز من أجلها والمصاريف من البيع، أربعة أمور، وهي:

- ١- يجب على معاون التنفيذ أن يكف عن بيع باقي المنقولات المحجوز عليها.
- ٢- تصبح باقي المنقولات المحجوز عليها والتي لم يتم بيعها، طليقة من قيد الحجز، وبالتالي تكون تصرفات المدين فيها سواء كانت سابقة على الحجز أو لاحقة عليه؛ نافذة في حق الكافة.

(١) د. أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ، ص ٤٣٨.

- ٣- تخصص المبالغ المتحصلة لوفاء الديون المحجوز من أجلها والمصاريف.
- ٤- إذا أوقع حجز على الثمن المتحصل من البيع تحت يد معاون التنفيذ -بطريق حجز ما للمدين لدى الغير- فإنه لا يتناول إلا ما زاد عن وفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف^(١).

سادسا: محضر الحجز:

يجب على معاون التنفيذ أن يحرر محضرا بالبيع الذي تم، ويجب أن يشتمل المحضر على البيانات العامة في أوراق المحضرين، فضلا عن البيانات التي نص عليها المشرع في المادة (٣٩٢) مرافعات، وهي: جميع إجراءات البيع، وما لقيه معاون التنفيذ من الاعتراضات أثناء البيع، وما حدث من عقبات، والإجراءات التي اتخذها معاون التنفيذ بشأن هذه الاعتراضات والعقبات، وحضور المحجوز عليه أو غيابه عن المزاد، والثمن الذي رسا به المزاد، وبيانات من رسا عليه المزاد وتوقيعه.

سابعا: آثار البيع:

بمجرد إجراء البيع على النحو المقرر قانونا، وأداء الثمن ممن رسا عليه المزاد؛ تنتقل ملكية الأشياء المباعة إلى المشتري، إذا كانت مملوكة للمدين^(٢).

أما إذا كانت الأشياء المباعة غير مملوكة للمدين، أو كان الحجز باطلا؛ فإن المشتري يملكها إذا كان حسن النية (مادة ٩٧٦ مدني)، باعتبار أن الحياة في المنقول سند الملكية؛ فلا يجوز للمالك الحقيقي استردادها من مشتريها بعد تسليمها إليه؛ إلا إذا كان المشتري سيء النية، أو كانت مسروقة أو ضائعة.

وفي حالة السرقة أو الضياع، لا يجوز الاسترداد إلا في خلال ثلاث سنوات؛ بشرط أن يؤدي للمشتري الثمن الذي دفعه (مادة ٩٧٧ مدني)^(٣).

(١) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٤٨٠.

(٢) وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "من رسا عليه المزاد في بيع الأشياء المحجوزة لا يستمد حقه على الأشياء المحجوزة من دين الحاجز ولكن الحق الذي يدعيه يستند إلى محاضر البيع التي اشترى بمقتضاها تلك الأشياء. (نقض ١٩٥٧/٥/٣٢ لسنة ٨ قضائية، ص ٥٢٠).

(٣) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٤٤٠.

الفصل الثاني الحجز التحفظي

الفصل الثاني

الحجز التحفظي

قلنا إن الحجز التحفظي يهدف إلى وضع منقولات المدين تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها تصرفاً يضر بالدائنين، فهو يختلف عن الحجز التنفيذي من ناحية الهدف، والشروط الواجب توافرها لإجراء كل منهما، والإجراءات الواجبة الإلتباع، ولذلك نقسم الحديث في هذا الفصل إلى المباحث الآتية:

الأول: في التعريف بالحجز التحفظي، والثاني في شروطه، والثالث في حالاته، والرابع في إجراءاته.

المبحث الأول

التعريف بالحجز التحفظي

فكرته وتعريفه:

قدر المقنن أن نظام الحجز التنفيذي على المنقول قد لا يسعف الدائن في حماية حقه في الضمان العام لدينه، فقد يبادر المدين إلى تهريب منقولاته قبل أن يتمكن الدائن من الحصول على سند تنفيذي يجيز له التنفيذ على هذه المنقولات، أو قبل أن يعين مقدار حقه، كما قدر المقنن أنه . في بعض الحالات . يكون من مصلحة الدائن مباغته مدينه بتوقيع الحجز قبل أن يكلفه بالوفاء ويعلنه بالسند التنفيذي، مخافة لجوء المدين إلى تهريب المنقولات.

لذلك وضع المقنن نظاماً للحماية المؤقتة للحق يجوز للدائن بمقتضاه اتخاذ إجراء وقتي سريع بقصد التحفظ على منقولات المدين، واكتفي في ذلك بأن يقدم الدائن ما يرجح وجود حقه قبل المدين، إلى أن يتمكن الدائن من إثبات وجود حقه في ذمة المدين على وجه أكيد، فيتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي.

ويمكن تعريف الحجز التحفظي بأنه ضبط منقولات المدين ووضعها تحت يد القضاء ومنع المحجوز عليه من التصرف فيها تصرفاً يضر بحق الحاجز.

التفرقة بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي:

الحجز التحفظي والحجز التنفيذي كلاهما يؤدي إلى التحفظ على المال المحجوز عليه ومنع المدين من التصرف فيه تصرفاً يضر بالدائنين، وبينما يقتصر الهدف من الحجز التحفظي على ذلك يتعداه الحجز التنفيذي حيث يهدف إلى بيع الأموال المحجوزة، وإيفاء حقه منها أو من ثمنها، وترتب على اختلافهما في الهدف وجود فروق بينهما أهمها ما يلي:

١- إجراء الحجز التنفيذي يتطلب حصول الدائن على سند تنفيذي بحقه قبل الشروع في التنفيذ، بينما إجراء الحجز التحفظي لا يتطلب وجود سند تنفيذي؛ حيث لا يلزم من إجراء هذا الحجز إجراء بيع المال المحجوز، ومع هذا فلا مانع من إجراء الحجز التحفظي بمقتضى سند تنفيذي، إذا رأى الدائن أن مصلحته في إجراء حجز تحفظي بقصد مباغطة المدين.

٢- الحجز التنفيذي يؤدي إلى وضع المال المحجوز تحت يد القضاء، ومنع المحجوز عليه من التصرف فيه تصرفاً يضر بالدائنين، ويؤدي بذاته إلى بيع المال المحجوز وإيفاء حق الحاجز منه أو من ثمنه، بينما الحجز التحفظي يؤدي إلى وضع المال المحجوز تحت يد القضاء ومنع المحجوز عليه من التصرف فيه تصرفاً يضر بالدائنين، ولا يؤدي بذاته إلى بيع المال المحجوز.

٣- يشترط في الحق الذي يجري الحجز التنفيذي اقتضاء له أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، بينما لا يشترط في دين الحاجز حجزاً تحفظياً إلا أن يكون محقق الوجود وحال الأداء ولا يلزم أن يكون معين المقدار، غاية الأمر أن الحجز التحفظي في هذه الحالة لا يوقع إلى بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً.

٤- يشترط أن يسبق الحجز التنفيذي إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان الحجز باطلاً، بينما لا يشترط هذا الشرط في إجراء الحجز التحفظي. كقاعدة. نظراً لأن المقصود منه مباغطة المدين وضبط ماله قبل تهريبه، ويرد على هذه القاعدة استثناء فيما إذا أمر القاضي بتوقيع الحجز بشرط إعلان الأمر قبل توقيع الحجز. (المادة ٣١٩/٣).

٥- الحجز التنفيذي يجرى على المنقول كما يجرى على العقار، بخلاف الحجز التحفظي فلا يجرى إلا على المنقول، وقيل في تعليل ذلك إن الحجز التحفظي يهدف إلى ضبط المال الذي يمكن تهريبه والعقار لا يتصور تهريبه، وهو تبرير محل نقد الفقه ذلك أن العقار وإن كان يتعذر تهريبه بالإخفاء يمكن تهريبه بالتصرف فيه بالبيع أو نحوه، وقد لا تجدي دعوى عدم نفاذ التصرف التي قررها القانون المدني لعلاج الموقف مما يتطلب تقرير حماية مؤقتة لحق الدائن على عقارات مدينه كجزء من ضمانته العام ويجيز القانون الجزائري توقيع حجز تحفظي على العقارات^(١) كما يجيز القانون التونسي ذلك^(٢).

٦- يسقط الحجز التنفيذي إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه، نظراً لأنه يهدف مباشرة إلى هذه الغاية، بينما الحجز التحفظي لا يهدف إليها، ومن ثم لا يبدأ ميعاد السقوط إلا من تاريخ تحويله إلى حجز تنفيذي^(٣).

(١) المادة ٣٤٧ من قانون الإجراءات المدنية الجزائري .

(٢) المادة ٣٢٣ من قانون المرافعات التونسي .

(٣) راجع في التفرقة بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي، إجراءات التنفيذ أ.د. أحمد أبو الوفا، ص ٨٣٣ وما بعدها، أصول التنفيذ أ.د. محمد محمود إبراهيم ص ٣٧٤ وما بعدها .

المبحث الثاني

الشروط العامة لصحة الحجز التحفظي

يجوز للدائن إجراء حجز تحفظي على منقولات مدينه حتى ولو لم يكن بيده سند تنفيذي بحقه، ومع هذا فنظراً لأن الحجز يرتب أثراً هاماً وهو حبس المال المحجوز ومنع المدين من التصرف فيه تصرفاً يضر بالدائنين، فقد استوجب المقتن لإمكان توقيع الحجز التحفظي شروطاً عامة يجب توافرها فضلاً عن الشروط الخاصة الواجب توافرها في كل حالة من حالات الحجز التحفظي ونتحدث هنا عن الشروط العامة، أما الشروط الخاصة فنتناولها عند الحديث عن هذه الحالات .

والشروط العامة الواجب توافرها منها ما يتعلق بالحق الذي يجري الحجز من أجله، ومنها ما يتعلق بسند الحجز، ومنها ما يتعلق بمحل الحجز

أ- الشروط الواجب توافرها في الحق الذي يجري الحجز من أجله :

نصت المادة ١/٣١٩ على أنه "لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء"، كما نصت المادة ١/٣٢٥ على ذات الشروط بقولها "يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون...".

وعلى ذلك فيجب أن يكون الحق الذي يجري الحجز من أجله مبلغاً من النقود وأن يكون محقق الوجود، وحال الأداء، ونوجز ذلك فيما يلي:

١- **أن يكون مبلغاً من النقود** : ذلك أن الحجز سيؤدي إلى التنفيذ على المال المحجوز جزءاً تحفظياً، ويكون التنفيذ ببيع هذا المال والبيع لا يجوز إلا لأداء مبلغ من النقود^(١) ويستثنى من ذلك الحجز الاستحقاقى حسبما سيرد.

وعلى هذا لا يجوز توقيع الحجز التحفظي لإجبار مدين على القيام بالتزام بعمل^(٢).

٢- **أن يكون محقق الوجود**: تظهر أهمية هذا الشرط عند إجراء الحجز التحفظي دون سند تنفيذي، ذلك أن الدائن إذا كان بيده سند تنفيذي فيجب أن يكون الحق

(١) الوجيز أ.د. عبد العزيز بديوي ص ٣٠٢ .

(٢) التنفيذ الجبري أ.د. فتحي والي ص ٢٦٩ .

موجوداً في ذمة المدين على وجه أكيد، وذلك بأن يكون غير متنازع عليه نزاعاً جدياً وغير معلق على شرط واقف، فإن كان الدين متنازعا فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتاً بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي، أما الدين الاحتمالي فلا يصح أن يكون سبباً للحجز^(١)، فلا يجوز توقيع الحجز بناء على حكم بغرامة تهديديه.

وأما إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم قضائي فيجب الحصول على إذن من القاضي بتوقيع الحجز، والقاضي لا يصدر الإذن بتوقيع الحجز إلا إذا كان الحق محقق الوجود بمعنى أن الحق ثابت بسبب ظاهر يدل على وجوده في ذمة المدين، وغير متنازع عليه نزاعاً جدياً؛ فإن كان الظاهر أن الحق محل شك كبير، أو متنازع عليه نزاعاً جدياً، كما إذا كان الحق مجحوداً جحوداً جدياً من الملتزم به اعتبر الحق غير محقق الوجود ولا يصدر القاضي الإذن بالحجز.

ولكن لا يعني تحقق وجود الحق انتفاء كل نزاع في شأنه، وإلا لأمكن لكل مدين أن يدفع الحجز بإثارة أي نزاع في الدين ولو لم يكن نزاعاً جدياً، فالدين المتنازع فيه يجوز أن يكون محقق الوجود ويوقع الحجز بموجبه إذا كان ثابتاً بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي^(٢). والقرار الذي يصدر من القاضي بتوقيع الحجز لتحقيق وجود الحق، أو بعدم توقيع الحجز لعدم وجود سبب ظاهر عليه لا يقيد محكمة الموضوع فيما ذهب إليه.

٣- أن يكون حال الأداء: يجب أن يكون الحق الذي يجرى الحجز التحفظي بمقتضاه حال الأداء بمعنى أن يكون غير مؤجل أو معلق على شرط، ويعتبر الحق حالاً إذا كان الأجل مقرراً لمصلحة الدائن وحده ونزل عن حقه فيه، وترتيباً على هذا لا يجوز توقيع الحجز التحفظي بموجب دين لم يحل أجله، أو بموجب دين معلق على شرط واقف لا يتحقق.

(١) نقض مدني، جلسة ١٩٥٤/٢/١١ الطعن رقم ٤٣٤ لسنة ٢١ ق .

(٢) نقض مدني، جلسة ١٩٧٨/٤/٦ الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٤٥ ق.

تعيين المقدار :

لم تتطلب المادة ٣١٩ ولا المادة ٣٢٥ أن يكون الحق معين المقدار كشرط من الشروط العامة للحجز التحفظي، ومن ثم إذا كان الحق محقق الوجود وحال الأداء يجوز توقيع الحجز التحفظي بمقتضاه حتى ولو كان الحق غير معين المقدار. وعلى هذا يجوز توقيع الحجز التحفظي بمقتضى حكم بالتعويض ولو لم يحدد مقداره، ويجوز توقيع الحجز التحفظي بمقتضى حكم إلزام بالمصاريف ولو كانت غير محددة .

غاية الأمر أنه في هذه الحالة (عدم تعيين المقدار) يجب على الدائن قبل توقيع الحجز اللجوء إلى قاضي التنفيذ لتقدير حقه تقديرًا مؤقتًا. ويفيد هذا التقدير في إحاطة المدين علماً بمقدار ما عليه وتمكينه من درء خطر الحجز أو الحد منه بالإيداع والتخصيص وفقاً للمادة (٢٠٣) أو قصر الحجز وفقاً للمادة (٣٠٤).

ب- الشروط اللازمة في سند الحاجز حجزاً تحفظياً:

في الحديث عن الشروط اللازمة في سند الحاجز نفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: حالة ما إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم قضائي غير نافذ، أي حكم غير حائز لقوة الأمر المقضي به وغير مشمول بالإنفاذ المعجل. ولا يشترط في هذه الحالة الحصول على إذن من القضاء بتوقيع الحجز، بل يجوز توقيع الحجز التحفظي هنا بدون إذن من القضاء.

الحالة الثانية: ما إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم قضائي غير نافذ، أو كان معه سند تنفيذي أو حكم قضائي، ولكن الحق الثابت به غير معين المقدار. وفي هذه الحالة يشترط لتوقيع الحجز التحفظي الحصول على إذن من القضاء بتوقيع الحجز التحفظي، وإلا كان الحجز باطلاً، وعند عدم تعيين المقدار يستصدر الدائن أمر تعيين المقدار والإذن بالحجز بإجراءات واحدة.

الجهة المختصة بإصدار الإذن:

عند توقيع الحجز على المنقول لدى المدين يكون الاختصاص لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها، وعند توقيع الحجز على ما للمدين لدى الغير يكون الاختصاص لمحكمة التنفيذ الواقع في دائرتها موطن المحجوز لديه (المادة ٢٧٦/١) "وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الهيئة التي تنتظر الدعوى". (المادة ٣١٩ / ٤).

ففي هذه الحالة (إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة) يكون الاختصاص بإصدار الإذن مشتركاً بين قاضي التنفيذ وبين رئيس الهيئة التي تنتظر الدعوى، وذلك للارتباط بين الدعوى القائمة أمام الهيئة والأمر بالحجز بمقتضى الحق المقامة به الدعوى.

ويستثنى من اختصاص قاضي التنفيذ بإصدار الإذن بالحجز حالة ما إذا كان حق الدائن مما يجب استصدار أمر بأدائه.

ففي هذه الحالة يختص بإصدار الأمر بالحجز القاضي المختص بإصدار أمر الأداء؛ وذلك توحيداً للاختصاص بإصدار الأمر بالأداء والإذن بالحجز. (المادة ٢١٠/١).

إجراءات استصدار الإذن:

طلب الإذن بالحجز والقرار الصادر في ذلك والتظلم من القرار يخضع للقواعد العامة في الأوامر على العرائض، وعلى ذلك يقدم الطلب بعريضة من نسختين متطابقتين ومشملة على الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها، فضلاً عن ذلك يجب أن يشمل طلب الإذن بالحجز على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.

سلطة القاضي الأمر:

يصدر القاضي قراره بدون إجراء تحقيق في حضور الخصوم . كقاعدة . ولكن يعتمد على ظاهر الأوراق والمستندات المؤيدة للطلب؛ فإذا رجح من ظاهرها وجود

الحق أذن بالحجز، أما إذا رجح من ظاهرها قيام نزاع جدي، أو رجح عدم وجود الحق، فإن القاضي لا يتعمق في بحث المستندات والوقائع بل يرفض إصدار الإذن. واستثناءً من القواعد العامة في الأوامر على العرائض للقاضي قبل إصداره أمره أن يجرى تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.

وللقاضي سلطة تقديرية في إصدار الإذن، فله أن يأمر بإجراء الحجز إذا توافرت الشروط، وله أن يرفض الإذن لاختلال شرط من الشروط أو إذا ظهر له رغم توافر الشروط أن الدائن سيء النية لا يقصد إلا الإضرار بسمعة مدينه، أو أن المدين موسر لا حاجة للتحفظ على ماله، وللقاضي أن يأذن بالحجز بمقتضى جزء من حق الدائن دون جزء آخر رأى أنه غير مستوف للشروط، كما أن له أن يعلق توقيع الحجز على اتخاذ تدبير معين كإعلان المدين بالأمر ومضي مدة قبل توقيع الحجز (المادة ٣/٣١٩) أو كتعليق الحجز على إيداع كفالة أو تحقق شرط معين.

ج- الشروط اللازمة في محل الحجز:

يجرى الحجز التحفظي على المنقول دون العقار، يستوي أن يكون المنقول مادياً أو منقولاً معنوياً، كالدين أو الحق الذي للمدين في ذمة غيره، ولو كان الدين مؤجلاً أو معلقاً على شرط ويكفي لتوقيع الحجز وصحته أن يكون الدين المحجوز عليه قد نشأ سببه قبل توقيع الحجز، ولو كان مؤجلاً الاستحقاق إلى ما بعد حصول الحجز^(١). ولكن يشترط في المنقول الذي يجرى عليه الحجز التحفظي أن يكون قابلاً للحجز، بمعنى أن يكون من الأموال التي يجوز الحجز عليها، وبالقدر المسموح به^(٢). وعلى ذلك لا يجوز توقيع الحجز التحفظي على العقارات بطبيعتها، ولا على المنقولات التي تخصص لخدمة العقار، لأنها أصبحت عقاراً بالتخصيص.

(١) نقض مدني جلسة ١٣/٩/١٩٧٢، الطعن رقم ٤٠٦ لسنة ٣٧ ق .

(٢) الوجيز في قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري والتحفظ للدكتور عبد العزيز بديوي، ص ٣١١

المبحث الثالث

حالات الحجز التحفظي

رأى المقتن أن حصر الحالات التي يجوز فيها للدائن أن يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات مدينه لا يواجه جميع الحالات التي قد تعرض في العمل، ويكون هناك ضرورة للتحفظ فيها على أموال المدين، ولذلك أورد نصاً أجاز بمقتضاه للقاضي وفقاً للظروف أن يأذن للدائن بتوقيع الحجز التحفظي إذا كان هناك ما يبرر خشيته من فقد ضمان حقه، كما نص على حالات خاصة.

هذا: ونتناول الحالة العامة أولاً وهي حالة الحجز حماية للضمان العام ثم الحالات الأخرى الخاصة التي نص عليها القانون .

المطلب الأول

الحجز حماية للضمان العام

للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على أموال مدينه في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه، والغرض من تشريع هذه الحالة إيجاد وسيلة تغطي جميع الحالات التي تعرض في العمل ويكون هناك ضرورة للتحفظ فيها على أموال المدين. ويشترط في هذه الحالة توافر الدليل على خشية الدائن من فقدان ضمانه، ولا يقصد بالضمان هنا الضمان الخاص، ولكن يقصد به الضمان العام الذي للدائن على جميع أموال مدينه، والمراد بالخشية الخوف من فقد الضمان العام بسبب ظروف محددة، وعبء إثبات ذلك يقع على عاتق الدائن^(١).

ومن الحالات التي تتوافر فيها الخشية من فقد الضمان العام الحالات التي كانت واردة في المادة ٦٠١ من قانون المرافعات السابق وهي:

- ١- إذا لم يكن للمدين موطن مستقر بمصر.
- ٢- إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.

(١) أصول التنفيذ أ . د . محمد محمود إبراهيم ص ٣٨٦، نقض مدنس جلسة ١٩٧٨/٤/٦، الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٤٥ ق، جلسة ١٩٧٩/٦/٢٥، الطعن رقم ٤٤٠ لسنة ٤٥ ق .

- ٣- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياح.
- ٤- إذا كان الدائن حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة (وهذه هي الحالة التي نصت عليها المادة ١/٣١٦ من القانون الجديد) .
- ٥- إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها. ومع هذا يجوز توقيع الحجز التحفظي في كل حالة أخرى يبدو فيها خطر فقد الدائن لضمائه بناء على وقائع معينة كتصرف المدين في أمواله بسرعة، أو حدوث اختلال في حالته المالية، ولا يتوقف ذلك على شعور الدائن بل يتوقف على الظروف الموضوعية للمدين^(١) .

المطلب الثاني

الحالات الخاصة

إلى جانب الحالة العامة السابقة تضمن قانون المرافعات عدة حالات خاصة للحجز التحفظي، وإيراد هذه الحالات والنص عليها بجانب الحالة العامة السابقة يفيد إعفاء الدائن في هذه الحالات ومثيلاتها مما نص عليه في قوانين متفرقة أو نصوص خاصة من عبء إثبات خشية فقده لضمان حقه^(٢) ، ونتناول هذه الحالات فيما يلي:

أ- الحجز على التاجر المدين بمقتضى كمبيالة أو سند تحت الإذن:

يجوز توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين إذا كان الدائن حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن، وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة، والحكمة من النص على هذه الحالة مراعاة ما تقتضيه المعاملات التجارية من سرعة وإتقان.

ويشترط لتوافر هذه الحالة الشروط الآتية :

- ١- أن يكون بيد الدائن كمبيالة أو سند تحت الإذن.

(١) النظرية العامة للتنفيذ أ . د . وجدي راغب، ص ١٩٣ .

(٢) التنفيذ الجبري أ . د . فتحي والي ص ٢٦٤ .

٢- أن يكون المدين المطلوب توقيع الحجز على أمواله تاجراً، فإن لم يكن كذلك فلا يجوز توقيع الحجز التحفظي تطبيقاً لهذه الحالة، ولكن لا يشترط توافر هذه الصفة في الدائن.

٣- أن يكون للمدين التاجر المطلوب توقيع الحجز على أمواله توقيع على الكمبيالة أو السند الإذني يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة، كساحب الكمبيالة أو المسحوب عليه القابل، أو مظهرها فهم ملزمون بالوفاء لحاملها (المادة ٤٣٨ من قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩)، وكمحرر السند أو مظهره.

٤- أن يكون الدائن قد اتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون التجارة للرجوع على المدين، وإلا سقط حقه في الرجوع، ومن ثم يتمتع توقيع الحجز التحفظي، وذلك كتحرير وإعلان بروتستو عدم الدفع في الميعاد، وذلك للرجوع على غير الساحب والمسحوب عليه القابل^(١).

ب- الحجز الذي يوقعه مؤجر العقار على منقولات المستأجر:

نصت المادة ١/٣١٧ على أنه: "المؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً". وحق الامتياز الذي ورد هذا النص ضماناً له امتياز مؤجر العقار على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة، ونص على هذا الامتياز بالمادة ١١٤٣ مدني.

ويشترط لتوافر هذه الحالة الشروط الآتية :

١ - أن يكون الدائن طالب الحجز مؤجراً لعقار، سواء كان مالكاً له أو صاحب حق انتفاع عليه، أو مستأجراً أصيلاً، أو مجرد واطع يد عليه^(٢). ومن ثم فمؤجر المنقول لا يستطيع أن يحجز تحفظياً وفقاً لهذه الحالة.

(١) النظرية العامة للتنفيذ أ. د. وجدي راغب ص ١٩٤ .

(٢) التنفيذ الجبري أ. د. فتحي والي ص ٢٦٧ .

٢ - أن يكون المدين المطلوب الحجز على منقولاته مستأجراً أصلياً أو من الباطن ومن ثم إذا لم يكن المطلوب الحجز عليه مستأجراً وإنما هو غاصب مثلاً فلا يجوز توقيع الحجز التحفظي على منقولاته.

٣ - أن يكون الدين الذي يحجز من أجله من الديون التي يضمنها حق امتياز المؤجر، وهي أجرة المباني والأراضي الزراعية لمدة سنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار.

٤ - أن يقع الحجز على محل الامتياز وفقاً للقانون المدني، ومحل الامتياز وفقاً للقانون المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة إذا اعتقد المؤجر بحسن نية أنها مملوكة للمستأجر وتدخل أيضاً منقولات الزوجة، كما تدخل منقولات المستأجر من الباطن إذا اشترط المؤجر عدم الإيجار من الباطن، فإن لم يشترط فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذر فيه المؤجر.

ويلاحظ: أنه يترتب على إعلان الحجز للمستأجر من الباطن اعتبار الأجرة محجوزة تحت يده (المادة ٣٢٣)، ومعنى ذلك أن الحجز على منقولات المستأجر من الباطن وإعلان الحجز له بمثابة حجزين تحفظيين أولهما حجز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة، وثانيهما حجز ما للمستأجر الأصلي لدى المستأجر من الباطن من الأجرة.

ومع هذا: "إذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة" (المادة ٢/٣٢٣).

ج- الحجز الاستحقاقى:

نصت المادة ٣١٨ على أنه: "لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه". فهذا الحجز يوقعه مالك المنقول بمقتضى ما له من حق تتبع منقوله تحت يد حائزه، والهدف من الحجز هنا ضبط المنقول المملوك للحاجز ومنع الحائز من تهريبه

أو التصرف فيه تصرفاً يؤدي إلى نقله إلى غير حائزه، ليتمكن مالكه من استرداده بعد الحكم له بملكيته .

وهذا الحجز لا يتحول إلى حجز تنفيذي يؤدي إلى بيع المنقول، وإيفاء الدائن حقه من حصيلة التنفيذ، كالحجز التحفظي العادي، وإنما يمكن الحاجز من التنفيذ المباشر، واسترداد المنقول بعد توقيع الحجز (١).

(١) النظرية العامة للتنفيذ القضائي أ . د . وجدي راغب ص ١٩٥ .

المبحث الرابع إجراءات الحجز التحفظي

توقيع الحجز:

إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم قضائي غير نافذ، أو لم يكن بيده شيء من ذلك، ولكنه حصل على أمر من القضاء بتوقيع الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة تحت يد المدين، فيوقع الحجز التحفظي عن طريق حجز المنقول تحت يد المدين، وفي ذلك نصت المادة ١/٣٢٠ على أنه "يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب"^(١) عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع .

والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من كتاب التنفيذ هي إجراءات حجز المنقول لدى المدين، ومن ثم يتم الحجز التحفظي على المنقولات تحت يد المدين عن طريق تحرير محضر حجز يحرره معاون التنفيذ في مكان توقيع الحجز، ويجب أن يشتمل على البيانات التي نصت عليها المادة ٣٥٣ فيما عدا تحديد ميعاد يوم للبيع، لأن البيع غير مقصود من هذا الحجز عند توقيعه.

إعلان الحجز والأمر الصادر به:

يجب على الحاجز أن يعلن إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز. (المادة ٢/٣٢٠)، أما إذا كان المحجوز عليه قد أعلن بالأمر بالحجز قبل توقيعه بناء على ذات الأمر الصادر من القاضي بالحجز، أعلن محضر الحجز فقط دون الأمر الصادر به لسبق إعلانه^(٢). ويترتب على عدم إعلان المدين بالحجز والأمر الصادر به خلال ثمانية الأيام اعتبار الحجز كأن لم يكن.

(١) الكتاب المشار إليه هو الكتاب الثاني من قانون المرافعات وهو كتاب التنفيذ .

(٢) التنفيذ الجبري أ . د . أمينة النمر ص ٤٠١ .

دعوى صحة الحجز :

في الأحوال التي يكون الحجز فيها بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز رفع دعوى بثبوت الحق وصحة الحجز في خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز وإلا اعتبر كأن لم يكن.

موضوع الدعوى: يتعين أن تشتمل صحيفة الدعوى على طلبين:

١ - الحكم على المدين المحجوز عليه بثبوت الحق الذي يتم الحجز بموجبه أو تعيين مقداره بصفة قطعية وهذا هو الطلب الأساسي.

٢ - الحكم بصحة إجراءات الحجز لتوافر شروط الحجز التي يتطلبها القانون حتى يحسم النزاع حول موضوع صحة الإجراءات فلا يعاد طرحه على القضاء.

الخصوم في دعوى صحة الحجز:

المدعى في دعوى صحة الحجز هو الحاجز فهو صاحب المصلحة في تقرير صحة الحجز والمدعى عليه هو المحجوز عليه فهو الشخص الذي يسعى الدائن إلى إثبات حقه في مواجهته، وفي حجز ما للمدين لدى الغير يجوز اختصام المحجوز لديه مع المحجوز عليه، و"إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز"^(١). وإذا لم يختصم المحجوز لديه فله أن يتدخل في الدعوى، ذلك أن المحجوز لديه صاحب مصلحة في دعوى صحة الحجز، فإذا كان الحجز قد وقع باطلاً كانت له مصلحة محققة في الدفع ببطلانه ليتحلل من الواجبات التي يفرضها عليه قيام الحجز"^(٢). وإذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فإنه يصبح خصماً ذا صفة يحتاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ويلتزم تنفيذه في هذا الصدد^(٣).

(١) المادة ٣٣٤ مرافعات .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٣٧/٤/١، الطعن رقم ٨٤ لسنة ٦ ق .

(٣) الطعن رقم ٣٤١ لسنة ٤٠ ق، جلسة ١٩٩٣/٣/٨، الطعن رقم ١٩٤١ لسنة ٥١ ق .

الاختصاص بدعوى صحة الحجز:

تختص بدعوى صحة الحجز المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص، وتطبيقاً لذلك يكون الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية أو الجزئية حسب قيمة الدعوى، وتقدر قيمة دعوى صحة الحجز بقيمة الدين المحجوز من أجله . إذ كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون، أما إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوز أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال ^(١).

وعلى هذا فإن الدعوى المتعلقة بحجز المنقول المردة بين الدائن والمدين بشأن صحة الحجز الذي أوقعه الدائن على منقول للمدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن على مال للمدين . عقاراً أو منقولاً من رهن أو امتياز أو اختصاص تقدير بقيمة الدين المحجوز من أجله أو المقرر الحق العيني ضماناً له وليس بقيمة المال، لأن الغاية من الحجز أو الحق العيني التبعية هو ضمان الحصول على هذا الدين فالنزاع بين الدائن والمدين حول أيهما لا أهمية له إلا بالنظر إلى هذا الدين، أما إذا رفع الغير دعوى استحقاقه للمنقول المحجوز عليه أو للمال المحمل بحق عيني تبعية فإنها تكون دعوى متعلقة بالمال وليس بالدين فتقدر بقيمة المال ^(٢) كما يكون الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المحجوز عليه، حتى ولو اختصم فيها المحجوز لديه ^(٣)، ذلك أن المحجوز عليه هو الخصم الأصلي والحقيقي فيها، " إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتتظر فيهما معا "؛ حتى لا تتعدد الدعاوى الناشئة عن المطالبة بحق واحد ^(٤).

(١) المادة ٣٧ / ٩ مرافعات .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٩٨/٢/١٩، الطعن رقم ٥٤٣٩ لسنة ٦١ ق .

(٣) التنفيذ الجبري أ . د . فتحي والي ص ١٧٨ .

(٤) المادتان ٣٢١، ٣٣٣ / ٢ مرافعات، وانظر نقض مدني جلسة ١٩٦٩/٥/١٣، الطعن رقم ٢٢١ لسنة ٣٥ ق .

إجراءات الدعوى والحكم فيها:

ترفع الدعوى بالطريق المعتادة لرفع الدعوى أي بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة، وتنتظر المحكمة دعوى صحة الحجز، وتفصل فيها وفقاً للقواعد العامة والحكم الصادر فيها يخضع للقواعد العامة في الطعن في الأحكام .

وإذا رفعت دعوى صحة الحجز بغير الطريق المعتاد لرفع الدعوى، كأن تقدم في طلب عارض أثناء نظر الدعوى بالحق، فإن المحكمة تحكم بعدم قبول دعوى صحة الحجز لرفعها بغير الطريق القانوني^(١)، وإذا لم يتم رفع دعوى صحة الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ الحجز فإنه يعتبر كأن لم يكن .

إجراءات الحجز اقتضاء لدين ثابت بالكتابة :

إذا كان حق الدائن مبلغاً من النقود يسري عليه نظام أوامر الأداء بأن كان الدين ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو نوعه أو مقداره، وأراد هذا الدائن توقيع حجز تحفظي على منقولات لدى المدين، فإما أن يكون هذا الدائن قد حصل على أمر الأداء، أو لم يحصل عليه.

الحالة الأولى: إذا كان الدائن قد حصل على أمر بأداء دينه وأراد توقيع حجز تحفظي ففي هذه الحالة يوقع الدائن الحجز وفقاً للقواعد العادية.

الحالة الثانية: إذا كان الدائن لم يحصل على أمر بأداء دينه، وأراد توقيع حجز تحفظي فهذا لا يستطيع هذا الدائن أن يوقع الحجز وفقاً للقواعد العادية وإنما يوقع هذا الحجز وفقاً لأحكام المادة ٢١٠ مرافعات وهذه الإجراءات تختلف عن الإجراءات العادية على الوجه الآتي:

(١) نقض مدني جلسة ١٩٧٩/٦/٢٠ الطعن رقم ١١٤٥ لسنة ٤٨ ق، جلسة ١٩٧٨/٦/١٤ الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٤٣ ق .

الأمر بالحجز والقاضي المختص به:

يحصل الدائن على أمر من القاضي بتوقيع الحجز، واستثناء من أحكام المواد ٢٧٥، ٣١٩، ٣٢٧ لا يحصل الدائن على هذا الأمر من قاضي التنفيذ، وإنما يحصل عليه من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء حسب قيمة الدين مع مراعاة قواعد الاختصاص.

فإذا توافرت في الدين المطالب به شروط استصدار أمر الأداء . بأن كان ثابتاً بالكتاب حال الأداء معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره . فعلى الدائن إذا أراد توقيع الحجز التحفظي أو الحجز ما للمدين لدى الغير وفاء لدينه، أن يستصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء، وتقدير توافر الشروط المذكورة هو مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة^(١).

ويقدم الطلب على عريضة ويصدر القاضي أمره بمقتضى سلطته اللوائية ويتبع في إجراءات الأمر وإصداره والتظلم منه وسقوطه القواعد المطبقة على الأوامر على العرائض.

طلب أمر بالأداء وصحة إجراءات الحجز:

ويجب على الحاجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز إلى القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء . وهو نفس القاضي الذي أصدر أمر الحجز . وإذا لم يقدم طلب الأمر بالأداء خلال ثمانية الأيام اعتبر الحجز كأن لم يكن. (المادة ٢/٢١٠) .

وللقاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز ما للقاضي المختص بإصدار أمر الأداء من سلطة فله أن يصدر الأمر بأداء كل الدين فإن لم يرد إجابة الطالب إلى كل طلباته امتنع عليه إصدار الأمر ووجب عليه أن يحدد جلسة للخصوم لنظر الموضوع.

(١) المادة ٢١٠ / ١ وانظر نقض مدني جلسة ١٩٧٧/١/١٥ الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٤٢ ق .

وله في صدد صحة الحجز سلطة القاضي الذي ينظر دعوى صحة الحجز .
ويلاحظ ما نصت عليه المادة ٢١٠ / ٣ بقولها " وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء، وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة ٢٠٤ " .

وعلى هذا إذا تظلم المدين من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق كأن يدعي انقضاء الدين فإنه يمتنع على القاضي أن يصدر أمر الأداء ويجب عليه أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، ولكن لا يوجد ما يمنع من صدور الأمر في طلب الأداء لثبوت الحق فيه ورفض طلب صحة الحجز لعيب في إجراءاته، ذلك أن إصدار أمر الأداء لا يمنع إلا في حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق^(١) .

اقتضاء الحاجز حقه:

نصت المادة ٣٢٢ على أنه " إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من الباب الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة ٣١٨ "، وعلى ذلك إذا حصل الدائن على حكم بصحة الحجز وثبوت الدين في الأحوال التي يكون الحجز التحفظي فيها بناء على أمر القاضي، أو أن الحكم القضائي غير النافذ أصبح نافذاً بمقتضى القواعد العامة، أو كان بيد الدائن سند تنفيذي من بادئ الأمر ففي هذه الأحوال يكون الحق موجوداً في ذمة المدين على وجه أكيد ويكون من حق الدائن استيفاء حقه، إما بتسليم المنقول في حالة الحجز الاستحقاقى، وإما ببيع المنقولات المحجوزة واستيفاء حقه من حسيطة التنفيذ . ويتم ذلك بإجراءات بيع المنقول تحت يد المدين المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث.

ويلاحظ أنه يجب على الدائن قبل البدء في التنفيذ أن يعلن السند التنفيذي للمدين، وأن يكلفه الوفاء، وأن يمضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.

(١) نقض مدني جلسة ١٩٧١/٦/٢٤، الطعن رقم ٥ لسنة ٣٧ ق .

الفصل الثالث

حجز ما للمدين لدى الغير

الفصل الثالث

حجز ما للمدين لدى الغير

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود وحال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، ويسمى هذا الحجز حجز ما للمدين لدى الغير، وقد نظم المشرع أحكامه في الفصل الثاني من الباب الثاني في الكتاب الثاني من قانون المرافعات (المواد ٣٢٥ - ٣٥٢)، وعنوان هذا الفصل، حجز ما للمدين لدى الغير. وهو نوع من الحجز التحفظية التي تجرى على منقولات المدين المادية والمعنوية لدى الغير.

ونتناول بيان ماهية هذا الحجز وشروطه وطبيعته وإجراءاته والاعتراضات التي تنثور بشأنه والآثار المترتبة عليه، في أربعة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول

ماهية حجز ما للمدين لدى الغير وإجراءاته

يقتضي بيان ماهية حجز ما للمدين لدى الغير أن نعرف به أولاً ونبين محله وأطرافه وطبيعته وشروطه، ثم نتناول إجراءاته، وذلك في ثلاثة مطالب على النحو الآتي:

المطلب الأول

ماهية حجز ما للمدين لدى الغير

أولاً: تعريفه:

هو الحجز الذي يوقعه الدائن على حقوق مدينه أو منقولاته التي في ذمة الغير أو حيازته بقصد منع هذا الغير من الوفاء للمدين أو تسليمه ما في حيازته من منقولات تمهيداً لاقتضاء حق الحاجز منها أو من ثمنها بعد بيعها^(١).

ويفترض هذا الحجز وجود ثلاثة أشخاص؛ الأول: الحاجز الذي يتخذ إجراءات الحجز، والثاني هو المحجوز عليه وهو المدين مباشرة للحاجز، أما الشخص الثالث؛

(١) أستاذي د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٢١٥.

فهو المحجوز لديه الذي يتم الحجز تحت يده على الأموال والحقوق المستحقة للمحجوز عليه^(١)؛ وهو من عبرنا عنه بـ "الغير" عند حديثنا عن أطراف التنفيذ.

ومن الأمثلة العملية لهذا الحجز أن يكون المدين مالكا لعقار يؤجره، فيحجز الدائن على الإيجار المستحق لدى المستأجر، أو أن يقوم الدائن بالحجز على أموال مدينه المودعة في أحد البنوك، ومن ذلك أيضا أن يكون للمدين منقولات في حيازة شخص آخر فيقوم الدائن بالحجز عليها لدى هذا الشخص^(٢).

"تتطبق قاعدة حجز ما للمدين لدى الغير، سواء كان المحجوز لديه شخصا طبيعيا أو معنويا، وسواء كان الشخص الطبيعي وطنيا أم أجنبيا، وفي هذه الحالة يجب أن يكون موجودا في مصر، حتى يكون ملتزما بالخضوع لإجراءات التنفيذ الجبري والاشتراك فيها، ويكون من الجائز الحكم عليه بالجزاء المقرر قانونا لمخالفة هذه الإجراءات. ويجوز الحجز لدى المحجوز لديه إذا كان شخصا معنويا، سواء كان شخصا خاصا أو شخصا عاما، وفي هذه الحالة تتبع إجراءات الحجز المقررة في قانون المرافعات طالما أن الحاجز شخصا خاصا أو شخصا عاما رأى اتباع هذه الإجراءات دون القواعد المقررة في قانون الحجز الإداري"^(٣).

ثانيا: محل هذا الحجز:

إذا كان الحجز التنفيذي والحجز التحفظي على المنقول لدى المدين لا يجرى على إلا على المنقولات المادية؛ فإن حجز ما للمدين لدى الغير يجرى على المنقولات المادية لدى الغير، وعلى حقوق المدين لدى هذا الغير، فيجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء؛ أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط (مادة ١/٣٢٥ مرافعات). ومن ثم فإن حجز ما للمدين لدى الغير قد يكون منقولا ماديا في حيازة الغير، أو حقا في ذمة هذا الغير:

(١) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٤٧٥.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ١٦٨/٦.

(٣) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٤٧٥.

أ- المنقول المادي في حيازة الغير (المحجوز لديه):

يوجب القانون في حجز منقولات المدين الموجودة في حيازة الغير، اتباع إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، وليس اتباع إجراءات حجز المنقول لدى المدين على النحو الذي سبق بيانه، وذلك حرصاً على عدم الإضرار بالغير الذي يوجد المنقول لديه؛ إذ قد يؤدي اتباع إجراءات حجز المنقول لدى المدين، إلى التأثير على سمعة هذا الغير في دين لا يكون مسئولاً عنه، أو الحجز على مال من أمواله المملوكة له، تحت مظنة كونها من أموال المدين المحجوز عليه.

ومن ناحية ثانية؛ فإن هذا الطريق يحقق مصلحة للحاجز، والذي يكون من مصلحته أن يبدأ هذا الحجز بإجراء يوجه مباشرة إلى الغير حتى يفاجيء المدين بحبس المال المحجوز تحت يد المحجوز لديه، فلا يترك له فرصة استرداده أو تهريبه، فيكون أوفى بحاجة الحاجز وأقرب إلى تحقيق غرضه^(١).

ويجب لإجراء هذا الحجز؛ أن يوجد المنقول المادي في حيازة الغير، ومثال ذلك المنقولات المودعة في مخزن للودائع، أو الطرود أثناء نقلها لدى السكة الحديد أو شركة النقل، أو منقول اشتراه المدين وانتقلت ملكيته إليه وما زال في حيازة البائع^(٢).

ب- حقوق المدين في ذمة الغير (المحجوز لديه):

يجوز الحجز على حقوق المدين في ذمة الغير؛ بحيث يكون كل حق للمدين لدى الغير محله مبلغ من النقود يتم الحجز عليه بإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، ولو لم يكن هذا الحق معين المقدار أو حال الأداء، فيجوز للحاجز الحجز على الأجرة تحت يد المستأجر ولو لم يحل ميعادها، ويجوز الحجز على مرتب الموظف أو أجر العامل ولو قبل استحقاقه، ويجوز الحجز على دين معين لدى المحجوز لديه، كما يجوز الحجز على كل ما يكون مديناً به للمحجوز عليه، وفي هذه الحالة يكون الحجز عاماً لا يرد على مال معين بذاته.

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٤٨٠.

(٢) د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ٢٩٠.

كما يشمل الحجز كل دين ينشأ للمدين المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في الذمة، ولو نشأ الدين بعد إعلان الحجز، حيث نصت المادة (٢/٣٢٥) على أنه "ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا على دين بذاته"، وذلك دون حاجة إلى إجراء آخر من جانب الحاجز، بشرط أن يتم الحجز على مال من الأموال التي يجوز الحجز عليها، وألا يكون الدين قد انقضى قبل الحجز بالوفاء أو المقاصة أو غير ذلك؛ وإلا يكون الحجز قد ورد على غير محل.

الجزاء المترتب على مخالفة هذا الطريق من طرق الحجز:

أوجب المشرع اتباع إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير في حجز منقولات المدين لدى هذا الغير، ويرى الفقه أن هذه القواعد غير متعلقة بالنظام العام^(١)، ولذلك إذا أوقع حجز المنقول مباشرة على الدائن وكان المحجوز عليه تحت يد غيره، ولم يتمسك الحائز بحقه؛ بأن قدم المنقول لمعاون التنفيذ دون اعتراض؛ فلا يجوز بعد ذلك المنازعة في صحة الحجز. إذ يمكن بالنسبة للمنقول المادي الذي في حيازة الغير، اتباع طريق حجز المنقول لدى المدين، إذا رضي الغير بدخول معاون التنفيذ عنده؛ لأن الأمر متوقف على إرادة الغير.

وعكس ذلك يرى بعض الفقه؛ وجوب اتباع ما أوجبه المشرع في حجز ما للمدين لدى الغير، وإذا تم الحجز بدخول معاون التنفيذ إلى مكان وجود المنقولات المراد حجزها وتحرير محضر الحجز على أموال المدين؛ يكون الحجز باطلا، لمخالفة الطريق الذي أوجب القانون اتباعه، وأن بطلان الحجز في هذه الحالة من النظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، إذ يتعلق بالطرق المقررة قانونا للأشخاص لاستيفاء الحماية القانونية، وهي من النظام العام^(٢).

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/١٧١.

(٢) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص٤٧٨.

ثالثاً: المقصود بالغير في هذا الحجز:

المقصود بالغير هنا، هو كل شخص حائز غير المدين تقوم بينه وبين المدين المحجوز عليه علاقة مديونية ويحتل فيها الأخير مركز الدائن^(١).

وينصرف لفظ المديونية هنا إلى أوسع المعاني، فيشمل المدين الحقيقي الذي يلتزم بنقل ملكية شيء للمحجوز عليه لم تنتقل بعد ملكيته كالنقود وغيرها، كما يشمل الحائز لشيء مملوك للمحجوز عليه يلتزم برده أو تسليمه إلى مالكة المدين، ومن هذا القبيل المودع والدائن والمرتهن والسنديك بالنسبة لما يحوزه من أموال التفليسة والوكيل والحارس القضائي والبنك فيما يتعلق بالحساب الجاري، ومعاون التنفيذ بالنسبة لما تحت يده من مبالغ^(٢).

والغير بهذا المعنى هو من لا يخضع للمدين خضوع التابع للمتبع، بحيث يتمتع على المدين أن يستولي على الأشياء التي في يده كيفما شاء دون أن يكون للحائز رأي في تمكين المدين أو عدم تمكينه من هذا الاستيلاء. وعلى ذلك يعتبر من الغير الوكيل والمستأجر والمودع لديه والمستعير والولي والوصي والقيم، ولا يعتبر من الغير، الخادم والبواب؛ فيحجز على ما في أيديهم حجز المنقول لدى المدين^(٣).

رابعاً: طبيعة حجز ما للمدين لدى الغير:

هذا الطريق من طرق الحجز يبدأ دائماً حجزاً تحفظياً، حتى ولو تم توقيعه بمقتضى سند تنفيذي؛ إذ إن طبيعة هذا الحجز تحتم أن يبدأ تحفظياً؛ لأن المال المراد حجزه ليس في حيازة المدين ولكنه في حيازة الغير، فيقع الحجز ابتداءً دون علم المدين، ولكن لابد من علم المدين في مرحلة لاحقة من توقيع الحجز، وتتوالى بعد ذلك الإجراءات ليتحول هذا الحجز من حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي، ومن ثم فهو

(١) ويشترط أن يكون المحجوز لديه مديناً للمدين المحجوز عليه، ومن ثم لا يجوز الحجز على الشريك تحت يد مديني الشركة ذات الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية أعضائها، ولا الحجز على الشركة تحت يد مديني أحد الشركاء فيها، وهكذا.

(٢) المستشار. محمد عزمي البكري، الحجز القضائي على المنقول، ص ٤٩٤.

(٣) د. رمضان عبدالكريم علام، الوجيز في قواعد التنفيذ الجبري، ص ٣٥٠.

يبدأ تحفظيا ثم يتحول إلى حجز تنفيذي، ولأن هذا الحجز يبدأ حجزاً تحفظياً معتمداً على عنصر المفاجأة والمباغته؛ فلا يلزم اتخاذ مقدمات التنفيذ قبل إجرائه^(١).

خامساً: السند الذي يتم بمقتضاه حجز ما للمدين لدى الغير:

تكفل المشرع ببيان طبيعة هذا السند بنصه في المادة (٣٢٧) مرافعات على أنه "إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز. ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت معين المقدار". ويتضح من هذا النص أن هناك ثلاث حالات تتعلق بحصول الدائن على سند لإجراء حجز ما للمدين لدى الغير، وهي:

الحالة الأولى: أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي:

وفي هذه الحالة يكون للدائن أن يجري حجز ما لمدينه لدى الغير، بدون اشتراط إذن القاضي، بحيث لا يتوقف الحجز في هذه الحالة على إذن من قاضي التنفيذ؛ وإنما يوقع الدائن هذا الحجز مباشرة بناء على السند التنفيذي الذي بيده.

الحالة الثانية: إذا كان بيد الدائن حكم غير نافذ بدين ثابت ومعين المقدار:

وفي هذه الحالة إذا كان الدائن قد حصل على حكم قضائي بحقه، ولو كان هذا الحكم غير نافذ، كالحكم الابتدائي القابل للاستئناف، أو المطعون فيه بالفعل بالاستئناف، وغير مشمول بالنفاذ المعجل؛ فإن للدائن الذي حصل على هذا الحكم أن يجري به حجز ما يكون لمدينه لدى الغير، باعتباره حجزاً تحفظياً، وذلك بشرط أن يكون الدين الثابت في الحكم معين المقدار؛ فإن لم يكن الدين معين المقدار^(٢)، فلا يستطيع الدائن إجراء الحجز بمقتضى هذا الحكم؛ وإنما لابد من إذن قاضي التنفيذ.

(١) أستاذي د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٢١٦.

(٢) كالحكم الذي يصدر بمسؤولية المتسبب في الضرر دون أن يتعرض لتقدير التعويض الواجب عليه، والحكم الذي يصدر بإلزام الخصم بالمصاريف دون أن يحدد مقدارها.

وقد رأى المشرع أن مثل هذا الحكم -غير النافذ- والصادر بثبوت الحق من المحكمة المختصة، أقوى في الدلالة على جدية المطالبة بالحق من مجرد الأمر الوقتي الصادر من القاضي بتوقيع الحجز بعد بحث سطحي للتحقق من ثبوت المديونية، ولأن الحكم بثبوت الدين يتضمن إذن القضاء بتوقيع الحجز بموجبه، ولأن هذا الحكم إما أن يطعن فيه فيغني ذلك عن دعوى جديدة ترفع بطلب ثبوت الدين، أو لا يطعن فيه فيصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي، ويحسم النزاع بصدد الدين^(١).

الحالة الثالثة: وجوب صدور أمر بالحجز من قاضي التنفيذ:

إذا لم يكن بيد الدائن سنداً تنفيذياً، أو كان بيده هذا السند وكان الدين غير معين المقدار، ولم يكن بيده حكم قضائي غير نافذ بدين معين المقدار؛ فإنه لا يجوز إجراء الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ، يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً. ويختص بإصدار الإذن وتقدير الدين في هذه الحالة قاضي التنفيذ، وهو اختصاص نوعي مقصور عليه دون غيره، إلا إذا كان الدين مما ينطبق عليه نظام أمر الأداء، فيختص بالإذن بالحجز وتقدير الدين حينئذ القاضي المختص بإصدار أمر الأداء (مادة ٢١٠ مرافعات).

ولم ينص المشرع في شأن الإذن بحجز ما للمدين لدى الغير، على اختصاص رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام المحكمة المختصة، على عكس المادة (٢/٣١٩) بشأن الحجز التحفظي على المنقول لدى المدين، ومن ثم لا ينعقد الاختصاص لرئيس الهيئة في هذه الحالة^(٢). وهذه مفارقة تشريعية غير موفقة في نظرنا؛ إذ نعتقد أنه لا فارق بين سلطة رئيس الهيئة في حالة الحجز التحفظي، وسلطته في حالة حجز ما للمدين لدى الغير، فكلاهما حجز تحفظي، والدعوى في كلتا الحالتين دعوى بالحق أمام قاض مختص بنظرها.

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٤٩٢ - ٤٩٣.

(٢) د. عزمي عبدالفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، ص ٤٨٩.

وفيما يتعلق بالاختصاص المحلي بإصدار الأمر، نجد أن للفقهاء في هذه المسألة اتجاهين؛ أولهما: يرى أن هذا الاختصاص ينعقد لقاضي التنفيذ الذي يقع بدائرته موطن المحجوز عليه، إذ لا يتصور هنا إعمال نص المادة (١/٢٧٦)، لأن المحجوز لديه لا شأن له بهذه الخصومة، سواء أمر القاضي بالحجز أو رفض طلب إجراء الحجز، لأن المحجوز لديه لا صفة له في ذلك وليس بطرف في الإجراءات ولا يختصم فيها^(١). ونتفق مع هذا الرأي.

وثانيهما: يرى أن قاضي التنفيذ المختص، هو القاضي الذي يتبعه موطن المحجوز لديه، عملاً بالمادة (٢٧٦) مرافعات، والتي تضمنت القاعدة العامة في الاختصاص المحلي بشأن منازعات التنفيذ، وتقضي هذه القاعدة بأن الاختصاص في حجز ما للمدين لدى الغير، ينعقد لمحكمة موطن المحجوز لديه^(٢).

هذا وقد أوجبت المادة (١/٣٢٧) أن يقدم طالب الحجز طلب إجراء الحجز إلى قاضي التنفيذ بعريضة، ومن ثم يتبع في هذا الطلب القواعد والإجراءات الخاصة بالأوامر على العرائض، ولقاضي التنفيذ في نظره لهذا الطلب السلطات المخولة له في إصدار الأوامر على العرائض.

كما يتبع في التظلم من الإذن بتوقيع الحجز الإجراءات والقواعد المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض، ويكون تظلم الدائن في حالة رفض طلب الحجز، أمام المحكمة التابع لها قاضي التنفيذ الذي رفض طلب الحجز، أما تظلم المحجوز عليه الذي صدر الأمر ضده، فيكون أمام هذه المحكمة أو أمام القاضي الذي أصدر الأمر. ولا يجوز للمحجوز لديه التظلم من أمر الحجز؛ لأنه لا يصدر في مواجهته؛ فلا تكون له صفة في التظلم منه. والحكم الصادر في التظلم، حكم وقتي لا يمس الموضوع، ولا يقيد محكمة الموضوع عند نظرها دعوى صحة الحجز.

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/١٧٦.

(٢) د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ٢٥٨ - د. رمزي سيف، إجراءات التنفيذ، ص ٣١٤.

سادسا: شروط الحق المحجوز لأجله وشروط محل الحجز:

ونعني بذلك ما يلزم توفره من الشروط في الدين الذي يجرى حجز ما للمدين لدى الغير اقتضاء له، وهو دين الحاجز، وما يلزم توفره من الشروط في المال الذي يجرى الحجز عليه لدى المحجوز لديه، وهو دين المحجوز عليه لدى المحجوز لديه، وذلك على النحو الآتي:

أ- الديون التي يجوز الحجز اقتضاء لها:

تضمنت المادة (١/٣٢٥) مرافعات، الشروط التي يجب توفرها في الحق الذي يجوز الحجز اقتضاء له، فأوجب أن يكون هذا الحق محقق الوجود، وأن يكون حال الأداء، ولم تشترط أن يكون معين المقدار؛ إذ يجب في حالة الدين غير المقدر، اللجوء إلى قاضي التنفيذ لتقدير هذا الدين بشكل مؤقت والإذن بالحجز (مادة ٣٢٧ مرافعات). وقد سبق أن بينا المقصود بشرط تحقق الوجود، وشرط حلول الأجل، عند حديثنا عن شروط الحجز التحفظي على المنقول لدى المدين، وعن الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له، في الفصل الثالث من الباب الأول، فنحيل إلى ماسبق.

ب- المال الذي يجرى الحجز عليه في حيازة الغير أو في ذمته:

تضمنت المادة (١/٣٢٥) أيضا بيان ما يجوز حجزه لدى الغير، فنصت على أنه "...ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط". ومن ثم فإن الحجز يشمل المنقولات المادية في حيازة الغير، والحقوق في ذمته، على التفصيل الذي سبق بيانه في محل الحجز.

وهذه الحقوق جميعها سواء كانت منقولات أو ديونا في ذمة الغير، لا يشترط بشأنها تحقق الوجود، أو حلول الأجل، أو تعيين المقدار؛ وإنما يجوز الحجز ولو كان الدين محل نزاع أو مؤجلا أو معلقا على شرط، غاية ما في الأمر ألا يقع الحجز على مال من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها، ويجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك (مادة ٣٣٨).

المطلب الثاني

إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير

نصت المادة (٣٢٨) مرافعات على أن حجز ما للمدين لدى الغير، يجرى بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين، بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه، وأوجببت المادة (٣٣٢) إبلاغ الحجز للمحجوز عليه خلال ميعاد محدد، ويجب على الحاجز رفع دعوى صحة الحجز في أحوال معينة وفي ميعاد محدد (مادة ٣٣٣)، كما يجب على المحجوز لديه إيداع التقرير بما في ذمته في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها، فإذا سارت الإجراءات على النحو المقرر قانوناً وتأكد حق الحاجز كان له أن يستوفي حقه من التنفيذ على المال المحجوز عليه لدى الغير. ومن ثم فإن إجراءات هذا الحجز تسير على النحو الآتي:

أولاً: إعلان الحجز إلى المحجوز لديه:

يجب على الدائن أن يقوم بإعلان الحجز إلى الغير (المحجوز لديه)، ويتم الإعلان بورقة تسمى ورقة الحجز بمقتضاها يكون الحجز قد تم توقيعه، وهي ورقة من أوراق المحضرين، لذا يجب أن تشتمل على البيانات العامة لهذه الأوراق وفقاً للمادة التاسعة مرافعات، فضلاً على البيانات التي نص عليها المشرع في المادة (٣٢٨) مرافعات، وهذه البيانات هي:

- ١- صورة سند الحجز: وعبرت عنه المادة (٣٢٨) بـ "صورة الحكم أو السند الرسمي"^(١) الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين".
- فإذا كان الحجز قد تم بمقتضى سند تنفيذي، أو بمقتضى حكم غير نافذ، أو بإذن من قاضي التنفيذ، فإنه يجب على الحاجز إرفاق صورة هذا السند في إعلان المحجوز

(١) هذه عبارة المادة ٣٢٨ بند ١، وهي عبارة غير دقيقة، حيث ذكرت "السند الرسمي" مع أن المقصود السند التنفيذي، والسند الرسمي إذا كان موثقاً؛ فإنه يكون سنداً تنفيذياً في مفهوم المادة (٢٨٠) مرافعات، وتقتضي دقة الصياغة تعديل عبارة هذا البند واستبدالها بعبارة "صورة سند الحجز" لتشمل جميع ما ورد في هذا البند من سند تنفيذي أو حكم غير نافذ أو أمر قاضي التنفيذ.

لديه، وذلك حتى يعلم هذا الأخير بحقيقة الدين المحجوز لأجله، وبحصول الدائن الحاجز على سند يعطيه الحق في الحجز، فيمتنع عن الوفاء للمحجوز عليه. كما أن هذا البيان يحول دون الحجز الكيدية^(١) بديون لا وجود لها ولا دليل عليها. ولا يغني عن هذه الصورة ذكر بيان يتعلق بها في ورقة إعلان الحجز.

٢- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده ومصاريفه: وهو بيان جوهري يحقق مصلحة المحجوز لديه، ويمكنه من معرفة ما يجب عليه إيداعه خزانة المحكمة؛ إذا أراد الإيداع والتخصيص، كما أن هذا البيان يفيد المحجوز عليه في معرفة ما يوفيه للحاجز حتى يتخلص من الحجز، ويفيد كذلك في تحديد المحكمة المختصة قيميا بدعوى صحة الحجز^(٢).

مع ملاحظة أنه إذا كان يجب على الحاجز بيان أصل المبلغ وفوائده ومصاريفه؛ فإنه لا يجوز له أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم إليه في مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين، على ألا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيها (مادة ٣٢٦ مرافعات).

٣- تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا للجهالة، ونهي المحجوز عليه من الوفاء به للمحجوز عليه:

وللفقه في مسألة تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا للجهالة، اتجاهان؛ الأول: يرى أن هذا التعيين لازم في حالة الحجز على عين معينة، أو حق دائنية معين لدى المحجوز لديه، أما إذا كان الحجز عاما واردا على جميع أموال المدين لدى المحجوز لديه، فلا يلزم التعيين؛ وإنما يتم تعيينه في مرحلة لاحقة عند التقرير بما في الذمة، ويكون التقرير هو أداة هذا التعيين^(٣).

(١) د. طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، ص ٢٨٠.

(٢) المرجع السابق، ص ٢٨٠.

(٣) د. رمزي سيف، إجراءات التنفيذ، ص ٣٢٢ - د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ٢٩٨.

والثاني: يرى أن هذا التعيين لازم في كل الحالات، سواء كان المحجوز عليه عين معينة أو جميع ما للمدين لدى المحجوز لديه، بل التعيين أكثر لزوماً في حالة الحجز على جميع ما للمدين^(١). وفضلاً عن هذا التعيين؛ فإنه يجب أن يتضمن البيان، نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في ذمته للمحجوز عليه، وهذا هو جوهر الحجز والهدف الأساس من إعلان ورقة الحجز، وبمقتضاه يكون المحجوز لديه قد أعلن بعدم الوفاء للمحجوز عليه.

٤- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز عليه.

وذلك تيسيراً على المحجوز لديه، ولإتاحة الفرصة له لكي يعلن الحاجز في هذا الموطن بالأوراق المتعلقة بالحجز^(٢).

٥- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً: وهذه المدة تحتسب من اليوم التالي لحصول الإعلان، وقد أوجب القانون على قلم معاوني التنفيذ، عدم إعلان ورقة الحجز؛ إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها، مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة، ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته. (مادة ٣/٣٢٨).

الجزاء المترتب على تخلف بيانات إعلان الحجز:

نص المشرع صراحة في المادة (٢/٣٢٨) على بطلان الحجز؛ إذا لم تشتمل ورقة الحجز على البيانات الواردة في البنود ١ و ٢ و ٣، وهذه البيانات هي: صورة السند الذي يجري الحجز بمقتضاه، وأصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده ومصاريفه، ونهى المحجوز لديه عن الوفاء أو التسليم مع تعيين المحجوز عليه. ولا يتعلق هذا البطلان بالنظام العام؛ ومن ثم يزول إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً (مادة ٢٢ مرافعات). أما غير ذلك من البيانات فلم ينص المشرع على البطلان جزاء

(١) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٤٨٨ - د. طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ، ص ٤٨١.

(٢) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٥١٧.

مخالفتها، ومن ثم فإن إغفال البيان الرابع أو تعيينه (الموطن المختار)، يؤدي إلى إعمال المادة (١٢) مرافعات، وذلك بجواز الإعلان في قلم كتاب المحكمة، كما أن إغفال البيان الخامس (التكليف بالتقرير)، يرتب عدم التزام المحجوز عليه بإيداع التقرير ما لم يتم تكليفه بذلك بإعلان لاحق مستقل.

ثانيا: إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه:

أوجبت المادة (٣٣٢) مرافعات على الحاجز أن يقوم بإبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه، بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه، مع تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه.

ويلاحظ أن المشرع عبر هنا بتعبير الإبلاغ، وعبر عن الإجراء السابق للمحجوز لديه بالإعلان؛ لأن الإجراء الذي يتم للمحجوز لديه هو "إعلان" بالمعنى الفني الدقيق، أما الإجراء الذي يتم للمحجوز عليه فهو "إبلاغ" ويقال له أحيانا "إخبار".

فالمقصود هنا مجرد إنهاء خبر إلى المدين عن الحجز الذي تم لدى الغير، وإحاطته علما بهذا الحجز، كونه المدين الملتزم بالدين، ولعل في إبلاغه بالحجز ما يدفعه إلى استئجار خطورة الإجراء الذي تم وما يتبعه من إجراءات للتنفيذ على أمواله لدى الغير وبيعها، فيبادر بسداد ما عليه اختيارا قبل التنفيذ الجبري، وليعلم أيضا السبب الذي لأجله امتنع المحجوز لديه عن الوفاء له بما لديه عنده^(١).

وقد أوجب القانون أن يتم هذا الإبلاغ خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان الحجز إلى المحجوز لديه، ورتب القانون على مخالفة هذا الميعاد، اعتبار الحجز كأن لم يكن (مادة ٢/٣٣٢)، وهو جزاء مقرر لمصلحة المحجوز عليه.

ثالثا: رفع دعوى صحة الحجز: (إحالة):

يجب على الحاجز خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان الحجز للمحجوز لديه، أن يرفع إلى المحكمة المختصة دعوى بثبوت الحق وصحة الحجز؛ وإلا اعتبر الحجز

(١) المستشار. محمد عزمي البكري، الحجز القضائي على المنقول، ص ٥٤٠.

كأن لم يكن، وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتتظر فيهما معا. (مادة ٣٣٣ مرافعات).
وقد سبق أن تناولنا هذه الدعوى عند حديثنا عن الحجز التحفظي، فنحيل إلى ما سبق في هذا الشأن.

رابعاً: تقرير المحجوز لديه بما في ذمته:

رأينا أن هذا الحجز يوقعه الدائن على حقوق مدينه أو منقولاته التي في ذمة الغير أو حيازته بقصد منع هذا الغير من الوفاء للمدين أو تسليمه ما في حيازته من منقولات تمهيدا لاقتضاء حق الحاجز منها أو من ثمنها بعد بيعها؛ ولما كان الحاجز ليست لديه وسيلة خاصة للتحقق مما لمدينه لدى الغير، ولا يستطيع إثبات المديونية بين المحجوز عليه والمحجوز لديه؛ فإن المشرع أعفاه من عبء الإثبات وألقاه على عاتق المحجوز لديه، إدراكاً منه باستقلال العلاقة بين المحجوز عليه والمحجوز لديه، ومن ثم أوجب على المحجوز لديه أن يكشف عن حقيقة هذه العلاقة من خلال التقرير بما في ذمته مع تقديم كافة المستندات المؤيدة لما يقر به^(١).
ونتناول بيان ماهية التقرير والتكليف به وإجراءاته والجزاء المترتب على الإخلال به، وذلك على النحو التالي:

أ- ماهية التقرير بما في الذمة:

التقرير بما في الذمة نظام خاص بحجز ما للمدين لدى الغير يلتزم بمقتضاه المحجوز لديه أن يقرر طبقاً للأوضاع التي بينها القانون بما في ذمته للمحجوز عليه. بمعنى أن يتوجه إلى قلم كتاب المحكمة ويقدم بياناً كتابياً بما في ذمته للمحجوز عليه من دين أو منقولات؛ فإذا قرر بأنه مدين له كان الإقرار إيجابياً وإذا قرر بأنه غير مدين له كان الإقرار سلبياً^(٢). ويؤدي هذا التقرير فائدة مهمة في بيان محل الحجز

(١) د. أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ، ص ٥٤٠ - د. طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ، ص ٢٩١.

(٢) د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ٥٢٦ - محمد عزمي البكري، ص ٥٧٨.

وتحديد عناصره، وبما يسمح بمعرفة القدر الذي سوف يستوفي منه الحاجز دينه، أو المنقولات التي سيتم بيعها واستيفاء دينه من قيمتها^(١).

ب- التكاليف بالتقرير وميعاده:

أوجب القانون أن يقوم الحاجز بتكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته، وأن يرد هذا التكليف كبيان في إعلان الحجز (مادة ٣٢٨)، وإذا لم يتضمن إعلان الحجز هذا البيان، فلا يترتب على ذلك بطلان الحجز؛ وإنما يكون من الجائز إجراء هذا التكليف بورقة مستقلة لاحقة لإعلان الحجز؛ فإذا أغفل الحاجز هذا البيان ولم يكلف المحجوز لديه بالتقرير بورقة مستقلة؛ فإن المحجوز لديه لا يكون ملزماً بواجب التقرير. ولا يتوقف هذا الواجب الإجرائي -التقرير بما في الذمة- على حصول الحاجز على السند التنفيذي؛ وإنما يجب على المحجوز لديه التقرير بما في ذمته حتى قبل حصول الحاجز على هذا السند بمجرد تكليفه به بورقة الإعلان وخلال الميعاد المقرر، وذلك خلافاً لما كان عليه قانون المرافعات القديم، والذي كان يشترط لقيام المحجوز لديه بواجب التقرير أن يكون بيد الحاجز سنداً تنفيذياً، ولكن القانون الحالي عدل عن هذا الاتجاه.

وعلى هذا فبمجرد تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته، وجب عليه القيام بذلك حتى ولو لم يكن مع الحاجز سند تنفيذي، أو كان المحجوز لديه معتقداً براءة ذمته، أو كان هناك نزاع حول الدين بينه وبين المحجوز عليه، حتى ولو كان هذا النزاع شائعاً ويعرفه الحاجز أو كان يجب عليه معرفته^(٢).

وإذا تعددت الحجوز تحت يد الغير فإنه يكلف بالتقرير في كل مرة يعلن فيها بحجز جديد، نظراً لاستقلال الحجوز المتعددة^(٣)، بمعنى أن المحجوز لديه ملزم بالتقرير بما في ذمته في كل مرة يعلن فيها بحجز جديد ويكلف فيه بالتقرير، وإذا

(١) د. عزمي عبدالفتاح، قواعد التنفيذ الجبري، ص ٥٢٤.

(٢) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٥٣٧.

(٣) د. رمزي سيف، إجراءات التنفيذ، ص ٣١٤.

تعددت الحجوز قبل قيامه بواجب التقرير فمن الممكن أن يقدم تقريراً واحداً بالنسبة لهذه الحجوز جميعاً، وإذا قدم المحجوز لديه التقرير بما في الذمة ثم وقع حجز جديد فإنه يستطيع الإحالة إلى التقرير السابق تقديمه مادام الحجز التالي قد أوقع على ذات المال السابق حجزه بلا تغيير^(١).

وقد أوجب القانون أن يقدم المحجوز لديه التقرير بما في الذمة إلى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز وتكليفه بالتقرير (مادة ٣٣٩ مرافعات)، أو من تاريخ تكليفه به في ورقة مستقلة.

ويلتزم المحجوز لديه بهذا الواجب ولو لم يكن مديناً للمحجوز عليه، أو لم يكن حائزاً لمنقولات له، وسواء كان سبب عدم المديونية انتفاء الدين أصلاً أو انقضاؤه لأي سبب كالوفاء والحوالة وغيرها، وعليه في هذه الحالة أن يقرر بعدم مديونيته، فلا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه (مادة ٣/٣٣٩ مرافعات).

كما يلتزم بواجب التقرير ولو كان يعتقد بطلان الحجز، طالما لم يصدر حكم بهذا البطلان، وعليه حين يعتقد ذلك أن يتمسك بهذا البطلان في التقرير ذاته، وإلا يعتبر متنازلاً عن حقه في التمسك بالبطلان إعمالاً لنص المادة (٢٢) مرافعات.

ج- مشتملات التقرير بما في الذمة:

التقرير بما في الذمة قد يكون إيجابياً مثبتاً لمديونية المحجوز عليه لدى المحجوز لديه، وقد يكون سلبياً نافياً لها، وفي كلا الحالتين يجب أن يكون التقرير مفصلاً^(٢).

١- فإذا كان التقرير إيجابياً، فقد أوجبت المادة (١/٣٣٩) أن يتضمن التقرير مقدار الدين، وسببه، وسنده، وجميع الحجوز الموقعة تحت يد المحجوز لديه. وإذا كانت للمدين منقولات تحت يده، وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها.

٢- وإذا كان التقرير سلبياً، وجب على المحجوز لديه أن يبين الدين الذي كان تفصيلاً وأسباب انقضائه.

(١) د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ٣٣٢- نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٥٣٧.

(٢) د. طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ، ص ٢٩٨.

وفي جميع الأحوال يجب عليه أن يودع مع التقرير المستندات المؤيدة له أو صورا منها موقعا عليها منه.

وإذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من كان يمثلته، كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه بالتقرير بما في الدمة خلال خمسة عشر يوما.

استثناء خاص بالحجز تحت يد الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة:

أوردت المادة (٣٤٠) مرافعات استثناء خاصا فيما يتعلق بالتقرير بما في الدمة، في حالة الحجز على ما للمدين تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة، حيث أوجب عليها بدلا من التقرير بما تحت يدها في قلم كتاب المحكمة؛ أن تعطي للحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.

وذلك نظرا لكثرة الحجز التي توقع تحت يد المصالح الحكومية، ومن ثم رأى المشرع أن يجنب هذه المصالح مشقة التوجه إلى قلم الكتاب للتقرير في كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها، وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقاليم، فأعفى هذه المصالح من اتباع إجراءات التقرير، وتقوم الشهادة التي تعطي منها مقامه، ومن ثم يجب أن تتضمن الشهادة البيانات الواجبة في التقرير^(١).

د - طبيعة التقرير وقوته^(٢):

يعد التقرير بما في الدمة إقرار ملزم للمحجوز لديه فقط ولا تمتد قوته الملزمة إلى المحجوز عليه، ولا يملك المحجوز لديه الرجوع فيه إلا في الحدود التي يجوز الطعن فيها على الإقرار، وهو ليس إقرار قضائي؛ لأنه يتم خارج مجلس القضاء؛ وإذا يتم بورقة رسمية؛ فلا يجوز إثبات عكس ما جاء فيه إلا بالادعاء بالتزوير.

(١) د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٢٢٤.

(٢) د. أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ، ص ٥٤٧ - ٥٤٨.

هـ - حالات الإغفاء من التقرير بما في الذمة:

إذا كان المحجوز لديه ملتزما بالتقرير بما في الذمة في جميع الأحوال كما رأينا، طالما أن الحاجز قد كلفه بواجب التقرير؛ فإن هناك حالات نص عليها القانون يعفى فيها المحجوز لديه من التقرير بما في ذمته، ذلك أن الغرض من التقرير يتحقق بإجراء آخر في هذه الحالات، وهي:

١- الإيداع مع التخصيص:

ويكون ذلك وفق ما قرره المادة (٣٠٢) مرافعات، فيجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع، إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف، يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوزا على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ المودع. وسواء تم الإيداع والتخصيص من المحجوز لديه أو المحجوز عليه، فإنه يترتب عليه انتهاء أثر الحجز بالنسبة للمحجوز لديه، ومن ثم لا يكون ملزما بالتقرير بما في ذمته.

٢- الإيداع بإذن من قاضي التنفيذ:

وذلك وفقا للمادة (٣٠٣) مرافعات، حيث يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. ويصبح المبلغ المودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.

وفي هذه الحالة أيضا يزول أثر الحجز عن الأموال المحجوز عليها لدى المحجوز لديه، ولا يكون ملزما بالتقرير بما في ذمته.

٣- الإيداع من المحجوز لديه وبغير تخصيص (إيداع الوفاء):

وذلك إذا قام المحجوز لديه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحجوز عليه، بإيداع ما في ذمته خزانة المحكمة التي يتبعها. وهذا الإيداع لا يكون مصحوبا

بتخصيص ما يودع للوفاء بدين الحاجز، ومع ذلك فإنه يؤدي إلى إعفاء المحجوز لديه من واجب التقرير بما في ذمته^(١).

وقد نصت على هذه الحالة المادة (٣٣٦) مرفعات، بنصها على أن "الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه، ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء. ويكون الإيداع في خزنة المحكمة التابع لها المحجوز لديه".

ونظمت المادة (٣٣٧) ما يتعلق بهذا الإيداع، فأوجبت انتقال الحجز على المبالغ التي تودع في هذه الحالة، وأوجبت على قلم كتاب المحكمة التي تم الإيداع في خزانتها إخبار كلا من الحاجز والمحجوز عليه بالإيداع الذي تم من المحجوز لديه، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخه، على أن يتم هذا الإخبار بكتاب مصحوب بعلم الوصول. واشترطت المادة ذاتها لصحة هذا الإيداع وترتيب آثاره في زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وإعفاء المحجوز لديه من واجب التقرير بما في ذمته، ما يلي:

١- أن يكون الإيداع مصحوبا ببيان موقع عليه من المحجوز لديه، يذكر فيه الحجز التي وقعت تحت يده وتواريخها وأسماء الحاجزين وصفاتهم وموطنهم، والسندات التي تم الحجز بناء عليها، والمبالغ المحجوز من أجلها.

٢- أن يكون المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز قبل الإيداع. ونصت المادة صراحة على أن هذا الإيداع يغني عن التقرير بما في الذمة، إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز. وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف، جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تكليفه بذلك.

و- دعوى المنازعة في التقرير:

الهدف من التقرير هو الكشف عن حقيقة دين المحجوز عليه لدى المحجوز لديه وإيضاح علاقة المديونية، حتى يتمكن الحاجز من الإلمام بكل الظروف المحيطة بها؛

(١) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٥٣٩.

فإما أن يثق بما جاء في التقرير، وإما أن ينازع في صحة بياناته^(١)، ذلك أن له إذا لم يقتنع بصحة التقرير أن ينازع فيه، وللمحجوز عليه أيضا أن ينازع في صحة التقرير المقدم من المحجوز لديه إذا قرر ما يخالف حقيقة علاقة المديونية بينهما.

وتتم هذه المنازعة في التقرير من خلال دعوى تسمى "دعوى المنازعة"، وهي الدعوى التي يرفعها الحاجز أو المحجوز عليه ضد المحجوز لديه الذي أقر بما في ذمته تقريراً لا يسلم به الحاجز أو المحجوز عليه، وذلك بهدف تبيان حقيقة العلاقة بين المحجوز عليه والمحجوز لديه، وللحصول على حكم بصحة حقوق المحجوز عليه^(٢).

وقد نصت على هذه الدعوى المادة (٣٤٢) مرافعات، بنصها على أنه "ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه".

ومن ثم فإن هذه الدعوى يختص بها نوعياً ومحلياً قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته موطن المحجوز لديه، باعتباره المدعى عليه في هذه الدعوى، سواء كان المدعي فيها الحاجز أو المحجوز عليه. وتقدر قيمتها بقيمة الحق المطلوب الحكم بثبوته في ذمة المحجوز لديه، ولا يعتد في هذا التقدير بدين الحاجز لدى المحجوز عليه؛ إذ هو ليس محل نزاع في هذه الدعوى^(٣).

وترفع الدعوى بالإجراءات المعتادة، بإيداع صحيفة قلم كتاب محكمة التنفيذ التابع لها موطن المحجوز لديه، ويكون الحكم الصادر فيها حجة على أطراف الدعوى فقط.

ز - الإخلال بواجب التقرير والجزاء المترتب عليه:

يتضح مما سبق أن المحجوز لديه يلتزم بواجب إجرائي مهم مقتضاه -بعد الامتناع عن الوفاء بما في ذمته للمحجوز عليه- أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب المحكمة الجزئية التي يقع موطنه في دائرتها، في ميعاد محدد ووفقاً لإجراءات محددة؛ فإذا أخل

(١) د. أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ، ص ٥٤٨.

(٢) المستشار. محمد عزمي البكري، الحجز القضائي على المنقول، ص ٦١٠.

(٣) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٥١٤.

بهذا الواجب الإجرائي؛ فإن المشرع نص على جزاء يتناسب مع أهمية التقرير من ناحية ومع الضرر الذي يصيب الحاجز من ناحية ثانية، ولا يوقع هذا الجزاء إلا إذا وجدت حالة من حالات الإخلال التي نص عليها المشرع. ومن ثم فإننا نبين حالات الإخلال بواجب التقرير، ثم نتحدث عن الجزاء المقرر على هذا الإخلال، وذلك على النحو الآتي:

١- الإخلال بواجب التقرير بما في الذمة:

- وردت صور هذا الإخلال في المادة (٣٤٣) مرافعات، بنصها على أنه "إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة ٣٣٩ أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير...".
- ووفقا لهذا النص؛ فإن الإخلال بواجب التقرير يحدث في أي حالة من الحالات الآتية:
- عدم تقديم التقرير على الإطلاق: وذلك لأي سبب؛ كأن يعتقد المحجوز لديه عدم مديونيته، فيمتنع عن التقرير.
 - التقرير على نحو مخالف لما أوجبه القانون: كأن يأتي التقرير مبهما أو غامضا لا تتضح منه حقيقة علاقة المحجوز لديه بالمحجوز عليه ولا مقدار الحقوق محل الحجز، ولا طبيعة المنقولات المحجوز عليها وتفاصيلها.
 - عدم التقرير في الميعاد المقرر قانونا: وهو خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان ورقة الحجز إذا تضمنت التكليف بالتقرير، أو من تاريخ التكليف به في ورقة مستقلة.
 - التقرير بغير الحقيقة: وذلك بأن يصور المحجوز لديه علاقته مع المحجوز عليه على خلاف الحقيقة، كأن يقرر أنه لم يكن مدينا، أو أن الدين قد انقضى، أو يقرر دينا أقل من الدين الحقيقي^(١).
 - إخفاء الأوراق الواجب إيداعها لتأييد التقرير: إذ يوجب المشرع أن يودع المحجوز لديه مع التقرير جميع المستندات المؤيدة لتقريره، فإذا أخفى هذه

(١) د. رمزي سيف، إجراءات التنفيذ، ص ٣٢٣.

المستندات، فإنه يكون قد أخل بواجب التقرير. ويشترط في هذه الحالة أن يكون إخفاء الأوراق بقصد إخفاء حقيقة المديونية.

٢- الجزء المترتب على هذا الإخلال:

إذا توفرت حالة من حالات الإخلال بالتقرير على النحو المشار إليه؛ جاز الحكم على المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله، لصالح الحاجز الذي حصل على سند تنفيذي بدينه، وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة، وإلزام المحجوز لديه كذلك بمصاريف هذه الدعوى، وبالتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيريه (مادة ٣٤٣ مرافعات). ويشترط لإعمال هذا الجزء ما يلي:

- أن يطلب الحاجز الحكم بهذا الجزء على المحجوز لديه، ويكون ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة تسمى "دعوى الإلزام"، ويختص بنظرها قاضي التنفيذ التابع له موطن المحجوز لديه باعتباره المدعى عليه فيها. ولم يقيد المشرع هذه الدعوى بميعاد معين، ومن ثم فإن للمدعي (الحاجز) رفعها في أي وقت ما لم يسقط حقه بالتقادم.
- أن يكون هذا الحاجز الذي يطلب الحكم بالجزء قد حصل على سند تنفيذي بحقه لدى المحجوز عليه؛ ويستوي في ذلك أن يكون السند سابقا على إخلال المحجوز عليه بالتقرير أو لا حقا عليه، قبل الحجز أو بعده.
- ألا يكون الحاجز قد اقتضى حقه من المحجوز عليه أو من طريق آخر: ذلك أن هذا الجزء قائم على افتراض مؤداه أن المحجوز لديه تعمد حرمان الحاجز من الحصول على حقه لدى المحجوز عليه؛ فإذا حصل الدائن على حقه هذا، فلا يتصور إلزام المحجوز لديه به مرة ثانية، وإنما يكون له في هذه الحالة أن يرجع على المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات عن الضرر الذي أصابه^(١).

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٥٦١.

- ألا يكون الحجز قد سقط لأي سبب من الأسباب؛ فإذا سقط الحجز فلا محل للإلزام المحجوز لديه بالوفاء بالدين المحجوز لأجله^(١).

وقد أشارت المادة (٣٤٣) إلى أن الحكم بهذا الجزاء، سلطة جوازية للمحكمة، وهي في ذلك تحكم بالجزاء المقرر أو لا تحكم به وفقا لما تتبينه من ظروف الدعوى وملابساتها ومدى أثر سلوك المحجوز لديه في ضوء تقديرها لحسن نيته أو سوءها.

وإذا تعدد الحاجزون وتعددت التقارير بما في الذمة بالنسبة للمحجوز لديه؛ فإن صدور حكم لصالح حاجز معين، لا يمنع الحاجز الآخر من طلب توقييع هذا الجزاء مرة ثانية على نفس المحجوز لديه إذا خالف واجب التقرير بما في الذمة بالنسبة له^(٢).

وإذا اقتضى الحاجز دينه من المحجوز لديه بناء على حكم في دعوى الإلزام؛ عد ذلك وفاء بدين الحاجز في مواجهة المحجوز عليه، ويحل المحجوز لديه محل الحاجز في الدين الذي له في ذمة المحجوز عليه، فله حينئذ أن يرجع على هذا الأخير بما وفى به للحاجز بعد خصم ما يكون مستحقا للمحجوز عليه عنده^(٣).

المطلب الثالث

إجراءات خاصة ببعض صور حجز ما للمدين لدى الغير

هناك بعض صور لحجز ما للمدين لدى الغير تختلف في إجراءاتها عما تناولناه في المطلب السابق، ونتناول هذه الصور بإيجاز على النحو الآتي:

أولاً: الحجز تحت يد النفس:

تنص المادة (٣٤٩) مرافعات على أنه "يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز.

(١) د. أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ، ص ٥٦١.

(٢) د. رمضان عبدالكريم علام، الوجيز في قواعد التنفيذ الجبري، ص ٣٦٣.

(٣) أستاذي د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٢٣٠.

وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن".

ووفقا لهذا النص فإنه إذا وجد شخصان كل منهما دائن ومدين للآخر، ولم ينقضي أي الدينين بالمقاصة، فإن لكل منهما مصلحة أكيدة على توقيع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون في ذمته للآخر، لكي يمنع خصمه بهذا الحجز من تحويل الدين للغير، فلا يمكن المقاصة بين الدينين بعد ذلك، ويبقى هو ملزما بالوفاء للمحال له، وقد لا يمكنه فيما بعد استيفاء حقه من خصمه بسبب إعساره.

وتظهر هذه المصلحة في صورة أوضح إذا كان دين طالب الحجز غير معين المقدار ودين خصمه معينا، إذ لولا جواز الحجز لكان هذا الطالب ملزما بأن يفي ما عليه فورا، وأن ينتظر تعيين مقدار المطلوب له، وقد يعسر مدينه أثناء مدة الانتظار. وكذلك إذا أوقع شخص ثالث حجزا على أحد الدينين المتقابلين؛ فإن هذا الحجز يمنع بينهما المقاصة التي تتوفر شروطها بعد الحجز، فيكون لمن وقع الحجز تحت يده مصلحة ظاهرة في أن يوقع بموجب حقه حجزا آخر تحت يد نفسه ليزاحم به الحاجز الأول^(١).

وبهذا يكون لكل دائن من الدائنين توقيع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه، وبذلك تجتمع في الحاجز صفتان هما صفة الحاجز وصفة المحجوز عليه، ويكون أشخاص الحجز اثنين بدلا من ثلاثة.

وليس بلامر أن تجتمع صفة الدائن والمدين في كلا الشخصين في وقت واحد؛ فإذا توفرت الصفة في شخص واحد وكان الآخر دائنا فقط؛ فإن الأول يستطيع توقيع الحجز تحت يد نفسه، ويستفاد ذلك من عبارة نص المادة (١/٣٤٩).

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/٢٥١.

محل الحجز تحت يد النفس وسنده:

يرد الحجز تحت يد النفس على الديون في الذمة أو المنقولات في حيازة الحاجز، كما هو الشأن في القاعدة العامة في حجز ما للمدين لدى الغير، وذلك إذا كان الدين المحجوز لأجله محقق الوجود وحال الأداء، ولا يشترط أن يكون معين المقدار وإنما يشترط حينئذ اللجوء إلى قاضي التنفيذ لتعيين مقدار الدين بشكل مؤقت.

وأما عن سند هذا الحجز فإنه تنطبق عليه القواعد الخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير، فيشترط أن يكون بيد الدائن الحاجز تحت يد النفس، سندا تنفيذيا أو حكما غير نافذ؛ فإن لم يكن هذا ولا ذاك فلا بد من إذن قاضي التنفيذ بإجراء الحجز، وإذا كان الدين المحجوز لأجله مما ينطبق عليه نظام أوامر الأداء، فيجب الحصول على إذن الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء.

إجراءات الحجز تحت يد النفس:

من المؤكد أنه لا حاجة في هذا الحجز إلى إعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه، على النحو المقرر في حجز ما للمدين لدى الغير، لأن المحجوز لديه هنا هو الحاجز نفسه، ومن ثم فلا يتصور إعلان نفسه، ولذلك نص المشرع على أن يكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز.

وإن كنا نرى هنا عدم دقة صياغة المادة (١/٣٤٩) في هذا الشأن، فليس من المتصور مثلا أن يتضمن الإعلان نهي المحجوز لديه لنفسه عن الوفاء للحاجز، ولا أن يكلف نفسه بالتقرير بما في الذمة، ولا أن يعين موطنا مختارا لنفسه في البلدة التي يقيم فيها؛ ولذا نرى أنه كان من الأدق أن ينص المشرع على البيانات الواجب ذكرها في الإعلان في هذه الحالة دون أن يحيل إلى بيانات ورقة إبلاغ الحجز، للاختلاف بين الحالتين.

كما أن الحجز هنا ليس بحاجة إلى نظام التقرير بما في ذمة المحجوز لديه، لأن هذا النظام أساسه افتراض جهل الحاجز بما يكون للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه، والأمر هنا بطبيعة الحال على خلاف ذلك، ولهذا كان من الأولى أن ينص المشرع في المادة المشار إليها على وجوب بيان محل الحجز على وجه دقيق.

هذا ونؤيد ما ذهب إليه الفقه القانوني من أنه إذا كان محل الحجز تحت يد النفس منقولاً، فلا مانع من سلوك طريق حجز المنقول لدى المدين، حيث تختفي هنا علة اتباع هذا الطريق إذا كان المنقول في حيازة الغير، وهي إيذاء سمعة المحجوز لديه واحتمال الحجز على مال من أمواله^(١).

وقد أوجب القانون في الحجز تحت يد النفس، أن يرفع الحاجز دعوى صحة الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان المدين بالحجز؛ وإلا أصبح الحجز كأن لم يكن.

ثانياً: حجز ما للمدين لدى الغير استيفاء لحق ثابت بالكتابة (إحالة):

إذا كان الدين المحجوز لأجله مما ينطبق عليه نظام أوامر الأداء، فيجب اتباع القواعد المقررة في هذا الشأن، والتي سبق تناولها في الحجز التحفظي، فنحيل إليها.

ثالثاً: الحجز تحت يد الحكومة:

سبق أن أشرنا إلى أنه يجوز للدائن حجز ما يكون لمدينه تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها، وفي هذه الحالة تعفى المصلحة الحكومية المحجوز تحت يدها من التقرير بما في ذمتها، وعليها أن تقدم للحاجز شهادة بما تحت يدها، وتقوم هذه الشهادة مقام التقرير بما في الذمة. وقد أوجب القانون إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها أن يتم إعلان المحجوز لديهم في هذه الحالة لأشخاصهم (مادة ٣٢٩ مرافعات).

والحجز الواقع تحت يد مصلحة من هذه المصالح أو الهيئات لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه الحالة باستبقاء الحجز؛ فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات، اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه. ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزنة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها. (مادة ٣٥٠ مرافعات).

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٥٣٩.

المبحث الثاني

الاعتراض على حجز ما للمدين لدى الغير

قد يشوب حجز ما للمدين لدى الغير بعض العيوب، سواء تعلقت هذه العيوب بأصل الحق أو بالمال المراد الحجز عليه أو بإجراءات الحجز ذاتها^(١).

فقد يحدث أن يكون الحجز مشوبا بالبطلان لعيب يتعلق بالشكل أو يتعلق بالموضوع، كأن يوقع بغير إذن من القاضي في حالة يجب فيها استئذانه، أو كأن تخلو ورقة إعلان الحجز من بيان من البيانات الوجوب ذكرها فيها، أو لا يتم إبلاغ الحجز للمحجوز عليه في الميعاد المقرر، أو لا ترفع دعوى صحة الحجز في حالة من الحالات التي يجب رفعها فيها، أو يصدر الإذن بالحجز بالمخالفة للاختصاص، كما لو صدر من قاضي التنفيذ في دين ينطبق عليه نظام أوامر الأداء، أو أن يوقع الحجز اقتضاء لدين غير محقق الوجود أو غير حال الأداء، أو يوقع على مال من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها، أو بعد وفاء المحجوز عليه بدين الحاجز^(٢).

ولما كانت القاعدة أن الإجراء يظل صحيحا منتجا لآثاره إلى أن يحكم ببطلانه؛ فإن المحجوز لديه يظل مقيدا بعدم الوفاء للمحجوز عليه إلا برضا الحاجز أو بعد الحكم ببطلان الحجز، ويكون للمحجوز عليه الحق في التظلم من إذن القاضي بالحجز، في الحالات التي يوقع الحجز بإذن منه، ويكون للمحجوز لديه فرصة الاعتراض على الحجز أثناء نظر دعوى صحة الحجز، وقد يهمل الحاجز موالة هذه الدعوى أو يعتمد تعطيل الفصل فيها، فيبقى الحجز قائما منتجا لآثاره ومعطلا للمال المحجوز عليه؛ ولذلك حدد المشرع وسائل للاعتراض على حجز ما للمدين لدى الغير والتخلص من آثاره، وهذه الوسائل هي: دعوى رفع الحجز، ودعوى عدم الاعتداد بالحجز^(٣).

(١) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٥٦٢.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٥٧٤.

(٣) المرجع السابق، نفسه.

المطلب الأول

دعوى رفع الحجز

"يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه، ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه، ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها"^(١).

ويتضح من هذه المادة أنه يجوز للمحجوز عليه أن يعترض على حجز أمواله لدى الغير وأن يلجأ إلى قاضي التنفيذ طالبا رفع هذا الحجز بدعوى تسمى "دعوى رفع الحجز"، ونتناول بيان هذه الدعوى والأحكام المتعلقة بها فيما يلي:

أولاً: تعريف دعوى رفع الحجز:

دعوى رفع الحجز هي الدعوى التي يرفعها المحجوز عليه في حجز ما للمدين لدى الغير على الحاجز بطلب الحكم له برفع الحجز بقصد التخلص من الحجز وآثاره والتمكن من تسلم المال المحجوز من المحجوز لديه، وذلك عندما يكون الحجز باطلا لعب من العيوب التي تبطله سواء كان العيب شكليا يتصل بالإجراءات الشكلية اللازمة لصحة الحجز أم كان عيبا موضوعيا يتصل بالشروط الموضوعية كالأركان اللازمة لصحة الحجز^(٢).

ويتضح من هذا التعريف أن دعوى رفع الحجز تعد من منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير؛ فإذا شاب الحجز عيب مبطل طبقا للقواعد القانونية؛ فإن المحجوز عليه يستطيع التمسك بهذا البطلان في صورة دعوى مبتدأة يطلب فيها رفع الحجز ليتمكن من استرداد أمواله المحجوز عليها^(٣).

وبطبيعة الحال لا يجوز رفع هذه الدعوى إذا كانت دعوى صحة الحجز ما زالت قائمة سواء أمام محكمة أول درجة أو في الاستئناف؛ إذ يملك المحجوز عليه في

(١) المادة (٢٣٥) مرفعات.

(٢) د. رمزي سيف، إجراءات التنفيذ، ص ٣٦٣- د. نبيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٥٦٣.

(٣) د. رمضان عبدالكريم علام، الوجيز في التنفيذ الجبري، ص ٤٣٥.

الحالتين التمسك ببطلان الحجز. كما أنه إذا قضت المحكمة في دعوى صحة الحجز بصحة الإجراءات؛ فلا يجوز رفع دعوى رفع الحجز بعد ذلك والادعاء ببطلان هذه الإجراءات، وذلك إعمالاً لقاعدة حجية الأحكام؛ اللهم إلا إذا كان ذلك لسبب جديد نشأ بعد حكم صحة الحجز^(١).

ثانياً: الخصوم في الدعوى:

ترفع هذه الدعوى من المدين المحجوز عليه ويكون هو المدعي فيها، ويرفعها على الحاجز ويكون هو المدعى عليه فيها، أما المحجوز لديه؛ فلم يستلزم المشرع اختصاصه، باعتبار أن موضوع الدعوى ينصب على العلاقة بين المحجوز عليه والدائن الحاجز على أمواله، ومع هذا يجوز للمحجوز عليه أن يقوم بإبلاغ المحجوز لديه برفع هذه الدعوى، ويرتب هذا الإبلاغ أثره في منع المحجوز لديه من الوفاء للحاجز إلى حين الفصل فيها^(٢).

ثالثاً: المحكمة المختصة بالدعوى:

حددت المادة (٣٣٥) المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى والفصل فيها، بنصبها على رفعها أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه المحجوز عليه، ومن ثم فإن الاختصاص بها نوعياً ينعقد لقاضي التنفيذ، ومحلياً قاضي التنفيذ التابع له موطن المحجوز عليه (المدعي)، وذلك خروجاً على القاعدة العامة في الاختصاص المحلي التي تقضي باختصاص محكمة موطن المدعى عليه.

رابعاً: إجراءات رفع الدعوى:

ترفع دعوى رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ المختص بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أي بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التنفيذ، ويكون ميعاد الحضور فيها ثمانية أيام وفقاً لقواعد الحضور المقررة أمام المحكمة الجزئية.

(١) د. أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ، ص ٥٢٤ و ٥٧٦.

(٢) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٥٤٣.

خامسا: الأثر المترتب على رفع الدعوى:

لا يترتب على رفع هذه الدعوى أثر بالنسبة لإجراءات التنفيذ، فلا يؤدي رفعها إلى وقف إجراءات التنفيذ، وإنما يترتب على إبلاغ المحجوز لديه بها أثر يتمثل في منعه من الوفاء للحاجز بما لديه، حتى يتم الفصل في الدعوى وصدر حكم ببطلان الحجز أو رفض الدعوى^(١).

وإذا قام المحجوز لديه بالوفاء للحاجز، رغم إبلاغه بدعوى رفع الحجز؛ فإنه يكون ملزما بما أوفاه في مواجهة المحجوز عليه إذا صدر حكم في الدعوى ببطلان الحجز. أما إذا رفع المحجوز عليه الدعوى ولم يبلغ المحجوز لديه بها، فقام الأخير بالوفاء للحاجز؛ فإن هذا الوفاء يكون مبرئا لزمته في مواجهة المحجوز عليه بقدر ما وفى به، ويشترط للاعتداد بالوفاء أن يكون قد تم بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما في الذمة^(٢)، حيث نصت المادة (٣٤٤) على أنه "يجب المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٨٥)^(٣) قد روعيت".

سادسا: الحكم في الدعوى:

تعد دعوى رفع الحجز منازعة موضوعية في التنفيذ، ومن ثم فإن قاضي التنفيذ يفصل فيها بحكم موضوعي يحسم النزاع حول صحة إجراءات الحجز، ويخضع هذا الحكم للقواعد العامة في الطعن على الأحكام. ويؤدي الحكم الصادر في الدعوى إلى زوال الحجز عن الأموال المحجوزة إذا صدر ببطلان الإجراءات، أو إلى بقاء الحجز واستمرار الإجراءات إذا حكم برفض الدعوى.

(١) أستاذي د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٢٣٤.

(٢) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٥٤٣.

(٣) وتنص هذه المادة على أنه "لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل".

المطلب الثاني

دعوى عدم الاعتداد بالحجز

فضلا عن حق المحجوز عليه في الاعتراض على الحجز عن طريق دعوى رفع الحجز بما تمثله من حماية موضوعيه، على النحو الذي بيناه في المطلب السابق؛ فإنه "يجوز لقاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك في الحالات الآتية:

- ١- إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو أمر.
- ٢- إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة ٣٣٢ ، أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في المادة ٣٣٣.

٣- إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقا للمادة ٣٠٢". (م ٣٥١ مرافعات).

ويكون ذلك وفقا ما أجازاه المشرع للمحجوز عليه من رفع دعوى مستعجلة تسمى "دعوى عدم الاعتداد بالحجز"، للحصول على الحماية القانونية بصفة مؤقتة بالإذن له بقبض الدين من المحجوز لديه على الرغم من الحجز وآثاره.

أولاً: تعريف دعوى عدم الاعتداد بالحجز:

دعوى عدم الاعتداد بالحجز، هي الدعوى التي يرفعها المحجوز عليه في مواجهة الحاجز بعد توقيع الحجز، ويطلب فيها الحكم مؤقتا بعدم الاعتداد بالحجز واعتباره كأن لم يكن والإذن له بقبض الدين من المحجوز لديه^(١).

وهي بذلك دعوى وقتية يرفعها المدين المحجوز عليه يطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز -ودون مساس بالموضوع- نظرا لفقد الحجز ركنا من أركانه أو لكونه ظاهر

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٦/٢٥٨.

البطلان، وذلك لحين الفصل في دعوى بطلان الحجز، دون أن يؤثر ذلك على الحكم في المنازعة الموضوعية^(١).

وإذا كان المشرع في المادة (٣٥١) مرافعات، لم يتناول إلا طلب المحجوز عليه الإذن بقبض الدين من المحجوز لديه، وهو ما قد يوحي بأن نطاق النص حالة توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على ديون المحجوز عليه فحسب؛ فإن هذه الدعوى يجوز رفعها لطلب الإذن بتسليم المنقولات المحجوزة في حالة توقيع الحجز على منقولات المدين المادية لدى الغير، باعتبار أن الطلب في الدعوى هو عدم الاعتداد بالحجز والحد من آثاره بصفة مؤقتة، وهو ما يجوز أيا كانت طبيعة المال المحجوز^(٢).

ثانيا: حالات رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز:

بين المشرع حالات رفع الدعوى في المادة (٣٥١)، وهي ليست واردة على سبيل الحصر؛ وإنما هي أهم الحالات التي ترفع فيها هذه الدعوى، وهي:

١- إذا وقع الحجز بغير سند، أي لم يكن بيد الدائن الحاجز سندا يبيح له حجز ما لمدينه لدى الغير، وقد سبق أن بينا ضرورة توفر هذا السند كشرط لإجراء الحجز؛ فإذا وقع دون أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي، أو حكم غير نافذ، أو أمر بتوقيع الحجز؛ فإن الحجز يكون باطلا ويكون للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز والإذن له بقبض الدين من المحجوز لديه أو الحصول على المنقول في حيازته.

٢- إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه خلال ثمانية أيام من تاريخ حجز ما له لدى المحجوز لديه (مادة ٣٣٢)، باعتبار أن هذا إجراء واجب رتب القانون على مخالفته بطلان الحجز؛ فيكون للمحجوز عليه حينذاك أن يطلب من القاضي عدم الاعتداد بهذا الحجز والإذن بقبض أو تسلم ما تم الحجز عليه.

(١) د. رمضان عبدالكريم علام، الوجيز في التنفيذ الجبري، ص ٤٢٧ - المستشار. محمد عزمي البكري، الحجز القضائي على المنقول، ص ٦٨٠.

(٢) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٥٤٦- د. طلعت دويدار، النظام القانوني للتنفيذ، ص ٣٢٣.

٣- إذا لم يرفع الحاجز دعوى صحة الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ حجز ما لمدينه لدى الغير في الحالات التي يجب فيها رفع هذه الدعوى (مادة ٣٣٣)، وهو من الواجبات الإجرائية التي رتب القانون على مخالفتها بطلان الحجز، ومن ثم يكون للمحجوز عليه أن يطلب عدم الاعتداد بهذا الحجز.

٤- إذا تم الإيداع والتخصيص، وذلك بإيداع مبلغ مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف وتخصيصه للوفاء بها (مادة ٣٠٢)، وبذلك يزول الحجز عن الأموال المحجوزة لدى الغير، ويكون للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ الإذن له بقبض المال المحجوز عليه.

ثالثاً: الخصوم في دعوى عدم الاعتداد بالحجز:

ترفع هذه الدعوى من المحجوز عليه ضد الحاجز، ولا يشترط اختصام المحجوز لديه فيها، ولكن الحكم الصادر بعد الاعتداد بالحجز يعتبر حجة على المحجوز لديه؛ فيلتزم بدفع الدين أو تسليم المنقولات للمحجوز عليه^(١).

رابعاً: إجراءات الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها:

ترفع الدعوى بالإجراءات المعتادة، وينعقد الاختصاص النوعي بنظرها لقاضي التنفيذ دون غيره، باعتبارها منازعة من منازعات التنفيذ الوقتية، ولم يحدد المشرع قاضي التنفيذ المختص بها محلياً على النحو الذي سبق في دعوى رفع الحجز؛ ومن ثم يكون الاختصاص منعقداً لقاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته موطن الحاجز باعتباره المدعى عليه في هذه الدعوى، وذلك إعمالاً للقاعدة العامة في الاختصاص المحلي.

خامساً: الأثر المترتب على الدعوى والحكم فيها:

على الرغم من كون الدعوى منازعة وقتية في التنفيذ؛ إلا أنه لا يترتب عليها أثر موقوف للتنفيذ، على خلاف القاعدة العامة في إشكالات التنفيذ الوقتية. والحكم الصادر فيها باعتبارها دعوى مستعجلة، هو حكم مستعجل، ويكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وفي جميع الأحوال يكون قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية.

(١) أستاذي د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٢٣٥.

المبحث الثالث

الآثار المترتبة على حجز ما للمدين لدى الغير

المطلب الأول

آثار الحجز بالنسبة للمحجوز لديه

١ - قطع التقادم:

يترتب على إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه قطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز لديه في مواجهة المحجوز عليه، وذلك عملاً بالمادة ٣٨٣ مدني، ويترتب هذا الأثر ولو لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي^(١).

٢ - منع المحجوز لديه من الوفاء للمحجوز عليه وامتناع المقاصة التي تتوافر شروطها بعد الحجز:

أوجبت المادة ٣٢٨ مرافعات أن تشتمل ورقة الحجز على نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه، وعلى ذلك فيمتنع على المحجوز لديه الوفاء بدينه للمحجوز عليه، وحيث امتنع هذا الوفاء يمتنع أيضاً على المحجوز لديه أن يتمسك بالمقاصة القانونية بين دين المحجوز عليه وأي دين ينشأ للمحجوز لديه في ذمة المحجوز عليه ما دامت هذه المقاصة قد توافرت شروطها بعد الحجز أما المقاصة التي تتوافر شروطها قبل الحجز فتتفد.

تحديد ما يمتنع الوفاء به:

منع المحجوز لديه من الوفاء للمحجوز عليه يعني حبس المال المحجوز لديه، وهو حبس كلي للمال الذي وقع الحجز عليه، وعلى ذلك فإذا وقع الحجز على منقولات، فإنه يمتنع على المحجوز لديه أن يسلمها كلها أو بعضها منها للمدين، حتى ولو كان ثمن الباقي يكفي لسداد دين الحجز، وإذا وقع الحجز على دين معين فيمتنع على المحجوز لديه الوفاء بهذا الدين بعينه وإذا كان للمحجوز عليه ديون آخر فيجوز للمحجوز لديه أن يفي بها للمحجوز عليه . بخلاف ما إذا وقع الحجز بعبارة عامة فإن

(١) نقض مدني جلسة ١٩٧٥/٤/٣٠، الطعن رقم ٣٨٢ لسنة ٣٩ ق .

المنع حينئذ يشمل كل دين ينشأ في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ولو كانت هذه الديون مؤجلة أو غير مستقرة في الذمة لقيام نزاع عليها أو لتعليقها على شرط موقف أو حادث احتمالي.

ويلحق بالدين المحجوز توابعه كالفوائد، وإذا كان الدين يستحق دورياً، كأقساط الأجرة والمرتببات، فإن المنع يشملها ولو كان واجب الأداء بعد التقرير بما في الذمة، بخلاف ما إذا نشأ دين على المحجوز لديه بعد التقرير بما في ذمته فإن المنع لا يشملها ولو حصل نزاع في التقرير بما في الذمة.

جزاء الوفاء بالمال المحجوز:

إذا وُفِّي المحجوز لديه بالمال رغم نهيهِ عن ذلك، فإن هذا الوفاء لا يحتج به على الحاجز، وله أن يلزم المحجوز لديه بالوفاء مرة ثانية، ولكن الوفاء الأول في ذاته صحيح بين المحجوز عليه والمحجوز لديه.

ومع هذا فيحتج على الحاجز بالوفاء في حالات منها:

أ- إذا وقع الحجز على ما لا يجوز حجزه، حيث "يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجو إلى حكم بذلك (المادة ٣٣٨) ويقصد بما لا يجوز حجزه" ما لا يجوز حجزه قانوناً من أجور الخدمة ومرتببات الموظفين ومقررات أرباب المعاشات...^(١)، فإذا امتنع المحجوز لديه من الوفاء رغم ذلك كان للمحجوز عليه اللجوء للقضاء لاستصدار حكم يلزمه بذلك.

ب- إذا كان الوفاء لا يترتب ضرراً بالنسبة للحاجز، كما لو حصل الوفاء لدائن ممتاز عن الحاجز بدين عادي.

٣ - اعتبار المحجوز لديه حارساً على المال المحجوز:

متى وقع الحجز اعتبر المال محجوزاً تحت يد القضاء واعتبر المحجوز لديه حارساً بقوة القانون ويلتزم بالمحافظة على الأموال المحجوزة فإن هو بددها وكان المحجوز أسهماً أو سندات أو غير ذلك من المنقولات عوقب بمقتضى المادة ٣٤١ مرافعات.

(١) نقض مدني جلسة ١٩٥٧/١٢/١٢، الطعن رقم ٣٢٠ لسنة ٢٢ ق .

المطلب الثاني

آثار الحجز بالنسبة للمحجوز عليه

١ - قطع التقادم :

يترتب على الحجز قطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز عليه في مواجهة الحاجز، وذلك عملاً بالمادة ٣٨٣ مدني التي نصت على الحجز بين أسباب قطع التقادم، ويترتب هذا الأثر ولو لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي.

٢ - منع المحجوز عليه من التصرف في المال المحجوز:

يترتب على الحجز منع المحجوز عليه من التصرف في المال المحجوز تصرفاً يضر بالدائن الحاجز، ولما كان الحجز لا يخرج المال من ملك المدين فإن هو تصرف في المال رغم الحجز فإن التصرف في ذاته يعتبر صحيحاً بين أطرافه وإنما لا ينفذ في مواجهة الدائن الحاجز، فإذا أبطل الحجز أو اعتبر كأن لم يكن فإن التصرف هنا يعتبر صحيحاً نافذاً.

ومن ناحية أخرى فيجوز إيقاع حجز جديدة على المال المحجوز نظراً لأن الحجز لا يخرج المال عن ملك المدين، فإذا وقع حجز ثم تصرف المدين في المال المحجوز عليه ثم وقع حجز ثان على هذا المال فإن هذا التصرف لا ينفذ في مواجهة الحاجز الأول لأن توقيع الحجز يمنع المدين من التصرف في المال المحجوز تصرفاً يضر بالدائن، بينما ينفذ هذا التصرف في مواجهة الحاجز الثاني لأنه حينما أوقع الحجز كان المدين قد تصرف في المال المحجوز قبل أن يوقع حجزه.

فالمراد بالمنع من التصرف هنا عدم نفاذ التصرف في المال بعد الحجز، فإن تصرف المدين في المال المحجوز عليه ثم وقع حجز آخر، فإن التصرف يسري في مواجهة الحاجز الثاني، ويعبر عن هذه القاعدة بأن الحبس في حجز ما للمدين لدى الغير هو حبس نسبي، ولما كان المحجوز لديه يتمتع عليه الوفاء للمحجوز عليه بكل المال المحجوز فإن حبس مال المحجوز عليه هنا هو حبس كلي نسبي .

المبحث الرابع

استيفاء الحاجز حقه

لاشك أن غرض الحاجز من حجز أموال مدينه لدى المحجوز لديه (الغير) حصول هذا الحاجز على الدين المحجوز لأجله، فحصول الحاجز على حقه هو خاتمة المطاف في هذا الحجز، ونظرا لأن المال المحجوز عليه موجود في حيازة شخص آخر؛ هو المحجوز لديه؛ فإن استيفاء الحق يختلف في بعض الإجراءات عن استيفائه في حال الحجز على المال لدى المدين، ويتفق معها في البعض الآخر، ونبين ذلك فيما يلي:

أولاً: الشروط اللازمة لتحول الحجز إلى حجز تنفيذي:

قلنا إن حجز ما للمدين لدى الغير يبدأ تحفظياً بقصد وضع المال المحجوز تحت يد القضاء، ومن ثم يجيز القانون إجراء هذا الحجز ولو لم يكن بيد الدائن سنداً تنفيذياً أو لم يكن حقه معين المقدار، وأوجب عليه حينئذ الحصول على إذن من قاضي التنفيذ^(١)؛ فإذا تمت إجراءات الحجز على النحو الذي بيناه، وأراد الدائن اقتضاء حقه جبرا من المال المحجوز تحت يد الغير؛ فإنه يجب في هذه الحالة توفر الشروط اللازمة لتحول هذا الحجز من حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي، وهذه الشروط هي^(٢):

١- أن تثبت مديونية المحجوز عليه للحاجز بسند تنفيذي؛ فإذا كان الحجز قد تم بمقتضى هذا السند، فلا يحتاج الحاجز إلى إثبات حقه بوسيلة أخرى، وإذا كان قد أجرى الحجز قبل الحصول على السند التنفيذي، فيجب الحصول عليه، سواء بالحكم في دعوى صحة الحجز، أو بصيرورة الحكم غير النافذ نهائياً وتحوله إلى سند تنفيذي^(٣).

(١) أو من قاضي أمر الأداء في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/٢٤٤.

(٣) أو بتأييد أمر الأداء إذا كان التنفيذ يتم بمقتضى أمر أداء وكان قد تم الطعن فيه.

- ٢- ثبوت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه، بالتقرير الإيجابي بما في الذمة، أو بصدر حكم في المنازعة في التقرير.
- ١- اتخاذ مقدمات التنفيذ وفقا للمادة (٢٨١) مرافعات، بإعلان السند التنفيذي إلى المدين، ومضي يوم بعد الإعلان، وتقديم طلب التنفيذ.
- ٢- أن يقوم الحاجز بإعلان المحجوز عليه بعزمه على استيفاء دينه من المحجوز لديه، قبل صول الوفاء بثمانية أيام على الأقل (مادة ٢٨٥ مرافعات)^(١).
- ٣- أن تمضي خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير المحجوز لديه بما في ذمته (مادة ٣٤٤ مرافعات)، حيث أوجبت هذه المادة مضي هذا الميعاد بعد التقرير بما في الذمة، فلا يجوز للحاجز استيفاء حقه قبل هذا الميعاد، ولا يجوز للمحجوز عليه تعجيل الوفاء قبله، وإلا كان مسئولا قبل المحجوز عليه إذا حكم ببطالان الحجز.
- ٤- ألا يكون المحجوز عليه قد رفع دعوى رفع الحجز، وأبلغها للمحجوز لديه قبل حصول الوفاء (مادة ٣٣٥ مرافعات).
- فإذا توفرت هذه الشروط؛ فإنه يكون للحاجز استيفاء حقه من المال المحجوز لدى المحجوز لديه.

ثانيا: إجراءات استيفاء الحاجز حقه:

بعد التحقق من توفر الشروط المشار إليها، ينتقل الحاجز إلى إجراءات استيفاء حقه من المال المحجوز لدى الغير، وذلك من خلال وسيلتين نص عليهما القانون، وهما: قيام المحجوز لديه بالوفاء، أو إجباره على الوفاء.

أ- قيام المحجوز لديه بالوفاء للحاجز:

إذا توفرت الشروط السابقة؛ فإنه يجب على المحجوز لديه أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما بقي منه (مادة ٣٤٤). فإذا تعدد الحاجزون ولم تكن المبالغ التي قرر بها أو التي حكم بها في دعوى المنازعة كافية للوفاء بحقوقهم، قام المحجوز

(١) ويجري نص هذه المادة على أنه "لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل".

لديه بإيداع هذه المبالغ خزانة المحكمة التي يتبعها مع تسليم قلم الكتاب بيانا بالحجوز الموقعة تحت يده^(١).

وللمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي (مادة ٣٤٥)، والقاضي المختص بتقدير هذه المصاريف هنا، هو قاضي التنفيذ^(٢).

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان حجز ما للمدين لدى الغير قد وقع على منقولات؛ فإن هذه المنقولات تباع بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد (مادة ٣٤٧ مرافعات).

وإذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء، بيع وفقاً لما تنص عليه المادة (٤٠٠) مرافعات^(٣)، ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ التابع له المحجوز لديه، ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق.

ب- إجبار المحجوز لديه على الوفاء للحاجز:

إذا لم يقيم المحجوز لديه بالوفاء للحاجز أو الإيداع في خزانة المحكمة على النحو المقرر قانوناً، كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي، مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه بما في ذمته (مادة ٣٤٦).

(١) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٥٢٠.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٦/٣٤٥.

(٣) ويجرى نصها على أنه "تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه القانون في المادتين السابقتين بواسطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعين قاضي التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان".

الباب الثالث التنفيذ على العقار

الباب الثالث

التنفيذ على العقار

تمهيد وتقسيم:

أولى المشرع إجراءات التنفيذ على العقار عناية خاصة تختلف عن غيرها من إجراءات التنفيذ الأخرى، وذلك لما للعقارات من أهمية اقتصادية واجتماعية، من ناحية، ولما قد يرد عليها من حقوق عينية للغير، من ناحية ثانية.

وقد نظم المشرع هذه الإجراءات في الفصل الثالث من الباب الثالث في الكتاب الثاني لقانون المرافعات (المواد ٤٠١ - ٤٦٨)، وتمر هذه الإجراءات بعدة مراحل، أولها اتخاذ مقدمات التنفيذ وفقا للمادة (٢٨١) مرافعات، ثم الحجز على العقار وفق إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات الحجز على المنقول التي سبق دراستها في الباب الثاني من هذا المؤلف، ثم التمهيد لبيع العقار المحجوز، ثم بيع العقار بعد استيفاء كافة الإجراءات والفصل في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ عليه.

وهذه الإجراءات واجبة الاتباع في بيع العقار، سواء كان عقارا بطبيعته أو عقارا بالتخصيص^(١)، وسواء كان مبنيا أم أرض فضاء، زراعية كانت أم أرض للبناء، فتشمل الإجراءات الأرض وما عليها من بناء أو أشجار ونباتات، كما تشمل ملحقات العقار من الثمار والمزروعات؛ إلا إذا كان قد سبق حجزها باعتبارها منقولا، كما تشمل المنقولات المخصصة لخدمة العقار واستغلاله، كالآلات والمعدات المخصصة لخدمة الأرض الزراعية، والحيوانات والماشية المخصصة لذلك، وكالآلات والعربات والمعدات الصناعية المخصصة لخدمة المصانع، والأثاث والمفروشات بالنسبة للفنادق^(٢).

ونتناول إجراءات التنفيذ على العقار في هذا الباب في أربعة فصول، الأول: حجز العقار، والثاني: التمهيد لبيع العقار، والثالث: بيع العقار، أما الرابع: فنخصه لبيان منازعات التنفيذ على العقار.

(١) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٥٢٠.

(٢) إلا أنه يشترط لصحة الحجز على العقار بالتخصيص تبعا للعقار المخصص لخدمته؛ أن يكونا مملوكين لمالك واحد.

الفصل الأول

حجز العقار

الفصل الأول

حجز العقار

تبدأ إجراءات التنفيذ على العقار بالحجز عليه وفق إجراءات الحجز المقررة قانوناً، وهذه الإجراءات، تختلف عن إجراءات الحجز على المنقول بشكل كبير، كما أنها تباشر في مواجهة المدين مالك العقار، أو في مواجهة غيره ممن يكون مالكا للعقار ولو لم يكن مديناً للحاجز، بمعنى أن إجراءات التنفيذ قد تتم على عقار مملوك للمدين، وقد تتم على عقار مملوك لغيره، وذلك على خلاف القاعدة المقررة في الحجز على المنقول، والتي تشترط أن يكون المنقول المحجوز عليه مملوكاً للمدين.

أما العقار فكما أشرنا قد يكون مملوكاً لشخص آخر غير المدين ورغم ذلك يتم الحجز عليه، كما لو كان مملوكاً للحائز الذي انتقلت إليه ملكية العقار من المدين^(١)، أو مملوكاً لشخص آخر لم تنتقل الملكية إليه من المدين وهو الكفيل العيني الذي يقدم عقاره ضماناً لدين على غيره.

المبحث الأول

حجز عقار المدين

تبدأ إجراءات حجز العقار في مواجهة المدين بإعلان ورقة إلى هذا المدين، تسمى تنبيه نزع الملكية، ويجب بعد ذلك تسجيل هذا الإعلان. ومن ثم فإن حجز العقار يتم بإجراء مركب من عنصرين، الأول: إعلان تنبيه نزع الملكية، والثاني: تسجيل التنبيه.

المطلب الأول

إعلان تنبيه نزع الملكية

أوجبت المادة (٤٠١) مرافعات، أن يتم إعلان تنبيه نزع ملكية العقار لشخص المدين أو في موطنه، وبمقتضى هذا الإجراء تبدأ إجراءات الحجز على العقار ووضعه تحت يد القضاء.

(١) إذا كان للدائن الحاجز حقا عينيا يخوله تتبع العقار.

ولا يعد هذا الإعلان بديلا عن مقدمات التنفيذ؛ إذ يجب في جميع الأحوال اتخاذ هذه المقدمات قبل إعلان التنبيه، وإلا كان الحجز باطلا، كما لا تغني مقدمات التنفيذ عن إعلان التنبيه؛ فهي وإن كانت تشتبه معه بعض الشيء؛ إلا أنها لا تغني عنه. ويعد هذا التنبيه ورقة من أوراق المحضرين، ولذا يجب أن يشتمل على البيانات العامة لهذه الأوراق وفقا للمادة التاسعة مرافعات، فضلا عن البيانات الخاصة بالتنبيه والتي ورد النص عليها في المادة (٤٠١)، وهذه البيانات الخاصة هي:

١- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند^(١).

فالحجز هنا حجز تنفيذي يشترط لصحته أن يكون بيد الدائن سندا تنفيذيا، ويجب أن يبين في التنبيه نوع السند وتاريخه وتاريخ إعلانه للمدين، للتأكد من قيام الحاجز بسبق إعلان السند كمقدمة للتنفيذ، ولم يشترط المشرع أن يشتمل التنبيه على صورة السند، اكتفاء بالصورة التي سبق إعلان المدين بها عند اتخاذ مقدمات التنفيذ.

كما يجب أن يشتمل التنبيه على بيان مقدار دين الحاجز لدى المدين، ولا شك أن هذا الدين معين المقدار سلفا، فالحجز التنفيذي يجرى اقتضاء لدين محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار، وهذا التعيين لمقدار الدين في التنبيه يفيد المدين في معرفة المطلوب منه على وجه التحديد، حتى يتمكن من الوفاء به وتقادي إجراءات الحجز على العقار.

٢- إغذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه وبيع عليه العقار جبرا. ويعد هذا البيان مرادفا لتكليف المدين بالوفاء على النحو الواجب في إعلان السند التنفيذي، وهذا التكرار للإغذار بالوفاء قبل بيع العقار، يظهر حرص المشرع على حث المدين على الوفاء قبل بيع أمواله جبرا، حتى تبدو له جدية الإجراءات وإصرار الدائن على بيع أمواله لاقتضاء حقه، فيبادر المدين إلى الوفاء بها.

(١) نعتقد أن دقة الصياغة توجب أن تكون عبارة المشرع "بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه وتاريخ إعلانه، ومقدار الدين المطلوب الوفاء به".

٣- وصف العقار محل الحجز: سواء كان هذا العقار مبنيا أم غير مبني، عقارا واحدا أم عقارات متعددة، فيجب في جميع الحالات أن يبين الدائن الحاجز على وجه التحديد العقار المطلوب الحجز عليه، من خلال وصفه، وبيان موقعه، ومساحته، وحدوده، وأرقام القطع، وأسماء الأحواض التي يقع فيها العقار وأرقامها، وغير ذلك مما يفيد في تعيينه بالتطبيق لقانون الشهر العقاري في شأن تحديد وصف العقار. فيجب أن يشتمل التنبيه على نوع العقار، وبيان ما فيه من منقولات مخصصة لخدمته باعتبارها عقارات بالتخصيص تحجز تبعا له.

وإذا لم يكن الدائن على علم بالمعلومات الكافية لوصف العقار؛ فإن عليه أن يستصدر أمرا بالترخيص لمعاون التنفيذ بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار، ولمعاون التنفيذ أن يستصحب من يعاون في ذلك، والأمر الصادر بالإذن بدخول العقار أو عدم الإذن به لا يجوز التظلم منه.

ولم يبين المشرع في المادة (٤٠١) لمن تقدم العريضة والمختص بإصدار الإذن في هذه الحالة، ولذا نرى أن الاختصاص ينعقد لإدارة التنفيذ، عملا بالقاعدة المقررة في المادة (٢٧٤)، والتي أناطت الاختصاص بإصدار الأوامر لإدارة التنفيذ^(١).

٤- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ^(٢).

وقد أوجبت المادة (٤٠١) أن يتم إعلان التنبيه لشخص المدين أو في موطنه، ونصت صراحة على بطلان التنبيه إذا خلا من البيان الأول المتعلق بالسند التنفيذي ومقدار

(١) ولا نعتقد هنا باختصاص قاضي التنفيذ الذي يقع العقار في دائرته، عملا بالمادة (٢/٢٧٦) والتي تنص على أن الاختصاص عند التنفيذ على العقار يكون للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، ذلك أن هذا النص في نظرنا يتعلق بالفصل في منازعات التنفيذ على العقار.

(٢) نصت المادة (١٢) مرافعات على أنه "إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار. وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يبلغ خصمه بذلك صح إعلانه فيه، وتسلم الصورة عن الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة".

الدين المحجوز لأجله، وكذلك البيان الثالث الخاص بوصف العقار، أما البيان الثاني فلا يترتب على تخلفه بطلان التنبيه، وذلك لأن إعلان التنبيه للمدين يتضمن معنى إعداره بوفاء الدين وإلا يباع العقار جبراً، كما أن تخلف البيان الرابع يؤدي إلى إعلان الأوراق في قلم كتاب المحكمة المختصة^(١)، ولا يترتب بطلان التنبيه.

وتجدر الإشارة إلى أن بطلان التنبيه لا يتعلق بالنظام العام؛ وإنما مقرر لمصلحة المدين، ومن ثم يجب أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه^(٢). ولا يغني عن البطلان تحقق الغاية إذ البيان هنا مقصود لذاته، وذلك كما في بيان تاريخ إعلان السند التنفيذي.

ويحصل التمسك ببطلان التنبيه بدفع شكلي يدلي به المدين قبل التكلم في الموضوع، وقبل الرد على الإجراء بما يدل على اعتباره صحيحاً أو قبل القيام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك عملاً بالمادة (٢٢) مرافعات^(٣).

ويترتب على حصول التنبيه على النحو المقرر قانوناً قطع التقادم الساري لمصلحة المدين المحجوز عليه في مواجهة الدائن الحاجز (مادة ٢٣٨ مدني)، ولكن لا يترتب عليه اعتبار العقار محجوزاً؛ وإنما لابد من تسجيل التنبيه لتحقيق هذا الأثر.

المطلب الثاني

تسجيل تنبيه نزع الملكية

لا يترتب إعلان تنبيه نزع الملكية أثراً في اعتبار العقار محجوزاً؛ إلا إذا تم تسجيل هذا التنبيه في مكتب الشهر العقاري الذي يتبعه العقار، ولذلك أوجب القانون على الدائن أن يقوم بعد إعلان التنبيه إلى المدين بتسجيله، فنص في المادة (١/٤٠٢) على أنه "يسجل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه".

(١) ولا شك أن المحكمة المختصة هنا، هي المحكمة التي يقع العقار في دائرتها (مادة ٢/٢٧٦).

(٢) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٨٨.

(٣) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٦٣٣.

فإذا كان العقار أو العقارات المراد نزع ملكيتها تقع في دائرة أكثر من مكتب؛ فإنه يجب تسجيل التنبيه في كل مكتب منها، والحكمة من ضرورة تسجيل التنبيه هي كفالة العلانية والشهر، حماية للغير الذي قد يتعامل على هذا العقار؛ إذ التسجيل يمكن أي شخص يريد التعامل على هذا العقار من معرفة مركزه القانوني بمجرد اطلاعه على سجلات الشهر العقاري؛ فإذا وجد أن العقار محجوزا فيكون على علم أن شرائه للعقار المحجوز لن يكون نافذا في مواجهة الدائن الحاجز^(١).

هذا ولم يحدد المشرع مياعدا يجب تسجيل التنبيه خلاله بعد إعلانه للمحجوز عليه؛ فيجوز إجراؤه في أي وقت، وذلك خلافا لما كان مقررا في القانون السابق، والذي كان يوجب أن يتم التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ إعلان تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر كأن لم يكن.

أولوية مباشرة الإجراءات في حالة تعدد الحجوز:

حرص المشرع في المادة (٢/٤٠٢) أن يبين كيفية مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار في حال تعدد الحجوز عليه، ذلك أن الحاجز قد يجد عند تسجيل تنبيهه حاجزا آخر أو أكثر سبق له تسجيل تنبيهه على ذات العقار، وعندئذ لا يجوز المضي في الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد؛ وإنما تكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل.

وهذه وسيلة للتنسيق بين الإجراءات في حالة تعدد الحجوز على العقار، حتى لا تتضارب إجراءات التنفيذ عليه، إذ الواجب توحيد الإجراءات، بأن يقوم حاجز واحد من هؤلاء الحاجزين بمباشرة إجراءات التنفيذ نيابة عن باقي الحاجزين، وقد أعطى المشرع هذه الأولوية في مباشرة الإجراءات لأول حاجز قام بتسجيل تنبيه نزع ملكية على العقار، حتى وإن كان هناك من هو أسبق منه في إعلان التنبيه؛ إذ العبرة هنا بتسجيل التنبيه بمعنى أن من سجل تنبيهه أولا تكون له أولوية مباشرة الإجراءات ولو كان قد أعلن التنبيه بعد تنبيه آخر لم يتم تسجيله إلا في وقت لاحق.

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٦/٣٩٥.

وإذا فأسبقية تسجيل التنبيه تعطي لمن قام به أولوية فقط في مباشرة الإجراءات، ولا تعطيه أولوية في استيفاء دينه بالتقدم على غيره من الحاجزين، فهي مجرد أولوية إجرائية تمكنه فقط من مباشرة إجراءات التنفيذ^(١).

ولا إشكالية في تأخر هذا الحاجز أو تباطئه أو توأطئه في مباشرة الإجراءات؛ ذلك أن المشرع، أجاز لمن أعلن تنبيهها لاحقاً في التسجيل أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يأذن له في الحل محل هذا الحاجز في السير في الإجراءات (مادة ٤٠٢/٣).

ولم يبين المشرع كيفية اللجوء إلى قاضي التنفيذ للحصول على الإذن بالحلول محل من يباشر الإجراءات؛ ولذلك رأى بعض الفقه أن ذلك يكون بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ ويصدر إذنه بالحلول عليها وفقاً لإجراءات الأوامر على العرائض^(٢)، بينما يرى البعض الآخر (وهو ما نرجحه) أن اللجوء إلى قاضي التنفيذ في هذه الحالة لا يكون بالعريضة لأن المشرع لم ينص عليها؛ وإنما يجب أن يتم بدعوى مستعجلة باعتباره طلباً وقتياً لا يمس حقوق الدائنين الحاجزين وليس طلباً موضوعياً^(٣).

ويجب على مكتب الشهر العقاري أن يقوم بالتأشير بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق واللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر العقاري (مادة ٤٠٣/٢ مرافعات).

التأشير في حالة تعدد الحجز على العقار:

إذا تبين عند تسجيل تنبيه نزع الملكية، سبق تسجيل تنبيه آخر عن العقار ذاته؛ فإن على مكتب الشهر العقاري أن يقوم بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه، وعليه أن يؤشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول، وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه.

(١) د. طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ، ص ٣٥٧.

(٢) د. محمد عبدالخالق عمر، ص ٣٩٨.

(٣) د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ٤٠٨.

الأثر المترتب على تسجيل التنبيه:

حددت المادة (٤٠٤) مرافعات هذا الأثر صراحة بنصها على أنه "يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً"، فإذا كان أثر إعلان التنبيه يقتصر على قطع التقادم على نحو ما أشرنا؛ فإن تسجيل التنبيه يؤدي إلى حجز العقار ووضعه تحت يد القضاء، ويظل العقار مملوكاً للمدين رغم الحجز عليه إلى أن يتم بيعه. ويترتب على اعتبار العقار محجوزاً من تاريخ تسجيل التنبيه جملة من الآثار سنتناولها لاحقاً. فالعقار يكون محجوزاً بتمام تسجيل التنبيه، وهذا التسجيل هو الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين، وتلك التي لا تنفذ في حقهم أيأ كان شخص المتصرف مديناً أو حائزاً دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة^(١).

سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية:

يسقط تسجيل تنبيه نزع الملكية في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كانت إجراءات حجز العقار تتخذ في مواجهة الحائز؛ ولم يتم تسجيل إنذار الحائز (بدفع الدين أو تخلية العقار)، أو لم يتم التأشير بتسجيل الإنذار على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه؛ فإن ذلك يؤدي إلى سقوط تسجيل التنبيه (مادة ٤١٢ مرافعات).

الحالة الثانية: إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع، خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية، فهنا يعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن (م ٤١٤). وسقوط تنبيه نزع الملكية في الحالتين يقع بقوة القانون، غير أنه لا يتعلق بالنظام العام؛ وإنما مقرر لمصلحة الأشخاص لتخليص الأموال من الحجز الموقع عليها واستعادة المالك لها سلطانه عليها، إذا تبين عدم جدية إجراءات التنفيذ على العقار أو التراخي أو الإهمال في متابعتها^(٢).

(١) نقض ١٩٧٤/٤/٣٠، سنة ٢٥، ص ٨٧٤.

(٢) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٩٠-٣٩١.

المبحث الثاني

حجز عقار غير المدين

إجراءات حجز العقار التي تناولناها في المبحث السابق، تتعلق بالتنفيذ على العقار المملوك للمدين المحجوز عليه، وهناك بعض الحالات يمكن فيها الحجز والتنفيذ على عقار غير مملوك للمدين وإنما مملوك لشخص آخر، وهذا قد يبدو غريبا للوهلة الأولى، إذ كيف يمكن التنفيذ على عقار شخص آخر غير المدين، والحقيقة أن هذا الشخص رغم أنه غير المدين إلا أنه تربطه به علاقة خاصة؛ ولذلك حصر المشرع حجز عقار غير المدين بناء على هذه العلاقة الخاصة في حالتين فقط، هما: حجز العقار في مواجهة الحائز، وفي مواجهة الكفيل العيني.

المطلب الأول

حجز عقار الحائز

أولاً: من الحائز المقصود في هذا الحجز؟

الحائز وفق تعريف القانون المدني في المادة (٢/١٠٦٠) هو "كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية العقار المرهون أو حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين".

غير أن الحائز في مفهوم التنفيذ على العقار يأخذ معنى مختلفاً عن ذلك بعض الشيء، فهو وفقاً للمادة (٤١١) مرافعات، من اكتسب ملكية عقار مرهون أو حقاً عينياً عليه يجوز رهنه بموجب سند مسجل سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون بالرهن^(١).

ومن ثم فلا يقصد بالحائز هنا واضع اليد على العقار، بالمعنى العام للحيازة، وإنما يقصد به ذلك الشخص الذي آلت إليه ملكية العقار بعقد مسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية على هذا العقار، وكانت ملكية العقار محملة بحق عيني تبقي نافذ في مواجهة الغير، دون أن يكون ذلك الشخص الذي انتقلت إليه ملكية العقار مسئولاً عن الدين

(١) نقض: الطعن رقم ١١٥ لسنة ٣٩ قضائية - جلسة ١٠/٢٢/١٩٧٤.

مسئولية شخصية، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق العيني أن ينفذ على هذا العقار في يد الحائز بمقتضى حق التتبع المقرر له.

ففي هذه الصورة من صور الحجز على العقار، يكون العقار الذي يجرى التنفيذ عليه مرهونا أو محملا بحق اختصاص أو امتياز للدائن طالب التنفيذ، وقد تصرف فيه المدين الراهن أو من في حكمه إلى شخص آخر، قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية؛ فيحق للدائن المرتهن أو صاحب حق الاختصاص أو الامتياز أن يتتبع العقار المحمل بهذا الحق وينفذ عليه تحت أي يد يكون، ذلك أن التصرف لا ينفذ في مواجهة الدائن صاحب الحق العيني التبعية ما دام قد تم بعد قيد هذا الحق^(١).

ويمكننا وفقا لهذا المفهوم القول بأنه يشترط في الحائز بالمعنى المقصود في مجال التنفيذ العقاري، توفر الشروط الآتية^(٢).

١- أن يوجد حق عيني تبعية على العقار كالرهن أو الامتياز أو الاختصاص وأن يشهر هذا الحق ليكون نافذا في مواجهة الغير.

٢- أن تنتقل ملكية العقار بعد شهر الحق العيني التبعية إلى شخص آخر، أو أن ينتقل حق عيني آخر خلاف حق الملكية بشرط أن يكون هذا الحق العيني مما يجوز رهنه على استقلال وبالتالي بيعه بالمزاد مستقلا.

٣- يجب أن يكون التصرف الناقل لحق الملكية أو أي حق عيني آخر، قد تم تسجيله قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية^(٣).

٤- ألا يكون من انتقلت إليه ملكية العقار مسئولا شخصيا عن الدين، كأن يكون مثلاً أحد المدينين المتضامنين مع المدين مالك العقار.

فإذا توفرت هذه الشروط أصبحنا أمام "حائز" غير مدين بصفة شخصية، ومع ذلك يعد ذا صفة في توجيه الإجراءات ضده، بالإضافة للمدين وذلك إذا كان المنفذ هو صاحب الحق العيني التبعية على العقار^(١).

(١) أستاذي د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٢٥٩.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٦/٤٣٣-٤٣٤.

(٣) لأن التصرف بعد تسجيل التنبيه لا يكون نافذا ولا يعتد به في مواجهة الدائن الذي قام بتسجيل التنبيه.

ثانيا: إجراءات حجز العقار في مواجهة الحائز:

متى تحددت صفة الحائز وفقا للشروط السابقة؛ فإن المشرع يوجب اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار في مواجهته، وذلك رعاية لمصلحة هذا الحائز، ومصلحة الغير الذي قد يتعامل معه، ولا شك أنه يجب قبل اتخاذ هذه الإجراءات، اتخاذ مقدمات التنفيذ في مواجهة المدين أولا، ثم بعد ذلك اتخاذ إجراءات الحجز في مواجهة المدين والحائز، ويقتضي الترتيب المنطقي لإجراءات الحجز في هذه الحالة، القيام أولا بإعداد تنبيه نزع الملكية ثم إعلانه للمدين، ثم القيام بتسجيله، ثم القيام بإنذار الحائز بدفع الدين المحجوز لأجله، أو تخلية العقار، أو بتحمل إجراءات التنفيذ في مواجهته^(١).

أ- إنذار الحائز:

يوجب قانون المرافعات على الحاجز أن ينذر الحائز بدفع الدين أو تخلية العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته، ويجب أن يكون الإنذار مصحوبا بتبليغ التنبيه إلى الحائز؛ وإلا كان باطلا (مادة ٤١١ مرافعات)، وذلك حتى يصل إلى علم الحائز أن المدين قد أعلن بالتنبيه وليعرف نوع السند الحاصل للتنفيذ بمقتضاه، وذات العقار الجاري التنفيذ عليه، ومقدار الدين المطلوب الوفاء به، فيتمكن من اختيار أحد الأمور التي منحه القانون حق الخيار منها^(٢).

فالإنذار إذا هو إعلان يوجهه الحاجز إلى الحائز ينذره فيه بدفع الدين أو تخلية العقار؛ وإلا فإنه سيجري التنفيذ في مواجهته، والغرض هنا دعوة الحائز إلى اتخاذ موقف يتحدد على أساسه موقف الدائن الحاجز؛ فإما أن يختار الحائز دفع الدين أو تخلية العقار، وإما أن يستمر الدائن الحاجز في التنفيذ على العقار^(٣).

وقد أوجبت المادة (٢/٤١١) أن يكون الإنذار مصحوبا بصورة من تنبيه نزع الملكية، وهو ما يعني ضرورة أن يكون إعلان التنبيه سابقا على إنذار الحائز، فلا

(١) د. رمضان عبدالكريم علام، الوجيز في التنفيذ الجبري، ص ٣٧٣.

(٢) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٥٩٥.

(٣) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٦٧١.

(٤) دأمانة النمر، التنفيذ، ص ٤٠٦.

يجوز إنذار الحائز قبله؛ وإن كان المشرع لم يقيد الإنذار بضرورة تسجيل التنبيه، بمعنى أنه يجوز أن يتم إعلان التنبيه ثم تسجيله ثم إنذار الحائز، ويجوز أن يتم إعلان التنبيه ثم إنذار الحائز ثم تسجيل التنبيه بعد الإنذار^(١).

كما لم يقيد المشرع إجراء الإنذار بتاريخ معين بعد التنبيه، غاية ما في الأمر أنه اشترط تسجيل الإنذار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه؛ وإلا سقط تسجيل التنبيه، وبالتالي الإنذار تبعا له، ومعنى ذلك أن الإنذار يتقيد في حالة تسجيل التنبيه قبل القيام به، بضرورة أن يتم الإنذار وتسجيله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه (مادة ٤١٢ مرافعات).

الأثر المترتب على إنذار الحائز:

يترتب على إنذار الحائز -ومن تاريخ إجراءاته بصرف النظر عن تسجيله- جميع الآثار التي تترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية^(٢)، حيث نصت المادة (٣/٤١١) على أنه "ويترتب على إعلان الإنذار في حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد من ٤٠٦ - إلى ٤١٠".

ب- تسجيل إنذار الحائز:

أوجب القانون على الدائن الحاجز أن يقوم بتسجيل إنذار الحائز، وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه وليس من تاريخ الإنذار، وترتب على مخالفة ذلك سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية ذاته (مادة ٤١٢ مرافعات)، بمعنى زوال الحجز عن العقار، فيعود كأنه لم يكن محجوزا عليه، وإن كان لا يترتب على ذلك سقوط التنبيه ذاته، بمعنى أنه

(١) وإن كان من مصلحة الدائن ألا ينذر الحائز إلا بعد تسجيل التنبيه، حتى لا يبادر الحائز بالتصرف في العقار لشخص آخر، مما يلزم الدائن بإنذار الحائز الثاني، لأن تصرف الحائز الأول تم قبل حجز العقار بتسجيل التنبيه، ومن ثم فالأفضل للدائن أن يعلن التنبيه ويقوم بتسجيله أولا، ثم يقوم بعد ذلك بإنذار الحائز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه. (د. محمد محمود إبراهيم، أصول التنفيذ، ص ٥٤٧).

(٢) فيما عدا عدم نفاذ التصرف فهو يتقرر من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية.

يجوز للدائن أن يقوم بإعادة تسجيل التنبيه مرة ثانية، ثم يقوم بتسجيله وإنذار الحائز وتسجيل إنذار الحائز خلال الميعاد المشار إليه.

ووفقا للمادة (٤١٣) فإنه إذا تبين عند تسجيل إنذار الحائز سبق تسجيل إنذار له على العقار ذاته من دائن آخر؛ فإن على مكتب الشهر العقاري أن يقوم بالتأشير بالإصدار الجديد على هامش تسجيل الإنذار السابق، مبينا تاريخ الإنذار الجديد، ويقوم كذلك بالتأشير على الإنذار الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود إنذار سابق، ويبين تاريخ تسجيله، وتتبع في هذا الشأن الأحكام المقررة في المادتين (٤٠٢ و ٤٠٣ مرافعات).

ج- جزاء عدم تسجيل إنذار الحائز أو التأشير به:

يتضح من نص المادة (٤١٢) أن تسجيل تنبيه نزع الملكية يسقط؛ إذا لم يتم تسجيل إنذار الحائز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه، أو إذا لم يتم التأشير بتسجيل الإنذار على هامش التنبيه خلال الميعاد ذاته، ويسقط تسجيل التنبيه من باب أولى إذا لم يتم الإنذار بداية. ومؤدى سقوط تسجيل التنبيه سقوط الإنذار كذلك وسقوط تسجيله إذا تم بعد الميعاد.

وجزاء السقوط المقرر هنا وإن كان يقع بقوة القانون؛ إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام، وإنما يتعلق بمصلحة من تقرر لمصلحته، ولذا يجب عليه التمسك به في الوقت المناسب، وإلا سقط هذا الحق بالنزول عنه صراحة أو ضمنا^(١).

المطلب الثاني

حجز عقار الكفيل العيني

الكفيل العيني هو من يرهن عقارا مملوكا له ضمانا لدين على شخص آخر ويكون مسئولا عن الدين في حدود العقار المرهون، فهو كالحائز ليس مسئولا عن الدين مسئولية شخصية، ولكنه يختلف عن الحائز في أنه مسئول عن الدين مسئولية عينية مقصورة على العقار المرهون، كما يختلف عن الحائز في أنه يرتب برضائه حقا عينيا

(١) د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ٤١٦.

تبعيا على عقاره لضمان حق على غيره، بينما الحائز ينتقل إليه العقار من قبل وبفعل المدين الأصلي بحق عيني تبعي دون أن يكون للحائز يد في ذلك أو رضاء بذلك^(١). وقد نص المشرع على إجراءات التنفيذ على العقار في مواجهته في المادة (٢/٤٠١) مرافعات، بنصها على أنه "إذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة ٢٨١".

ومن ثم فإنه في حالة التنفيذ على عقار مملوك للكفيل العيني (الراهن) فإن إجراءات التنفيذ تبدأ بإعلان المدين بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء وفقا للمادة (٢٨١)، ثم يتم إعلان تنبيه نزع الملكية إلى الكفيل العيني وليس إلى المدين، لأن العقار مملوك للكفيل العيني، كما يجب بعد ذلك تسجيل التنبيه في مكتب الشهر العقاري التابع له العقار على أن يتم هذا التسجيل باسم الكفيل العيني أيضا.

وذلك لأن من يريد التعامل على هذا العقار سوف يتعامل مع مالكة، وهو الكفيل العيني، ولذلك وجب أن يعلم بحقيقة وضع العقار وأنه مرهون للغير وأنه محل للتنفيذ الجبري، ولا يمكنه معرفة ذلك إلا إذا اتخذت الإجراءات في مواجهة مالك العقار وتم تسجيل التنبيه بنزع الملكية باسمه وفي مواجهته. كما أنه من تاريخ تسجيل التنبيه يعتبر العقار محجوزا في مواجهة الكفيل العيني ومن ثم تترتب كافة الآثار الخاصة باعتبار العقار محجوزا.

وبذلك يكون المشرع قد وضع نظاما يحمي الغير الذي يتعامل على العقار المملوك للكفيل العيني؛ بأن جعل التنفيذ يتم بإجراء يسجل باسم هذا الكفيل؛ لأنه لو سجل باسم المدين ما استطاع الغير أن يعلم بالحجز^(٢).

(١) د. أحمد مليجي، الموسوع الشاملة، ج ٦/٣٨٧.

(٢) د. رمزي سيف، إجراءات التنفيذ، ص ٤٣٥.

المبحث الثالث

الآثار المترتبة على حجز العقار

يترتب على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار؛ اعتباره محجوزا (مادة ٤٠٤ مرافعات)، إلا أن مجرد الحجز على العقار، لا يؤدي إلى خروجه من ملك مالكه، فيظل العقار مملوكا له رغم الحجز، ولكن تنقيد سلطاته عليه، فلا يملك سلطة التصرف فيه، كما تنقيد سلطة مالك العقار في استغلاله وتأجييره، وتلحق ثمار العقار به وتعتبر محجوزة تبعا له، وذلك على النحو الآتي:

الأثر الأول: عدم نفاذ التصرف في العقار:

بمجرد تسجيل تنبيه نزع الملكية لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار، ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين، ولا في حق الدائنين المشار إليهم في المادة ٤١٧، ولا من حكم بإيقاع البيع عليه؛ إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية. (مادة ٤٠٥ مرافعات).

ومن ثم فإن حجز العقار وإن لم يسلب المحجوز عليه حقه في التصرف في العقار باعتباره مالكا له؛ إلا أنه يقيد هذا الحق بعدم نفاذ التصرف الصادر منه، فالتصرف الصادر من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، هو تصرف صحيح فيما بين المتعاقدين (المتصرف والمتصرف إليه)، ولكنه غير نافذ في مواجهة أشخاص معينين نص عليهم المشرع في المادة (٤٠٥) مرافعات، والعلة في ذلك أن حجز العقار يترتب عليه تعلق حق الحاجز ومن في حكمه بالعقار؛ فإذا تصرف المحجوز عليه فيه تصرفا من شأنه الإضرار بهذه الحقوق المتعلقة بالعقار، وجب تقرير الحماية القانونية لها بعدم نفاذ التصرف في مواجهة صاحب الحق^(١).

ونبين نطاق أثر عدم نفاذ التصرف، من حيث التصرفات، والأشخاص، وما قد يؤدي إلى سريان هذا التصرف رغم ذلك، على النحو الآتي:

(١) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٩٣.

أ- نطاق هذا الأثر من حيث التصرفات التي لا تنفذ:

لا ينفذ أي تصرف في العقار من جانب المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بعد تسجيل التنبيه، يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ من ملك المدين أو يرتب حقا عليه^(١)، سواء كان هذا التصرف بنقل الملكية، أم نقل حق عيني آخر متفرع عن الملكية أم إنشائه، وسواء كان الحق العيني أصليا، أو كان تبعا كالرهن أو الامتياز أو الاختصاص، وسواء في ذلك أكان التصرف بعوض أم بغير عوض.

ونطاق هذا الأثر بعدم نفاذ التصرف يتعلق زمنيا بالتصرفات التي تشهر بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية، بحيث يكون التصرف نافذا إذا تم شهره قبل تسجيل التنبيه، ولا يكون كذلك إذا تم الشهر بعد تسجيل التنبيه^(٢).

ويلاحظ أن هذا الأثر لا يقتصر على التصرفات الصادرة من مالك العقار بإرادته، بل يمتد أيضا إلى الحقوق العينية التي تترتب على العقار بغير إرادته، أي بموجب أحكام أو أوامر صادرة من القضاء، ومثالها حقوق الارتفاق التي يحكم بها أو حقوق الاختصاص التي تتقرر لصالح أحد الدائنين بأمر القاضي على العقار المنفذ عليه، بل من الممكن أيضا أن يمتد هذا الأثر إلى حقوق الامتياز التي تتقرر بمقتضى القانون؛ إذ الأمر لا يتعلق هنا بعدم نفاذ التصرفات الصادرة من مالك العقار؛ وإنما يتعلق بعدم نفاذ الحقوق العينية التي تترتب على العقار^(٣).

وعلى الرغم من عدم نفاذ التصرف في مواجهة أشخاص معينين، إلا أن التصرف يكون صحيحا وناظا بين طرفيه، وينتج التصرف جميع آثاره بين المالك والمتصرف إليه، باعتبار أن التصرف صادرا من مالك لم يخرج العقار المحجوز عن ملكه^(٤).

(١) وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "تسجيل تنبيه نزع الملكية. حد فاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين، وتلك التي لا تنفذ في حقهم. التصرف اللاحق لتسجيل تنبيه نزع الملكية، صحيح بين طرفيه؛ وإن كان للدائنين طلب عدم نفاذه في حقهم". (الطعن رقم ٩٢٠ لسنة ٥٥ قضائية - جلسة ١٩٨٨/١١/٣٠).

(٢) نقض: الطعن رقم ٨٠ لسنة ٤٥ قضائية - جلسة ١٩٩٥/٢/٢.

(٣) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٦/٤٠٤.

(٤) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٢٥١.

ب- نطاق هذا الأثر من حيث الأشخاص:

حددت المادة (٤٠٥) نطاق أثر عدم سريان التصرف في العقار المحجوز من

حيث الأشخاص الذين لا يسري التصرف في مواجهتهم، وهؤلاء الأشخاص هم:

١- الدائنون الحاجزون الذين سجلوا تنبيهاتهم بنزع الملكية، وسواء كانوا دائنين

عاديين أم أصحاب حقوق عينية تبعية كالرهن أو الاختصاص أو الامتياز^(١)،

وسواء في ذلك أكان هذا الحاجز مباشرا للإجراءات أم مجرد حاجز سجل

تنبيهه ولا يباشر الإجراءات.

٢- الدائنون المشار إليهم في المادة (٤١٧) مرافعات، ويقصد بهم أصحاب

الحقوق العينية التبعية المقيدة على العقار قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية وهؤلاء

يصبحون طرفا في الإجراءات من تاريخ التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع

الملكية بإخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع.

٣- من حكم بإيقاع البيع عليه، أي مشتري العقار بالمزاد العلني، فلا تسري

تصرفات المدين أو الحائز أو الكفيل العيني على العقار في مواجهته، وهذا

من قبل حمايته من مثل هذه التصرفات باعتباره مشتريا للعقار بشكل صحيح.

ج- سريان التصرف بعد تسجيل التنبيه بالإيداع مع التخصيص:

إذا كانت التصرفات المشار إليها لا تنفذ في مواجهة الأشخاص الذين حددهم

القانون على النحو الذي بيناه؛ فإن أثر الحجز يزول وتسري هذه التصرفات إذا تم

إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف، وخصص

هذا المبلغ للوفاء بها دون غيرها؛ إذ بمجرد الإيداع والتخصيص على هذا النحو يزول

الحجز على العقار وينتقل إلى المبلغ المودع (مادة ٣٠٢/١ مرافعات).

(١) وفي الواقع فإن هذا الأثر يفيد منه الدائن العادي أكثر مما يفيد منه الدائن صاحب الحق العيني التبعية،

ذلك أن للأخير حق التتبع الذي يمكنه من تتبع العقار المرهون له أو المقيد له عليه حق امتياز أو اختصاص

في أي يد يكون، فلا يضره كثيرا أن يتم التصرف في العقار، أما الدائن العادي فإن الضرر في حقه أبلغ أثرا

إذا لم يكن هذا الأثر مقررًا، لأنه سيفقد ضمان دينه ويكون في خطر يحتاج معه إلى حماية تشريعية، ولذا فإن

إفادته من هذا الأثر أكثر من الدائن صاحب الحق العيني.

الأثر الثاني: إلحاق الثمار بالعقار:

يترتب على اعتبار العقار محجوزا من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية؛ أن تلحق ثمار العقار به، فتصير محجوزة تبعا له، وقد نص المشرع على ذلك صراحة في المادة (١/٤٠٦) مرافعات، بنصها على أن "تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه". كما نص على ذلك أيضا في المادة (١٠٣٧) من القانون المدني، بنصها على أنه "يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التي أعقبت التسجيل ويجرى في توزيع هذه الغلة ما يجرى في توزيع ثمن العقار".

أ- معنى إلحاق الثمار بالعقار:

ومعنى إلحاق الثمار بالعقار أنها تصبح جزءا منه وتأخذ حكمه، رغم أنها في الأصل منقول، فهي تعتبر محجوزة تبعا لحجز العقار بقوة القانون دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات مستقلة لحجزها، كما أن ثمنها يوزع مع ثمن العقار المتحصل من بيعه بالمزاد العلني، وبذات الطريقة التي يوزع بها الثمن، فتكون الأولوية للدائنين المرتهنين أو أصحاب حقوق الاختصاص أو الامتياز، بحسب درجاتهم، بحيث لا يأخذ الدائنون العاديون من الثمار أو قيمتها إلا بعد أن يستوفي الدائنون الممتازون حقوقهم، ويقسم الباقي بينهم بالمحاصة؛ فإذا لم يكن بين الحاجزين والدائنين دائن ممتاز؛ فإن ثمار العقار تقسم هي وثمرتها بالمحاصة بين الدائنين العاديين^(١).

ومعنى ذلك أنه يتم إلحاق الثمار بالعقار من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية (ومن تاريخ الإنذار بالنسبة للحائز) بغير حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر من إجراءات التنفيذ، ولو كان الدائن الحاجز دائنا عاديا؛ باعتبار أن الإلحاق أثر من آثار التنفيذ على العقار؛ فتوزع بين الدائنين العاديين قسمة غرماء؛ إذا لم يوجد دائنون ممتازون^(٢).

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٦٥٤ - د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٤١٨/٦.

(٢) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٤٠٣ - د. نبيل عمر اسماعيل، إجراءات التنفيذ، ص ٦١١.

ب- الحكمة من إلحاق الثمار بالعقار:

على الرغم من أن الثمار لا تعتبر من ملحقات العقار؛ إلا أن المشرع قرر إلحاقها به للاعتبارات الآتية:

- ١- أن إلحاق الثمار بالعقار يؤدي بلا شك إلى توفير أكبر مبلغ ممكن للدائنين.
- ٢- نقاديا للإضرار بالدائنين؛ إذ لو تركت الثمار للمدين دون اعتبارها محجوزة تبعا لحجز العقار؛ فإنه سوف يسعى إلى إطالة الإجراءات، للاستفادة بالثمار أطول فترة ممكنة قبل أن يفقد عقاره؛ ولذلك فإن إلحاق الثمار بالعقار يؤدي إلى عدم تشجيع المدين على إثارة المنازعات وتعطيل إجراءات التنفيذ^(١).
- ٣- منعا من تحايل الدائن العادي الذي قد يعتمد على إطالة مدة الحجز بإثارة منازعات فرعية تؤخر إجراءات التنفيذ، بأمل الإفادة من اقتسام ثمار العقار بطريق المحاصة بين جميع الدائنين^(٢).

ج- تحديد الثمار التي تلحق بالعقار:

الثمار التي تلحق بالعقار وتصير محجوزة تبعا له، قد تكون ثمارا مدنية، أو طبيعية، أو صناعية:

- ١- الثمار المدنية: مثل أجرة العقار، وهذه تلحق بالعقار عن المدة اللاحقة لتسجيل تنبيه نزع الملكية، ولا يلحق منها ما كان سابقا على تسجيل التنبيه ولو استحق أدائه بعد التسجيل، وعلى ذلك لو كانت أجرة العقار تدفع مؤخرا واستحققت بعد تسجيل التنبيه؛ فإن أجرة الفترة اللاحقة للتسجيل هي التي تلحق بالعقار؛ أما أجرة الفترة السابقة للتسجيل فلا تلحق؛ وإنما تقسم بالمحاصة بين جميع الدائنين.
- ٢- الثمار الطبيعية: مثل المحصولات الزراعية، وهذه قد تنثر إشكالية متعلقة بما يتم حجزه منها، فقد تجنى المحصولات فور تسجيل التنبيه، بينما تكون بقيت في الأرض عدة شهور قبله.

(١) د. عبدالباسط جميعي، نظام التنفيذ، ص ٢٦٣.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٦٥٥.

وفي هذه الحالة لا يلحق المحصول بالعقار؛ إلا بقدر الفترة اللاحقة لتسجيل التنبيه وحتى جني المحصول أو حصاده، فإذا تم جني المحصول بعد تسجيل التنبيه، وكان قد بقى في الأرض لمدة شهرين قبل التسجيل وشهرين بعد التسجيل؛ فتلحق نصف المحاصيل بالعقار، ويوزع النصف الآخر بالمحاصة بين جميع الدائنين^(١).

٣- الثمار الصناعية: مثل انتاج المناجم والمحاجر: فيلحق منها بالعقار ما يستخرج بعد تسجيل التنبيه، أما ما يتم استخراجه قبل التسجيل فلا يلحق بالعقار^(٢).

ولكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ أمرا بتكليف أحد معاوني التنفيذ أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات (مادة ٤٠٦/٢ مرفعات)، وتباع الثمار والمحصولات بالمزاد أو بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضي، ويودع الثمن في خزانة المحكمة (مادة ٤٠٦/٣).

ونتيجة لكون الثمار لا تلحق بالعقار إلا من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية؛ فإن تصرف المالك فيها قبل هذا التاريخ يكون صحيحا وناظرا حتى ولو لم يكن قد تم نزع المحصولات أو لم يتم جنيها إلا بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية، بشرط أن يكون هذا التصرف ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وألا يشوبه تدليس، وأن يكون من قبيل الإدارة الحسنة^(٣).

ويشير التصرف في ثمار العقار المحجوز قبل تنبيه نزع الملكية، إشكالية تتعلق بمزاحمة المتصرف إليه للدائن المرتهن، في هذه الثمار، ونبين ذلك فيما يلي:

د- مزاحمة الغير للدائن المرتهن في الثمار^(٤):

قد يزاحم الغير الدائن المرتهن في الثمار، فقد يكون هذا الغير مشتريا لها، أو حاجزا عليها باعتبارها منقولا، أو يكون المدين قد قبض الأجرة أو أحالها إلى الغير مقدما.

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٦٥٦.

(٢) أستاذي د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٢٥٥.

(٣) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٦٥٨.

(٤) أستاذي د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٢٥٥.

١- بيع الثمار:

إذا باع المدين المحصولات وهي قائمة ثم سجل تنبيه نزع الملكية قبل الجني؛ فالأرجح أن هذه المحصولات لا تلحق بالعقار؛ وإنما تكون من حق المشتري، ما دام البيع قد تم بعقد ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. ذلك أن الرهن لا يقيد حق المدين في إدارة العقار والتصرف في الثمرات؛ وإنما تسجيل التنبيه هو الذي يغل يده.

٢- حجز الثمار:

إذا حجز على الثمار قبل جنيها باعتبارها منقولا، ثم سجل تنبيه نزع الملكية، فتلحق الثمار بالعقار عن المدة اللاحقة لتسجيل التنبيه، ذلك أن الحاجز الأول لا يتمتع بميزة عن غيره من الحاجزين، ثم بعد ذلك لا يتساوى مع غيره من الدائنين الذين لهم امتياز على الثمار بحكم القانون^(١).

ويتعين ملاحظة أن القاعدة أنه؛ إذا رهن المدين العقار رهنا حيازيا ثم شرع في التنفيذ عليه وسجل التنبيه بنزع الملكية؛ فإن ثماره تلحق به لمصلحة الدائنين المرتهنيين رهنا رسميا أو يستحقها الدائن المرتهن حيازيا بحسب تقدم تاريخ الرهن الرسمي أو تاريخ قيد الرهن الحيازي^(٢).

٣- قبض الأجرة أو حوالتها مقدما:

إذا قبض المدين الأجرة عن مدة قادمة وأعطى مخالصة أو أحال الأجرة، ثم سجل تنبيه نزع الملكية ولم تنقض هذه المدة؛ فإن كانت هذه المدة سنة فأقل سرت المخالصة أو الحوالة، حتى ولو لم تكن ثابتة التاريخ. أما إذا كانت المدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات؛ فيجب أن تكون المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه، وإلا اعتبرت لمدة سنة. وإذا زادت المدة عن ثلاث سنوات؛ فيجب أن تكون مسجلة قبل تسجيل التنبيه؛ وإلا اعتبرت المخالصة أو الحوالة لمدة ثلاث سنوات (مادة ٤٠٩).

(١) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٤٠٣.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٦/٤٢٢.

الأثر الثالث: تقييد سلطة المدين^(١) في الانتفاع بالعقار أو استغلاله:

يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية تقييد سلطة المدين في الانتفاع بالعقار واستغلاله، ويفرق في هذا الشأن بين ما إذا كان المدين يستعمل العقار وينتفع به قبل الحجز، وبين ما إذا كان العقار مؤجراً لشخص آخر، وذلك على النحو الآتي:

أ- إذا كان المدين يستعمل العقار بنفسه:

إذا كان المدين يستعمل العقار بنفسه، كما لو كان أرضاً زراعية يزرعها أو بناء يسكنه؛ فإنه يكون حارساً على العقار إلى أن يتم البيع، وعليه أن يحافظ على العقار إلى اليوم المحدد للبيع؛ فإذا كان العقار أرضاً تغل ثماراً؛ فإن عليه أن يحصد المحصولات ويجني الثمار ويبيعها^(٢) متى كان ذلك من قبيل أعمال الإدارة الحسنة^(٣)، وعليه أن يحتفظ بالثمن لحساب الدائنين أو يودعه خزانة المحكمة^(٤)، وإذا كان المدين ساكناً في العقار؛ فإنه يبقى ساكناً فيه بغير أجر إلى أن يتم البيع؛ لأن الحجز لا يخرج العقار عن ملكية المدين المحجوز عليه. ولقاضي التنفيذ بناء على طلب الدائن الحاجز أن يحكم بعزل المدين من الحراسة وتعيين حارس آخر بدلاً منه، وله أن يأمر بتحديد سلطة المدين على العقار.

حيث نصت المادة (١/٤٠٧) مرافعات، على أنه "إذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي". كما نصت المادة ذاتها في فقرتها الثانية على أنه "وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجر إلى أن يتم البيع".

(١) وكذلك الحائز والكفيل العيني إذا تم حجز العقار في مواجهة أي منهما.

(٢) ولكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ أمراً بتكليف أحد معاوني التنفيذ أو الدائنين أو غيرهم بحصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها.

(٣) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٣٩٨. ويذهب الفقه القانوني إلى أن للمدين أن يحجز من ثمرات الأرض ما يلزم لقوته ومن يعولهم، وذلك وفقاً بهم وقياساً على ما هو منصوص عليه في حجز المنقولات من عدم جواز الحجز على ما يلزم لقوت المدين وعائلته.

(٤) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٦٦١.

وحراسة المدين للعقار هي حراسة قانونية؛ أي أنه طالما يستغل المدين العقار بنفسه؛ فإنه يعتبر حارسا عليه بقوة القانون؛ فإذا اختلس المدين الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو أثلّف هذا العقار؛ فإنه يعاقب بعقوبة التبديد وفقا لأحكام المواد (٣٤١ و ٣٤٢ و ٣٦١) من قانون العقوبات^(١).

ب- إذا كان العقار مؤجرا:

إذا كان العقار المحجوز عليه مؤجرا؛ فإنه تجب التفرقة بين عقد الإيجار ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وبين عقد الإيجار غير ثابت التاريخ، وذلك على النحو الآتي:

١- إذا كان العقار مؤجرا وكان عقد الإيجار ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية؛ فإنه ينفذ في حق الدائنين الحاجزين (عاديين أم ممتازين)، كما يسري في حق الدائنين المشار إليهم في المادة (٤١٧) المعتبرين طرفا في الإجراءات، ويسري أيضا في حق مشتري العقار بالمزاد العلني، هذا بشرط ألا تزيد مدة الإيجار في جميع الأحوال على تسع سنوات^(٢)، ذلك أن المادة (١١) من قانون تنظيم الشهر العقاري تنص على عدم سريان الإيجار في حق الغير فيما يزيد على تسع سنوات؛ إلا إذا كانت العقود مسجلة قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية بالنسبة للدائن العادي، وقبل قيد الرهن بالنسبة للدائن المرتهن ومن في حكمه، وقبل صدور حكم إيقاع البيع بالنسبة لمشتري العقار بالمزاد^(٣).

٢- إذا لم يكن عقد الإيجار ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية؛ فلا يسري في حق من تقدم ذكرهم؛ إلا إذا كان الإيجار من قبيل أعمال الإدارة الحسنة.

(١) حيث نصت المادة (٤١٠) مرافعات على أنه "تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد ٣٤١ و ٣٤٢ و ٣٦١ من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو أثلّف هذا العقار أو أثلّف الثمرات.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٦٦٣.

(٣) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٤٠٠.

ويعتبر الإيجار كذلك إذا كانت الأجرة مساوية لأجرة المثل، ولا تزيد مدة الإيجار عن سنة بالنسبة للمباني وثلاث سنوات بالنسبة للأراضي الزراعية، وتطبق ذات القاعدة على عقود الإيجار الصادرة بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية؛ لأنها تصدر في الفترة التي يتعلق فيها حق الدائن بالأجرة.

حجز الأجرة تحت يد المستأجر:

تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان العقار المحجوز عليه مؤجراً؛ فإن الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية تعتبر محجوزة تحت يد المستأجر، وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين (مادة ٢/٤٠٧)، وإذا وفي المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً (مادة ٣/٤٠٧ مرافعات).

أما إذا كان المدين قد قبض الأجرة مقدماً أو قام بحوالتها إلى الغير؛ فإن المخالصة عن الأجرة المعجلة والحالة بها، يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة ٤١٧ ومن حكم بإيقاع البيع عليه، وفقاً للقواعد التي أشرنا إليها سلفاً.

الفصل الثاني التمهيد لبيع العقار

الفصل الثاني

التمهيد لبيع العقار

مرحلة التمهيد لبيع العقار، تشتمل على إجراءات رئيسين؛ أولهما: إيداع قائمة شروط البيع، وثانيهما: الفصل في الاعتراضات على بيع العقار.

المبحث الأول

إيداع قائمة شروط بيع العقار والإخبار والإعلان عن إيداعها

يوجب القانون على الدائن الذي يباشر الإجراءات أن يودع قائمة شروط بيع العقار قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الميعاد المقرر قانوناً، وعلى قلم الكتاب فور هذا الإيداع وخلال الميعاد المقرر أن يقوم بإخبار الأشخاص الذين أوجب القانون إخبارهم بإيداع القائمة، ثم يقوم بالإعلان عن هذا الإيداع في إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية، ونبين ذلك في مطلبين:

المطلب الأول

إيداع قائمة شروط البيع

أولاً: إجراءات الإيداع وميعاده:

قلنا إن تسجيل تنبيه نزع الملكية يعتبر كأن لم يكن وبالتالي يزول الحجز عن العقار؛ إذا لم يتم إيداع قائمة شروط البيع خلال الميعاد المقرر، إذ لم يشأ المشرع أن يترك العقار المحجوز عليه معطلاً بما يترتب على تسجيل التنبيه من آثار، دون مواءمة الإجراءات من الدائن الحاجز، ولذلك أوجب عليه أن يقوم بعد تسجيل التنبيه بإيداع قائمة شروط البيع.

ولم يوجب القانون على الدائن إيداع القائمة بعد مضي مدة محددة من تاريخ تسجيل التنبيه؛ وإنما يجوز له أن يقوم بهذا الإيداع في أي وقت فور تسجيل التنبيه، وبهذا أصبح من حقه أن يعلن التنبيه ويسجله ويودع القائمة في ذات اليوم، خلافاً لما كان

ينص عليه قانون المرافعات القديم، والذي كان يوجب مضي تسعين يوما بين تسجيل التنبيه وإيداع القائمة.

غير أن القانون أوجب على الدائن الذي يباشر الإجراءات أن يودع القائمة خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل التنبيه، وإلا اعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن، وذلك بنصه في المادة (١٤/١) مرافعات، على أن "يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن".

كما تنص المادة (٢/٤٥٢) على أنه "إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة وأربعين يوما التالية لتسجيل آخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله في مباشرة الإجراءات".

وتنص المادة (٤٥٣) على أنه "إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو اعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن وفقا لحكم المادة ٤١٤ أو بمقتضى حكم صدر بذلك، فعلى مكتب الشهر العقاري عند التأشير بهذا الشطب أن يؤثر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه آخر يتناول العقار وعليه خلال الثمانية أيام التالية أن يخبر الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات.

وللدائن الأسبق في التسجيل أن يسير في الإجراءات من آخر إجراء صحيح...". ويتضح من هذه النصوص، أن المشرع حدد إجراءات إيداع قائمة شروط البيع على النحو الآتي:

- ١- يتم إيداع القائمة من الدائن الحاجز المباشر للإجراءات، ومن ثم إذا تعدد الدائنون الحاجزون، فلا يجوز لغير الدائن المباشر للإجراءات أن يودع القائمة.
- ٢- لا يجوز للمدين أن يقوم بإيداع قائمة شروط البيع، وإذا تم هذا الإيداع فإنه يكون باطلا ولا يرتب أثرا.
- ٣- لا يجب مضي مدة بين تسجيل التنبيه وإيداع القائمة؛ ومن ثم يجوز أن يتم في يوم واحد أو يتم الإيداع في أي يوم لاحق للتسجيل خلال الميعاد المقرر قانونا.

- ٤- لا تعد قائمة شروط البيع صحيفة دعوى؛ وإنما إجراء من إجراءات التنفيذ، ومن ثم لا يجب أن توقع من محام كما هو مقرر في شأن صحف الدعاوى التي تزيد قيمتها عن حد معين.
- ٥- يتم إيداع قائمة شروط البيع في قلم كتاب محكمة التنفيذ المختصة، وهي المحكمة التي يقع العقار المحجوز عليه في دائرتها؛ فإذا كان العقار واقعا في دوائر محاكم متعددة، وجب إيداع نسخة من القائمة في قلم كتاب كل محكمة منها.
- ٦- يتم إيداع القائمة بمحضر رسمي يسمى محضر إيداع قائمة شروط البيع، يحرره الكاتب المختص في قلم كتاب محكمة التنفيذ.
- ٧- يجب أن يتم إيداع القائمة خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتسجيل التنبيه باعتبار التسجيل هو الإجراء المجري للميعاد، وينقضي هذا الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.
- ٨- إذا تقاعس الدائن المباشر للإجراءات عن إيداع قائمة شروط البيع خلال الخمسة وأربعين يوما التالية لتسجيل آخر تنبيه قام هو بإجرائه؛ فيجوز في هذه الحالة للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محل من كان يباشر الإجراءات في متابعة هذه الإجراءات^(١).
- ٩- لم يشترط المشرع لقيام الدائن اللاحق بإيداع القائمة وفقا للبند السابق، صدور إذن من القاضي؛ وإنما يتم الإيداع والحلول بمجرد انقضاء خمسة وأربعين يوما^(٢).
- ١٠- على من يباشر الإجراءات أن يودع قلم كتاب المحكمة، أوراق الإجراءات خلال الثلاثة أيام التالية لإنذاره بذلك على يد معاون التنفيذ؛ وإلا كان ملزما بالتعويضات^(٣).

(١) وفي ذلك نقول المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات "انقص المشروع الميعاد الذي تنص عليه المادة ٦٩٣ من القانون القائم إلى خمسة وأربعين يوماً حثاً لمباشر الإجراءات على إيداع القائمة وحتى يترك لمن يحل محله ميعاداً مناسباً للقيام بالإيداع قبل سقوط تسجيل التنبيه".

(٢) وفي ذلك نقول المذكرة الإيضاحية "قد رأى المشروع أيضاً الاستغناء عن إنذار الدائن مباشر الإجراءات قبل الحلول، مراعاة لأن الدائن يعلم بالميعاد القانوني ويجب على احترامه بغير إنذار، كما رأى المشروع تبسيطاً للإجراءات إعفاء الدائن اللاحق من استئذان القاضي في الحلول.

١١- إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو اعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن؛ فإن للدائن الأسبق في التسجيل أن يسير في الإجراءات من آخر إجراء صحيح.

ويجب أن يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه؛ وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن (مادة ٤٥٣/٢).

ثانيا: مشتملات قائمة شروط البيع:

حرص المشرع على تحديد مشتملات قائمة شروط البيع بالنص عليها في المادة (٤١٤) مرافعات، ويبدو الهدف من إيداع القائمة في بيان كل ما يهم أصحاب الشأن في التنفيذ على العقار، سواء الراغب في دخول المزاد لشراء العقار، أو من له مصلحة تتعلق به، ولذلك فهي تشتمل على ما يتعلق بمدى صحة إجراءات التنفيذ وعلى بيان العقار محل التنفيذ وقيمه على وجه التقريب، ومقدار الديون المقيدة عليه وأصحاب هذه الديون، ومشروع عقد البيع ليطلع عليه كل من يتقدم للمزاد وليتمكن أصحاب المصلحة من دراسته وإبداء ما يعن لهم من ملاحظات بصده^(٢).

ووفقا لنص المادة (٤١٤) فإن القائمة يجب أن تشتمل على البيانات الآتية:

- ١- بيان السند التنفيذي الذي حصل التنفيذ بمقتضاه.
- ٢- تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمي تسجيلهما وتاريخه.
- ٣- تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه، وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها.
- ٤- شروط البيع: ويقصد بها، الشروط التي يقدمها مباشر الإجراءات لإجراء البيع، ومثالها قبول المشتري سريان عقود الإيجار في مواجهته، ولو لم تكن ثابتة التاريخ

(١) مادة (٢/٤٥٢) ووفقا لهذه المادة لا ترد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع.

(٢) د. أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ، ص ٦٨٢.

رسمياً قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، ويجب ألا تكون الشروط المقترحة لإجراء البيع والواردة في القائمة، مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب؛ وإلا جاز الاعتراض عليها بالطريق المقرر قانوناً للاعتراض على القائمة^(١).

٥- الثمن الأساسي للعقار المحجوز عليه: حيث يجب على الدائن أن يضمن القائمة الثمن الأساسي لبيع العقار، وقد كان المشرع في القانون القديم يترك للدائن حرية تحديد هذا الثمن، وفي مقابل ذلك يلزمه بشراء العقار إذا لم يتقدم أحد لشرائه بهذا الثمن.

إلا أنه عدل عن هذا المسلك المنتقد، إلى وضع معيار جديد يتم على أساسه تحديد الثمن الأساسي للعقار المحجوز عليه في قائمة شروط البيع، وذلك باتباع القواعد المقررة في المادة (١/٣٧) مرافعات، والتي تقضي بأن يكون تقدير قيمة العقار باعتبار خمسمائة مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً، وأربعمائة مثل الضريبة المربوطة عليه إذا كان العقار من الأراضي (الزراعية أو أراضي البناء)؛ فإذا لم يكن العقار مقدراً عليه ضريبة؛ قدرت المحكمة قيمته، وذلك بناء على عريضة يقدمها الحاجز المباشر للإجراءات إلى قاضي التنفيذ^(٢). وإذا كان الثمن الذي تم تقديره محل اعتراض ممن له صفة في ذلك؛ فإن له أن يقدم اعتراضه عن طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع^(٣).

٦- تجزئة العقار إلى صفقات: حيث يجوز للدائن المباشر للإجراءات أن يجزء العقار المحجوز عليه إلى صفقات وتباع كل صفقة منها على استقلال؛ إذا رأي أن هناك مصلحة في ذلك، كما لو كانت هذه التجزئة تؤدي إلى بيع العقار بشكل أسهل أو

(١) ومثال هذه الشروط المخالفة؛ أن يشترط البائع مخالفة القواعد المقررة قانوناً لإجراء المزايعة والواردة في المادة ٤٤٠ مرافعات. أو الإعفاء من رد الثمن في حالة استحقاق العقار أو يمنع بعض الأشخاص من الشراء بدون سبب قانوني. (د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٤١٠).

(٢) ومن المؤكد أن الثمن الذي يحدده الحاجز المباشر للإجراءات في القائمة ليس ثمناً نهائياً؛ وإنما مجرد تحديد مؤقت قابل للزيادة والنقصان بحسب المزاد وما ينتج عنه.

(٣) د. عزمي عبدالفتاح، قواعد التنفيذ الجبري، ص ٥٩٦.

أيسر، أو كان ذلك يزيد في عدد الراغبين في الشراء ويزيد في حصة بيع العقار عما لو بيع في صفقة واحدة^(١). وعلى الدائن إذا قام بتجزئة العقار على هذا النحو، أن يبين الثمن الأساسي لكل صفقة من هذه الصفقات، وحدود كل صفقة منها.

ثالثاً: تحديد جلستي الاعتراضات والبيع:

تودع القائمة كما قلنا في قلم كتاب محكمة التنفيذ المختصة، وهي المحكمة التي يقع العقار المحجوز عليه في دائرتها، وعلى قلم الكتاب أن يقوم بتحرير محضر بإيداع القائمة، وعليه أن يثبت في هذا المحضر تاريخ جلسة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على البيع وتحديد الجلسة التي يجرى فيها البيع، إذا لم تقدم اعتراضات (مادة ٤١٤ مرافعات).

ويجب على قلم الكتاب أن يتقيد في تحديد الجلستين بما نصت عليه المادة (٤١٩) مرافعات، والتي نصت على أن "تحدد في محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أو جلسة حل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة ٤١٧^(٢) ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً؛ فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير في إجراءات الإعلان عن البيع".

ويتضح من هذا النص أن على قلم الكتاب في تحديده لميعاد الجلسة الأولى (المقررة لنظر الاعتراضات) أن تكون بعد انقضاء ثلاثين يوماً التالية للخمس عشرة يوماً المقررة لإخبار الأشخاص الواجب إخبارهم بإيداع القائمة^(٣).

(١) د. أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ، ص ٦٨٥.

(٢) وهذا الميعاد هو الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع والمقرر للإخبار فيها عن إيداع القائمة.

(٣) فإذا لم تقدم اعتراضات؛ يسقط تحديد جلسة الاعتراضات وتتخذ الإجراءات للإعلان عن البيع.

وأن يراعي في تحديد الجلسة الثانية (جلسة بيع العقار) مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما بين جلسة نظر الاعتراضات وجلسة البيع.

رابعاً: مرفقات القائمة:

أوجب المشرع في المادة (٤١٥) أن ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية:

- ١- شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز.
- ٢- السند التنفيذي الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.
- ٣- التنبيه بنزع الملكية.
- ٤- إنذار الحائز إن كان.
- ٥- شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة.

خامساً: الجزاء المترتب على مخالفة إجراءات إيداع القائمة:

- ١- رتب القانون على عدم إيداع القائمة خلال التسعين يوما التالية لتسجيل التنبيه، اعتبار التسجيل كأن لم يكن، وهذا الميعاد ناقص يجب أن يتم الإيداع خلاله؛ فإذا انقضى اليوم الأخير منه دون الإيداع؛ سقط تسجيل التنبيه واعتبر كأن لم يكن، وبالتالي سقوط الحجز على العقار.
- والحكمة من وجوب الإيداع خلال هذا الميعاد على حد تعبير المذكرة الإيضاحية، ألا يبقى المدين تحت رحمة الدائن الحاجز، وحتى لا يبقى مصير المدين معلقاً بيد الدائن الذي سجل تنبيه نزع الملكية؛ إذ يجب الإسراع في البيع، بحيث لا يبقى الحجز مدة طويلة^(١).

ويقع هذا الجزاء بقوة القانون بمجرد انقضاء التسعين يوماً، ولا يتعلق السقوط هنا بالنظام العام؛ وإنما هو مقرر لمصلحة من يتعين عليه التمسك به، ولا يجوز لقاضي التنفيذ الحكم به من تلقاء نفسه^(٢).

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/٤٤٣.

(٢) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص٤١٢.

٢- كما نص القانون في المادة (٤٢٠) على البطلان كجزاء على مخالفة الأحكام المنصوص عليها بشأن بيانات القائمة ومرفقاتها والتي ورد النص عليها في المادتين (٤١٤ و ٤١٥)، فإذا لم تشتمل القائمة على البيانات المنصوص عليها في المادة (٤١٤) أو لم يرفق بها المستندات والأوراق المشار إليها في المادة (٤١٥)؛ فإن إيداع القائمة يكون باطلا وتزول الآثار القانونية المترتبة عليه. و جدير بالذكر أنه يعمل في هذه الحالة بالقواعد العامة للبطلان والمقررة في المادة (٢٠) مرافعات، بحيث يترتب البطلان بقوة القانون جزاء على عدم مراعاة ما نص عليه المشرع في شأن القائمة، وليس على مدعي البطلان إثبات تخلف الغاية لكي يتم الحكم بالبطلان؛ وإنما يجب على الخصم الذي يدعي تحقق الغاية رغم تخلف البيان أو الإجراء أن يثبت أن الغاية من البيان أو الإجراء قد تحققت، وذلك حتى لا يحكم بالبطلان^(١).

المطلب الثاني

الإخبار بإيداع القائمة والإعلان عنه

يوجب القانون أن يتم الإعلان عن إيداع قائمة شروط البيع، بإعلام كل من يهمه هذا الإيداع، حتى يتمكن صاحب المصلحة من إبداء ما يراه من ملاحظات أو أوجه بطلان عند الاعتراض عليها، ويتم هذا الإعلان بوسيلتين، الأولى: إخبار أشخاص بعينهم يوجب القانون إخبارهم بإيداع القائمة خلال ميعاد محدد من تاريخ الإيداع، والثانية: الإعلان العام عن الإيداع للكافة، ونبين ذلك فيما يلي:

أولاً: الإخبار بإيداع القائمة:

يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين، والحائز، والكفيل العيني، والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم، والدائنين

(١) وتأسيسا على ذلك إذا لم تشتمل القائمة على بيان من البيانات الواجب ذكرها فيها، وأمكن استكمالها من الأوراق المرفقة بالقائمة؛ فلا يحكم بالبطلان إذا أدى هذا الاستكمال إلى نفي التجهيل المدعى به، وذلك كما لو خلت من وصف العقار المحجوز وتعيين حدوده، وأمكن معرفة ذلك من الشهادة العقارية المرفقة بالقائمة.

أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه^(١)، ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد (مادة ١٧٤/١ مرافعات).

كما يجب إخبار مصلحة الضرائب، عملاً بنص المادة (٢/١٧١) من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣، ذلك أن لها امتيازاً على أموال الممول، ويحصل الإخبار هنا بخطاب مسجل بعلم الوصول^(٢).

ويتم الإخبار بإيداع القائمة، بموجب ورقة من أوراق معاونين، تتضمن البيانات العامة لهذه الأوراق^(٣) فضلاً عن البيانات الخاصة المنصوص عليها في المادة (٤١٨)، وهي:

- ١- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.
- ٢- تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال.
- ٣- بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة.
- ٤- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.
- ٥- إنذار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل؛ وإلا سقط حقه في تقديم الاعتراض.
- ٦- إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة ٤٢٥ مرافعات.

(١) وهؤلاء هم الدائنون أصحاب الرهون الرسمية والحيازية وحقوق الاختصاص والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل تسجيل التنبيه.

(٢) أستاذي د. حامد أبو طالب، إجراءات التنفيذ الجبري، ص ٢٨٢.

(٣) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٦/٥٩٤.

هذا ويترتب على خلو ورقة الإخبار من هذه البيانات أو بعضها؛ بطلان الإخبار، وفقا لنص المادة (٤٢٠) مرافعات، ولا شك أن البطلان هنا وإن كان مقررا بنص القانون؛ إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام، ويعمل في شأنه بالقاعدة العامة المقررة في المادة (٢٠) مرافعات، بحيث لا يقضى بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء أو البيان.

ويجب على معاون التنفيذ الذي قام بإعلان ورقة الإخبار، إخطار مكتب الشهر بحصول الإخبار خلال ثمانية أيام من إجرائه، وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه، ويصبح الدائنون الذين تم إخبارهم وفقا للمادة (١/٤١٧) طرفا في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير، ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأثيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو بمقتضى أحكام نهائية (مادة ٤١٧). ويترتب على ذلك أنه ليس للدائن المباشر للإجراءات الاتفاق بمفرده مع المدين أو الحائز على شطب تسجيله أو إنذاره للحائز، والتأثيرات المتعلقة بهما، أو أن يسحب القائمة المودعة، أو يشطب التأشير بإيداعها، ذلك أن هذه الإجراءات لم تعد ملكا للدائن المباشر للإجراءات أو وفقا على مصلحته؛ وإنما يجب للقيام بذلك رضاء جميع الدائنين الذين تم إخبارهم، أو صدور أحكام نهائية عليهم جميعا^(١). ويترتب على إغفال إخبار جميع أصحاب الشأن أو بعضهم بإيداع القائمة؛ عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يتم إخباره^(٢).

ثانيا: الإعلان العام عن إيداع القائمة:

وهو إعلان يوجه إلى كافة وليس إلى أشخاص بعينهم كما في الإخبار، والغرض منه؛ أن يعلم بالتنفيذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص، بحيث يكون لمن تعلق له حق بالعقار، أو لمن له مصلحة، إبداء ما يراه من اعتراضات على قائمة شروط البيع. ولذلك أوجب القانون أن يعلن قلم الكتاب عن إيداع قائمة شروط بيع العقار في إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية، وأن يقوم فضلا عن ذلك

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/٤٤٣.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص٦٩٣.

بلصق إعلانات في اللوحة لمعدة للإعلانات بالمحكمة، وذلك خلال ثمانية أيام^(١) من تاريخ آخر إخبار بإيداع القائمة، وعلى قلم الكتاب أن يودع محضر لصق أو تعليق الإعلان في اللوحة ونسخة من الصحيفة المنشور فيها الإعلان، ملف التنفيذ خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان (مادة ١/٤٢١ مرافعات).
وفضلا عن هذا الإعلان أجاز القانون لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه (مادة ٢/٤٢١).

المبحث الثاني

الاعتراض على قائمة شروط البيع

رأينا أن التنفيذ على العقار يمر حتى الآن بإجراءات متعددة ومدد زمنية طويلة، فالدائن يقوم أولا وبعد إعلان السند التنفيذي للمدين؛ بإعلان تنبيه نزع الملكية، ثم يقوم بتسجيل التنبيه، ثم يقوم بإنذار الحائز وتسجيل الإنذار، ثم يقوم بإيداع قائمة شروط البيع، ثم يتولى قلم الكتاب إخبار الأشخاص الواجب إخبارهم بإيداع القائمة، ويؤشر بالإخبار على هامش تسجيل التنبيه، ثم يعلن إعلانا عاما عن إيداع القائمة.

وبديهي أنه قد تحدث اعتراضات على هذه الإجراءات من أطراف التنفيذ أو غيرهم، وهذه الاعتراضات يجب تصفيتها قبل بيع العقار؛ ولذا أوجب المشرع كما رأينا تحديد جلسة للنظر فيما يكون من اعتراضات على التنفيذ على العقار، وهذه الاعتراضات قد يكون موضوعها بطلان في الإجراءات المشار إليها، أو ملاحظات على الشروط الواردة في قائمة شروط البيع، وقد تكون اعتراضات أخرى غير ذلك ولكن المشرع رأى ضرورة تصفيتها قبل البيع.

ونتناول الحديث عن هذه الاعتراضات في مطلبين، نبين في الأول منهما ماهية الاعتراض وموضوعه ونبين في الثاني النظام الإجرائي للاعتراض.

(١) وهو ميعاد ناقص يجب أن يتم الإعلان خلاله.

المطلب الأول

ماهية الاعتراض وموضوعه

أولاً: تعريف الاعتراض:

الاعتراض على القائمة هو التمسك بتعديل شروط البيع، أو ببطان إجراءات التنفيذ على العقار لسبب يتعلق بالشكل أو بالموضوع أو لأي سبب آخر، بشرط أن يكون هذا السبب مؤثراً في طريق التنفيذ أو في سيره أو في صحته أو بطلانه أو في جوازه أو عدم جوازه^(١).

والاعتراض بهذا المعنى هو خصومة ذات شكل خاص ترفع في ميعاد معين وفي شكل خاص للتمسك بما تقدم، ومن شأنها أن توقف إجراءات البيع حتى يفصل فيها بحكم انتهائي؛ إذ لو صحت لأدت إلى بطلان التنفيذ أو تعديل شروط البيع، وليست هذه الخصومة مقصورة على المعارض ومباشر الإجراءات فحسب؛ وإنما هي من شأن المدين أيضاً (أو الحائز) وجميع أصحاب المصلحة في التنفيذ على العقار^(٢).

ويرى البعض^(٣) أن الاعتراض على القائمة -كاصطلاح قانوني- يقصد به معنيان:
الأول: شكلي: وهو الطريقة أو الوسيلة القانونية التي تستعمل في إبداء المنازعات، أو بعبارة أخرى؛ الإجراء الذي تقدم به الملاحظات ووجه الاعتراض التي يبدي بها صاحب المصلحة عدم رضاه عن شروط القائمة أو عن إجراءات التنفيذ.
والثاني: موضوعي: ويقصد به ذات المنازعة في إجراءات التنفيذ أو فيما تضمنته القائمة من شروط، وبعبارة أخرى مضمون الاعتراض.

ثانياً: موضوع الاعتراضات:

بينت المادة (٤٢٢) الاعتراضات على قائمة شروط البيع بأنها؛ أوجه البطلان السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات، وجميع الملاحظات على شروط

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٦٩٦- د. نبيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٦٢٤.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٦٩٨ و ٦٩٩.

(٣) د. عبدالباسط جميعي، طرق وإشكالات التنفيذ، ص ٤٣.

البيع، كما أن المادتين (٤٢٣ و ٤٢٤) اشتملت على طلبات تقدم بطريق الاعتراض على القائمة، وأوجبت المادة (٤٢٥) اتباع طريق الاعتراض أيضا في حالة أخرى. ومن ثم فإن موضوع الاعتراضات قد يكون أحد ثلاثة أنواع؛ الأول: أوجه البطلان، والثاني: الملاحظات، والثالث: بعض الاعتراضات الخاصة. ونبين ذلك فيما يلي:

النوع الأول: أوجه البطلان:

ويقصد بها في مفهوم المادة (٤٢٢) العيوب الشكلية والموضوعية التي تشوب الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات، بما في ذلك مقدمات التنفيذ، فأوجه البطلان قد تكون شكلية، وقد تكون موضوعية:

أ- البطلان لعيب شكلي:

إذا شاب الإجراءات بطلان لعيب شكلي؛ فإن هذا البطلان يثار بطريق الاعتراض، ومثال ذلك: عدم إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه قبل إعلان التنبيه، أو بطلان تنبيه نزع الملكية أو إعلانه، أو بطلان إعلان الحائز أو الكفيل العيني، أو عدم تسجيل التنبيه بعد إعلانه، أو عدم تسجيل إنذار الحائز، أو البطلان الذي يشوب إيداع القائمة أو الإعلان عنه. وبصفة عامة كافة العيوب الشكلية التي تصيب الإجراءات المتخذة قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات.

ب- البطلان لعيب موضوعي:

كذلك إذا كان العيب الذي شاب الإجراءات عيب موضوعي؛ فإنه يثار بطريق الاعتراض على القائمة، ومثال العيوب الموضوعية: البطلان لعدم توفر الحق في التنفيذ لعدم توفر شروط الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له، والبطلان لعدم جواز الحجز على العقار كونه غير مملوك للمدين، أو أن الحاجز ليس له صفة ولا مصلحة في الحجز، أو أن التنفيذ تم بناء على حكم غير نافذ وغير مشمول بالنفاد المعجل.

النوع الثاني: الملاحظات على شروط البيع:

ويقصد بها كل نقد يوجه إلى شروط البيع الواردة بالقائمة، بقصد تعديلها أو تغييرها أو الإضافة إليها أو حذف بعضها^(١).

١- ومعنى الملاحظات بالإضافة؛ أن يضيف كل ذي مصلحة ممن يجوز لهم الاعتراض، ما يراه من الشروط محققا لمصلحته، كما لو طلب مستأجر العقار الإشارة إلى حقه حتى لا ينازعه مشتري العقار.

٢- ومعنى الملاحظات بالتغيير؛ أن يطلب كل ذي مصلحة تغيير شرط أو أكثر من شروط البيع دون المساس بجوهره، مثل طلب زيادة الثمن الأساسي^(٢)، أو إجراء البيع صفقة واحدة بدلا من صفقات، أو العكس.

٣- وأما الملاحظات بالحذف، فيقصد بها حذف شرط مخالف للنظام العام أو القانون أو شرط ضار بالمزايدة، مثل حذف شرط يتضمن الفوائد الربوية، وطلب حذف شرط عدم رد الثمن في حالة استحقاق العقار، وطلب حذف شرط إجراء بيع العقار صفقة واحدة^(٣).

النوع الثالث: الاعتراضات الواردة في نصوص خاصة:

أجاز المشرع في نصوص خاصة إبداء بعض الاعتراضات بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، وهذه الاعتراضات هي: طلب وقف التنفيذ على الحصة الشائعة، وطلب وقف بيع بعض العقارات المحجوزة، وطلب تأجيل إجراءات بيع العقار، وطلب وقف الإجراءات لرفع دعوى الفسخ على المدين، وقد ورد النص على هذه الاعتراضات في المواد (٤٢٣-٤٢٥) مرافعات، ونتناولها على النحو الآتي:

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٧٠٤.

(٢) كأن تكون الحصة شائعة في عقار مرهون، أو أحد العقارات المرهونة، أو حصة شائعة في مجموع عقارات مرهونة

(٣) د. طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، ص ٣٨٥.

أ- طلب وقف التنفيذ على الحصة الشائعة:

إذا كان التنفيذ على حصة شائعة تدخل ضمن أعيان مفرزة، فلكل دائن ذي حق مقيد على هذه الأعيان المفرزة التي تدخل ضمنها الحصة الشائعة^(١)، أن يطلب التنفيذ على الأعيان المفرزة، ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة الشائعة^(٢).

والغرض من هذا النظام تفادي بيع الحصص الشائعة بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية وتبعيض الضمان مما يعود ضرره على الدائنين معاً؛ فإذا لم يتخذ الدائن صاحب الحق المقيد على أعيان مفرزة إجراءات التنفيذ خلال الأجل الذي حدده الحكم لاتخاذ الإجراءات جاز للحاجزين على الحصة الشائعة ولسائر الدائنين الذي صاروا طرفاً في الإجراءات أن يمضوا في بيع الحصة^(٣).

وفي هذه الحالة يصدر الحكم بوقف إجراءات التنفيذ مؤقتاً على الحصة الشائعة، ويحدد الحكم القاضي بوقف الإجراءات للمعترض مدة يجب خلالها أن تبدأ إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة، وإذا انقضت هذه المدة دون أن يبدأ المعترض إجراءاته يجوز التنفيذ على الحصة الشائعة^(٤).

ب- طلب وقف بعض العقارات المحجوزة:

يجوز القانون لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المبينة في التنبيه؛ إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه، تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في إجراءات التنفيذ. (مادة ٤٢٤/١ مرافعات).

(١) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٤٢٢.

(٢) المرجع السابق، ص ٤٢٣.

(٣) د. أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ، ص ٧٩٥.

(٤) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٤٢٢.

ولا يترتب على صدور الحكم بوقف إجراءات التنفيذ على بعض العقارات زوال الحجز عليها؛ وإنما يظل هذا الحجز قائماً بالنسبة إليها ومنتجاً لآثاره إلى أن يتم بيع العقارات التي صدر الحكم بقصر الحجز عليها^(١).

وإذا تبين بعد البيع أن ثمن العقارات المباعة يكفي للوفاء بحقوق جميع الدائنين؛ فإن ذلك يؤدي إلى زوال الحجز عن العقارات التي أوقفت الإجراءات بشأنها؛ أما إذا لم تكفي حصيلة البيع للوفاء بهذه الديون؛ فإن لكل دائن أن يمضي في التنفيذ على العقارات التي وقف بيعها.

ووفقاً للفقرة الأخيرة من المادة (٤٢٤) فإنه يجوز إبداء طلب الوقف في أية حالة تكون عليها الإجراءات قبل اعتماد العطاء، إذا طرأت ظروف تبرر ذلك، كما لو ارتفعت أسعار العقارات المحجوز عليها.

ج- طلب تأجيل إجراءات بيع العقار:

يجب القانون للمدين وحده^(٢) أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، تأجيل إجراءات بيع العقار إذا كان صافي ما تغله أموال المدين في سنة واحدة يكفي لحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذي صاروا طرفاً في الإجراءات (مادة ٤٢٤/٢). ويجوز للمدين إبداء هذا الطلب إذا طرأت ظروف تبرر ذلك في أية حالة تكون عليها الإجراءات إلى ما قبل اعتماد العطاء. (مادة ٤٢٤/٣).

ويدل النص صراحة على أن العبرة ليست فقط بالقيمة التي يغلها العقار المحجوز؛ وإنما أموال المدين، سواء كانت العقار المحجوز عليه أم غيره من الأموال المملوكة للمدين، شريطة أن يكون ما يتحصل من هذه الأموال في مدة لا تزيد عن سنة.

ولم يحدد النص المدة التي يؤجل إليها البيع؛ وإنما أشار إلى المدة التي تتحصل فيها قيمة الأموال المحجوز لأجلها، ومن ثم يمكن أن يؤجل البيع لأكثر من سنة، ليقوم المدين خلال السنة بالوفاء بحقوق الحاجزين ومن صاروا طرفاً في الإجراءات.

(١) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٤٢٤.

(٢) ومن ثم فلا يستفيد من النص غير المدين، كالحائز والكفيل العيني.

وبلاحظ أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير وجهة الأسباب التي تدعو لطلب تأجيل إجراء البيع، واطمئنانها على قدرة المدين على الوفاء في الأجل الذي تحدده له، والغرض من ذلك تمكين المدين من فرصة للوفاء بما هو مطلوب منه واستبعاد عقاره من البيع بعد قيام القرينة على ترجيح إمكانه الوفاء إذا أمهل^(١).

وإذا أصدرت المحكمة حكمها بتأجيل البيع إعمالاً لهذا النص؛ فإن عليها أن تضمن الحكم الصادر بالتأجيل، الموعد الذي تبدأ فيه الإجراءات في حالة عدم الوفاء، وعليه أن تراعي في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.

د - طلب وقف إجراءات التنفيذ حتى يفصل في دعوى الفسخ:

وتتمثل هذه الحالة في أن بائع العقار محل التنفيذ أو المقايض به، يريد أثناء إجراءات التنفيذ عليه أن يرفع على المشتري أو المقايض (وهو المدين المحجوز عليه) دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو فرق المقايضة^(٢).

وفي هذه الحالة أوجبت المادة (٤٢٥) على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطريق المعتاد ويدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه.

وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ على العقار

(١) د. رمزي سيف، إجراءات التنفيذ، ص ٤٣٨.

(٢) د. طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ، ص ٣٨٧.

المطلب الثاني

النظام الإجرائي للاعتراض على قائمة شروط البيع

أولاً: الأشخاص الذين يجوز لهم الاعتراض:

حددت المادة (٤٢٢) مرافعات، الأشخاص الذين يجوز لهم الاعتراض على القائمة، وصنفتهم في هذا التحديد إلى صنفين:

- ١- أشخاص يفترض فيهم توفر الصفة والمصلحة للاعتراض على قائمة شروط البيع، وهم: المدين، والحائز، والكفيل العيني، والدائنون الذين سجلوا تنبيهاتهم، والدائنون أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية والذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات من تاريخ التأشير على هامش تسجيل التنبيه بإخبارهم بإيداع القائمة.
- ٢- كل ذي مصلحة -غير هؤلاء السابق ذكرهم ممن يفترض فيهم الصفة والمصلحة- ويمكن أن يكون منهم دائنوا المدين العاديون، ودائنوه أصحاب الحقوق المقيدة على العقار بعد تسجيل التنبيه، ومن له حق انتفاع أو ارتفاق على العقار، ومستأجر العقار له مصلحة في النص على حقه في القائمة، حتى لا ينازعه مشتري العقار فيما بعد، وللدائن مباشر الإجراءات حق الاعتراض، رغم أنه الذي وضع الشروط وأودع القائمة؛ إلا أنه قد يرى تعديل بعض الشروط التي وضعها^(١).

وهؤلاء يجب أن تتوفر فيهم المصلحة بأوصافها المقررة في المادة الثالثة مرافعات؛ فلا تكفي المصلحة الاقتصادية، كمن يطلب تعديل بعض شروط القائمة التي تضر بمصلحته الاقتصادية كمشتري للعقار بالمزاد.

ثانياً: إجراءات الاعتراض وميعاده والمحكمة المختصة به:

أوجبت المادة (٤٢٢) مرافعات، أن تقدم أوجه البطلان في الإجراءات، والملاحظات على شروط البيع، بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل؛ وإلا سقط الحق في التمسك بها. ولكل ذي

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٦٩٨ و ٦٩٩.

مصلحة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض.

ومن ثم فلا يجوز الاعتراض الذي يقدم بالطريق المعتاد لرفع الدعوى، ولا يوقف البيع، ولا يمنع من سقوط الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات، كما لا يجوز الاعتراض لأول مرة في الجلسة المحددة لنظر اعتراض آخر، سواء أكان الاعتراض مقدما من ذات المعارض لسبب آخر في الميعاد أم من غيره^(١).

ووفقا للمادة (٤٢٢) فإنه يجب أن يتم التقرير بالاعتراض في قلم كتاب محكمة التنفيذ^(٢) قبل الجلسة المقررة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل، وهذا الميعاد من المواعيد المرتدة، بمعنى أنه يجب أن يتم الإجراء (التقرير بالاعتراض) قبل الميعاد.

والغرض من هذا الميعاد؛ تمكين أصحاب الشأن من الاطلاع على الاعتراض قبل الجلسة، للرد عليه أثناء انعقادها، وتمكين المحكمة من الاطلاع على الاعتراض؛ لتفصل فيه بشكل فوري في الجلسة إن أمكن ذلك.

وعلى الرغم من وجوب الالتزام بهذا الميعاد؛ إلا أنه تقبل من أطراف التنفيذ الطلبات الجديدة المتصلة بالنظام العام، ولو لم يتم التقرير بها في الميعاد، كما تقبل الطلبات والملاحظات المقدمة من غير هؤلاء ممن لم يتم إخبارهم بإيداع القائمة، في أية حالة تكون عليها الإجراءات ولا ينتقيد هؤلاء بالميعاد الوارد في المادة (٤٢٢)^(٣).

ووفقا للفقرة الثانية من المادة ذاتها؛ فإن لكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم بالفقرة الأولى للمادة؛ إبداء ما لديه من الملاحظات أو أوجه البطلان، بطريق التدخل عند نظر الاعتراض، أي ولو كان قد فوت على نفسه الميعاد المحدد للاعتراض.

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٧٠٠.

(٢) وهي محكمة التنفيذ التي يقع في دائرتها العقار المحجوز عليه أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة.

(٣) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٧٠١.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجب إعلان التقرير بالاعتراض إلى ذوي الشأن، ولا يكلفون بالحضور أمام المحكمة، لعلمهم سلفا بالجلسة المحددة لنظر الاعتراضات، حيث سبق إخبارهم بها ضمن بيانات الإخبار عن إيداع قائمة شروط البيع.

ثالثا: الأثر المترتب على الاعتراض:

يترتب على التقرير بالاعتراض في قلم كتاب محكمة التنفيذ في الميعاد المحدد، أثران^(١):

الأول: وقف إجراءات التنفيذ إلى حين صدور حكم في الاعتراض: ويترتب هذا الأثر بقوة القانون بمجرد تقديم الاعتراض، ودون صدور حكم بالوقف.

والثاني: سقوط تحديد الجلسة المحددة لبيع العقار؛ فإذا حكم في الاعتراض برفضه، أو انتهت الخصومة فيه دون حكم في الموضوع، كان لذي الشأن طلب تحديد جلسة للبيع.

حيث يجوز للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا فيها؛ أن يستصدر أمرا من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة البيع، ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا. (مادة ١/٤٢٦ مرافعات).

رابعا: الفصل في الاعتراض:

يشكل الاعتراض على قائمة شروط البيع خصومة قضائية بالمعنى الدقيق، شأنه في ذلك شأن كافة منازعات التنفيذ، ومن ثم ينظر القاضي الاعتراض ويفصل فيه بحكم يحسم المنازعة^(٢).

وتختلف سلطة قاضي التنفيذ عند الفصل في الاعتراض بحسب موضوع الطلب في الاعتراض، فإذا تضمن الاعتراض أسباب بطلان شكلية؛ فصلت فيها المحكمة. وإذا تضمن الاعتراض أسباب بطلان موضوعية؛ فإن قاضي التنفيذ يفصل في

(١) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٤٢٦.

(٢) د. طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ، ص ٣٩٢.

المنازعات المتعلقة بالبطلان والملاحظات على شروط القائمة، باعتبارها منازعة موضوعية، ويكون الحكم الصادر فيها حكماً موضوعياً، سواء كان صادراً بإجابة المعارض، أو برفض المعارض، أو صادراً دون الفصل في موضوع المعارض، كالحكم بعدم قبول المعارض لانتفاء المصلحة أو رفعه بعد الميعاد.

وإذا تضمن المعارض أسباب بطلان موضوعية، ولم تتوفر للمحكمة عناصر البت في الموضوع، جاز لها ألا تتعرض للموضوع، وتأمراً بالاستمرار في التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة^(١).

وبالنسبة للمعارض على قائمة شروط البيع بطلبات وقف التنفيذ وتأجيله وفقاً للمادتين (٤٢٣ و ٤٢٤) مرافعات؛ وهي دعاوى وقتية بحسب طبيعة الطلب منها، يكون الحكم بوقف الإجراءات بالنسبة لبعض العقارات وقصره على البعض الآخر ووقف التنفيذ على الحصة الشائعة وتأجيل البيع حكماً وقتياً.

وإذا صدر حكم قاضي التنفيذ برفض المعارض؛ فإنه يجوز أن يكون مشمولاً بالإنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها، عملاً بالمادة (٥/٢٩٠) مرافعات، والتي تقضي بشمول الأحكام الصادرة لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به بالإنفاذ المعجل.

وقد سبقت الإشارة إلى أنه وفقاً لتعديل المادة (٢٧٧) مرافعات بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧؛ فإن جميع الأحكام التي يصدرها قاضي التنفيذ سواء كانت موضوعية أم وقتية، وأياً كانت قيمة الدعاوى التي صدرت فيها الأحكام؛ فإن الطعن فيها يكون بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية التي يتبعها قاضي التنفيذ.

(١) الطعن رقم ٣٤ لسنة ٣٤ قضائية - جلسة ١٩٦٧/٦/٢٧.

الفصل الثالث

بيع العقار

الفصل الثالث

بيع العقار

بعد انتهاء مرحلة التمهيد لبيع العقار، ننتقل إلى المرحلة الثالثة من مراحل التنفيذ على العقار، وهي مرحلة البيع، وتعد أكثر المراحل أهمية، لما يجرى فيها من نزع ملكية العقار جبرا عن مالكة ونقلها إلى المشتري بالمزاد العلني.

حيث يتم بيع العقار في مزاد علني يحيطه المشرع بكثير من الضمانات الإجرائية والقضائية، تختلف عن تلك المقررة في التنفيذ على المنقول، إذ يتولى قاضي التنفيذ بنفسه إجراء المزايدة على العقار، عبر إجراءات تكاد تكون معقدة ومطولة قصد بها الاحتياط في نزع ملكية العقار وبيعه بالمزاد العلني.

وتبدأ هذه الإجراءات بضرورة تقديم طلب من ذوي الشأن بتحديد جلسة لإجراء البيع، ثم تحديد مكان البيع وفق القواعد المقررة، ثم الإعلام بالبيع من خلال إخبار أشخاص محددين أوجب المشرع أن يتم إخبارهم بالبيع قبل ميعاده، ثم الإعلان العام عن البيع ليعلم به كل من يرغب في شراء العقار بالاشتراك في المزاد.

فإذا تم الإعلام بالبيع بشكل صحيح؛ فإن على ذوي الشأن تقديم طلب لقاضي التنفيذ بإجراء البيع في الجلسة المحددة، وقد يتم تأجيل البيع أو وقفه لأسباب حدده المشرع، فإذا استؤنف البيع وتم بيع العقار؛ فإن على المشتري بالمزاد أن يدفع الثمن الذي رسى به المزاد، وقد يتخلف عن دفع هذا الثمن فيتأجل البيع أو تعاد المزايدة، وفي جميع الأحوال لا يكفي القانون برسو المزاد واعتماد العطاء لاكتساب ملكية العقار؛ وإنما يوجب أن يصدر حكم بإيقاع البيع ويتم تسجيله ليترتب على هذا الحكم آثار مهمة تتعلق بملكية العقار وتطهيره من الحقوق العينية التبعية. ونبين ذلك في ثلاثة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: الإعلام بالبيع.

المبحث الثاني: إجراءات البيع.

المبحث الثالث: الحكم بإيقاع البيع وآثاره.

المبحث الأول الإعلام بالبيع

يقتضي بيع العقار بالمزاد العلني أن يتم نشر خبر المزاد بين الناس حتى يتمكن من يرغب في الشراء من دخول المزاد والتقدم لشراء العقار، ومن ثم ضمان حضور أكبر عدد من المزايديين وبما يزيد المنافسة بينهم ويؤدي إلى ارتفاع ثمن العقار، ولا يتم ذلك إلا من خلال الإعلام بالبيع وتاريخه ومكانه، بالوسائل المقررة قانوناً.

والإعلام بالبيع يقتضي أن يكون تاريخ البيع محدداً ومعلوماً، وأن يكون مكان البيع محدداً ومعلوماً كذلك، ثم يتم بعد ذلك الإخبار بالبيع والإعلان عنه وفقاً للقواعد المقررة، ونبين ذلك فيما يلي:

أولاً: تحديد ميعاد البيع ومكانه:

أ- تحديد ميعاد جلسة البيع:

رأينا أن المشرع يوجب أن يشتمل محضر إيداع قائمة شروط البيع على تاريخ جلسة للنظر في الاعتراضات على القائمة وتاريخ جلسة يجري فيها بيع العقار؛ فإذا لم تقدم اعتراضات؛ فإن تحديد ميعاد الجلسة الأولى يعتبر كأن لم يكن ويتم الإعلان عن البيع في الجلسة المحددة دون حاجة إلى تحديد ميعاد جديد^(١) (مادة ٤١٩ مرافعات). أما إذا قدمت اعتراضات؛ فإن تحديد ميعاد جلسة البيع يعتبر كأن لم يكن ويتم تحديد جلسة جديدة بعد الفصل في الاعتراضات.

وهذا يعني أن تحديد جلسة البيع الوارد في محضر إيداع القائمة هو تحديد مؤقت وليس نهائي، وموقوف على عدم تقديم الاعتراضات، فإذا قدمت اعتراضات على القائمة؛ سقط هذا التحديد^(٢)، ويجب أن يتم تحديد جلسة جديدة للبيع وفقاً للقواعد المقررة في المادة (١/٤٢٦) مرافعات.

(١) د. أمينة النمر، إجراءات التنفيذ، ص ٤٣٣.

(٢) د. رمضان عبدالكريم علام، الوجيز في التنفيذ الجبري، ص ٣٧٥.

ووفقا للمادة المشار إليها؛ فإن للدائن الذي يباشر الإجراءات، ولكل دائن أصبح طرفا في الإجراءات^(١)، أن يستصدر أمرا من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة البيع، ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ، وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا^(٢). ولا يقتصر الحق في طلب تحديد جلسة البيع على هؤلاء فقط؛ وإنما يجوز وفقا للمادة (٤٣٥) للمدين أو الحائز أو الكفيل العيني، أن يطلب من القاضي تحديد هذه الجلسة وإجراء المزايدة.

ب- تحديد مكان البيع:

يقتضي الإعلام بالبيع أن يتم أيضا تحديد المكان الذي سيجرى فيه البيع، ووفقا للمادة (٤٢٧) مرافعات؛ فإن الأصل أن يتم البيع في المحكمة، ومع ذلك فإن لكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار، أو في مكان غيره.

ثانيا: الإخبار بالبيع والإعلان عنه:

أ- الإخبار بالبيع:

يوجب القانون -بعد تحديد ميعاد البيع ومكانه- أن يقوم قلم الكتاب بالإخبار عن البيع، ويتم الإخبار لأشخاص محددين وفقا للمادة (٢/٤٢٦) مرافعات، وهم: المدين والحائز والكفيل العيني، والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم، والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه.

(١) وفقا للمادة ٤١٧ مرافعات.

(٢) وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "الأصل وعلى ما تقضي به المادة ٤٢٦ من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ لا يصدر أمرا بتحديد جلسة البيع إلا بعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا، ومن المقرر أن عدم نهائية الحكم المنفذ به أمام قاضي التنفيذ هو من أسباب الوقف الوجوبي لإجراءات البيع بحيث يسوغ الطعن بالاستئناف في الحكم بإيقاع البيع إذا ما صدر بعد رفض طلب وقف الإجراءات بناء عليه، عملا بالمادة ١/٤٥١ مرافعات ويوجب الحكم بوقف البيع". (نقض ١٩٧٩/١/١٤ لسنة ٢٧ قضائية ص ٢١٣).

وقد حددت المادة المشار إليها وسيلة هذا الإخبار، بالنص على أن يخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (٤١٧) بتاريخ جلسة البيع ومكانه.

كما حددت المادة (٢/٤٢٦) المشار إليها الميعاد الذي يجب أن يتم فيه الإخبار، وهو ثمانية أيام على الأقل قبل الجلسة المحددة للبيع^(١).

ولم ينص المشرع على البطلان جزاء لتخلف الإخبار أو عدم القيام به في الميعاد المحدد؛ ومن ثم لا يحكم بالبطلان إلا إذا تم التمسك به من صاحب المصلحة فيه، وعليه أن يثبت عدم تحقق الغاية بتخلف إخباره أو إخباره بعد الميعاد، وذلك عملاً بالقاعدة العامة في البطلان وفقاً للمادة (٢٠) مرافعات^(٢).

ب- الإعلان العام عن البيع:

فضلاً عن الإخبار عن البيع على النحو المشار إليه، والذي يتم لأشخاص محددين؛ فإن القانون يوجب الإعلان العام عن البيع، وهذا الإعلان هو جوهر عملية الإعلام ببيع العقار؛ إذ به يتحقق علم الناس ببيع العقار ويتمكنوا من الاشتراك في المزاد والتقدم لشراء العقار، وقد أوجب القانون على قلم كتاب المحكمة أن يعلن عن البيع بوسيلتين، هما: اللصق والنشر:

١- الإعلان باللصق:

يوجب القانون (مادة ٤٢٨) أن يقوم قلم الكتاب بالإعلان عن البيع بلصق إعلانات تشتمل على بيانات محددة، في أماكن محددة، وفي ميعاد محدد. حيث يجب أن تشتمل هذه الإعلانات وفقاً للمادة (٤٢٨) على البيانات الآتية:

(١) وتجدر الإشارة إلى أن القاعدة المقررة في المادة ٢/٤٢٦ بوجوب إخبار هؤلاء الأشخاص، لا تنطبق وتعتبر شرطاً لازماً لصحة الإجراءات؛ إلا إذا كان ميعاد الجلسة قد تحدد وفقاً لنص المادة ١/٤٢٦، أو كان الميعاد المحدد في محضر إيداع القائمة قد تعدل بسبب تأجيل البيع أو وقفه أما إذا كان الميعاد كما هو في جلسة

(٢) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٦٣٦.

- ١- اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار.
 - ٢- بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع، وذلك بتعيين العقار بشكل واضح من حيث موقعه وحدوده ومساحته ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه، وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تحديد العقار وبيانه بشكل واضح.
 - ٣- تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع.
 - ٤- الثمن الأساسي للعقار، أو الثمن الأساسي لكل صفقة إذا كان البيع يتم على صفقات.
 - ٥- تاريخ يوم المزاد وساعته، أي الميعاد المحدد لجلسة بيع العقار.
 - ٦- بيان المكان الذي يجري فيه البيع، سواء كان المحكمة المختصة بالتنفيذ، أو العقار نفسه، أو أي مكان آخر يكون قاضي التنفيذ قد حدده بناء على طلب ذوي الشأن ووفقاً للمادة (٤٢٧).
- ويجب على قلم الكتاب لصق هذه الإعلانات في الأماكن المحددة بالمادة (٤٢٩) مرافعات، وهي:
- ١- باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.
 - ٢- باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز أو للقسم الذي تقع العقارات المعلن عن بيعها في دائرته.
 - ٣- اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ، فإذا كانت العقارات تقع في دوائر محاكم متعددة، فيتم لصق إعلانات في اللوحة المخصصة للإعلانات بكل محكمة من هذه المحاكم.
- وعلى معاون التنفيذ أن يثبت في ظهر صورة الإعلان أنه أجرى اللصق في الأماكن المحددة، ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ.
- وقد أوجبت المادة (٤٢٨) مرافعات، أن يتم لصق هذه الإعلانات قبل اليوم المحدد لإجراء البيع بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ولا تقل عن خمسة عشر يوماً.

ويجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنًا من قاضي التنفيذ بلصق عدد آخر من إعلانات البيع، بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، ويجوز عند الاقتضاء الاقتصاد في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي. وسواء أمر القاضي بزيادة الإعلان باللصق أو بالاقتصاد فيه؛ فإن الأمر الصادر منه لا يكون قابلاً للتظلم (مادة ٤٣١ مرافعات).

٢- الإعلان بالنشر:

فضلاً عن الإعلان باللصق على النحو السابق بيانه؛ فإن القانون أوجب في المادة (٤٣٠) على قلم الكتاب أن يقوم بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية، ولا يذكر في هذا الإعلان حدود العقار.

وقد أوجبت هذه المادة أن يتم الإعلان بالنشر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (٤٢٨)، أي قبل اليوم المحدد للبيع بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً.

ويجب على قلم الكتاب بعد نشر الإعلان أن يودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشراً عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه.

وتجيز المادة (٤٣١) لكل من الحاجز والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة، أن يستصدر إذنًا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام، دون أن يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي حال من الأحوال. كما يجوز عند الاقتضاء الاقتصاد في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي.

وسواء صدر أمر القاضي بزيادة النشر أو بالاقتصاد فيه؛ فإن هذا الأمر لا يكون قابلاً للتظلم منه.

ثالثاً: بطلان الإعلان عن البيع:

الإعلان عن البيع وفقاً للإجراءات والمواعيد التي سبق بيانها، واجب إجرائي يجب القيام به قبل بيع العقار؛ فإذا تخلف إجراء من إجراءات الإعلان أو خولف الميعاد المقرر لإجرائه؛ فإن الإعلان يكون باطلاً وفقاً للقواعد العامة في البطلان إذا لم تتحقق الغاية من البيان أو الإجراء المعيب، وهذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام، وإنما يتعلق بمصلحة الخصوم، ومن ثم يجب على صاحب المصلحة التمسك به وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة قانوناً.

وقد تضمنت المادة (٤٣٢ مرفعات) كيفية التمسك بالبطلان وميعاده، فأوجبته على ذي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة بالتنفيذ على العقار، قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل؛ فإذا لم يراعي هذا الميعاد؛ سقط حقه في التمسك بالبطلان.

وإذا تمسك الخصم بالبطلان على الوجه وفي الميعاد المقرر قانوناً؛ فإن على قاضي التنفيذ أن يحكم في أوجه البطلان في نفس اليوم المحدد لبيع العقار، ولا يتم تحديد يوم آخر للفصل في أوجه البطلان حتى لا تتعطل إجراءات البيع بعد الإعلان عنه، وعليه أن يحكم في أوجه البطلان المقرر بها في قلم الكتاب قبل افتتاح المزيدة. والحكم الذي يصدره القاضي في هذا الشأن، سواء ببطلان الإجراءات أو عدم بطلانها يكون حكماً نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق.

فإذا حكم القاضي ببطلان إجراءات الإعلان عن البيع؛ فإن عليه أن يأمر بتأجيل البيع إلى يوم آخر يحدده ويأمر بإعادة إجراءات الإعلان التي حكم ببطلانها. أما إذا رأى أن النعي بالبطلان غير صحيح وأن إجراءات الإعلان صحيحة؛ فإنه يحكم برفض طلب البطلان ويأمر بإجراء المزيدة على الفور.

المبحث الثاني

إجراءات البيع

بعد الانتهاء من الإعلان عن البيع على النحو الذي بيناه؛ تتخذ إجراءات بيع العقار، وذلك وفقا لإجراءات محددة نص عليها القانون، تبدأ بتقديم طلب البيع من أحد ذوي الشأن إلى قاضي التنفيذ، لإجراء البيع، والذي قد يتم تأجيله رغم تقديم الطلب، كما قد يقف لسبب من الأسباب، فإذا استؤنفت الإجراءات بعد التأجيل أو الوقف، أو كانت الإجراءات قد تمت بغير تأجيل أو وقف؛ فإن البيع يتم في جلسة المزايدة، عبر إجراءات محددة للمزايدة، فإذا تم البيع في جلسة المزايدة؛ فإن هناك واجبات تقع على عاتق من اعتمد عطاؤه، ليتم بعد ذلك التقرير بالشراء. ونبين ذلك فيما يلي:

أولاً: إجراء البيع بناء على طلب:

على الرغم من كافة الإجراءات السابق بيانها والتي تبدأ بتبنيه نزع الملكية ثم تسجيله ثم إيداع القائمة والفصل في الاعتراضات عليها، ثم الإعلان عن البيع في جلسة ومكان تم تحديدهما مسبقاً؛ إلا أن المشرع يوجب لإجراء البيع أن يتم تقديم طلب به من ذوي الشأن، فلا يجوز البيع رغم كل ما سبق من إجراءات إلا بعد تقديم هذا الطلب؛ وإذا تم البيع بغير طلب؛ فإنه يكون باطلاً.

أ- صاحب الصفة في تقديم طلب البيع:

حدد المشرع صاحب الصفة في تقديم طلب البيع بنصه في المادة (١/٤٣٥) على أن "يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو أي دائن أصبح طرفاً في الإجراءات وفقاً للمادة ٤١٧ وذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع".

ومن ثم فإن الصفة في طلب البيع قاصرة على من حددتهم المادة المشار إليها؛ فإذا تم تقديم الطلب من غيرهم؛ فإنه لا يكون مقبولا، ولو كان لمقدمه مصلحة في البيع، كمن يرغب في شراء العقار، وإذا أجرى قاضي التنفيذ المزايدة من تلقاء نفسه

بغير طلب؛ فإن البيع يكون باطلا كذلك^(١)، كما يبطل البيع إذا تم بناء على طلب من دائن عادي غير حاجز^(٢)؛ إذ العبرة في الاعتداد بالطلب أن يكون مقدمه ممن ورد ذكرهم في المادة المذكورة.

ب- الحكمة من اشتراط طلب إجراء البيع:

تكمن الحكمة في اشتراط هذا الطلب في حماية المدين حتى لا يباع عقاره بغير داع؛ إذ لو لم يطلب البيع أحد ممن أشارت إليهم المادة (٤٣٥) فإنه يكون من الأفضل عدم اتمامه، لاحتمال الاتفاق بينهم جميعا على ترك إجراءات التنفيذ أو إرجائها بسبب الوفاء ببعض الديون والتراضي على إمهال المدين في أداء البعض الآخر، أو بسبب عدم ملائمة الوقت للبيع بثمان مناسب^(٣).

ج- الأثر المترتب على عدم تقديم الطلب:

يجب تقديم طلب البيع من أحد المذكورين، وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحدهم كان البيع باطلا (مادة ٤٣٥/٢)، فإذا لم يتقدم أحد ذوي الشأن بطلب إجراء المزايدة؛ فإن على قاضي التنفيذ أن يأمر بشطب قضية البيع، أي يوقف البيع إلى أجل غير مسمى، حتى ولو حضر جميع ذوي الشأن ولم يقدم أحدهم طلب البيع، والشطب هنا مجرد إجراء يقصد به إلغاء وإسقاط تحديد يوم البيع، ومن ثم وقف التنفيذ، ويظل البيع موقوفا حتى يقدم الطلب من أحد ذوي الشأن، فإذا تم تقديمه بعد الشطب، فإن قاضي التنفيذ يحدد جلسة وفقا لما نصت عليه المادة (٤٢٦) مرافعات^(٤).

(١) وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه "لايجوز للقاضي أن يسير في إجراءات البيع من تلقاء نفسه بل سيره فيه موقوف على طلب الدائن طالب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة، بحيث إذا لم يطلبه أحد من هؤلاء فواجبه إيقاف البيع، وأرباب الشأن من بعده وما يريدون، أما أن يجرى المزاد وتوقيع البيع من تلقاء نفسه مع عدم وجود طلب من صاحب الحق القانوني فيه؛ فإن حكمه يقع باطلا لعدم استيفائه شرطا أساسيا من الشروط المقررة". (نقض ١٩٣٥/٦/٦ مجموعة القواعد القانونية، ج ٤٧٥/١ قاعدة رقم ٢٥).

(٢) نقض: الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٤٩ قضائية - جلسة ١٩٨٠/٤/١٠.

(٣) د. أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ، ص ٧٣١.

(٤) ويجب في هذه الحالة مراعاة القواعد المتعلقة بالإخبار والإعلان عن البيع.

ثانيا: تأجيل البيع أو وقفه:

على الرغم من تقديم طلب بإجراء البيع على النحو الذي أشرنا إليه؛ فإن هذا البيع قد يتم تأجيله، كما قد يتم وقفه.

أ- تأجيل البيع:

قد يتأجل بيع العقار بعد تحديد جلسة البيع والإعلان بها، وذلك لأكثر من سبب، كما لو كان صافي ماتغله أموال المدين في سنة واحدة يكفي للوفاء بالديون، أو كان الإعلان عن البيع باطلا لسبب من الأسباب، أو تم التأجيل مراعاة لأسباب قوية، أو تم التأجيل لتتقيص الثمن، وذلك على النحو الآتي:

١- التأجيل بسبب ما تغله أموال المدين في سنة:

أشرنا إلى أن القانون يجيز للمدين وحده أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، تأجيل إجراءات بيع العقار إذا كان صافي ما تغله أموال المدين في سنة واحدة يكفي لحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذي صاروا طرفا في الإجراءات (مادة ٢/٤٢٤). ويجوز للمدين إبداء هذا الطلب إذا طرأت ظروف تبرر ذلك في أية حالة تكون عليها الإجراءات إلى ما قبل اعتماد العطاء. (مادة ٣/٤٢٤).

وفي هذه الحالة يتم تأجيل البيع إلى جلسة أخرى يحددها قاضي التنفيذ مراعيًا في ذلك إمهال المدين سنة للوفاء بديونه قبل بيع العقار المحجوز عليه.

وهذا التأجيل قد يحدث نتيجة الاعتراض على قائمة شروط البيع بطلب التأجيل من المدين، كما قد يحدث بطلب يقدم من المدين لقاضي التنفيذ في أي وقت قبل اعتماد العطاء، ولو في جلسة البيع.

٢- التأجيل بسبب بطلان الإعلان عن البيع:

قلنا إنه إذا تخلف إجراء من إجراءات الإعلان عن البيع أو خولف الميعاد المقرر لإجرائه؛ فإن الإعلان يكون باطلا وفقا للقواعد العامة في البطلان إذا لم تتحقق الغاية من البيان أو الإجراء المعيب، ويجب على صاحب المصلحة التمسك بالبطلان وفقا

للإجراءات والمواعيد المحددة قانوناً، وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة بالتنفيذ على العقار، قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل؛ فإذا حكم القاضي ببطالان إجراءات الإعلان؛ فإن عليه أن يأمر بتأجيل البيع إلى يوم آخر يحدده ويأمر بإعادة إجراءات الإعلان التي حكم ببطالانها (مادة ٤٣٢ مرافعات).

٣- التأجيل مراعاة لأسباب قوية:

حيث نصت المادة (٤٣٦) مرافعات على أنه "يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية ولا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع".

فيتم التأجيل في يوم البيع ذاته إذا وجدت أسباب قوية لذلك التأجيل، كما إذا حدثت ظروف من شأنها أن قل عدد الحاضرين للاشتراك في المزايدة، كانقطاع المواصلات، أو حدوث اضطرابات تحول دون حرية الانتقال، أو ارتكاب أعمال إجرامية أو تدليسية بقصد منع الراغبين في المزايدة من الحضور أو الحد من حرية المزايدة، أو حدث خطأ في الإعلان عن البيع في الصحف أدى إلى عدم حضور المزايدين^(١).

ويتم تأجيل البيع في هذه الحالة بذات الثمن الأساسي دون تغيير، ولا يقوم القاضي من تلقاء نفسه بالتأجيل، بل لابد من طلب يقدم من أحد ذوي الشأن، ويخضع تقدير المبرر القوي للتأجيل لسلطة القاضي التقديرية، ولا يكون حكمه في هذا الشأن قابلاً للطعن فيه بأي طريق^(٢).

٤- التأجيل لتقصي الثمن:

حيث نصت المادة (٤٣٨) مرافعات على أنه "إذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضى الحال ذلك". وسنتناول هذه الحالة لاحقاً.

(١) د. أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ، ص ٧٣٤.

(٢) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٦٣٩.

تحديد جلسة البيع بعد التأجيل والإعلان عنها:

إذا تم التأجيل قبل يوم البيع أو في يوم البيع ذاته؛ فإنه يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالتأجيل على تحديد جلسة لإجراء البيع في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من التأجيل (مادة ٤٤١ مرافعات)، ويجب أن يعاد الإعلان عن البيع وفقا للقواعد المقررة في المواد (٤٢٨-٤٣٠)، ولكن لا يعاد الإخبار عن البيع؛ إلا إذا كان التأجيل قد حدث لعدم الإخبار^(١).

ب- وقف البيع:

قد يحكم قاضي التنفيذ بوقف بيع العقار في بعض الحالات، وتختلف سلطته في الحكم بالوقف باختلاف الأسباب، فبعض أسباب الوقف توجب على القاضي الحكم به ولا تكون له سلطة في ذلك، وبعضها الآخر تترك فيه للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالوقف من عدمه، ومن ثم فإن وقف البيع إما أن يكون وجوبيا وإما أن يكون جوازيا:

حالات الوقف الوجوبي:

نقصد بحالات الوقف الوجوبي، تلك التي يجب على القاضي فيها أن يحكم بوقف بيع العقار المحجوز دون أن تكون له سلطة تقديرية في الوقف، وهي حالات لم ترد في القانون على سبيل الحصر، وأهمها:

١- عدم صلاحية السند التنفيذي لإجراء البيع بمقتضاه، بحيث يحكم القاضي بالوقف وجوبا إذا كان السند الذي يجرى التنفيذ بمقتضاه غير صالح لإجراء بيع العقار، ويرجع عدم الصلاحية إلى كون السند غير صالح بداية للبيع، أو صار هذا السند غير صالح لسبب طرأ عليه، وذلك على النحو الآتي:

الصورة الأولى: أن يكون السند غير صالح بداية لإجراء البيع، وإن كان صالحا للحجز بمقتضاه، كما لو كان التنفيذ يجرى بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، وحل ميعاد

(١) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٦٣٩.

جلسة بيع العقار قبل أن يصبح الحكم نهائياً، حيث أوجبت المادة (٤٢٦) على القاضي قبل تحديد جلسة البيع أن يتحقق أولاً من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً.

الصورة الثانية: أن يطرأ على السند التنفيذي ما يجعله غير صالح لإجراء البيع بمقتضاه، كما لو كان حكماً نهائياً مطعوناً عليه بالنقض أو التماس إعادة النظر، وأمرت محكمة الطعن بوقف التنفيذ إعمالاً للمادتين (٢٤٤ و ٢٥١) مرافعات. أو كان السند التنفيذي قد رفعت بشأنه دعوى التزوير، وأمرت المحكمة التي تنتظرها بإجراء التحقيق حول التزوير إعمالاً لنص المادتين (٥٢ و ٥٥)^(١) من قانون الإثبات.

٢- إذا رفعت دعوى الفسخ من بائع العقار المحجوز أو المقايض به، تطبيقاً لنص المادة (٤٢٥) مرافعات ووفقاً للإجراءات والمواعيد التي أوجبتها؛ فإن على قاضي التنفيذ أن يأمر بوقف بيع العقار.

٣- إذا تبين للقاضي أنه لم يتم الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة بشكل صحيح على قائمة شروط البيع، أو أن بعض الأحكام الصادرة في هذه الاعتراضات لم تصبح نهائية بعد، كما لو كان الحكم برفض الاعتراض مطعوناً عليه بالاستئناف وما زال الطعن منظوراً أمام محكمة الاستئناف.

٤- إذا رفعت دعوى الاستحقاق الفرعية بطلب الحكم باستحقاق العقار وبطلان إجراءات التنفيذ، فإن على القاضي أن يأمر بوقف البيع لحين الفصل في الدعوى، وإذا حل يوم البيع قبل أن يحكم القاضي بالوقف، كان لرافع الدعوى أن يطلب من القاضي وقف البيع، وذلك بطلب يقدم قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل (مادة ٤٥٥ مرافعات)، وعلى القاضي في هذه الحالة أن يجيبه إلى طلبه ويحكم بالوقف.

(١) نصت المادة (٥٢) إثبات على أنه "إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق". ونصت المادة (٥٥) من القانون ذاته على أن "الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة ٥٥ يقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية".

٥- إذا لم يتقدم أحد ذوي الشأن بطلب البيع في اليوم المحدد لإجراء المزايدة؛ فإن على قاضي التنفيذ أن يأمر بشطب قضية البيع، ويوقف البيع لأجل غير مسمى.

الأثر المترتب على توفر حالة من حالات الوقف الوجوبي:

باستثناء الحالة الأخيرة من حالات الوقف الوجوبي^(١) التي بينهاها؛ فإن وقف البيع هنا يكون وجوبيا على القاضي وعليه أن يحكم به دون سلطة تقديرية في ذلك، إذ تنحصر سلطته هنا على التحقق من توفر مقتضيات الوقف في كل حالة، وعلى الرغم من وجوبية الوقف بحكم القانون؛ إلا أن القاضي لا يملك الحكم به من تلقاء نفسه؛ وإنما يجب للحكم به أن يطلبه أحد الخصوم.

والحكم الصادر في طلب الوقف هو حكم صادرا في طلب وقتي، ويكون قابلا للطعن فيه، على النحو الآتي:

١- إذا كان الحكم صادرا بقبول طلب الوقف، فإنه يكون قابلا للطعن وفقا للقواعد العامة. (ويستثنى من ذلك حكم الوقف نتيجة لرفع دعوى الاستحقاق، فقد قدمنا أنه غير قابل للطعن فيه بأي طريق).

٢- أما إذا كان الحكم قد صدر برفض الوقف في حالة من حالات الوقف الوجوبي وتم البيع؛ فإن الطعن في حكم رفض الوقف يكون تبعا للطعن في حكم البيع ذاته وفقا للمادة (٤٥١)، ولا يطعن في حكم رفض الوقف على استقلال.

حالات الوقف الجوازي:

تختلف هذه الحالات عن الحالات السابقة في أن الوقف هنا جوازي ومتروك لسلطة القاضي التقديرية بحسب ما يستبينه من طلب الوقف وما يستند إليه من المبررات، وحالات الوقف الجوازي تتعلق بأسباب تستجد بعد الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع، ومن أمثلتها:

(١) إذ يتم الوقف هنا وجوبا بحكم القانون ولو لم يطلبه أحد الخصوم، وعلى القاضي أن يأمر بالشطب من تلقاء نفسه، ما دام لم يتقدم أحد ذوي الشأن بطلب إجراء البيع.

- ١- إذا حدث بطلان في الإجراءات استجد بعد الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع.
- ٢- إذا كان هناك بطلان في الإجراءات سابق على جلسة الاعتراضات ولم يبد قبلها؛ إلا أنه متعلق بالنظام العام، فيجوز إيدأؤه في أية حالة تكون عليها الإجراءات.
- ٣- أن يطلب ذي المصلحة وقف البيع لحين صدور حكم في المنازعة الموضوعية بانقضاء الدين، أو إلغاء سند الحجز، أو سقوط الدين بمضي المدة.
- ٤- إذا تم طلب الوقف من أحد الدائنين الذين يجب إخبارهم بالبيع، ولم يكن قد تم إخباره، فله أن يقدم اعتراضاته وملاحظاته أمام قاضي التنفيذ بدعوى أصلية، ويطلب وقف البيع.

سلطة قاضي التنفيذ في الحكم بالوقف الجوازي:

إذا رأى القاضي أن يجيب الطالب إلى طلب الوقف بعد تحققه من جدية الطلب والأسباب التي يستند إليها؛ فإنه يحكم بالوقف، وإذا رأى غير ذلك فإنه يحكم برفض طلب الوقف ويأمر بالسير في إجراءات التنفيذ.

والحكم الصادر منه بوقف البيع يكون قابلاً للطعن فيه وفقاً للقواعد العامة، بخلاف الحكم برفض الوقف فإنه لا يطعن فيه لا على استقلال ولا مع الطعن في حكم البيع، لأن الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الوقف قاصر على حالات الوقف الوجوبي^(١).

ثالثاً: إجراء البيع في جلسة المزادة العلنية:

يجرى بيع العقار في الجلسة المحددة للبيع والتي سبق الإخبار والإعلان عنها، ويتم البيع في محكمة التنفيذ التي يقع العقار في دائرتها، أو في نفس العقار، أو في أي مكان آخر يحدده قاضي التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن.

(١) د. عبدالباسط جميعي، طرق وإشكالات التنفيذ، ص ٦١.

وإذا كان بيع المنقول يجرى بمعرفة معاون التنفيذ؛ فإن العقار على خلاف ذلك؛ إذ يجب أن يتولى قاضي التنفيذ بنفسه في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، وذلك بناء على طلب من أحد ذوي الصفة في طلب البيع، وبعد التحقق من الإعلان عن البيع والفصل في الاعتراضات وأن السند التنفيذي أصبح صالحاً لإجراء البيع بمقتضاه.

وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة معاون التنفيذ على الثمن الأساسي والمصاريف، والثمن الأساسي هو ذلك الذي تم تحديده في قائمة شروط البيع وفقاً للمادة (١/٣٧) مرافعات، أو بناء على الفصل في اعتراض متعلق به، أما المصاريف فيقدرها قاضي التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في جلسة البيع قبل افتتاح المزايدة (مادة ٤٣٤ مرافعات)، ولا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك^(١).

ويعين قاضي التنفيذ قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها، مراعيًا في ذلك مقدار الثمن الأساسي (مادة ١/٤٣٧ مرافعات)، والمقصود بذلك القيمة التي يزايد بها كل مزايّد على من يسبقه، كأن تكون ألف جنيه، أو عشرة آلاف، وهكذا، وهذه القيمة يقدرها القاضي مراعيًا في ذلك الثمن الأساسي للبيع بحيث إذا كان هذا الثمن كبيراً كانت مقادير التدرج كذلك^(٢).

وبعد أن يقوم معاون التنفيذ في جلسة البيع بالمناداة على الثمن الأساسي والمصاريف؛ فإن الأمر لا يخلو من أحد الفروض الآتية^(٣):

أ- ألا يتقدم مشتر في جلسة البيع، وفي هذه الحالة يجب على قاضي التنفيذ أن يحكم بتأجيل البيع إلى جلسة أخرى، وينقص الثمن بمقدار العشر، ويجوز تكرار هذه

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/٥١٧.

(٢) د. عبدالباسط جميعي، إشكالات التنفيذ، ص ٧١.

والحكمة من تعيين القاضي لمقادير التدرج، ألا يزايد مشتر على سابقه بمبلغ زهيد لا يلتفت إليه في عقار كبير القيمة، ويراعى أن تحديد القيمة التي يزايد بها، يحول دون المزايدة بقيمة أقل منها.

(٣) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/٥١٧.

العملية -التأجيل وإنقاص الثمن بمقدار العشر - كلما اقتضى الحال ذلك (مادة ٤٣٨ مرافعات).

ب- أن يتقدم مشتر واحد في جلسة البيع، وفي هذه الحالة يعتمد القاضي العطاء إذا انقضت ثلاث دقائق دون أن يتقدم أحد للزيادة على هذا العرض.

ج- أن يتقدم أكثر من مشتر في جلسة البيع، وفي هذه الحالة يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فوراً لمن تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العرض الذي لا يزداد عليه خلال ثلاث دقائق منها للمزايدة (مادة ٤٣٩ مرافعات).

هذا وتجدر الإشارة إلى أن قرار القاضي باعتماد العطاء هو عمل إجرائي لا يتم البيع به، بمعنى أن اعتماد العطاء لا يترتب عليه بذاته أن يصبح من اعتمد عطاؤه مشترياً للعقار؛ وإنما لا بد من الحكم بإيقاع البيع عليه^(١)؛ إذ بهذا الحكم فقط يصبح مشترياً للعقار وبعد أن يقوم بسداد الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل.

رابعاً: واجبات المزايد بعد اعتماد عطاؤه:

يجب على من اعتمد عطاؤه أن يقوم حال انعقاد جلسة البيع بدفع الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل، إلا أنه قد يحدث غير ذلك، وقد عالجت المادة (٤٤٠) مرافعات، احتمالات الدفع أو عدمه بعد اعتماد العطاء، وذلك وفقاً لثلاثة فروض:

الفرض الأول: أن يقوم من اعتمد عطاؤه بدفع الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه.

ويحكم القاضي كذلك بإيقاع البيع على من اعتمد عطاؤه إذا حصل على إعفاء من الإيداع من قاضي التنفيذ، متى كان دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفائه من الإيداع، وللمحكمة سلطة تقديرية في هذا الإعفاء. ولا يشمل الإعفاء من الإيداع هنا رسوم التسجيل إذ يجب دفعها في جميع الأحوال (مادة ٤٤٢).

(١) د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ٥٣٤.

الفرض الثاني: ألا يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كاملاً؛ وإنما يودع الخمس فقط^(١): ففي هذه الحالة يجب تأجيل البيع وجوباً إلى جلسة أخرى تقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستين يوماً من الحكم بالتأجيل، ويجب في هذه الحالة الإعلان عن اليوم المحدد لإجراء البيع وفقاً للقواعد المقررة للإعلان.

ويجب أن يشتمل الإعلان عن البيع في هذه الحالة على: بيان إجمالي بالعقارات التي اعتمد عطاؤها، وعلى اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار، والثمن الذي اعتمد به العطاء (مادة ٣/٤٤١).

وإذا تم تأجيل البيع وفقاً لهذه الحالة؛ فإن الأمر في الجلسة المؤجل إليها لا يخلو من أحد الفروض الآتية^(٢):

١- قيام من اعتمد عطاؤه بإيداع باقي الثمن (أو يحصل على إعفاء من قاضي التنفيذ من الإيداع)، فهنا يحكم القاضي بإيقاع البيع عليه، بشرط ألا يتقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً بكامل الثمن الجديد.

٢- أن يتقدم في هذه الجلسة من يقبل شراء العقار مع زيادة العشر مصحوباً لكامل الثمن، فتعاد المزايدة في هذه الجلسة على أساس هذا الثمن (قيمة العطاء زائداً العشر).

٣- ألا يقوم من اعتمد عطاؤه ودفع خمس الثمن بإيداع باقي الثمن (ولم يحصل على الإعفاء)، ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر؛ فهنا تجب إعادة المزايدة فوراً في نفس الجلسة^(٣) على ذمة من اعتمد عطاؤه، وتعاد المزايدة بالثمن الأساسي الذي بدأت به في الجلسة السابق.

فإذا لم يوجد مشتر أجل قاضي التنفيذ البيع لجلسة أخرى يحددها مع نقص عشر الثمن مرة بعد مرة.

(١) إذا لم يكن قد حصل على إعفاء من قاضي التنفيذ من إيداع الخمس أو مما هو أقل من كامل الثمن.

(٢) أستاذي د. حامد أبو طالب، إجراءات التنفيذ، ص ٣٢٧.

(٣) وهي الجلسة الثانية التي تم تأجيل البيع إليها وأعيد الإعلان عنها.

ويراعى في الجلسة أو الجلسات الأخرى التي يتم تأجيل البيع إليها مع إنقاص عشر الثمن، أنه لا يقبل عطاء إلا مصحوبا بكامل الثمن، وإذا بيع العقار بثمن أقل من الذي اعتمد في الجلسة الأولى؛ ألزم المزايد الأول (الذي تخلف عن إيداع الثمن) بما نقص من ثمن العقار والفوائد، ولكن إذا بيع العقار بثمن أكثر؛ فإن الزيادة يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال (مادة ٤٤٣)، ولا يجوز لمن تعاد المزايدة على ذمته أن يشترك في المزايدة الجديدة، ولكن له أن يدفع بقية الثمن في أي وقت قبل إعادة المزايدة، وعندئذ يحكم القاضي بإيقاع البيع عليه.

الفرض الثالث: إذا لم يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كاملا أو خمسه ولم يحصل على إعفاء من الإيداع: فإن المزايدة تعاد على ذمته في نفس الجلسة (مادة ٤٤٠/٣).

خامسا: التقرير بالشراء للغير:

يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك (مادة ٤٤٤).

ويلاحظ أن هناك أشخاص يحظر عليهم إجراء المزايدة على العقار لحسابهم، سواء بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وهؤلاء الأشخاص هم المدين والقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها والمحامون الوكلاء عن المدين أو عمن يباشر الإجراءات؛ فإذا تقدم أحدهم للمزايدة فإن البيع يكون باطلا (مادة ٣١١ مرافعات).

كما يلاحظ عدم سريان هذا الحظر في حق الحائز أو الكفيل العيني، حيث يجوز لأي منهما التقدم لشراء العقار في المزاد، وقد أشارت المادتين (١٠٧٤ و ١٠٧٥ مدني والمادة ٤٤٨ مرافعات) بالنسبة للحائز، ويسري هذا الحكم أيضا على الكفيل العيني، كونه غير مسئول عن الدين مسئولية شخصية^(١).

(١) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٦٤٧.

المبحث الثالث

الحكم بإيقاع البيع

لا يترتب على مجرد اعتماد عطاء المزايد انتقال ملكية العقار إليه، وإنما يجب صدور حكم من قاضي التنفيذ بإيقاع البيع عليه بعد اعتماد عطاؤه، ولا بد من تسجيل هذا الحكم حتى تنتقل ملكية العقار للمشتري بالمزاد العلني. ومن ثم نتناول بيان شكل حكم البيع وبياناته وطبيعته وتسجيله وآثاره في مطلبين على النحو الآتي:

المطلب الأول

شكل الحكم بإيقاع البيع وبياناته وطبيعته وتسجيله

أولاً: شكل الحكم وبياناته وطبيعته:

نصت المادة (٤٤٦) مرافعات على أن "يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه. ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره".

ووفقاً لهذه المادة فإن حكم إيقاع البيع يأخذ من حيث الشكل شكل الحكم القضائي؛ إذ يجب أن يصدر بديباجة الأحكام، كما يجب أن يشتمل على الأوراق والبيانات التي نصت عليها المادة المشار إليها، وهي:

- ١- بيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع.
- ٢- إجراءات الإعلان عن بيع العقار.
- ٣- يجب أن يشتمل منطوق الحكم على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني - بحسب الأحوال - بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه.
- ٤- صورة من قائمة شروط البيع.
- ٥- صورة من محضر جلسة بيع العقار.

وفضلاً عن هذا، يشتمل الحكم في حال صدوره بعد تخلف المزايد عن إيداع الثمن على إلزام هذا المزايد بدفع فرق الثمن إذا بيع العقار بأقل منه، ويكون الحكم في هذه الحالة سندا تنفيذياً بهذا الفرق، يمكن التنفيذ بمقتضاه جبراً عن المزايد وعلى أمواله ببيعها لاقتضاء فرق الثمن^(١).

ولا يعتبر حكم إيقاع البيع حكماً قضائياً من حيث المضمون، وذلك لأنه لا يحسم نزاعاً ولا يفصل في خصومة ولا يلزم تسببيه^(٢)، ومن ثم هو قرار يصدر بما للقاضي من سلطة ولائية^(٣).

ولذلك قضت محكمة النقض بأن "الحكم الصادر برسو المزايد ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات؛ وإنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه، ومن ثم فإنه يترتب على صدور حكم مرسى المزايد وتسجيله الآثار التي تترتب على عقد البيع الاختياري وتسجيله"^(٤).

ويعتبر حكم إيقاع البيع خاتمة المطاف بالنسبة لإجراءات التنفيذ العقاري، ولا يتبقى بعده سوى توزيع حصيلة التنفيذ، وهو يمثل الغاية التي يصبو إليها الحاجزون وكل من يعد طرفاً في الإجراءات وأصحاب المصلحة في شراء العقار، ولهذا فأهميته كبيرة بالنسبة لكل هؤلاء فضلاً عن المدين والحائز وكل من تعلق له مصلحة في التنفيذ،

(١) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٤٤٩.

وقد نصت المادة (٤٤٣) على أن "يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد، ويتضمن الحكم بإيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال".

(٢) د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ٥٣٩.

(٣) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٧٦٤.

ولكن إذا فصل حكم إيقاع البيع في مسألة عارضة طرحت على القاضي؛ فإنه يكون حكماً في خصوصها، ويخضع للقواعد العامة المقررة للأحكام.

(٤) الطعن رقم ١٦٧٦ لسنة ٥٣ قضائية - جلسة ١٩/١١/١٩٨٦.

وهو سند ملكية المشتري وبمقتضاه يتلقى حقه، ولذلك كانت أهميته بالغة بالنسبة إليه^(١).

ثانياً: تسجيل حكم إيقاع البيع:

لا يكفي مجرد صدور حكم إيقاع البيع لاكتساب المزايد الذي اعتمد عطاؤه ملكية العقار وانتقالها إليه؛ وإنما يلزم تسجيل الحكم لترتيب هذا الأثر^(٢).

ويقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال الثلاثة أيام التالية لصدوره (مادة ١/٤٤٧ مرافعات)، ذلك أن المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري توجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك^(٣).

وقد سبقت الإشارة إلى وجوب دفع رسوم التسجيل قبل صدور هذا الحكم، وذلك عند دفع الثمن الذي رسا به المزداد، حيث أوجبت المادة (٤٤٠) على من يعتمد القاضي عطاؤه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل.

وإذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه؛ فإن تسجيل حكم البيع لا يكون واجباً، ويؤشر بالحكم في هامش تسجيل السند الذي تملك الحائز بمقتضاه العقار أصلاً، ويؤشر بالحكم كذلك على هامش تسجيل إنذار الحائز (مادة ٤٤٨)، ونرى أن الأمر كذلك بالنسبة للكفيل العيني، فإذا رسي المزداد عليه فإنه لا يجب تسجيل حكم البيع وإنما يكتفى بالتأشير على النحو المقرر بالنسبة للحائز^(٤).

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/٥٤٠.

(٢) د. أمينة النمر، إجراءات التنفيذ، ص ٤٥٠.

(٣) د. رمزي سيف، إجراءات التنفيذ، ص ٢٧١.

(٤) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٦٥٢.

المطلب الثاني

آثار حكم إيقاع البيع وتنفيذه والطعن فيه

تعتبر إجراءات التنفيذ على العقار قد تمت من تاريخ حكم إيقاع البيع، غير أن آثار هذا الحكم لا تترتب إلا من تاريخ تسجيله؛ فإذا تم تسجيل الحكم وفقا للقواعد المقررة قانونا؛ فإن هذ التسجيل تترتب عليه بعض الآثار، فضلا عن ترتيب حقوق والتزامات في حق مشتري العقار، كما يكون من الجائز الطعن في هذا الحكم وفق قواعد محددة، ونتناول ذلك على النحو الآتي:

أولاً: الآثار المترتبة على تسجيل حكم إيقاع البيع:

يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع أثرين مهمين، أولهما: انتقال ملكية العقار إلى المشتري بالمزاد، وثانيهما: تطهير العقار من الحقوق العينية التبعية.

الأثر الأول: انتقال ملكية العقار إلى المشتري بالمزاد:

يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع انتقال ملكية العقار إلى المشتري بالمزاد العلني، ويكون الحكم المسجل سندا بملكيته، ذلك أن لحكم إيقاع البيع طبيعة مزدوجة، حيث يعد عقد بيع ناقل للملكية من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني إلى مشتري العقار بالمزاد العلني وإن لم يكن البيع صادرا من مالك العقار^(١). وقد نصت المادة (٢/٤٤٧) على ذلك صراحة بنصها على أن يكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع عليه البيع.

فبيع العقار بالمزاد العلني هو بيع ينعقد في مجلس القضاء وتحت إشرافه، ويجب تسجيل الحكم الصادر بإيقاع البيع لانتقال الملكية إلى الراسي عليه المزاد؛ فإذا تم هذا التسجيل فإنه يترتب عليه الآثار التي تترتب على عقد البيع الاختياري وتسجيله^(٢).

(١) د. أمينة النمر، إجراءات التنفيذ، ص ٤٥٠.

(٢) نقض: الطعن رقم ٩٩١ لسنة ٦١ قضائية - جلسة ١٩٩٢/٦/٢٣.

وقد نص المشرع في المادة المشار إليها أن الحكم المسجل لا ينقل إلى المشتري إلا ما كان للمدين أو الحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع، ولا شك أن ذلك إعمالاً للقاعدة التي تقضي بأن الشخص لا ينقل إلى غيره من الحقوق أكثر مما يملك؛ ومن ثم فالعقار ينتقل إلى المشتري بالمزاد محملاً بما كان محملاً به من الحقوق العينية الأصلية التي كانت على العقار قبل تسجيل الحكم كحق الانتفاع أو الارتفاق.

ويتضح من ذلك أن حكم إيقاع البيع بعد تسجيله، ينقل إلى المشتري الملكية ذاتها التي كانت للمنفذ ضده بما عليها من أعباء، ولا ينشئ ملكية جديدة مبتدأة لمن وقع عليه البيع، فيعتبر المشتري بالمزاد خلفاً للمنزوعة ملكيته إيجاباً وسلباً، فيخرج العقار من ذمة الأخير لينتقل إلى ذمة الأول بالحالة التي كان عليها، وتسري في حقه كافة الحقوق العينية الأصلية التي يكون العقار محملاً بها كحق الارتفاق أو حق الانتفاع، كما يسري في حقه ما عقده من إيجار، ويجوز أن ترفع عليه ما كان يجوز رفعه على المنزوعة ملكيته من دعاوى الإلغاء أو البطلان أو الفسخ أو الرجوع^(١) أو الاستحقاق أو الرجوع لعبث يشوب إجراءات التنفيذ^(٢)، كما يستمر في مواجهته ما يكون قد رفع منها، ويحتاج بالأحكام الصادرة ضد المدين قبل تسجيل حكم مرسى المزاد، ولو لم تسجل تلك الأحكام الصادرة أو صحف الدعاوى التي صدرت فيها، لأنه باعتباره خلفاً للمدين يعتبر ممثلاً فيها^(٣). ولا يسري في حق المشتري من تصرفات المدين إلا ما يسري في مواجهة أطراف التنفيذ^(٤).

(١) ويجب ملاحظة ما تنص عليه المادة ١٥ من قانون تنظيم الشهر العقاري من وجوب تسجيل دعاوى الإبطال والفسخ والإلغاء والرجوع أو التأشير بها على هامش تسجيلات العقود المطعون فيها. وما نصت عليه المادة ١٧ من أثر التسجيل أو التأشير في الاحتجاج بالحق الذي يثبت للمدعي بالحكم في الدعوى على من ترتبت له حقوق عينية على العقار.

(٢) نقض ١٩٦٧/٣/٧ سنة ١٨ ص ٥٥٧.

(٣) د. رمزي سيف، إجراءات التنفيذ، ٤٩٥ - د. فتحي والي التنفيذ الجبري، ٤٩٢.

(٤) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٦/٥٥٣.

وتجدر الإشارة إلى أن عقود الإيجار التي أبرمها المدين بعد صدور حكم مرسى المزاد لا تسري في مواجهة المشتري بالمزاد العلني، ولو كانت سابقة على تسجيل الحكم^(١).

وإذا تم إيقاع البيع بصور حكم مرسى المزاد؛ فإن ثمرات العقار وإيراداته تكون من حق الراسي عليه المزاد، ولا يتعلق بها حق للدائنين، لأن حقه الشخصي في تسلم العقار ينشأ من يوم صدور حكم مرسى المزاد لا من تسجيله، فتتقضي الحراسة التي يفرضها القانون ويرتفع عن المدين وصف الحارس، ولا تكون له صفة في التصرف في ثمرات العقار وإيراداته أو في تأجيرها، ولا يكون تصرفه أو تأجيرها نافذاً في حق الراسي عليه المزاد^(٢).

ويترتب على ما سبق من قاعدة أن الشخص لا ينقل إلى غيره من الحقوق أكثر مما يملك، وأن تسجيل حكم إيقاع البيع لا ينشئ ملكية جديدة للمشتري بالمزاد العلني، وأن الملكية تنتقل إلى المشتري بالمزاد بالحالة التي كانت عليها قبل حكم إيقاع البيع، النتائج الآتية:

١- أنه إذا لم يكن المحجوز عليه مالكا للعقار؛ فإن حكم إيقاع البيع لا ينقل الملكية للمشتري.

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه "لا ينقل حكم رسو المزاد إلى الراسي عليه المزاد من الحقوق أكثر مما كان للمدين المنزوعة ملكيته، وإذا فمتي كان المدين قد باع الأطيان موضوع النزاع إلى الطاعنين بعقد جدي مسجل قبل نشوء الدين وبذلك انتقلت ملكيتها إليهم قبل اتخاذ إجراءات نزع الملكية؛ فإنه لا يكون من شأن حكم إيقاع البيع أن ينقل ملكية هذه الأطيان إلى من رسا عليه المزاد متى كانت غير مملوكة للمدين المنزوعة ملكيته"^(٣).

(١) نقض: الطعن رقم ٥ لسنة ٤٣ قضائية - جلسة ١٩٧٧/٥/٤.

(٢) نقض ١٩٧١/١٢/١٦ سنة ٢٢ ص ١٠٤٠.

(٣) الطعن رقم ٥٤٣ لسنة ٤٦ قضائية - جلسة ١٩٨١/١/٦.

- ٢- لا يحمى الراسي عليه المزاد من الدعوى التي يرفعها الغير باستحقاق العقار إذا لم يكن مملوكا أصلا للمدين أو كان قد خرج من ملكه بتصرف نافذ في حق الراسي عليه المزاد، ويجوز للمالك الحقيقي أن يرفع دعوى منع التعرض أو دعوى استرداد الحيازة على المشتري بالمزاد إذا كان حائزا للعقار وتوفرت لديه شروط قبول الدعوى، على اعتبار أن تنفيذ حكم مرسى المزاد في مواجهته ولم يكن طرفا في الإجراءات يعد تعرضا للحيازة أو سلبا لها^(١).
- ٣- عدم سريان التصرفات وعقود الإيجار التي أبرمها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في مواجهة المشتري بالمزاد إذا لم يكن عقد الإيجار ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية أو قبل إنذار الحائز أو لم يكن التصرف مشهرا قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية^(٢).
- ٤- انتقال العقار إلى المشتري بالمزاد محملا بالحقوق التي كان محملا بها قبل حكم إيقاع البيع، سواء كانت حق انتفاع أو ارتفاق أو وقف أو حكر^(٣).
- ٥- عدم الاحتجاج على من حكم بإيقاع البيع عليه بدعوى الفسخ التي رفعت من المقايض على المدين لعدم دفع الثمن أو الفرق به إذا لم يكن قد دون في ذيل قائمة شروط البيع في ميعاد الاعتراض بها بما يفيد رفعها، وفقا لأحكام المادة (٤٢٥) مرافعات.
- ٦- يكون للمشتري بالمزاد الحق في الثمار من يوم صدور الحكم بإيقاع البيع لا من يوم تسجيله، فيكون له الثمار التي كانت قائمة عند صدور الحكم، كما يكون له الثمار المدنية التي تستحق عن المدة التالية لصدور الحكم ولا ينفذ في حقه تصرف المدين في شيء من ذلك^(٤).

(١) نقض ١٩٤٩/١/١٧.

(٢) د. أمينة النمر، إجراءات التنفيذ، ص ٤٥١.

(٣) نقض: الطعن رقم ١١٩ لسنة ٢١ قضائية - جلسة ١٠/٦/١٩٥٤.

(٤) نقض ١٩٧١/١/١٢ لسنة ٢٢، ص ١٠٤٠.

الأثر الثاني: تطهير العقار من الحقوق العينية التبعية:

مؤدى القول بأن ملكية العقار تنتقل إلى المشتري بالمزاد العلني محملا بما قد يكون ثابتا عليه من حقوق تسري في مواجهة الدائنين (الحاجزين والمعتبرين طرفا في الإجراءات)؛ أن تنتقل هذه الملكية محملة بالحقوق العينية التبعية المقيدة على العقار قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، بحيث يكون لأصحاب هذه الحقوق أن ينفذوا على العقار تحت يد من حكم بإيقاع البيع عليه (المشتري بالمزاد)، وعليه في هذه الحالة أن يقوم بقضاء الدين، أو بتطهير العقار من الرهن أو يتخلّى عن العقار^(١).

إلا أن المشرع رأى استثناء من هذه القاعدة أن يضع بحكم إيقاع البيع حدا لحقوق الرهن والاختصاص والامتياز المحمل بها العقار، بحيث تنتقل الملكية نقية من هذه الحقوق بتسجيل حكم مرسى المزاد ويطهر العقار بحكم القانون في هذه الحالة^(٢).
فنص في المادة (٤٥٠) مرافعات، على أنه "يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقا لحكم المادة ٤٤٨ تطهير العقار من حقوق الامتياز والاختصاص والرهن الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين ٤١٧ و ٤٢٦ ولا يبقى لهم إلا حقهم في الثمن".

ووفقا لهذه المادة؛ فإن الحقوق التي يطهر منها العقار هي: حقوق الامتياز، وحقوق الاختصاص، والرهن الرسمية والحيازية، ويشترط لذلك شرطين:

- ١- أن يتم تسجيل حكم إيقاع البيع.
- ٢- أن يكون قد سبق إخبار صاحب الحق العيني التبعية بقائمة شروط البيع وبتاريخ جلسة البيع^(٣).

(١) يراجع في ذلك أحكام القانون المدني (المواد ١٠٦٠ - ١٠٧١).

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/٥٦١.

(٣) أما أصحاب الحقوق العينية التبعية المقيدة على العقار الذين لم يتم إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع - وهو فرض نادر الحدوث - فلم يحق تتبع العقار والتنفيذ عليه، وذلك بشرط أن تكون شروط البيع ماسة

"ويبرر هذا الاستثناء أن العقار قد بيع تحت إشراف القضاء وبإجراءات تكفل صيانة حقوق جميع الأطراف ومنهم أصحاب الحقوق العينية التبعية المقيدة على العقار الذين يمكنهم متابعة الإجراءات ومراقبتها والاعتراض عليها حتى يصل ثمن العقار إلى أعلى قدر ممكن، وبعد هذا كله لا معنى لقول ببقاء حقهم في تطهير العقار وطلب إعادة بيع العقار مرة ثانية، ولذلك اكتفى المشرع بتطهير العقار على هذا النحو بدلا من تطهيره وفقا لنصوص القانون المدني"^(١).

ومعنى تطهير العقار أن أصحاب هذه الحقوق، رغم أنها نافذة في مواجهة المشتري لقيدها قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، لا يستطيعون تتبع العقار في يده أو يد خلفائه، ولا يكون لهم إلا حق أولوية على الثمن الذي بيع به العقار، حتى تنتقل الملكية نظيفة إلى المشتري، مما يشجع على رفع ثمن العقار، كما أن حقوق هؤلاء مكفولة بإجراءات الشهر والإعلان، وهم يستوفون حقوقهم بالأولوية من ثمن العقار^(٢).

ثانيا: حقوق مشتري العقار بالمزاد والتزاماته:

تحدد حقوق مشتري العقار والتزاماته وفقا لقانون المرافعات والقانون المدني ووفقا لما ورد بقائمة شروط البيع، فإذا وجدت شروط خاصة في قائمة شروط البيع تحدد حقوق المشتري في تسلم العقار، ومدى حقه في ثماره، وحقوقه في الضمان فيعمل بهذه الشروط التي بيع العقار على أساسها واشتره المشتري على ذلك، فهذه الشروط ملزمة للمنفذ ضده وللدائنين وللمن حكم بإيقاع البيع عليه، أما إذا لم توجد شروط خاصة في القائمة فتتطبق قواعد البيع الواردة في القانون المدني، كما تطبق النصوص الخاصة الواردة في قانون المرافعات^(٣). وذلك على النحو الآتي:

بحقوقهم أو ضارة بمصالحهم؛ فإذا كان البيع بشروط مناسبة أو كان الثمن كافيا للوفاء بحقوقهم؛ فلا يكون لهم التنفيذ على العقار مرة ثانية.

(١) أستاذي د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٣٤٠.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٥٦١/٦.

(٣) أستاذي د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٣٤٤.

- ١- يكون لمشتري العقار أن يتسلمه وفقا للإجراءات المقررة في المادة (١/٤٤٩) مرافعات، فلا يعلن حكم إيقاع البيع، ويجرى تنفيذ هذا الحكم جبرا؛ بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس على حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه، على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل^(١).
- ٢- يكون لمشتري العقار الحق في ثمرات العقار وإيراداته من يوم صدور حكم البيع، ولا يتعلق بها حق للدائنين، ولا يكون للمدين الحق في التصرف في ثمار العقار أو إيراداته ولا الانتفاع بها أو استغلالها؛ فإذا تصرف في شيء منها فلا يكون تصرفه نافذا في مواجهة مشتري العقار بالمزاد.
- ٣- تنقضي الحراسة التي يفرضها القانون على العقار ولا يعد المدين حارسا عليه كما كان قبل البيع.
- ٤- ليس لمشتري العقار بالمزاد حق ضمان العيوب الخفية (مادة ٤٥٤ مدني)، وإنما له الحق في ضمان الاستحقاق؛ إذ يكون له الرجوع بالثمن والتعويضات إذا استحق العقار، ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع ما يمس حق المشتري في ضمان الاستحقاق. ويلتزم الدائنون بضمان الاستحقاق، أما المدين فلا يلتزم به لأن البيع ليس صادرا منه للمشتري^(٢).
- ٥- إذا كان في العقار منقولات متعلق بها حق لغير المحجوز عليه، وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن (مادة ٢/٤٤٩ مرافعات).

(١) تجدر الإشارة إلى أن المنفذ ضده (المدين أو الحائز أو الكفيل العيني) إذا كان ساكنا في العقار فلا يجبر على الإخلاء بل يظل بصفته مستأجرا لما يشغله من العقار، وذلك إعمالا للمادة السادسة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن.

(٢) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٤٥٣.

ثالثاً: تنفيذ حكم إيقاع البيع والطعن فيه:

يكون حكم إيقاع البيع نهائياً وقابلاً للتنفيذ الجبري بعد صدوره وتسجيله، ويكون هذا الحكم قابلاً للاستئناف في الحالات الواردة في المادة (٤٥١) على سبيل الحصر، وبعد استئناف الحكم في هذه الحالات استثناء على نفاذ الحكم باعتبار أن الاستئناف محصور في أسباب محددة^(١).

ووفقاً للمادة المشار إليها فإنه لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزادة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجب قانوناً.

ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.

ولم ينص المشرع على المحكمة المختصة بنظر الاستئناف على حكم إيقاع البيع، ولا يعد هذا الحكم صادراً في منازعة وقتية أو موضوعية من منازعات التنفيذ، ولا نتفق مع من يرى خضوع الحكم للقواعد العامة من حيث قابليته للاستئناف أو عدمه بحسب قيمة الدعوى، ولكن نرى أن تختص بنظر الاستئناف المحكمة الابتدائية قياساً على القاعدة المقررة في المادة (٢٧٧) والتي تقضي باستئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أي كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية.

وفضلاً عن جواز استئناف حكم إيقاع البيع للأسباب المشار إليها؛ فإنه يجوز رفع دعوى أصلية ببطالان هذا الحكم، وتعتبر هذه الدعوى منازعة موضوعية في التنفيذ، ينعقد الاختصاص بها لقاضي التنفيذ، ويترتب على الحكم فيها بالبطالان زوال البيع وزوال آثاره، ويجوز لكل ذي مصلحة رفعها بشرط اثبات صفته.

إلا أنه يراعى التفرقة في شأن رفع هذه الدعوى بين أطراف التنفيذ وغيرهم، إذ لا يكون لأطراف التنفيذ حق رفع هذه الدعوى إلا إذا كان الحكم مشوباً بالغش، أو ورد

(١) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٤٥٣.

خطأ مادي في تحديد مساحة العقار أو في حدوده، واستمر ذلك الجهل إلى ما بعد فوات ميعاد استئناف حكم إيقاع البيع.

أما بالنسبة لذوي الشأن الذين لم يشتركوا في التنفيذ، فلهم الحق في رفع دعوى أصلية ببطلان حكم إيقاع البيع في مواجهة المشتري بالمزاد^(١).

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٦/٥٦٨.

الفصل الرابع

دعوى الاستحقاق الفرعية

اختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ على العقار:

سبق أن أشرنا إلى أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقفية أيًا كانت قيمتها، وذلك بمقتضى نص المادة (١/٢٧٥) مرافعات، والتي أناطت هذا الاختصاص بقاضي التنفيذ بنص عام يشمل جميع هذه المنازعات، فضلا عن أن هناك نصوص خاصة أخرى أسندت له هذا الاختصاص بالنسبة لمنازعات معينة، وقد بينا ذلك عند الحديث عن الاعتراضات على قائمة شروط البيع، وبجانب هذه النصوص وتلك الاختصاصات؛ فإن المشرع أسند إلى قاضي التنفيذ عند التنفيذ على العقار الاختصاص بدعوى متميزة عن باقي المنازعات، وهي "دعوى الاستحقاق الفرعية"، وأفرد لها الفرع السادس من الفصل الثالث "التنفيذ على العقار"، حيث تضمنت المواد (٤٥٤ - ٤٥٨) التنظيم القانوني والإجرائي لهذه الدعوى.

ونتناول في هذا الفصل ماهية هذه الدعوى وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها والحكم فيها.

أولاً: ماهية دعوى الاستحقاق الفرعية وشروطها:

يشترط أن يكون العقار المحجوز عليه مملوكاً للمدين - مع مراعاة الحجز على عقار الحائز والكفيل العيني - ومع ذلك قد يتمسك الغير بملكية العقار المحجوز عليه، ولم يهمل المشرع ادعاء هذا الغير بالملكية، وفي الوقت ذاته لم يرغب في تعليق مصير التنفيذ وإجراءاته على الفصل في دعوى الملكية وبما قد يضر بالحاجز؛ فأنشأ طريقاً يحقق التوازن بين المصلحتين، يستطيع مدعي الملكية من خلاله المطالبة بملكية العقار وبطلان الحجز، وهذا الطريق هو "دعوى الاستحقاق الفرعية". وهي دعوى موضوعية يرفعها من يدعي ملكية العقار المحجوز قبل بيعه^(١).

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٨١٦.

وتعرف هذه الدعوى بأنها: "منازعة موضوعية في التنفيذ يرفعها شخص من الغير مدعيا ملكيته للعقار أو جزء منه، وذلك بعد بدء التنفيذ عليه وقبل تمامه، ويطلب فيها تقرير حق له على العقار وبطلان إجراءات التنفيذ"^(١).

كما تعرف بأنها: "دعوى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب استحقاق العقار المنفذ عليه أو جزء منه وبطلان إجراءات التنفيذ"^(٢).

ومن خلال تعريف هذه الدعوى يتبين أنه يجب أن تتوفر فيها الشروط الآتية^(٣):

١- أن ترفع الدعوى بعد البدء في التنفيذ وقبل تمامه^(٤)، أي قبل صدور حكم بإيقاع البيع^(٥). وتعد الدعوى دعوى استحقاق فرعية لو رفعت بعد التنبيه وقبل تسجيله، وتسمى فرعية لأنها تنفرع عن إجراءات التنفيذ.

٢- أن يرفع الدعوى شخص من غير أطراف التنفيذ، فلا يجوز لمن كان طرفا في إجراءات التنفيذ على العقار أن يرفع دعوى الاستحقاق الفرعية طالبا الحكم بملكية العقار؛ وإنما يبدي هذه المنازعة بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.

٣- أن ترفع الدعوى على كل من مباشر الإجراءات، والمدين، أو الحائز أو الكفيل العيني، وأول الدائنين المقيدين. وذلك لأن المدعي إذ يطالب بالملكية يوجه الطلب إلى المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال حتى يصدر الحكم في مواجهته، وهو إذ يطالب ببطلان إجراءات التنفيذ يوجه الطلب إلى الدائن مباشر الإجراءات والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة؛ وإن كان المشرع قد اكتفى باختصام أولهم باعتبار أنه المتقدم عليهم في المرتبة وهو صاحب المصلحة الأهم.

(١) د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٦٦١.

(٢) د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٣٥٥.

(٣) د. أمينة النمر، التنفيذ، ص ٤٦٤ - د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ، ص ٦٦١.

(٤) وتختلف هذه الدعوى عن دعوى الاستحقاق الأصلية، وهي التي ترفع قبل البدء في التنفيذ أو بعد تمامه، وتخضع للأحكام الخاصة بها، ولا تخضع لأحكام دعوى الاستحقاق الفرعية.

(٥) فيجب رفع هذه الدعوى قبل إيقاع البيع؛ لأن الهدف منها هو تقاضي البيع؛ فإذا صدر الحكم بإيقاع البيع فلا تقبل الدعوى لانقضاء المصلحة، سواء تم تسجيل حكم البيع أو لم يتم تسجيله.

٤- أن يطلب المدعي في هذه الدعوى ملكية العقار المحجوز كله أو جزء منه أو حصة شائعة أو مفرزة فيه، وأن يطلب بطلان إجراءات التنفيذ، لتخلف شرط من شروط صحة هذه الإجراءات باعتبار أنها تقع على مال ليس مملوكا للمدين المحجوز عليه.

ويعتبر طلب الملكية هو الطلب الأصلي في دعوى الاستحقاق الفرعية، أما طلب بطلان الإجراءات، فهو وإن كان طلبا مندمجا في الطلب الأصلي لأنه من مقتضيات الحكم بالملكية؛ إلا أن المدعي يجب أن يطلبه صراحة لتكون الدعوى من منازعات التنفيذ؛ فإن لم يطلب بطلان الإجراءات؛ كانت دعوى ملكية عادية ولا يختص بها قاضي التنفيذ ولا ترتب أثرا في وقف إجراءات التنفيذ.

ومع هذا يجوز للمدعي أن يطلب بطلان الإجراءات بطلب عارض بعد رفع الدعوى بطلب الملكية وقبل الحكم بعدم الاختصاص والإحالة، ولا يوقف التنفيذ في هذه الحالة إلا بعد التقدم بطلب بطلان الإجراءات لتصحيح شكل الدعوى.

ثانيا: النظام الإجرائي لدعوى الاستحقاق الفرعية:

نصت المادة (٤٥٤) مرفعات على أنه "يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين".

ويتضح من هذا النص أن المشرع حدد الخصوم في الدعوى، والاختصاص بها، وإجراءاتها، وميعاد رفعها، وذلك على النحو الآتي:

أ- الخصوم في دعوى الاستحقاق الفرعية:

بطبيعة الحال يجب أن يكون لهذه الدعوى طرفين، أولهما المدعي الذي يقوم برفع الدعوى، وثانيهما المدعى عليه، وهو من ترفع الدعوى في مواجهته.

١- المدعي في دعوى الاستحقاق الفرعية:

أوجب المشرع أن يتوفر في المدعي في هذه الدعوى وصف خاص، وهو أن يكون من الغير، فلا ترفع هذه الدعوى إلا من الغير، والمقصود به هنا من ليس طرفا في إجراءات التنفيذ^(١)، فلا يجوز لمن كان طرفا في هذه الإجراءات أن يرفع الدعوى، لأن وسيلته في التمسك بحق له على العقار، الاعتراض على قائمة شروط البيع في الميعاد المقرر على النحو الذي سبق بيانه.

٢- المدعى عليهم في دعوى الاستحقاق الفرعية:

أوجب المشرع أن ترفع هذه الدعوى في مواجهة أشخاص محددين يجب على المدعي اختصاصهم، وهم: المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، والدائن مباشر الإجراءات، وأول الدائنين المقيدين.

وإذا لم يتم اختصاص أحد من هؤلاء؛ فإن الدعوى تكون صحيحة ومقبولة، ولكن لا يكون الحكم الصادر فيها حجة في مواجهة من لم يختصم، ووفقا للرأي الراجح فإنه لا يترتب على الدعوى في هذه الحالة وقف إجراءات التنفيذ؛ لأن هذا الأثر لا يترتب إلا إذا استوفت الدعوى الإجراءات المطلوبة قانونا^(٢).

ب- المحكمة المختصة بالفصل في دعوى الاستحقاق الفرعية:

قلنا إن دعوى الاستحقاق الفرعية منازعة موضوعية في التنفيذ، ومن ثم يختص بها قاضي التنفيذ وفقا للقاعدة المقررة في المادة (٢٧٥) مرافعات، ووفقا لصريح نص المادة (٤٥٤) على رفع الدعوى أمام قاضي التنفيذ، فترفع أمام محكمة التنفيذ التي يقع العقار المحجوز عليه أو أحد أجزائه في دائرتها.

(١) ويلاحظ أنه قد يجمع الشخص بين صفتين، بحيث يكون طرفا في التنفيذ بصفة، وغيلا بصفة ثانية، كما لو حجز على شخص بصفته وليا على ابنه، وهو يدعي ملكية العقار بصفته الشخصية، أو حجز عليه بصفته وارثا وهو يدعي ملكية العقار بصفته الشخصية، ففي مثل هذه الحالة يجوز للشخص بناء على صفته الثانية أن يرفع دعوى الاستحقاق الفرعية.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٦/٥٩٣.

ج- إجراءات رفع دعوى الاستحقاق الفرعية وميعادها:

بينت المادة (٤٥٤) أن هذه الدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى، أي بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التنفيذ التابع لها العقار أو أحد أجزائه، وتعلن الصحيفة للمدعى عليهم وفقا للقواعد المقررة في إعلان صحف الدعاوى.

وقد أوجب المشرع في المادة (٤٥٥) أن تشتمل صحيفة الدعوى فضلا عن البيانات العامة، على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى^(١). وذلك لأنه يقع على عاتق المدعي عبء إثبات دعواه^(٢)؛ إلا إذا كان حائزا للعقار؛ فإن ظاهر الحال يؤيده في هذه الحالة وينتقل عبء الإثبات حينذاك إلى عاتق المدعى عليهم، بحيث يجب عليهم نفي هذا الظاهر وإثبات ملكية المدين للعقار^(٣).

ويجب على المدعي أن يودع خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة، والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء^(٤).

هذا ولم يقيد المشرع رفع الدعوى بالميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع؛ وإنما يجوز رفعها بعد البدء في التنفيذ وفي أية حالة كانت عليها الإجراءات، شريطة أن يكون ذلك قبل الحكم ببيع العقار.

(١) فإذا لم تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات العامة لصحف الدعاوى والمنصوص عليها في المادة (٦٣) مرفعات؛ فإن جزء ذلك البطان وفقا للقواعد العامة. على أنه لا يترتب على عدم إيداع المستندات أو توفر البيان الخاص بها بطلان الصحيفة؛ وإنما يترتب على ذلك تعطيل الأثر الموقوف للدعوى، بحيث لا تنتج الدعوى أثرها وهو الحكم بوقف إجراءات البيع.

(٢) ولا شك أنه ليس للمدعي التمسك بملكية العقار؛ إلا إذا كان عقد الملكية مسجلا.

(٣) نقض مدني: الطعن رقم ٢٥١ لسنة ٢٠ قضاائية- جلسة ١٢/٣/١٩٥٣.

(٤) ويقصد بهذه المصاريف: المصاريف اللازمة لإعادة الإعلان عن البيع بعد الحكم بوقفه، إذا حكم برفض دعوى الاستحقاق، وذلك لضمان الوفاء بهذه المبالغ، ولضمان جدية هذه الدعوى.

ثالثاً: الأثر المترتب على رفع دعوى الاستحقاق الفرعية:

قلنا إن هذه الدعوى هي منازعة موضوعية في التنفيذ، ومن ثم فوفقاً لطبيعة منازعات التنفيذ الموضوعية؛ لا يترتب على رفع هذه الدعوى وقف إجراءات التنفيذ بقوة القانون؛ وإنما يحكم القاضي بهذا الوقف في أول جلسة إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك والتي ورد النص عليها في المادة (٤٥٥) مرافعات، وهذه الشروط هي:

- ١- أن يتم رفع الدعوى بشكل صحيح وبالطريق المقرر قانوناً.
- ٢- أن يتم إيداع المبلغ المقدر للوفاء بأتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات.
- ٣- أن ترفع الدعوى في مواجهة من أوجب القانون اختصاصهم فيها.
- ٤- أن تشمل صحيفة الدعوى على بيان المستندات أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى.
- ٥- أن يطلب المدعي وقف إجراءات البيع.

فإذا توفرت هذه الشروط، وجب على القاضي أن يحكم بوقف التنفيذ في الجلسة الأولى لهذه الدعوى^(١)، فإذا حلت الجلسة المحددة لبيع العقار قبل الحكم بالوقف؛ فإن للمدعي أن يطلب من القاضي الأمر بوقف البيع قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل، وعلى القاضي أن يجيبه إلى طلبه.

ولا يترتب على الحكم بوقف التنفيذ زوال الحجز عن العقار، وإنما يظل الحجز باقياً إلى أن يتم الحكم في دعوى الاستحقاق الفرعية.

وجدير بالإشارة أن المشرع نص صراحة في المادة (٤٥٦) على أن الحكم الصادر بالوقف إذا توفرت شروطه، أو رفض الوقف إذا لم تتوفر هذه الشروط، لا يكون قابلاً للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

(١) والحكم بوقف التنفيذ وجوبي على القاضي متى توفرت هذه الشروط، وليس له حينئذ سلطة تقديرية في وقف التنفيذ أو استمراره.

وقد حددت المادة (٤٥٧) نطاق الحكم بوقف التنفيذ؛ بأنه إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزء من العقارات المحجوزة؛ فلا يوقف التنفيذ بالنسبة إلى باقيها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية^(١).

وقد أوجبت المادة (٤٥٨) على القاضي حين يحكم بوقف التنفيذ بالنسبة لجزء معين أو أجزاء محددة من العقارات المحجوزة، أن يقوم بتعديل الثمن الأساسي؛ إذا كان تقدير الثمن في قائمة شروط البيع قد تم على أساس بيع العقار كله صفقة واحدة. كما أوجبت المادة ذاتها على القاضي إذا تم استئناف إجراءات البيع بعد رفض دعوى الاستحقاق؛ أن يقوم بتقدير الثمن الأساسي للأجزاء التي وقفت إجراءات البيع بالنسبة إليها.

رابعاً: الحكم في دعوى الاستحقاق الفرعية:

يفصل قاضي التنفيذ في دعوى الاستحقاق الفرعية باعتبارها منازعة موضوعية في التنفيذ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها حكماً موضوعياً يحسم النزاع على أصل الحق، سواء كان الحكم صادراً باستحقاق العقار، أو برفض الاستحقاق، وتقتصر حجية هذا الحكم على أطرافه.

ومتى صدر الحكم بالملكية؛ فإنه يوجب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ، باعتبار أن الحكم الثاني متوقفاً على الأول، و يكون الحكم الصادر في هذه الدعوى قابلاً للاستئناف بحسب قيمة الدعوى والتي تقدر بقيمة العقار المتنازع عليه، وهذه القيمة تحدد وفقاً للمادة (١/٣٧) مرافعات.

ويجوز شمول الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق بالنفاذ المعجل، باعتباره صادراً في منازعة من منازعات التنفيذ الموضوعية، وفقاً لما نصت عليه المادة (٢٩٠) مرافعات، ومثال ذلك: إذا صدر الحكم برفض الاستحقاق؛ فإنه يكون صادراً لمصلحة طالب التنفيذ، ويجوز شموله بالنفاذ المعجل، سواء كان ذلك بكفالة أو بغير كفالة.

(١) كما لو كانت العقارات مما تتخفف قيمتها بتجزئة بيعها، وكان من المحتمل رفض دعوى الاستحقاق.

مبحث خاص قواعد توزيع حصيلة التنفيذ

مبحث خاص

قواعد توزيع حصيلة التنفيذ

أفرد المشرع الباب الرابع من الكتاب الثاني في قانون المرافعات، لبيان القواعد والإجراءات التي تتبع في توزيع حصيلة التنفيذ، وذلك في المواد (٤٦٩-٤٨٥)، وقد حلت إدارة التنفيذ محل قاضي التنفيذ فيما يتعلق بهذا التوزيع، في حين اقتصر اختصاص قاضي التنفيذ على الفصل في المناقضات والمنازعات المتعلقة بالتسوية. وذلك بنص المشرع في المادة الأولى من القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أنه "وتستبدل عبارة (إدارة التنفيذ) بعبارة (قاضي التنفيذ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي المواد ٣٥٦، ٣٥٨، ٣٦٥، ٣٦٧، ٣٧٦، ٣٧٩، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٨، ٤٨٢، ٤٨٣ من ذات القانون".

والقواعد المتعلقة بتوزيع حصيلة التنفيذ تسري على كافة المحجوز، سواء كان المال المحجوز منقولاً تحت يد المدين أو الغير، أو كان عقاراً مملوكاً للمدين أو الغير، وسواء كان التوزيع يجرى بالمحاسبة بين دائنتين عاديتين، أم بالترتيب حسب درجات الدائنين.

وقد قصد المشرع بهذه القواعد إتمام إجراءات التنفيذ فيما بعد بيع المال المحجوز، ليتم توزيع حصيلة هذا البيع بما يتفق وأحكام القانون وهدفه من الحماية الإجرائية في أعمال التنفيذ، ولمنع المشاكسات التي قد تثور بين الدائنين الحاجزين؛ ومن ثم أوجب أن يتم توزيع هذه الحصيلة تحت إشراف القضاء ورقابته، باعتبار أن هذا التوزيع هو الهدف الأساس من الحجز والبيع، ومن ثم فهو تكملة ضرورية لما سبقه من إجراءات. وقد وضع المشرع بهذه القواعد نظاماً إجرائياً يكفل ضمان التوزيع في حالة اتفاق الخصوم على التسوية، أو عدم اتفاقهم وحدوث منازعات بينهم، كما وضع نظاماً إجرائياً لفصل فيما يثور من المنازعات في هذه المرحلة الختامية لإجراءات التنفيذ، ونبين ذلك على النحو الآتي:

أولاً: الاختصاص بحصيلة التنفيذ وجواز الحجز عليها:

أ- الاختصاص بحصيلة التنفيذ:

بداية نؤكد على أن توزيع حصيلة التنفيذ لا يثير مشاكل إجرائية إلا حيث يتعدد الدائنون ذوو الحق في استيفاء ديونهم من هذه الحصيلة ولا تكون حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوقهم، وعندئذ يتدخل المشرع بقواعد توزيع هذه الحصيلة على هؤلاء الدائنين^(١).

أما إذا كان الحاجز واحدا فإنه يستوفي حقه مباشرة ممن تكون حصيلة التنفيذ تحت يده، سواء كان المحجوز لديه أو معاون التنفيذ أو كاتب المحكمة، وعلى من تكون الحصيلة تحت يده أن يستوثق من استيفاء الحاجز لشروط الوفاء له.

كما أنه إذا تعدد الدائنون الحاجزون وكانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوقهم جميعاً، ومن يعتبر طرفاً في الإجراءات، وجب على من تكون لديه المبالغ المتحصلة من التنفيذ أن يؤدي إلى كل دائن دينه بعد تقديم سنده؛ فإذا لم يكن بيد الدائن الحاجز سند تنفيذي؛ فلا يجوز الوفاء إلا بموافقة المدين، ويكون الوفاء في هذه الحالة اختيارياً تم برضاء المدين.

وفي هاتين الحالتين لا يلجأ إلى التوزيع بمعرفة إدارة التنفيذ وفقاً للقواعد المقررة؛ لأنه لا صعوبة في هاتين الحالتين، ولا حاجة لتدخل إدارة التنفيذ^(٢).

هذا وقد حرص المشرع على بيان من يختص بحصيلة التنفيذ، بنصه في المادة (٤٦٩) على أنه "متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضت خسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر".

(١) د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ٥٥٩.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٦/٦١٨.

وعلى ذلك فإن الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في إجراءات التنفيذ، يختصون بحصيلة التنفيذ ولا يشاركون فيها غيرهم من الدائنين، وقد وضع القانون حدا فاصلا بين من يشترك في التوزيع من الدائنين ومن لا يشترك؛ وهو وقت تمام الحجز على نقود لدى المدين إذا كان المال المحجوز نقودا، أو وقت تمام بيع المال المحجوز؛ فإن كان المال المحجوز منقولا يتم البيع بدفع الثمن، وإن كان المال المحجوز عقارا يتم بيعه بصور حكم إيقاع البيع، أما في حيز ما للمدين لدى الغير فيكون الحد الفاصل بين من يشترك ومن لا يشترك هو مضي خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما في الذمة. ويختص الدائنون الحاجزون ومن يعتبر طرفا في الإجراءات بحصيلة التنفيذ، بقوة القانون، دون أي إجراء يتخذ منهم أو من غيرهم، ولا يلزم صدور حكم بذلك^(١).

ب- جواز الحجز على حصيلة التنفيذ:

تجدر الإشارة إلى أن اختصاص الدائنين المذكورين في المادة (٤٦٩) بحصيلة التنفيذ، لا يحول دون إمكانية الحجز على هذه الحصيلة قبل توزيعها تحت يد من تكون بيده، ولكن الحاجزين اللاحقين الذين حجزوا على الحصيلة، لا يكون لهم الحق إلا فيما يتبقى منها بعد سداد ديون الحاجزين المشار إليهم.

ثانيا: الالتجاء إلى تطبيق قواعد التوزيع:

يتضح مما سبق أن الحاجة إلى الالتجاء إلى تطبيق قواعد التوزيع وإجراءاته على النحو المقرر في قانون المرافعات؛ إنما يكون في الحالة التي يتعدد فيها الحاجزون ومن في حكمهم، وتكون حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم؛ ففي هذه الحالة يوجب القانون على من تكون الحصيلة تحت يده؛ أن يودعها خزنة المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع حسب الأحوال، وعلى المودع أن يسلم قلم تاب المحكمة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده (مادة ٤٧١ مرافعات).

(١) أستاذي د. حامد أبو طالب، التنفيذ الجبري، ص ٣٦٨.

وتمشيا مع فلسفة تبسيط إجراءات توزيع حصيلة التنفيذ -التي انتهجها القانون الحالي- فقد رأى المشرع أن تسير إجراءات التوزيع كتكملة طبيعية وضرورية لإجراءات التنفيذ السابقة عليها، دون حاجة لتقديم طلب من ذوي الشأن، إذ لا يعدو التوزيع ان يكون مرحلة من مراحل التنفيذ الجبري كسائر المراحل، ولذلك أوجب على قلم الكتاب (مادة ٤٧٣) عرض الأمر على إدارة التنفيذ لتجري توزيع حصيلة التنفيذ وفقا للقواعد المقررة^(١).

ثالثا: واجبات من تكون لديه الحصيلة وأثر امتناعه عن تنفيذها:

- ١- قلنا إنه إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات؛ وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل دائن من الدائنين دينه، بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين (مادة ٤٧٠).
- ٢- إذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم؛ وجب على من تكون لديه حصيلة التنفيذ أن يودعها خزانة المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع حسب الأحوال، وعليه في هذه الحالة أن يعد بيانا بالحجوز الموقعة تحت يده ويسلمه لقلم كتاب المحكمة التي أودع خزانتها حصيلة التنفيذ. (مادة ٤٧٢).
- ٣- فإذا امتنع من لديه الحصيلة عن إيداعها خزانة المحكمة؛ فإن لكل ذي شأن الحق في أن يطلب من قاضي التنفيذ وبصفة مستعجلة أن يحكم بالإلزام الممتنع بالقيام بهذا الإيداع في موعد يحدده قاضي التنفيذ.
- ٤- إذا لم يقم من لديه الحصيلة بإيداعها بعد الحكم بالإلزامه بالإيداع وفقا للبند السابق وفي الموعد المحدد؛ فإن القانون يجيز التنفيذ الجبري على أمواله الشخصية سواء المنقولة أو العقارية، حيث يعد الحكم الصادر بالإلزامه بالإيداع سندا تنفيذيا يجوز بمقتضاه التنفيذ على أمواله (مادة ٤٧٤).

(١) د. رمزي سيف، إجراءات التنفيذ، ص ٥٧٤.

رابعاً: اتفاق الحاجزين على توزيع الحصيلة وأثره:

إذا لم تكن حصيلة التوزيع كافية للوفاء بديون جميع الحاجزين ومن اعتبروا طرفاً في الإجراءات، وتم إيداعها خزانة المحكمة؛ فإن ذلك لا يعني سلب حق هؤلاء في الاتفاق فيما بينهم على توزيع الحصيلة المودعة خزانة المحكمة؛ وإنما يكون لهم الحق في هذا الاتفاق ويكون ملزماً لهم، بشرط أن يتفقوا جميعاً على ذلك وأن يشمل الاتفاق المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال، وهنا لا تتبع إجراءات التوزيع المقررة قانوناً؛ وإنما يتم تنفيذ ما اتفقوا عليه، شريطة أن يتم هذا الاتفاق قبل مضي خمسة عشر يوماً من إيداع الحصيلة خزانة المحكمة (مادة ٤٧٣)^(١). ويعتبر هذا الاتفاق بمثابة عقد ملزم لهم جميعاً، ويقدم إلى المحكمة لصرف المبالغ بناء عليه.

خامساً: عدم اتفاق الحاجزين على توزيع حصيلة التنفيذ:

إذا أودعت حصيلة التنفيذ خزانة المحكمة ومضى خمسة عشر يوماً دون توصل ذوي الشأن إلى اتفاق على التوزيع؛ فإن على قلم الكتاب أن يقوم خلال الثلاثة أيام التالية لانتهاء الخمسة عشر يوماً المشار إليها؛ أن يعرض الأمر على إدارة التنفيذ لتقوم هي بهذا التوزيع وفقاً للقواعد المقررة قانوناً (مادة ٤٧٣).

سادساً: قواعد التوزيع وإجراءاته في حالة عدم اتفاق ذوي الشأن:

نظم المشرع قواعد وإجراءات توزيع حصيلة التنفيذ في حالة عدم اتفاق ذوي الشأن وذلك في المواد (٤٧٤) وما بعدها، وقد جاء هذا التنظيم على النحو الآتي:

أ- إعداد قائمة التوزيع المؤقتة:

إذا لم يتفق ذوو الشأن على توزيع حصيلة التنفيذ وتم إيداعها خزانة المحكمة، وبعد قيام قلم الكتاب بعرض الأمر على إدارة التنفيذ في الميعاد المقرر؛ فإنه يجب اتباع الإجراءات المقررة في المادة (٤٧٤)، على النحو الآتي:

(١) لأن إجراءات التنفيذ المقررة قانوناً تبدأ بانقضاء هذا الميعاد.

- ١- على إدارة التنفيذ أن تقوم خلال خمسة عشر يوما من عرض الأمر عليها أن تقوم بإعداد قائمة توزيع مؤقتة، وتودعها قلم كتاب المحكمة.
 - ٢- على قلم الكتاب بمجرد إيداع هذه القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات بتاريخ الجلسة المحددة لمناقشة القائمة المؤقتة وإجراء التسوية ودية.
 - ٣- يراعى في تحديد جلسة التسوية الودية ألا يجاوز ثلاثين يوما من إيداع القائمة المؤقتة، بحيث تقع الجلسة خلال هذا الميعاد^(١).
 - ٤- يكون ميعاد الحضور في هذه الجلسة عشرة أيام، وعلى قلم الكتاب أن يراعي ذلك في إعلان ذوي الشأن.
- ويجب على إدارة التنفيذ في إعداد هذه القائمة المؤقتة؛ أن تحدد مصاريف الحجز والبيع والتوزيع، ويكون لهذه المصاريف أولوية على أي حق ولو كان مضمونا برهن او كان ممتازا، ثم توزع الحصيلة بالترتيب وفقا لقواعد القانون، وتوزع الباقي منها -إن كان- على الدائنين العاديين توزيعا نسبيا، أي بحسب نسبة كل دين إلى مجموع الديون (أي قسمة غرماء)^(٢).

ب- مناقشة القائمة المؤقتة:

أراد المشرع بتحديد جلسة التسوية الودية بعد إيداع القائمة المؤقتة؛ أن يتيح لذوي الشأن فرصة مناقشة القائمة والتوزيع الوارد بها؛ فيجتمعون سويا للاتفاق على التوزيع الوارد بالقائمة أو يتفقون على توزيع آخر يرتضونه، تقاديا لما قد يثور من خلافات بسبب عدم المناقشة وجها لوجه^(٣).

ومن ثم ففي الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش جميع ذوي الشأن في القائمة المؤقتة، وتأمّر إدارة التنفيذ بإثبات ملاحظاتهم في محضر الجلسة، وتكون لإدارة التنفيذ

(١) وهذا الميعاد ميعاد تنظيمي على يترتب على مخالفته بطلان.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ٨٦٢.

(٣) د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ٥٧٧.

السلطة التامة في تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن أو يصح إعلانه، كما يكون لها ضم توزيع إلى آخر، أو تعيين خبراء لتقدير ثمن إحد ما بيع من العقارات جملة، ولها فضلا عن ذلك اتخاذ أي تدابير أخرى يقتضيها حسن سير الإجراءات (مادة ٤٧٥ مرافعات).
وقد افترض المشرع أن تتم التسوية أو لا تتم في هذه الجلسة وذلك وفقا لفرضين على النحو الآتي:

الفرض الأول: الاتفاق على التسوية الودية:

إذا حضر ذوو الشأن جلسة التسوية الودية وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية؛ فإن على إدارة التنفيذ أن تثبت اتفاقهم في محضر، ويوقعه مدير إدارة التنفيذ أو من ينوب عنه، وكاتب الجلسة، والحاضرون في جلسة التسوية من ذوي الشأن، ويعد هذا المحضر سندا تنفيذيا بتنفيذ ما اشتمل عليه (مادة ٤٧٦).

وإذا تخلف أحد ذوي الشأن عن الحضور في هذه الجلسة؛ فإن تخلفه لا يمنع من إجراء التسوية، بشرط عدم المساس بما أثبت في قائمة التسوية الودية لهذا الدائن المتخلف عن الحضور.

ولا يكون لمن تخلف عن حضور هذه الجلسة أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتتها إدارة التنفيذ بناء على اتفاق الخصوم (مادة ٤٧٧ مرافعات). أما إذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور جلسة التسوية الودية؛ فإن على إدارة التنفيذ أن تعتبر القائمة المؤقتة قائمة نهائية (مادة ٤٧٨/٢ مرافعات).

وإذا تمت التسوية الودية في هذه الجلسة بناء على اتفاق الأطراف؛ فإن على إدارة التنفيذ خلال الخمسة أيام التالية أن تقوم بإعداد قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف، وكذلك إذا تخلف جميع ذوي الشأن عن الحضور في الجلسة؛ اعتبرت القائمة نهائية، وتأمّر إدارة التنفيذ في الحالتين بتسليم أوامر الصرف على الخزانة وبشطب القيود سواء تعلقت بديون أدركت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع (مادة ٤٧٨ مرافعات).

الفرض الثاني: عدم الاتفاق على التسوية الودية:

إذا حضر ذوو الشأن جلسة التسوية الودية ولم يتفقوا على التوزيع وفقا للقائمة المؤقتة، أو على توزيع آخر يرتضونه؛ فإن مدير إدارة التنفيذ يأمر بإثبات مناقضاتهم في المحضر، ويحيل الاعتراض إلى قاضي التنفيذ الذي ينظر فيه على الفور.

ج- الإجراءات في حالة عدم الاتفاق على التسوية الودية:

إذا لم تتم التسوية الودية لا اعتراض بعض ذوي الشأن؛ فإن على مدير إدارة التنفيذ أن يأمر -كما أشرنا- بإثبات المناقضات على القائمة، ويحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات الآتية:

١- يجب تقديم المناقضة^(١) في جلسة التسوية الودية ولا يجوز تقديم مناقضة جديدة بعد هذه الجلسة، حتى إذا كان المعارض غائبا عن جلسة التسوية الودية، لأن القانون (مادة ٤٧٧/٢) لا يجيز له على نحو ما رأينا أن يطعن فيما أثبتته القاضي في هذه الجلسة.

٢- يترتب على تقديم المناقضة في القائمة المؤقتة، وقف إجراءات التوزيع فلا تقوم إدارة التنفيذ بإعداد القائمة النهائية وتسليم أوامر الصرف لمستحقيها إلا إذا تم الفصل في جميع المناقضات على القائمة المؤقتة، ومع ذلك فإن المناقضات في القائمة المؤقتة لا تمنع إدارة التنفيذ من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة الأولى على الدائنين المتنازع في ديونهم (مادة ٤٨٣).

٣- الحكم الصادر في المناقضة يكون نهائيا وغير قابل للاستئناف إذا كانت قيمة المبلغ المتنازع فيه أقل من أربعين ألف جنيه؛ فإذا تجاوزت قيمة الدين هذا المبلغ؛

(١) المناقضة في القائمة، هي اعتراض يثيره ذو الشأن على ما ورد في القائمة، ويمكن أن يكون موضوعها مقدار المصاريف إذا كان مبالغا فيها أو لم يقدرها القاضي، أو استبعاد دين من الديون المدرجة في القائمة، أو إدراج دين لم يدرج، أو مقدار دين، أو صحة الرهن أو درجته. (د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، ص ٥٩١).

- فإن الحكم الصادر في المناقضة يكون ابتدائياً وقابلاً للاستئناف بصرف النظر عن قيمة حق الدائن الذي قدم المناقضة أو قيمة حصيلة التنفيذ.
- ٤- ميعاد استئناف الحكم في المناقضة (متى كان قابلاً للاستئناف) عشرة أيام.
- ٥- تختص المحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة (٢٧٧ مرافعات) بنظر استئناف الحكم الصادر في المناقضة.
- ٦- يرفع الاستئناف في المناقضة بالإجراءات المعتادة، ويجب اختصاص جميع ذوي الشأن، ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي، بإخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي (مادة ٤٨١).
- ٧- تقوم إدارة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ الإخبار المشار إليه في البند السابق، أو من تاريخ الفصل في المناقضات إذا كان الحكم فيها نهائياً، أو من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه؛ بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر إن كان. (مادة ٤٨٢).
- ٨- تمضي إدارة التنفيذ في الإجراءات بعد إيداع القائمة النهائية وفقاً لأحكام المادة (٤٧٨).
- د- طلب بطلان إجراءات التوزيع:**
- لكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات، وذلك إما بطريق التدخل في جلسة التسوية الودية، أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة، ولا يحكم بالإبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه؛ فإذا حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة وألزم بالتعويضات إن كان لها وجه (مادة ٤٨٤).

الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع
٤	مقدمه
٦	مبحث تمهيدي: الحق في التنفيذ وأنواعه
١٤	الباب الأول: القواعد العامة في التنفيذ
١٦	الفصل الأول: أطراف التنفيذ والسلطة المختصة به
١٨	المبحث الأول: أطراف التنفيذ
١٨	المطلب الأول: طالب التنفيذ
٢٣	المطلب الثاني: المنفذ ضده
٢٨	المطلب الثالث: الغير: ودوره في التنفيذ الجبري
٣١	المبحث الثاني: السلطة المختصة بمباشرة إجراءات التنفيذ
٣٢	المطلب الأول: إدارة التنفيذ
٣٨	المطلب الثاني: معاونو التنفيذ
٤١	المطلب الثالث: قاضي التنفيذ
٥١	المطلب الرابع: السلطة المختصة بالتنفيذ في الفقه الإسلامي
٥٤	الفصل الثاني: السندات التنفيذية
٥٧	المبحث الأول: الأحكام
٥٨	المطلب الأول: صورة الحكم القضائي القابلة للتنفيذ الجبري
٦٢	المطلب الثاني: النفاذ العادي للأحكام
٦٢	الفرع الأول: القاعدة العامة في التنفيذ الجبري للأحكام
٦٤	الفرع الثاني: الاستثناء من قاعدة جواز تنفيذ الحكم
٦٥	الغصن الأول: وقف التنفيذ من محكمة النقض
٧١	الغصن الثاني: وقف التنفيذ من محكمة التماس إعادة النظر

٧٤	المطلب الثالث: النفاذ المعجل للأحكام
٧٥	الفرع الأول: فكرة النفاذ المعجل
٧٧	الفرع الثاني: أنواع النفاذ المعجل
٧٨	الغصن الأول: النفاذ المعجل القانوني
٨٥	الغصن الثاني: النفاذ المعجل القضائي
١٠١	الفرع الثالث: ضمانات المحكوم عليه في النفاذ المعجل
١٠٢	الغصن الأول: إلزام المحكوم له بتقديم كفالة
١٠٦	الغصن الثاني: وقف النفاذ المعجل من محكمة الاستئناف
١١٠	الغصن الثالث: إعادة الحال إلى ما كانت عليه وجبر الضرر
١١١	المطلب الرابع: التظلم من وصف الحكم (الاستئناف الوصفي)
١١٥	المطلب الخامس: تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر
١١٧	المبحث الثاني: أحكام المحكمين
١٢٠	المبحث الثالث: الأوامر
١٢١	المطلب الأول: الأوامر على عرائض
١٢٣	المطلب الثاني: أوامر الأداء
١٢٦	المطلب الثالث: أوامر التقدير
١٣٠	المبحث الرابع: المحررات الموثقة
١٣٢	المبحث الخامس: محاضر الصلح
١٣٣	المبحث السادس: الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي
١٣٤	المبحث السابع: السند التنفيذي في الفقه الإسلامي
١٣٦	الفصل الثالث: الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له والأموال التي يجوز الحجز عليها
١٣٨	المبحث الأول: الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له
١٤٤	المبحث الثاني: الأموال التي يجوز الحجز عليها (محل الحجز)

١٤٤	المطلب الأول: القواعد العامة في حجز الأموال ووسائل الحد من المغالاة فيها
١٤٤	الفرع الأول: القواعد العامة في حجز الأموال
١٤٩	المطلب الثاني: الشروط اللازم توفرها في المال المحجوز عليه
١٥٠	المطلب الثالث: الأموال التي لا يجوز الحجز عليها
١٦٢	المطلب الرابع: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها في الفقه الإسلامي
١٦٦	الفصل الرابع: مقدمات التنفيذ ومنازعاته
١٦٧	المبحث الأول: مقدمات التنفيذ
١٧٣	المبحث الثاني: منازعات التنفيذ
١٧٥	المطلب الأول: منازعات التنفيذ الوقتية (اشكالات التنفيذ الوقتية)
١٨٢	المطلب الثاني: المنازعات الموضوعية
١٨٦	الباب الثاني: إجراءات الحجز والتنفيذ على المنقول
١٨٧	تمهيد: ماهية الحجز وقواعده
١٩٢	الفصل الأول: الحجز التنفيذي على المنقول
١٩٦	المبحث الأول: إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول
١٩٦	المطلب الأول: إجراء الحجز وتعيين الحارس
١٩٦	الفرع الأول: إجراء الحجز والآثار المترتبة عليه
٢٠٤	الفرع الثاني: تعيين الحارس على المنقولات المحجوزة
٢١١	المطلب الثاني: التدخل في الحجز
٢١٢	الفرع الأول: التدخل في الحجز عن طريق جرد الأشياء المحجوزة
٢١٨	الفرع الثاني: التدخل عن طريق الحجز على الثمن تحت يد معاون التنفيذ
٢١٩	المطلب الثالث: الاعتراض على الحجز (دعوى استرداد المنقولات المحجوزة)
٢٢٥	المبحث الثاني: بيع المنقولات المحجوز عليها

٢٢٧	المطلب الأول: قواعد بيع المنقول المحجوز عليه
٢٣٣	المطلب الثاني: إجراءات البيع
٢٣٨	الفصل الثاني: الحجز التحفظي
٢٣٩	المبحث الأول: التعريف بالحجز التحفظي
٢٤٢	المبحث الثاني: الشروط العامة للحجز التحفظي
٢٤٧	المبحث الثالث: حالات الحجز التحفظي
٢٤٧	المطلب الأول: الحجز حماية للضمان العام
٢٤٨	الفرع الثاني: الحالات الخاصة للحجز التحفظي
٢٥٢	المبحث الرابع: إجراءات الحجز التحفظي
٢٥٨	الفصل الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير
٢٥٩	المبحث الأول: ماهية حجز ما للمدين لدى الغير وإجراءاته
٢٥٩	المطلب الأول: ماهية حجز ما للمدين لدى الغير
٢٦٨	المطلب الثاني: إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير
٢٨١	المطلب الثالث: إجراءات خاصة ببعض صور حجز ما للمدين لدى الغير
٢٨٥	المبحث الثاني: الاعتراض على حجز ما للمدين لدى الغير
٢٨٦	المطلب الأول: دعوى رفع الحجز
٢٩٨	المطلب الثاني: دعوى عدم الاعتداد بالحجز
٢٩٢	المبحث الثالث: الآثار المترتبة على حجز ما للمدين لدى الغير
٢٩٢	المطلب الأول: آثار الحجز بالنسبة للمحجوز لديه
٣٩٤	المطلب الثاني: آثار الحجز بالنسبة للمحجوز عليه.
٢٩٥	المبحث الرابع: استيفاء الحاجز حقه
٢٩٨	الباب الثالث: التنفيذ على العقار
٣٠٠	الفصل الأول: حجز العقار
٣٠١	المبحث الأول: حجز عقار المدين

٣٠١	المطلب الأول: إعلان تنبيه نزع الملكية
٣٠٤	المطلب الثاني: تسجيل تنبيه نزع الملكية
٣٠٨	المبحث الثاني: حجز عقار غير المدين
٣٠٨	المطلب الأول: حجز عقار الحائز
٣١٢	المطلب الثاني: حجز عقار الكفيل العيني
٣١٤	المبحث الثالث: الآثار المترتبة على حجز العقار
٣٢٤	الفصل الثاني: التمهيد لبيع العقار
٣٢٥	المبحث الأول: إيداع قائمة شروط البيع والإخبار والإعلان عن إيداعها
٣٢٥	المطلب الأول: إيداع قائمة شروط البيع
٣٣٢	المطلب الثاني: الإخبار بإيداع القائمة والإعلان عنه
٣٣٥	المبحث الثاني: الاعتراض على قائمة شروط البيع
٣٣٦	المطلب الأول: ماهية الاعتراض وموضوعه
٣٤٢	المطلب الثاني: النظام الإجرائي للاعتراض على قائمة شروط البيع
٣٤٦	الفصل الثالث: بيع العقار
٣٤٨	المبحث الأول: الإعلام بالبيع
٢٥٤	المبحث الثاني: إجراءات البيع
٣٦٦	المبحث الثالث: الحكم بإيقاع البيع
٣٦٦	المطلب الأول: شكل الحكم بإيقاع البيع وبياناته وطبيعته وتسجيله
٣٦٩	المطلب الثاني: آثار حكم إيقاع البيع وتنفيذه
٣٧٨	الفصل الرابع: دعوى الاستحقاق الفرعية
٣٨٥	مبحث خاص: قواعد توزيع حصيلة التنفيذ
٣٩٤	الفهرس